

Este libro constituye material de estudio y/o trabajo

Pertenece a: _____

Domicilio: _____

e-mail _____ Tel.: _____

Estudio: _____

e-mail _____ Tel.: _____

En caso de extravío, se agradece su inmediata devolución

Colección: *Guías de Estudio*

CIVIL

PARTE GENERAL

Autor: Dr. Miguel Angel Font

CATALOGACIÓN EN FUENTE

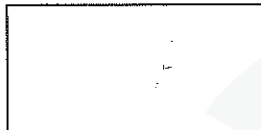
Font, Miguel Angel

Guía de estudio Civil Parte General / Miguel Angel Font. - 10a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Estudio, 2016. 336 p. ; 23 x 15,5 cm. - (Guías de estudio / Miguel Angel Font,)

ISBN 978-950-897-503-4

I. Derecho Civil. I. Título.
CDD 346

CONTROL INTERNO



50500006

© Editorial Estudio S.A.
Buenos Aires. Argentina.
Teléfonos: 4862-2014 y 4865-0537
www.editorialestudio.com.ar

Hecho el depósito de Ley 11.723.
Derechos reservados
Libro de edición argentina.
Impreso en la Argentina

GUÍA DE ESTUDIO

DEL

CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL

CIVIL

PARTE GENERAL

*Programa desarrollado de la materia conforme al nuevo
Código Civil y Comercial de la Nación*

- *Gráficos de cada capítulo*
- *Preguntas de autoevaluación*
- *Legislación actualizada*

**Nueva Edición
Actualizada**



Editorial Estudio

FOTOCOPIADORA
C.E.D.

COD. 505/6 SF
DF

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES DEL CÓDIGO CIVIL DE VÉLEZ SARSFIELD Y DEL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL

El Código de Vélez Sarsfield	23
¿Cómo se llegó a tener un Código Civil?	23
Fuentes del Código Civil de Vélez	24
Método del Código Civil de Vélez	24
Legislación modificatoria y complementaria	25
Proyectos de reforma	25
Nuevo Código Civil y Comercial	26
Aspectos valorativos del nuevo Código Civil y Comercial	26
Aspectos generales del nuevo Código Civil y Comercial	27
La Ley 26.994	28
Método o estructura interna del nuevo Código Civil y Comercial	30
Síntesis gráfica	31/33

CAPÍTULO I

TÍTULO PRELIMINAR DERECHO. FUENTES.

Generalidades	35
Contenido	35
Derecho	35
Concepto de Derecho. Derecho Objetivo y Derecho Subjetivo	35
Derecho Objetivo y Derecho Subjetivo	36
Derecho y orden religioso, social y moral	36
Derecho Natural y Derecho Positivo	37
Ramas del Derecho Positivo	37
La Consolidación de leyes vigentes. El Digesto Jurídico Argentino	38
Derecho Civil	39
Antecedentes históricos. Transformaciones. Contenido actual	39
Fuentes del derecho	40
Concepto	40
Clasificación de las fuentes	40
Las fuentes en el nuevo Código Civil y Comercial	41
a) La Ley	41
b) La Constitución Nacional	42

c) Los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte.....	42
d) Los usos, prácticas y costumbres	42
La Costumbre	42
Concepto.....	42
Elementos y caracteres	43
Valor de la Costumbre	43
Sistema de Derecho Escrito y Sistema de Common law	44
Distintos tipos de costumbre	44
La Costumbre en nuestro Derecho	44
<i>Síntesis gráfica</i>	<i>45/46</i>

CAPÍTULO II

INTERPRETACIÓN DE LA LEY

Concepto	47
Especies de Interpretación	47
Métodos y escuelas de Interpretación. Evolución.....	48
A) Tradicionales	48
B) Modernos	49
La Interpretación en nuestro Código. Elementos	50
Teoría de la hermenéutica.....	50
Elementos interpretativos	50
La interpretación en el Código de Vélez	51
La interpretación en el nuevo Código Civil y Comercial.....	51
Deber de resolver.....	52
<i>Síntesis gráfica</i>	<i>54</i>

CAPÍTULO III

LA LEY

Concepto	55
Caracteres.....	55
Clasificación de las leyes	55
Proceso de formación de las leyes	56
Efectos de la ley	57
Efectos de la ley con relación al territorio.....	57
Diferentes sistemas.....	57
Sistema del nuevo Código Civil y Comercial	57
Efectos de la ley con relación al tiempo	57
Vigencia de la ley	58
Principio de inexcusabilidad.....	58
Eficacia temporal de la ley	58
Efecto inmediato	58
Irretroactividad de las leyes	59

Las leyes supletorias y los contratos en curso de ejecución.....	59
Modo de contar los intervalos del derecho.....	60
<i>Síntesis gráfica</i>	<i>61/62</i>

CAPÍTULO IV

EJERCICIO DE LOS DERECHOS

Introducción.....	63
Principio de buena fe	63
Abuso del derecho.....	63
Principios del Código Civil de Vélez (Art. 1071)	64
Reformas de la Ley 17.711: Aceptación de la Teoría.....	65
Posición del nuevo Código Civil y Comercial	65
Orden público. Fraude a la ley	67
Leyes de orden público.....	67
Fraude a la ley.....	68
Renuncia general de las leyes.....	68
Derechos individuales y de incidencia colectiva	68
<i>Síntesis gráfica</i>	<i>70</i>

CAPÍTULO V

DERECHOS Y BIENES

Introducción	71
Titularidad de los derechos	71
Bienes y cosas.....	71
Conceptos	71
Bienes	72
Cosas	72
Derechos sobre el cuerpo humano	73
Derechos de las comunidades indígenas	73
Artículo 18 del Código y Art. 75, inc. 17 de la Constitución Nacional.....	73
Propiedad indígena en el Anteproyecto	74
Art. 9 de la Ley 26.994	74
<i>Síntesis gráfica</i>	<i>75</i>

CAPÍTULO VI

PERSONA HUMANA

Concepto	77
Método del nuevo Código Civil y Comercial.....	77

Comienzo de la existencia de la persona humana	77
La concepción dentro o fuera del seno materno	78
El comienzo de la existencia en el Anteproyecto	78
Ley 26.862 ("Reproducción Médicamente Asistida")	79
Duración del embarazo. Epoca de la concepción	80
Conceptos generales	80
Epoca de la concepción	80
Nacimiento con vida	81
Presunción del nacimiento con vida	81
Representación	82
Adquisición de derechos	82
Posibles fraudes	82
Cuestión de la viabilidad	82
Los Atributos de la persona	83
Concepto	83
Caracteres	83
Síntesis gráfica	84

CAPÍTULO VII CAPACIDAD

Concepto	85
Tipos de capacidad	85
Incapacidad de derecho	85
Concepto	85
Excepcionalidad de la incapacidad de derecho	86
Incapacidad de derecho en el Código de Vélez	86
Incapacidad de derecho en el nuevo Código Civil y Comercial	86
Incapacidad de ejercicio	87
Concepto	87
Incapacidad de ejercicio en el Código de Vélez	87
Incapacidad de ejercicio en el nuevo Código Civil y Comercial	87
Persona por nacer	87
Los menores de edad	88
Los menores de edad en el nuevo Código Civil y Comercial	88
La decisión del adolescente en los tratamientos médicos	89
Los menores y los "pequeños contratos"	90
Menor de edad con título profesional habilitante	90
Mayoría de edad y Emancipación	90
Mayoría de edad	90
Emancipación por matrimonio	91
Actos prohibidos al emancipado	91
Actos del emancipado sujetos a autorización judicial	92
Efectos de la anulación del matrimonio	92

El caso de los progenitores adolescentes	92
Emancipaciones que dejaron detener vigencia	93
Personas con capacidad restringida y personas con incapacidad	93
Reglas generales	93
Restricción de la capacidad	94
I) Persona con capacidad restringida	94
II) Persona con incapacidad	95
Solicitud de la declaración de incapacidad o capacidad restringida	95
El proceso de declaración	96
La sentencia	96
La internación de la persona	97
Actos de la persona declarada incapaz o con capacidad restringida	99
La revisión de la sentencia declarativa	99
Cese de la incapacidad y de las restricciones a la capacidad	99
Inhabilitados. Los Pródigos	100
Pródigos	101
Efectos de la inhabilitación	101
Cese de la inhabilitación	102
Síntesis gráfica	103/107

CAPÍTULO VIII LOS DERECHOS SUBJETIVOS DERECHOS Y ACTOS PERSONALÍSIMOS

Los Derechos Subjetivos	109
Concepto	109
Naturaleza jurídica de los derechos subjetivos. Distintas teorías	109
1) Teorías que niegan los derechos subjetivos	109
2) Teorías que reconocen los derechos subjetivos	110
Clasificación de los derechos subjetivos	110
1) Derechos Patrimoniales	110
2) Derechos Extrapatrimoniales	111
Derechos Personalísimos	111
Concepto	111
Regulación normativa	111
Los Derechos Personalísimos en el nuevo Código Civil y Comercial	112
Inviolabilidad de la persona humana. Dignidad	113
Derecho a la imagen y a la voz	113
Derecho a la intimidad	114
Derecho a la vida	115
Derecho a la integridad física	115
Derecho al honor	117
Derecho a la identidad y derecho a la identidad sexual	118
Ley de Identidad de Género	119
Derecho a la no discriminación	121

Derechos Personalísimos en el Pacto de San José de Costa Rica	121
Naturaleza jurídica de los Derechos Personalísimos	123
Caracteres de los Derechos Personalísimos	123
<i>Síntesis gráfica</i>	124

CAPÍTULO IX EL NOMBRE

Concepto	125
Elementos	125
Regulación normativa	125
Caracteres del nombre	125
Evolución histórica del nombre	126
El nombre individual	126
Concepto	126
Elección del prenombre	127
Régimen de la Ley 18.248	127
Régimen del nuevo Código Civil y Comercial	128
El apellido	128
Concepto	128
Distintos casos de adquisición	128
1) Casos de adquisición originaria	129
a) Hijos matrimoniales	129
b) Hijos extramatrimoniales	129
c) Hijos no reconocidos por ninguno de sus padres	130
d) Hijo adoptivo	130
2) Casos de Adquisición Derivada	131
Cambio de nombre o apellido	131
Inmutabilidad. Excepciones	131
Proceso	132
Protección jurídica del nombre	132
El sobrenombre	133
El seudónimo	133
<i>Síntesis gráfica</i>	134/135

CAPÍTULO X DOMICILIO

Concepto	137
Importancia	137
Caracteres	137
Especies	138

a) Domicilio Real	138
Concepto	138
Requisitos	138
Características	138
Constitución, conservación, cambio y extinción	139
Domicilio ignorado	139
b) Domicilio Legal	139
Concepto y características	139
Casos enumerados en el art. 74	140
Casos enumerados taxativamente en el Código Civil de Vélez	141
c) Domicilio Especial	142
Concepto	142
Domicilio contractual	142
Domicilio procesal	142
Domicilio conyugal	143
<i>Síntesis gráfica</i>	144

CAPÍTULO XI AUSENCIA SIMPLE Y AUSENCIA CON PRESUNCIÓN DE FALLECIMIENTO

Ausencia simple	145
Concepto	145
Requisitos	145
Legitimación para solicitarla	145
Juez competente	146
Procedimiento	146
Sentencia	146
Conclusión de la curatela	146
Ausencia con presunción de fallecimiento	146
Concepto	146
Distintos casos	147
1) Caso ordinario	147
2) Caso extraordinario genérico	147
3) Caso extraordinario específico	147
Cómputo de los términos	147
Legitimación para solicitarla	147
Procedimiento	148
Día presuntivo del fallecimiento	149
Efectos de la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento	149
Prenotación	149
Conclusión de la prenotación. Dominio pleno	150
<i>Síntesis gráfica</i>	151/152

CAPÍTULO XII

FIN DE LA EXISTENCIA DE LA PERSONA HUMANA

Concepto	153
"Muerte civil" y "Muerte natural"	153
Comprobación de la muerte	153
Conmoriencia	155
Prueba del nacimiento, de la muerte y de la edad	155
Partidas del Registro Civil	155
Concepto	155
Carácter y eficacia probatoria	155
Requisitos de las partidas	156
Ley 26.413 ("Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas")	156
Nulidad de las partidas	156
Rectificación de las partidas	157
Nacimiento o muerte ocurridos en el extranjero	157
Prueba	157
Inscripción en el Registro	158
Falta de registro o nulidad del asiento	158
Determinación de la edad	158
<i>Síntesis gráfica</i>	159

CAPÍTULO XIII

REPRESENTACIÓN Y ASISTENCIA.
TUTELA Y CURATELA

Representación y Asistencia	161
Representación	161
Características	162
Sistema de apoyos (asistencia)	162
Concepto	162
Actuación del Ministerio Público	162
Tutela	163
Concepto	163
Características de la tutela	163
Tutela dada por los padres (por testamento o escritura pública)	164
Tutela dativa	164
Tutela especial	165
Personas excluidas	165
Obligados a denunciar	166
Discernimiento de la tutela	166
Entrega de bienes, previo inventario y avalúo	167
Rendición de cuentas	167
Rendición de cuentas final	168
Actos del tutor	168

Actos que requieren autorización judicial	168
Actos prohibidos	169
Responsabilidad	169
Causas de terminación de la tutela	169
Remoción del tutor	170
Curatela	170
Concepto	170
Función principal del curador	170
Persona protegida con hijos	171
Terminación de la curatela	171
<i>Síntesis gráfica</i>	172/173

CAPÍTULO XIV
PERSONAS JURÍDICAS

Introducción	175
Definición	175
Comienzo de la existencia	175
Acto constitutivo	176
Estatuto	176
Personalidad diferenciada	176
Inoponibilidad de la personalidad jurídica	177
Clasificación	177
Personas Jurídicas Públicas	178
Enumeración	178
Ley aplicable	179
Personas Jurídicas Privadas	179
Enumeración	179
Participación del Estado	179
Leyes aplicables	179
Efectos y Atributos de la personalidad jurídica	180
Efectos	180
Atributos	180
Duración y objeto	181
Funcionamiento de la persona jurídica	182
Estatuto	182
Gobierno, administración y fiscalización	183
Administradores de la persona jurídica	183
Transformación. Fusión. Escisión	184
Disolución	184
Causales	184
Revocación de la autorización estatal	185
Liquidación	186
Concepto	186

Responsabilidades	186
Asociaciones civiles	187
Regulación normativa.....	187
Las asociaciones civiles en los Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial.....	187
Objeto	187
Acto constitutivo.....	188
Organo de administración.....	189
Organo de fiscalización	189
Control estatal.....	190
Participación en los actos de gobierno	190
Responsabilidad de los directivos.....	190
Participación en las asambleas	191
Renuncia, Exclusión y Responsabilidad del asociado	191
Intransmisibilidad	192
Disolución.....	192
Liquidación.....	192
Normas supletorias	193
Simple asociaciones	193
Regulación normativa.....	193
Ley aplicable. Reenvío	193
Acto constitutivo.....	193
Existencia.....	193
Prescendencia de órgano de fiscalización	193
Insolvencia.....	194
Fundaciones	194
Regulación normativa.....	194
Concepto, objeto, modo de constitución y patrimonio	194
Concepto	194
Características.....	195
Constitución y autorización	195
Aportes.....	196
Promesas de donación	197
Responsabilidad durante la etapa de gestación.....	197
Gobierno y administración	197
Consejo de Administración.....	197
Características del cargo de consejero.....	198
Comité Ejecutivo	198
Reuniones, convocatorias, mayorías, decisiones y actas.....	198
Remoción del consejo de administración	199
Contrato con el fundador o sus herederos	199
Destino de los ingresos. Deber de avisar.....	199
Información y contralor	199
Reforma del estatuto y Disolución	200
Reforma del estatuto. Mayorías necesarias	200
Destino de los bienes en caso de disolución.....	200

Revocación de las donaciones	200
Fundaciones creadas por disposición testamentaria	201
Autoridad de contralor	201
Atribuciones.....	201
Recursos.....	202
Síntesis gráfica	203/206

CAPÍTULO XV

BIENES

Regulación normativa	207
Conceptos	207
Cosas muebles	207
Cosas inmuebles	208
Cosas divisibles	208
Cosas principales	208
Cosas accesorias	208
Cosas consumibles.....	209
Cosas fungibles.....	209
Frutos y productos	209
Bienes fuera del comercio	210
Bienes con relación a las personas	210
Bienes pertenecientes al dominio público	210
Bienes del dominio privado del Estado	211
Bienes municipales.....	212
Bienes de los particulares	212
Aguas de los particulares.....	212
Bienes con relación a los derechos de incidencia colectiva	213
Límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes.....	213
Jurisdicción.....	213
Función de garantía	214
Bienes que constituyen la garantía	214
Limitaciones	214
Bienes excluidos de la garantía común.....	215
Medidas cautelares	215
Patrimonios especiales.....	216
Bienes afectados directamente a un servicio público	216
Vivienda	217
Regulación normativa.....	217
Afectación a Vivienda.....	217
Legitimados	217
Beneficiarios	218
Habitación efectiva.....	218
Subrogación real	218
Efecto principal de la afectación	218

Frutos producidos por el inmueble	219
Transmisión de la vivienda afectada	219
Régimen de impuestos y honorarios	219
Desafectación y cancelación de la inscripción	219
Deberes de la autoridad de aplicación	220
Diferencias fundamentales entre el régimen de la Ley 14.394 y el nuevo Código Civil y Comercial	220
<i>Síntesis gráfica</i>	221/222

CAPÍTULO XVI HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS

Regulación normativa	223
“Hecho” y “Hecho jurídico”	223
Clasificación de los hechos jurídicos	224
Hechos Naturales	224
Hechos Humanos	224
Involuntarios	224
Voluntarios	224
Lícitos	224
Ilícitos	225
Diferencias entre “hecho jurídico” y “acto jurídico”	225
Diferencias entre un “acto jurídico” y un “simple acto lícito”	225
<i>Síntesis gráfica</i>	226

CAPÍTULO XVII TEORÍA GENERAL DE LOS ACTOS VOLUNTARIOS

Concepto	227
Condiciones Internas	227
Discernimiento	227
Intención	227
Libertad	228
Condiciones Externas	228
Silencio como manifestación de la voluntad	228
Manifestación tácita de voluntad	229
Vicios de la voluntad	229
El Error como vicio de la voluntad	229
Concepto	229
Diferencia con la “ignorancia”	229
Clases de Error	229
1) Error de Derecho	229
2) Error de Hecho	230

Síntesis y ejemplos	231
Error de cálculo	231
Subsistencia del acto	231
Error en la declaración y en la transmisión	232
El Dolo como vicio de la voluntad	232
Concepto	232
Acción dolosa y Omisión dolosa	232
Especies de dolo	232
Requisitos del dolo para invalidar el acto	233
Efectos del dolo esencial	233
Efectos del dolo incidental	233
Efectos del dolo recíproco	233
Dolo de un tercero	233
Prueba del dolo	234
La Violencia como vicio de la voluntad	234
Conceptos	234
Requisitos para que el uso de fuerza invalide el acto	234
Requisitos para que el uso de intimidación invalide el acto	234
Efectos de la violencia	235
Violencia ejercida por un tercero	235
El temor reverencial	235
<i>Síntesis gráfica</i>	236

CAPÍTULO XVIII ACTO JURÍDICO

Concepto	237
Elementos esenciales	237
A) Sujetos	237
B) Objeto	237
Análisis del art. 279	238
Objeto de los contratos	239
Convalidación	239
C) Causa	239
El “problema” de la causa	240
Presunción de causa	240
“Falsa causa”	241
La causa en el acto abstracto	241
D) Forma y Prueba	241
Concepto de “forma”	241
La “forma” en el Código de Vélez	241
La “forma” en el nuevo Código Civil y Comercial	242
Forma impuesta	242
Expresión escrita	243
Firma	244
Firma a ruego	244
Firma digital	245

Instrumento Público	246
Concepto	246
Requisitos de validez del instrumento público	246
Enumeración legal	248
Eficacia probatoria	248
Impugnación del contenido del instrumento público	249
Escritura Pública	250
Definición	250
Otros conceptos	250
Requisitos de las escrituras públicas y deberes del notario	251
Nulidad de la escritura	253
Actas Notariales	253
Instrumentos privados y particulares	253
Concepto	253
Firma	254
Reconocimiento de la firma	254
Documento firmado en blanco	255
Fecha cierta	256
Correspondencia	257
Valor probatorio de los instrumentos particulares	258
Requisito del "doble ejemplar"	258
Contabilidad y estados contables	258
Regulación normativa	258
Concepto de "contabilidad"	260
Obligados a llevar contabilidad	260
Eximidos de llevar contabilidad	260
Modo de llevar la contabilidad	261
Registros indispensables	261
Formalidades de los libros	262
Prohibiciones	263
Conservación de libros y registros	263
Actos sujetos a autorización	263
Eficacia probatoria de la contabilidad	264
Pesquisas, investigaciones y exhibición de libros	264
Clasificación de los Actos Jurídicos	265
Síntesis gráfica	267/270

CAPÍTULO XIX

VICIOS DE LOS ACTOS JURÍDICOS

Lesión (o "explotación")	271
Concepto	271
Requisitos fundamentales	271
Efectos del vicio	272

Simulación	272
Concepto	272
Supuestos de simulación	272
Clases de simulación	273
Acción de simulación	273
Concepto	273
El "contradocumento"	273
Ejercicio de la acción	274
Efectos frente a terceros. Indemnización	274
Fraude	275
Concepto	275
Acción de inoponibilidad	275
Concepto	275
Legitimación	275
Requisitos de procedencia	276
Efectos frente a terceros. Indemnización	276
Extinción de la acción	277
Extensión de la inoponibilidad	277
Síntesis gráfica	278

CAPÍTULO XX

MODALIDADES DE LOS ACTOS JURÍDICOS

Concepto	279
Condición	279
Concepto	279
Especies de condición	279
Condiciones prohibidas	280
Condición impropia o suposición	281
Inejecución de la condición	281
Efecto	281
Condición pendiente	281
Cumplimiento de la condición suspensiva o resolutoria	282
No cumplimiento de la condición suspensiva	282
Plazo	282
Concepto	282
Diferencia con la condición	282
Clases de plazo	282
Beneficiario del plazo	283
Efectos	283
Caducidad del plazo	284
Cómputo del plazo	284
Cargo	284
Concepto	284
Caracteres	285

Incumplimiento del cargo	285
Especies	285
Cargo prohibido	285
Tiempo de cumplimiento	286
Transmisibilidad de derechos adquiridos con cargo	286
<i>Síntesis gráfica</i>	288/289

CAPÍTULO XXI REPRESENTACIÓN

Concepto	291
Clases de representación	291
Efectos	292
Extensión	292
Limitaciones	292
Representación voluntaria	293
Concepto	293
Caracteres	293
Forma	293
Representación en juicio	293
Capacidad	294
Vicios	294
Actuación en ejercicio del poder	295
Representación aparente	295
Acto consigo mismo	295
Ratificación	296
Obligaciones y deberes del representante	296
Obligaciones y deberes del representado	297
Poder conferido en términos generales y facultades expresas	297
Responsabilidad por inexistencia o exceso en la representación	298
Sustitución	298
Pluralidad de representantes	298
Apoderamiento plural	299
Extinción	299
Poder irrevocable	299
Oponibilidad a terceros	300
<i>Síntesis gráfica</i>	301/302

CAPÍTULO XXII INEFICACIA DE LOS ACTOS JURÍDICOS

Introducción	303
Eficacia e Ineficacia	303
Nulidad	303
Concepto	303

Caracteres esenciales	304
Articulación: vía de acción o de excepción	304
La conversión del acto	305
Acto indirecto	305
Categorías de nulidades	306
a) Nulidad absoluta y Nulidad relativa	306
Distinción	306
Consecuencias de la nulidad absoluta	307
Consecuencias de la nulidad relativa	307
b) Nulidad total y Nulidad parcial	307
Distinción	307
Integración	308
Efectos de la nulidad	308
Restitución con efecto retroactivo	308
Consecuencias y reparaciones	308
Efecto entre las partes	309
Efectos para terceros adquirentes de cosas registrables	309
Confirmación de los actos jurídicos	310
Concepto	310
Actos confirmables	310
Condiciones	310
Formas	311
Prueba	311
Efectos de la confirmación	311
Inoponibilidad	311
Concepto	311
Efectos del acto inoponible frente a terceros	312
Oportunidad para invocar la inoponibilidad	312
Diferencias entre Nulidad y e Inoponibilidad	312
<i>Síntesis gráfica</i>	313/315

CAPÍTULO XXIII TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS

Transmisión	317
Concepto	317
Clasificación	317
Sucesores	317
Transmisibilidad	317
Legitimación. Regla general "nemo plus iuris"	318
Excepciones	318
<i>Síntesis gráfica</i>	320

TEST DE AUTOEVALUACIÓN	321
------------------------------	-----

SÍNTESIS GRÁFICAS

Sobre Nuevo Código Civil y Comercial.....	31
Sobre Método del nuevo Código Civil y Comercial.....	32/33
Sobre Derecho	45
Sobre Fuentes del Derecho	46
Sobre Interpretación de la ley.....	54
Sobre La ley	61
Sobre Ejercicio de los derechos.....	70
Sobre Derechos y bienes	75
Sobre Persona humana	84
Sobre Capacidad	103/107
Sobre Derechos subjetivos. Derechos personalísimos.....	124
Sobre El Nombre.....	134
Sobre Domicilio	144
Sobre Ausencia simple y ausencia con presunción de fallecimiento.....	151/152
Sobre Fin de la existencia de la persona humana	159
Sobre Representación y asistencia.....	172/173
Sobre Personas jurídicas	203/206
Sobre Bienes.....	221/222
Sobre Hechos jurídicos	226
Sobre Teoría general de los actos voluntarios	236
Sobre Acto jurídico	267/269
Sobre Contabilidad y estados contables.....	270
Sobre Vicios de los actos jurídicos	278
Sobre Modalidades de los actos jurídicos	288/289
Sobre Representación	301/302
Sobre Ineficacia de los actos jurídicos.....	313/315
Sobre Transmisión de los derechos.....	320

INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES DEL CÓDIGO CIVIL DE VÉLEZ SARSFIELD Y DEL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL

EL CÓDIGO DE VÉLEZ SARSFIELD

El Código Civil Argentino, usualmente denominado "*Código de Vélez*", que rigió hasta agosto del 2015 (fecha en que comenzó a aplicarse el nuevo Código Civil y Comercial vigente) fue obra del Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield (abogado cordobés, nacido en 1800 y fallecido en 1875), el cual ejerció diversos cargos públicos: fue Diputado de la Legislatura de Bs. As., Senador Nacional y Ministro en varias presidencias.

Con relación a su labor intelectual y jurídica anterior a la redacción del Código Civil, cabe recordar que publicó las Institutas del Derecho Real de España, de José María Álvarez, obra a la cual le agregó un prólogo, nuestras leyes patrias y varias notas, incluyendo, además, cinco trabajos suyos. También editó "El prontuario de Práctica Forense", de Antonio de Castro y las "Instituciones Iuris Ecclesiastici" de Xaverii, en 1835. En 1854, publica su obra "Derecho Público Eclesiástico". Realiza también un trabajo titulado "Discusión de los Títulos de Chile a las Tierras del Estrecho de Magallanes". Colaboró con el Dr. Eduardo Acevedo, en la preparación del Código de Comercio de 1862.

¿Cómo se llegó a tener un Código Civil?.-

La Constitución Nacional de 1853 facultaba al Congreso Nacional para dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal y de Minería. Por razones de orden financiero, la tarea de codificación no pudo llevarse a cabo sino después de algunos años.

Fue así que en 1862, se sancionó el Código de Comercio, obra de Eduardo Acevedo, con la colaboración de Vélez Sarsfield.

En 1863, por Ley 36, el Poder Ejecutivo debía nombrar una comisión de varias personas para la redacción de los Códigos Civil, Penal y de Minería. Sin embargo, el Presidente Mitre, en lugar de nombrar una comisión, por decreto nombró sólo a Vélez Sarsfield para redactar el proyecto de Código Civil. Vélez Sarsfield se puso a trabajar de inmediato. En el aspecto jurídico no tuvo colaboradores, pero en lo material -o sea en la redacción y organización- lo ayudaron Eduardo Díaz de Vivar, la hija de Vélez, y un estudiante de Derecho llamado Victorino de la Plaza, quién más adelante habría de ser abogado y Presidente de la República Argentina. Presentado el proyecto al Congreso, el mismo fue aprobado "a libro cerrado" (sin discusión) en setiembre de 1869 por Ley 340, la cual fue promulgada por Sarmiento. Se estableció que el Código regiría más adelante, a partir del 1° de enero de 1871 (este tipo de entrada en vigor se denomina "diferida").

Fuentes del Código Civil de Vélez.-

Las fuentes del Código Civil de Vélez Sarsfield (es decir, las distintas leyes, costumbres, usos, Códigos, proyectos de Códigos y obras consultadas por Vélez para la preparación del Código Civil) fueron:

a) El Derecho Romano.- Son innumerables los casos en que los textos romanos son fuente de artículos del Código de Vélez. El Derecho Romano también llegó a Vélez por medio de sus expositores, como por ejemplo: Cujas, Pothier, Mainz, Ortolán, y, en especial, Savigny, cuya obra "Sistema del Derecho Romano actual" influyó en la parte de obligaciones y de posesión.

b) Legislación española y Derecho Patrio.- Muchos de los artículos del Código de Vélez tienen la nota de una *Ley de Las Partidas*, del *Fuero Real* o de las *Recopiladas*. Sin duda, los usos y costumbres del país también fueron fuente del Código de Vélez.

c) El Código Napoleón y sus comentaristas.- La influencia del Código Civil Francés fue muy grande, pues de los 2282 artículos que tiene el Código Civil Francés, cerca de la mitad han sido reproducidos en el Código de Vélez. Los comentaristas del Código Francés (Aubry y Rau, Zachariae, Troplong y Demolombe) también influyeron en Vélez.

d) La obra de Freitas.- Las obras del jurista brasileño Augusto Texeira de Freitas influyeron notablemente en Vélez Sarsfield. La "*Consolidación de las leyes civiles*" (recopilación de leyes) influyó sobre la metodología seguida por Vélez en el Código. Y el "Esbozo" (anteproyecto de Código Civil para Brasil) fue fuente de numerosos artículos.

e) Otras fuentes.- Lo fueron el Código Civil Chileno, de Andrés Bello (1855); el Código de Luisiana (Estado de EEUU); el Código Ruso; y el Proyecto de Código Civil para Uruguay, de Eduardo Acevedo.

Método del Código Civil de Vélez.-

El método seguido por Vélez para la realización del Código Civil fue el método de la "*Consolidación de las leyes civiles*", de Freitas, pero a diferencia de éste, Vélez no incluyó una parte general.

El Código Civil de Vélez estaba compuesto por:

• Dos Títulos Preliminares:

- I) De las leyes;
- II) Del modo de contar los intervalos del derecho;

• Cuatro Libros:

- I) Libro Primero: "*De las Personas*" (trataba sobre las personas en general; y sobre los derechos personales en las relaciones de familia).
- II) Libro Segundo: "*De los Derechos personales en las relaciones civiles*" (trataba sobre obligaciones, hechos y actos jurídicos, y contratos).
- III) Libro Tercero: "*De los Derechos Reales*".

IV) Libro Cuarto: "*De los derechos reales y personales. Disposiciones comunes*" (trataba sobre las sucesiones, los privilegios y la prescripción); tenía un Título Complementario sobre "*Aplicación de las leyes civiles*".

Así se completó el Código Civil de Vélez, con 4051 artículos y numerosas notas al pie de los mismos.

Legislación modificatoria y complementaria.-

Después de la entrada en vigencia del Código de Vélez se fueron dictando leyes que lo actualizaban, complementaban o modificaban. Así, podemos recordar: *Ley de Matrimonio Civil* (Ley 2393); *Ley de divorcio* (Ley 23.515); *Ley de Propiedad Intelectual* (Ley 11.723); *Ley de Patronato de Menores* (Ley 10.903); *Ley Omnibus* (Ley 14.394) que modificó varias instituciones; *Ley de Nombre* (Ley 18.248); leyes sobre *Adopción* (Leyes 19.134 y 24.779); *Ley de Habeas Data* (Ley 25.326); *Ley de Firma Digital* (Ley 25.506); *Ley sobre Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes* (Ley 26.061); y un recordatorio especial para la Ley 17.711 (Abril de 1968) que llevó a cabo una gran reforma del Código Civil, la cual, si bien no era integral, era una reforma parcial que alcanzó a 167 artículos, introduciendo en nuestro ordenamiento jurídico, nuevas instituciones adoptadas ya por la doctrina, la jurisprudencia y las legislaciones modernas, tal el caso del abuso del derecho y la lesión subjetiva.

Proyectos de reforma.-

Luego de la sanción del Código Civil de Vélez, y con el correr de los años, por efecto del trabajo de la doctrina y la jurisprudencia, se intentó mantener actualizado el Código. No obstante, gran parte de la doctrina aconsejaba realizar una reforma integral, pero bajo la condición de que dicha reforma no quebrara la doctrina jurisprudencial de nuestro país. Fue así que se realizaron diversos proyectos de reforma, tales los casos de:

- El Anteproyecto Bibiloni de 1926 (donde trabajaron inminentes juristas, como Bibiloni, Salvat, Lafaille, Rébora, etc. Tenía más de 3500 artículos, algunos de ellos con notas);
- El Proyecto de 1936 (se destacaron, en su redacción, Lafaille y Tobal. Tenía 2144 artículos);
- El Anteproyecto de 1954 (fue redactado por Jorge Joaquín Llambías con la colaboración de otros abogados. Tenía 1838 artículos. Contenía una Parte General que evitaba repeticiones; su lenguaje era sencillo y daba fundamental importancia a la jurisprudencia y a la doctrina nacional);
- Dos proyectos del Poder Ejecutivo, uno de 1993 y otro de 1998. El Proyecto de 1998 mantenía la estructura del Código Civil de Vélez, pero reunía la legislación civil y la comercial, unificando el régimen de las sociedades, de la prescripción, de los privilegios y de la responsabilidad contractual y extracontractual. Además,

incorporaba normas sobre cuenta corriente mercantil y cuenta corriente bancaria y aceptaba el derecho real de superficie.

Todos los proyectos anteriormente mencionados, por una u otra razón, no lograron entrar en vigencia.

NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL

(En vigencia desde el 1° de agosto de 2015)

- Por el Decreto 191/2011 se encargó la elaboración del Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación a una *Comisión*, integrada por el Dr. Ricardo Lorenzetti (como presidente) y las Dras. Elena Highton de Nolasco y Aída Kelmajer de Carlucci.

- El *Anteproyecto* (que comprendía el cuerpo de normas, dos Anexos y los Fundamentos de la normativa adoptada) fue presentado al Poder Ejecutivo en marzo de 2012, y luego fue revisado por el Poder Ejecutivo Nacional (Ministerio de Justicia), que le introdujo modificaciones.

- El *Proyecto* (es decir, el Anteproyecto con las modificaciones del PEN incluidas) se elevó al Congreso de la Nación, y fue analizado por una *Comisión Bicameral* (*Comisión Bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación*), la cual elaboró un dictamen positivo. El Proyecto fue aprobado por el Senado de la Nación, con las modificaciones que introdujo el Poder Ejecutivo.

- El 1° de octubre de 2014 el Proyecto fue tratado y aprobado en la Cámara de Diputados de la Nación en sólo una sesión.

- El día 7 de octubre de 2014 la Presidenta de la Nación promulgó el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, el que debía entrar en vigencia el 1° de enero de 2016, pero por Ley 27.077 se dispuso que debía entrar en vigencia el 1° de agosto de 2015.

Aspectos valorativos del nuevo Código Civil y Comercial.-

En los *Fundamentos* que acompañaron al Anteproyecto, los redactores del mismo destacan que han tenido muy en cuenta diversos principios o aspectos valorativos que lo caracterizan, ya que no están presentes en los Códigos de otros países, y que son los siguientes:

- 1) *Código con identidad cultural latinoamericana*. - El nuevo Código ha respetado en sus aspectos esenciales las tradiciones romana, hispánica, y francesa que tanta influencia han tenido en nuestra legislación, pero también ha incorporado nociones y criterios propios de la cultura latinoamericana.

- 2) *Código de la constitucionalización del derecho privado*. - El nuevo Código Civil y Comercial recepta la constitucionalización del derecho privado, estableciendo una comunidad de principios entre la Constitución, el derecho público y el derecho privado. Es por ello que se da mucha importancia a los tratados en general, en particular a los de Derechos Humanos, lo cual se manifiesta a través

de diversos institutos como ser: la protección de la persona humana a través de los derechos fundamentales; los derechos de incidencia colectiva; la tutela del niño, de las personas con capacidades diferentes, de la mujer, de los consumidores, de los bienes ambientales; etc.

Y, como consecuencia de la constitucionalización del derecho privado, hay un importante contenido de normas de orden público en áreas relevantes del nuevo Código.

- 3) *Código de la igualdad y la no discriminación*. - El nuevo Código Civil y Comercial tiende a regular los derechos de los ciudadanos sobre la base no de una igualdad abstracta, sino de una igualdad real, y desarrolla una serie de normas orientadas a plasmar una verdadera ética de los ciudadanos.

El sujeto del derecho privado es considerado en términos igualitarios, sin discriminaciones basadas en el sexo, religión, origen o riqueza. Es por ello que, en el nuevo Código, aparecen sujetos que antes no habían tenido una recepción sistemática, tal el caso de la mujer, del niño, de las personas con capacidades diferentes, del consumidor, de las comunidades originarias, etc.

El concepto de *derechos personalísimos* (ya reconocido por el derecho internacional) se incorpora al nuevo Código, reconociéndose en forma explícita los derechos a la intimidad, al honor, a la imagen y a la identidad. También se regula el derecho a disponer del propio cuerpo con limitaciones fundadas en principios bioéticos.

- 4) *Código de los derechos individuales y colectivos*. - El nuevo Código regula los derechos individuales, pero (en consonancia con la Constitución Nacional) innova al darle una importancia relevante a los derechos de incidencia colectiva (arts. 14, 240, 1714, etc).

- 5) *Código de la ampliación en materia de bienes*. - En el nuevo Código lo relativo a los bienes se ha ampliado notoriamente. Aparecen bienes que, siendo de la persona, no tienen un valor económico, aunque sí una utilidad, como sucede con el cuerpo, órganos, genes, etcétera. La relación exclusiva entre los bienes y la persona también ha cambiado y aparecen las comunidades, como ocurre con los pueblos originarios. Finalmente, los conflictos ambientales se refieren a bienes que son mencionados en el Código como del dominio público, pero la Constitución y la ley ambiental los consideran colectivos, y no solamente de propiedad del Estado.

- 6) *Código para una sociedad multicultural*. - En materia de familia y filiación, se han adoptado decisiones importantes a fin de regular a una serie de conductas sociales que no se pueden ignorar, tal el caso de las relativas a la reproducción asistida o a las técnicas de inseminación artificial o de fecundación in vitro.

- En materia de Matrimonio: se sigue el sistema igualitario sin hacerse distinciones de sexo, a los efectos de definir quienes pueden unirse en matrimonio, manteniendo el avance logrado con la Ley 26.618, de matrimonio igualitario. Se establece la posibilidad de optar entre el régimen de *comunidad de ganancias* y el de *separación de bienes* (con acuerdo prenupcial). Se regulan las uniones convivenciales, fenómeno social cada vez mas frecuente en la Argentina.

- En materia de Divorcio: se simplifican los trámites para su solicitud, considerando la libre petición de uno o ambos cónyuges, quienes a su vez podrán hacer

propuestas y acordar sobre los efectos que tendrá la disolución. La infidelidad deja de ser causal de divorcio.

• En materia de Adopción: se simplifica el régimen jurídico y se prioriza el interés del niño por sobre el de los adultos. Se mantiene la adopción plena y simple y se agrega la adopción por integración, en caso de familias conformadas por parejas que tengan hijos de otras relaciones.

7) Código para la seguridad jurídica en las transacciones comerciales. - Se han adoptado decisiones para promover la seguridad jurídica en las transacciones comerciales. Por eso se regulan formas modernas de contratación, como ser: contratos de distribución, bancarios, financieros, fideicomisos, agencia comercial, régimen contable de los comerciantes y muchos otros temas que, al estar regulados en el Código, brindan mayor seguridad jurídica y garantizan de mejor manera la defensa de los ciudadanos en su rol de consumidores.

Aspectos generales del nuevo Código Civil y Comercial.-

Entre los aspectos generales del nuevo Código cabe destacar que:

a) Unifica los Códigos Civil y Comercial, tema sobre el cual hay una amplia coincidencia y aceptación en la doctrina jurídica argentina.

b) Contiene un Título Preliminar y luego una Parte General que es para todo el Código, sin perjuicio de que para algunas instituciones (tal el caso de las obligaciones, los contratos y los derechos reales) también trae una parte general específica (principios comunes o disposiciones generales) para esa institución que regula.

c) No contiene notas, a diferencia del Código Civil de Vélez que sí las traía pero que no tenían valor legal.

d) Incluye algunas definiciones: se han incorporado sólo aquellas que tienen efecto normativo, evitándose las definiciones meramente didácticas. Encontramos definiciones sobre: persona jurídica (art. 141) escritura pública (art. 299), adopción (art. 594), obligación (art. 724), rendición de cuentas (art. 858), pago (art. 865), contratos (art. 957), etc.

e) Efectúa una redacción clara de las normas, a fin de facilitar su entendimiento para los profesionales y también para los que no lo son. Por esta razón, se ha evitado hacer remisiones, así como la utilización de vocablos alejados del uso ordinario y frases demasiado extensas, que importan dificultades de lectura.

Se han tratado de conservar, en lo posible, las palabras ya conocidas y utilizadas por la doctrina y jurisprudencia. No obstante, dado que hay numerosos cambios sociales, científicos, culturales, económicos, que demandan el uso de palabras ajenas al lenguaje jurídico ha sido inevitable recurrir a nuevas expresiones para reflejar nuevos fenómenos (ejemplos: unión convivencial, conviviente, persona con capacidad restringida, responsabilidad parental, etc).

También se ha puesto énfasis en la gramática y, en especial, se ha tratado de usar el tiempo presente en la redacción de todo el articulado, porque es el que más se adapta a la buscada claridad expositiva.

f) El Código se vincula con otros microsistemas normativos autosuficientes, con la intención de respetarlos, es decir, de no modificar sus normas, salvo que ello fuera absolutamente necesario. A pesar de esta intención, hay leyes que inevitablemente tuvieron que ser modificadas en forma parcial (por ej: la *Ley de Defensa del Consumidor* y la *Ley General de Sociedades*).

En otros casos se incorporaron al Código los textos de dichas leyes con escasas modificaciones (como ocurrió, por ejemplo, con las fundaciones y el leasing); y en otras, no hubo ninguna modificación (por ej: *Ley de Seguros* o *Ley de Concursos y Quiebras*).

g) Los redactores tuvieron en cuenta diversos antecedentes para la redacción del nuevo Código. En los *Fundamentos*, los redactores del Código dicen: "*Hemos tenido a la vista los antecedentes más significativos del derecho comparado, la doctrina de los autores nacionales y extranjeros con mayor prestigio académico, la opinión de los congresos de juristas, y los criterios de la jurisprudencia. Hemos utilizado los siguientes proyectos de reformas anteriores...*", y mencionan los siguientes:

- El Anteproyecto Bibiloni de 1926;
- El Anteproyecto de 1954 (redactado por Jorge Joaquín Llambías);
- El Proyecto de Unificación de la legislación Civil y Comercial, proveniente de la Cámara de Diputados de la Nación (año 1987);
- El Proyecto de 1993 (de la Comisión Federal de la Cámara de Diputados de la Nación);
- El Proyecto preparado por la Comisión creada por Decreto 468/92 del PEN.
- El Proyecto de 1998 (preparado por la Comisión creada por decreto 685/95 del Poder Ejecutivo Nacional).

Esta base fue enriquecida por numerosos trabajos críticos de la doctrina y decisiones jurisprudenciales que también se consideraron.

La Ley 26.994 (Prom: 7/10/2014).-

La Ley 26.994 consta de 10 artículos, de los cuales surge que:

- Aprueba el Código Civil Comercial de la Nación (Anexo I) y el Anexo II.
- Deroga:
 - Al anterior Código Civil (Ley 340);
 - Al Código de Comercio (Leyes 15 y 2637), a excepción de los arts. 891, 892, 907, 919, 926, 984 a 996, 999 a 1003 y 1006 a 1017/5, que se incorporaron como arts. 631 a 678 de la ley 20.094 (Ley de Navegación).
 - A las siguientes leyes: 11.357, 13.512, 14.394, 18.248, 19.724, 19.836, 20.276, 21.342 (salvo su art. 6), 23.091, 25.509 y 26.005;
 - A los arts. 361 a 366 del Capítulo II y el Capítulo III de la Ley 19.550;
 - A los arts. 36, 37 y 38 de la Ley 20.266;
 - Al art. 37 del Decreto 1798/94;
 - A los arts. 1° a 26 de la Ley 24.441;

- A los Capítulos I (salvo el segundo y tercer párrafos del art. 11) y III (salvo los párrafos segundo y tercero del artículo 28) de la Ley 25.248.

• Las leyes que integraban, complementaban o que estaban incorporadas al Código Civil o al Código de Comercio derogados mantienen su vigencia como *leyes que complementan al Código Civil y Comercial de la Nación* aprobado por esta ley, salvo las normas derogadas expresamente en el art. 3 de la ley.

• Toda referencia al Código Civil o al Código de Comercio contenida en la legislación vigente debe entenderse remitida al Código Civil y Comercial de la Nación que por la presente se aprueba.

• Originariamente, se establecía que esta ley entraría en vigencia el 1° de enero de 2016. Esto fue modificado por la Ley 27.077, que dispuso que entraría en vigencia el 1° de agosto de 2015.

• Los arts. 8 y 9 de la ley se refieren a normas complementarias y transitorias de aplicación del Código Civil y Comercial.

• El art. 10 es de forma: *Comuníquese al Poder Ejecutivo*.

• La Ley 26.994 contiene dos Anexos que fueron aprobados:

- El Anexo I incluye el texto del Código Civil y Comercial aprobado.

- El Anexo II incluye la sustitución de los artículos de las Leyes 17.081 (sobre Registros de la Propiedad Inmueble), 19.550 (Ley de Sociedades) y 24.240 (Ley de Defensa del Consumidor) por los textos que, para cada caso, se expresan.

Método o estructura interna del nuevo Código Civil y Comercial.-

El nuevo Código Civil y Comercial comienza con un *Título Preliminar*, que establece guías o directivas para todo el sistema unificado, haciendo referencia al Derecho, a la Ley, al ejercicio de los derechos y al derecho y los bienes.

Luego trae una *Parte General* (en el Libro Primero), con normas aplicables para todo el Código, sin perjuicio de que para algunas instituciones (tal el caso de las obligaciones, los contratos y los derechos reales) trae una *parte general específica* (principios o disposiciones comunes) para la institución que regula (por ej: las Obligaciones tienen Disposiciones Generales en los arts. 724 a 735; los Contratos en los arts. 1123 a 1128; los Derechos Reales en los arts. 1882 a 1891, etc.). Por último, se plasman los artículos que regularán los distintos aspectos de la institución en particular.

El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación contiene 2671 artículos, y se compone de seis libros:

- El Libro Primero: se refiere a la *Parte General*;
- El Libro Segundo: se refiere a las Relaciones de *Familia*;
- El Libro Tercero: se refiere a los *Derechos Personales*;
- El Libro Cuarto: se refiere a los *Derechos Reales*;
- El Libro Quinto: se refiere a la *Transmisión de derechos por causa de muerte*; y
- El Libro Sexto: se refiere a las *Disposiciones comunes a los derechos personales y reales*.

NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL

EL ANTEPROYECTO

Fue elaborado por una Comisión, integrada por el Dr. Ricardo Lorenzetti y las Dras. Elena Highton de Nolasco y Aída Kemelmajer de Carlucci.

- El Anteproyecto (comprendiendo el cuerpo de normas, 2 anexos y los Fundamentos de la normativa adoptada) fue presentado al Poder Ejecutivo, el cual le introdujo modificaciones.
- En el Congreso fue analizado por una *Comisión Bicameral*.
- Se aprobó con las modificaciones del PEN en Diputados y en Senadores.
- Se promulgó en Octubre de 2014.
- Debía entrar en vigencia el 1 de enero de 2016, pero por Ley 27.077 se dispuso que debía entrar en vigencia el 1 de agosto de 2015.

Aspectos valorativos del nuevo Código Civil y Comercial

- 1) *Identidad cultural latinoamericana*
- 2) *Constitucionalización del derecho privado*
- 3) *Igualdad y la no discriminación*
- 4) *Derechos individuales y colectivos*
- 5) *Ampliación en materia de bienes*
- 6) *Sociedad multicultural*
- 7) *Seguridad jurídica en las transacciones comerciales*

Aspectos generales del nuevo Código

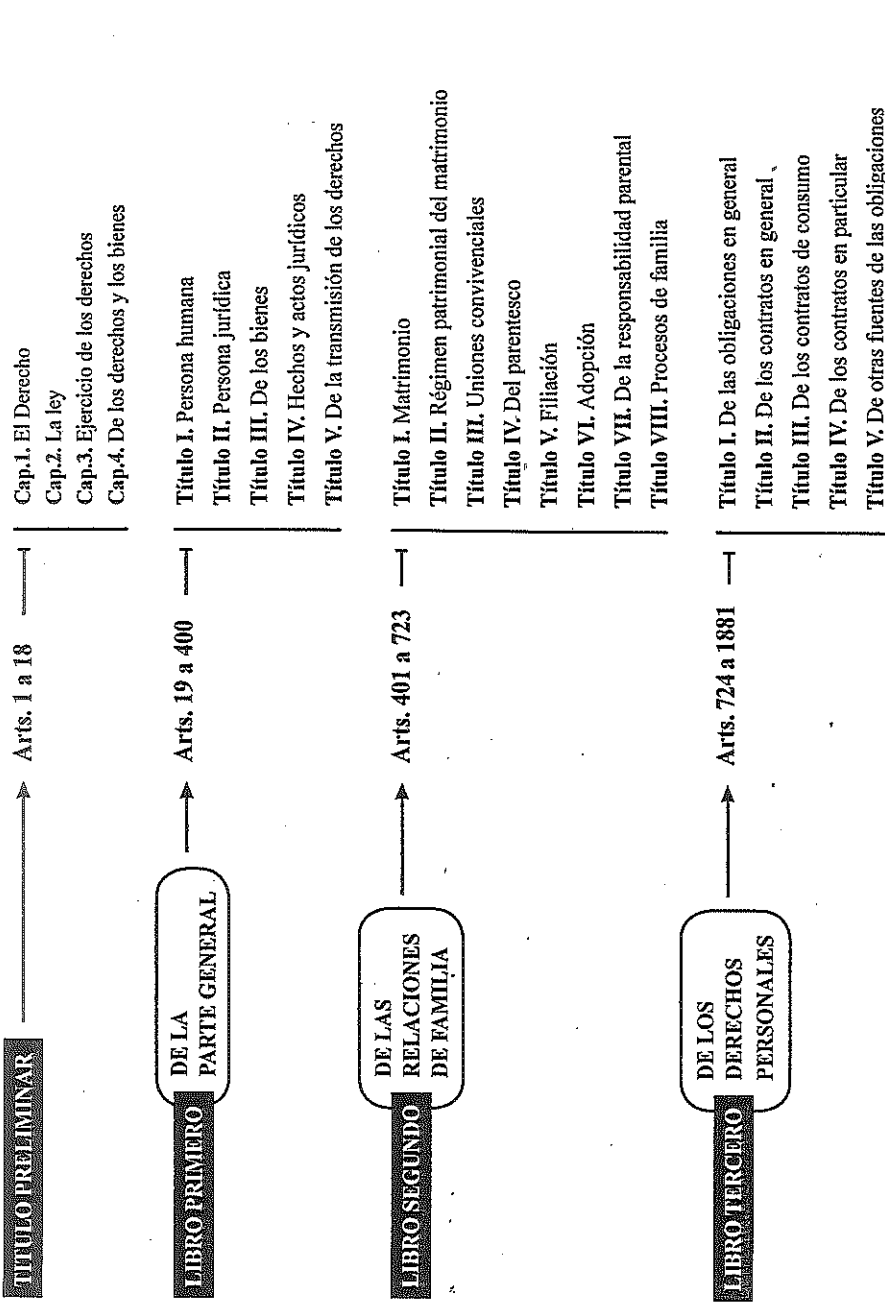
- a) *Unifica* los Códigos Civil y Comercial.
- b) Contiene un *Título Preliminar* y luego una *Parte General* que es para todo el Código.
- c) *No contiene* notas, a diferencia del Código Civil de Vélez que sí las traía pero que no tenían valor legal.
- d) *Definiciones*: se incorporaron aquellas que tienen efecto normativo, evitándose las definiciones didácticas.
- e) Efectúa una *redacción clara* de las normas, a fin de facilitar su entendimiento para los profesionales y para los que no lo son. Se evitan las remisiones. Se intentó conservar las palabras utilizadas por la doctrina y jurisprudencia. No obstante, fue inevitable recurrir a *nuevas expresiones* para reflejar nuevos fenómenos (Ej: unión convivencial, conviviente, persona con capacidad restringida, responsabilidad parental, etc).
- f) El Código se vincula con otros *microsistemas normativos autosuficientes*, con la intención de no modificar sus normas, salvo que fuera absolutamente necesario. A pesar de ello, hay leyes que tuvieron que ser modificadas en forma parcial (por ej: la *Ley de Defensa del Consumidor* y la *Ley General de Sociedades*).
- g) Los redactores tuvieron en cuenta diversos *antecedentes* para la redacción del nuevo Código.

- Anteproyecto Bibiloni de 1926 / • Anteproyecto de 1954 (redactado por Jorge Joaquín Llambías) /
- Proyecto de Unificación de la legislación Civil y Comercial, proveniente de la Cámara de Diputados de la Nación (año 1987) / • Proyecto de 1993 (de la Comisión Federal de la Cámara de Diputados de la Nación) / • Proyecto preparado por la Comisión creada por Decreto 468/92 del PEN / • Proyecto de 1998 (preparado por la Comisión creada por decreto 685/95 del Poder Ejecutivo Nacional).

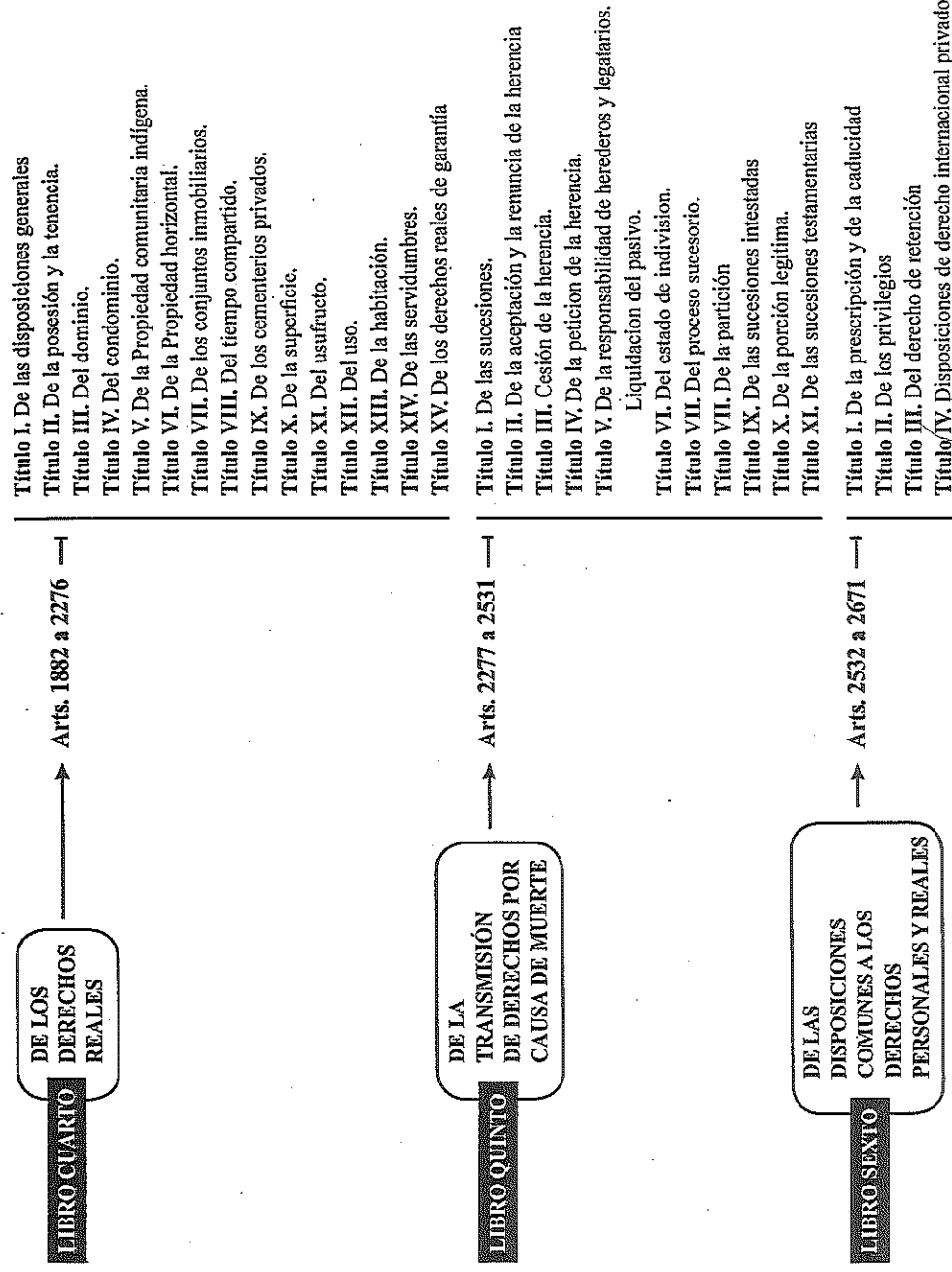
Ley 26.994

- Consta de 10 artículos.
- *Aprueba* el Código Civil Comercial de la Nación (Anexo I) y el Anexo II.
- *Deroga* al anterior Código Civil (Ley 340); al Código de Comercio (Leyes 15 y 2637), a excepción de los arts. 891, 892, 907, 919, 926, 984 a 996, 999 a 1003 y 1006 a 1017/5, que se incorporaron como arts. 631 a 678 de la Ley de Navegación; y a otra legislación.

MÉTODO DEL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL



SÍNTESIS GRÁFICA



SÍNTESIS GRÁFICA

CAPÍTULO I

TÍTULO PRELIMINAR

DERECHO. FUENTES.

Generalidades.-

El *Título Preliminar* es el núcleo o centro del ordenamiento jurídico sobre derecho privado, ya que en él se establecen reglas, principios o valores básicos que sirven de guía o directivas para todo el sistema de derecho privado (civil y comercial) que se ha unificado.

Ante la duda de si era necesario o no incluir un Título Preliminar en el nuevo Código, los redactores del mismo decidieron hacerlo y en los Fundamentos explican por qué lo hicieron: "Su aceptación se ha basado en una tradición histórica y en el presupuesto de que el Código es el centro del ordenamiento jurídico referido al derecho privado y por lo tanto, allí deben consignarse las reglas generales de todo el sistema".

Contenido.-

El Título Preliminar consta de 18 artículos y está dividido en cuatro Capítulos:

- 1) "Derecho";
- 2) "Ley";
- 3) "Ejercicio de los derechos";
- 4) "Derechos y bienes".

A través de estos Capítulos, el Título Preliminar define las fuentes del derecho, brinda reglas de interpretación, suministra guías para el ejercicio de los derechos, reconoce distintos principios generales (buena fe, abuso, fraude, etc.) y, finalmente, indica el ámbito de aplicación del Código en relación a los derechos y bienes.

Los dos primeros Capítulos ("Derecho" y "Ley") están dirigidos a los jueces, mientras que los otros dos ("Ejercicio de los derechos" y "Derechos y bienes") están dirigidos a los ciudadanos.

DERECHO

Concepto de Derecho. Derecho Objetivo y Derecho Subjetivo.-

Para que la convivencia de los hombres en la sociedad sea armoniosa, el Estado crea un ordenamiento jurídico estableciendo un sistema de reglas y normas a las cuales, *obligatoriamente*, el hombre debe ajustar su conducta. Este sistema de reglas y normas jurídicas que regulan la conducta del hombre y sus relaciones, es lo que se denomina *Derecho* y que la doctrina define así:

• **Salvat:** el Derecho es el "conjunto de reglas establecidas para regir las relaciones del hombre en sociedad".

• **Llambías:** lo define como el "ordenamiento social justo".

• **Borda:** expresa que es el "conjunto de normas de conducta humana establecidas por el Estado con carácter obligatorio y conforme a la justicia".

Derecho Objetivo y Derecho Subjetivo.-

La expresión "**Derecho**" puede ser empleada bajo dos puntos de vista diferentes: el "Derecho Objetivo" y el "Derecho Subjetivo".

En efecto, el Derecho es, por un lado, un conjunto de normas, de reglas, que regulan la conducta humana en la sociedad (Derecho Objetivo) y, por otro lado, el derecho otorga facultades o poderes al hombre para que pueda lograr sus fines (Derecho Subjetivo).

Estos dos conceptos (objetivo y subjetivo) no se excluyen sino que, por el contrario, coexisten. Así, por ejemplo, el "derecho objetivo" impone la obligación de que se respete la propiedad ajena, o de que el deudor pague sus deudas, etc., pero a la vez otorga al propietario la facultad o "derecho subjetivo" de exigir que se respeten las cosas de su propiedad, o al acreedor la facultad de exigir del deudor el pago del crédito, etc.

Derecho y orden religioso, social y moral.-

El Derecho no es el único conjunto normativo que rige la conducta del hombre, también la rigen los preceptos religiosos, las reglas sociales y las normas morales. Pero la distinción entre Derecho y Religión se planteó y resolvió a partir del Cristianismo y se resume en la frase: "dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios". La distinción entre el Derecho y las reglas sociales es notoria si tomamos en cuenta que las reglas sociales sólo rigen aspectos superficiales de la conducta, que hacen que el hombre sea más o menos agradable frente a los demás. Respecto al Derecho y a la Moral, si bien antiguamente ambos conceptos tendían a confundirse, en la actualidad está bien marcada la diferencia:

• **Las normas jurídicas son obligatorias:** el Estado las impone coactivamente al individuo, y si éste no las cumple se lo puede obligar a cumplir o se le pueden imponer sanciones.

• **Las normas morales no son obligatorias:** el individuo las cumple si quiere. Si no las cumple, a lo sumo podrá sufrir el rechazo de sus semejantes o el remordimiento de su conciencia.

Sin perjuicio de esta distinción doctrinaria, la compenetración entre ambos órdenes es evidente:

- En el **Código Civil** de Vélez diversos artículos contenían pautas morales al referirse "a la moral, a las buenas costumbres o a la buena fe" (ej.: arts. 14, inc. 1; 530; 953; 954; 1071; 1198; 1503; 1891; 2261; 3608; etc.) y ello se acrecentó con la reforma de la Ley 17.711 que consagró las instituciones de la "lesión subjetiva" (art. 974), el "abuso del derecho" (art. 1071) y la "teoría de la imprevisión" (art. 1198).

- En el **nuevo Código Civil y Comercial** las referencias a la moral, la buena fe o las buenas costumbres también están presentes en numerosos artículos (ej.: arts. 9; 10; 55; 56; 344; 386; 398; 957; 1004; 1014; etc.).

Derecho Natural y Derecho Positivo.-

Derecho Natural es el conjunto de reglas universales e inmutables, fundadas en la naturaleza humana, en la voluntad de Dios o reveladas por la recta razón. Se traduce en pautas muy genéricas, en grandes principios que, por tanto, permanecen inmutables a través de todos los tiempos, como la naturaleza humana misma.

Derecho Positivo, en cambio, es el derecho objetivo que rige en un Estado determinado, en un momento dado. Se puede distinguir así: derecho argentino, derecho español, derecho alemán, etc.

Cuando esos derechos (natural y positivo) no coinciden, ¿cuál prevalece?

- El "**positivismo**" entiende que sólo es Derecho el Derecho Positivo, al margen de otros conceptos (como la moral, la política, etc.) que trascienden la norma jurídica; si el Derecho se inspira en la moral vigente, mejor; pero si no lo hace, también es Derecho, y es de vigencia obligatoria por su sola sanción legislativa (Kelsen).

- El "**iusnaturalismo**" (Escuela del Derecho Natural), en cambio, entiende que no es válido el Derecho si no es justo (concepto moral) y que la injusticia de la norma justifica su desobediencia. Para determinar si una norma es justa o injusta, se debe recurrir al Derecho Natural: si la norma es acorde a él, es justa; de lo contrario, es injusta, y por lo tanto inválida.

Esta postura (esbozada ya por filósofos antiguos) fue desarrollada por Santo Tomás de Aquino para oponerse a los abusos del poder, por Hugo Grocio para justificar el origen del Derecho Internacional Público, y más recientemente se la utilizó para dar lugar al Derecho Laboral. En la actualidad renace, en forma implícita, en las normas sobre derechos humanos y en las de contenido ecologista.

Ramas del Derecho Positivo.-

El ordenamiento jurídico vigente es único, pero por razones científicas y didácticas que hacen a su mejor conocimiento, aparece dividido en dos grandes sectores o ramas: el **Derecho Público** y el **Derecho Privado**. Estos, a su vez, se dividen en otras ramas.

• **Derecho Público:** abarca las ramas del Derecho en las cuales uno de los sujetos es el Estado actuando como poder público, y en las que se regula su organización, funcionamiento, atribuciones y deberes, y sus relaciones con los particulares. Son ramas del Derecho Público, por ejemplo:

- el Derecho Constitucional;
- el Derecho Administrativo;
- el Derecho Penal;
- el Derecho Internacional Público;
- el Derecho Financiero;
- el Derecho Municipal;

- el Derecho Procesal (suele considerarse de Derecho Público ya que organiza el Poder Judicial y el procedimiento ante el mismo. Sin embargo hay autores que opinan que es Derecho Público cuando regula materias públicas -Penal, Administrativo, Constitucional, etc.-, y de Derecho Privado cuando rige el procedimiento en materias privadas -Civil, Comercial, etc.-);

- el Derecho Laboral (si bien al independizarse del Derecho Civil nació como rama del Derecho Privado, en la actualidad sufre tan fuerte ingerencia estatal -en los convenios colectivos, las conciliaciones, las reglamentaciones del trabajo, etc.-, que cada vez comparte más las características del Derecho Público);

- el Derecho Minero (si bien es considerado por algunos autores como rama de Derecho Privado, otros entienden que es de Derecho Público, ya que las minas -salvo algunas de escasa importancia regidas por el Derecho Privado- son de propiedad del Estado -son bienes privados pertenecientes al Estado como poder público-).

• **Derecho Privado:** comprende las ramas que regulan las relaciones de los particulares entre sí, y eventualmente de los particulares con el Estado, pero cuando éste actúa como persona de Derecho Privado (y no como poder público). Son ramas del Derecho Privado (con las aclaraciones precedentes):

- el Derecho Civil;
- el Derecho Comercial;
- el Derecho Agrario o Rural;
- el Derecho Internacional Privado;
- el Derecho de la Navegación (desprendimiento del Derecho Comercial);
- el Derecho Aeronáutico (desprendimiento del Derecho de la Navegación);
- el Derecho Espacial, que está en sus albores;
- el Derecho Industrial, que regula todo lo relativo a marcas y patentes.

A estas pautas de diferenciación entre Derecho Público y Derecho Privado, algunos agregan que en el Derecho Público está en juego el interés general, y en el Derecho Privado el interés de los particulares; sin embargo hay que admitir que en la defensa de los derechos de los particulares, también está comprometido el interés público.

Otros entienden que en el Derecho Público se da una *relación de subordinación*, por la supremacía del Estado sobre los particulares, y en el Derecho Privado una relación de *coordinación*, por el plano de igualdad que ocupan los particulares entre sí.

La Consolidación de leyes vigentes. El Digesto Jurídico Argentino.-

La Ley 26.939 (BO 16/06/2014) aprobó el Digesto Jurídico Argentino, el cual sistematiza y ordena las leyes nacionales vigentes desde 1853 hasta marzo de 2013.

Desde 1853 se han dictado miles de leyes. Esta proliferación de leyes hizo cada vez más difícil saber con exactitud cuáles estaban vigentes y cuáles no, ya que había muchas leyes que habían sido derogadas o modificadas por otras leyes; otras que

eran contradictorias con otras normas o quedaron caducas por haberse cumplido el objeto para el que fueron dictadas, etc.

El Digesto Jurídico Argentino realiza un reordenamiento y una clasificación de las leyes nacionales que se encuentran vigentes en distintas ramas del derecho. Es una consolidación normativa que contiene:

- a) Las leyes nacionales de carácter general vigentes, ordenadas por categorías;
- b) Un anexo con las leyes nacionales de carácter general no vigentes, ordenado por categorías;
- c) La referencia a las normas aprobadas por organismos supraestatales o intergubernamentales de integración de los que la Nación sea parte.

Las leyes que integran el Digesto Jurídico Argentino se identifican por categoría o materia con la letra correspondiente de acuerdo a lo siguiente:

ADM) Administrativo; ACU) Cultura, Ciencia y Tecnología; AED) Educación; ASA) Salud Pública; ASE) Seguridad; ASO) Acción y Desarrollo Social; B) Aduanero; C) Aeronáutico-Espacial; D) Bancario, Monetario y Financiero; E) Civil; F) Comercial; G) Comunitario; H) Constitucional; I) De la Comunicación; J) Diplomático y Consular; K) Económico; L) Impositivo; M) Industrial; N) Internacional Privado; O) Internacional Público; P) Laboral; Q) Medio Ambiente; R) Militar; S) Penal; T) Político; U) Procesal Civil y Comercial; V) Procesal Penal; W) Público Provincial y Municipal; X) Recursos Naturales; Y) Seguridad Social; Z) Transporte y Seguros.

Ejemplos: la Constitución Nacional pasa a ser H-0001; la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo pasa a ser P-1018; el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (Ley 17.454) pasa a ser U-0692; la Ley 13.512 de Propiedad Horizontal pasa a ser E-0322; etc.

Cabe aclarar que el Digesto Jurídico no realiza modificaciones a las leyes incluidas en el mismo.

La ley dispone la creación de la *Comisión Bicameral Permanente* del Digesto Jurídico Argentino (integrada por cuatro senadores y cuatro diputados, designados por cada una de las Cámaras), la cual tendrá la función de analizar las actualizaciones del Digesto Jurídico Argentino.

El Digesto entrará en vigencia luego de un período de 180 días a partir de la publicación oficial (16/06/2014).

DERECHO CIVIL

Antecedentes históricos. Transformaciones. Contenido actual.-

La expresión *Derecho Civil* se origina en el "ius civile" de los romanos. El *ius civile* (que comprendía el Derecho Público y el Derecho Privado) era el Derecho que se aplicaba sólo a los ciudadanos romanos, en tanto el *ius gentium* o *ius naturalis* regía para todos los hombres, fueran ciudadanos romanos o extranjeros.

En el año 212 d.C., el emperador Caracalla otorgó la ciudadanía a todos los habitantes del imperio romano, con lo cual el *ius civile* se transformó en el Derecho común aplicable a todos.

Con el tiempo, el *ius civile* se separa de las normas del Derecho Público y pasa a identificarse con el Derecho Privado, hasta que comienzan a desmembrarse de él las actuales ramas. Primero, se separa el Derecho Comercial, ya que los comerciantes comienzan a regirse por usos y costumbres mercantiles; luego el Derecho Laboral, cuando la locación de servicios del Derecho Civil se torna insuficiente para regular las variadas situaciones que suscita la relación laboral.

Actualmente el Derecho Civil sólo comprende una parte residual del Derecho Privado: comprende lo que no está específicamente regulado por las ramas desmembradas. Sin embargo, dado su carácter de tronco común, las ramas separadas recurrirán a él para obtener determinados principios fundamentales que siempre serán de aplicación supletoria cuando la legislación específica así lo disponga o cuando no contemple determinadas situaciones.

El contenido actual del Derecho Civil abarca todo lo relativo a la persona como tal, sus relaciones con otras personas (familiares, crediticias, etc.) y su vinculación con los bienes, desde su concepción hasta después de su muerte (derechos reales y sucesiones).

El nuevo Código Civil y Comercial, unifica todo el derecho privado. Trae un Título Preliminar con cuatro Capítulos dedicados al "**Derecho**" (*Derecho; Ley; Ejercicio de los derechos; y Derechos y bienes, respectivamente*). No define al Derecho pero lo diferencia de la *Ley*, a la cual regula específicamente en el Capítulo 2.

De la estructura del nuevo Código surge que *Derecho* y *Ley* no son lo mismo; *Derecho* es el orden jurídico general, en tanto que la *Ley* es su fuente principal, pero no la única fuente. Al respecto, en los Fundamentos se dice: "*Proponemos distinguir normativamente el derecho de la ley. Una identificación entre ambos no es admisible en el estadio actual de la evolución jurídico-filosófica*".

En el Capítulo 1 referido específicamente al "**Derecho**" se tratan las fuentes de derecho (art.1), las reglas de interpretación (art. 2) y el deber de resolver de los jueces (art. 3).

FUENTES DEL DERECHO

Concepto.-

"Fuentes del Derecho" son los distintos modos de creación o de expresión del derecho positivo.

La teoría de las fuentes tiene por objeto determinar cuáles son las causas (sociales, morales, políticas, etc.) que originan una norma y cuáles los modos de expresión (o manifestación) del Derecho.

Clasificación de las fuentes.-

Siguiendo la clasificación de Francisco Geny, se puede hablar de: fuentes formales y materiales.

a) **Fuentes Formales:** son las normas de aplicación obligatoria para el intérprete; son reglas establecidas específicamente para manifestar el Derecho vigente, y emanan de órganos con atribuciones para ello. La principal fuente formal del Derecho es la ley, pero ella no es la única fuente.

b) **Fuentes Materiales:** a diferencia de las anteriores, no son de aplicación obligatoria y sólo se aplicarán según su bondad o poder de convicción. Se recurre a ellas cuando las fuentes formales no contemplan la solución necesaria para un caso determinado.

Son fuentes materiales: la jurisprudencia y la doctrina

Las fuentes en el nuevo Código Civil y Comercial.-

Art. 1º.- "Fuentes y aplicación. Los casos que este Código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. A tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho".

En el nuevo Código Civil y Comercial los casos deben ser resueltos conforme a un sistema de fuentes en el que (conf. al art. 1) se reconocen las siguientes fuentes:

- a) la Ley;
- b) la Constitución Nacional;
- c) los Tratados de derechos humanos en los que la República sea parte.
- d) Los usos, prácticas y costumbres, cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho.

Algunas de estas fuentes ya estaban en el Código de Vélez. El nuevo Código agrega: la Constitución Nacional y los Tratados de derechos humanos.

a) La Ley.-

Los casos deben ser resueltos conforme a un sistema de fuentes, pero en este sistema la principal fuente formal es la Ley ya que de lo contrario, aparecerían sentencias que no aplican la ley, o se apartan de ella sin declarar su inconstitucionalidad, siendo ésta una decisión "contra legem" que origina litigiosidad innecesaria. La aplicación de la ley significa delimitar el supuesto de hecho y subsumirlo en la norma, es decir una deducción (conf. *Fundamentos*).

La ley tiene dos acepciones:

- en sentido amplio (o material): ley es toda norma general dictada por autoridad competente. Ej: un decreto presidencial.
- en sentido estricto (o formal): leyes son sólo aquellas que emanan del Poder Legislativo y de acuerdo con los procedimientos y formalidades establecidos en la Constitución.

Caracteres.- La ley presenta los siguientes caracteres:

- 1) Es **obligatoria y coactiva**: dado que existe la obligación de obedecer lo que mande la ley, y que, en caso contrario, habrá lugar a las sanciones que ella establezca.
 - 2) **Generalidad**: contempla un número indeterminado de hechos, y se aplica a cualquier persona que los realice.
 - 3) **Origen público**: la ley es establecida por la autoridad pública competente.
- Aparte de estos caracteres, más adelante veremos otros aspectos de la ley. Reñitimos al Capítulo III "La Ley", de esta obra.

b) La Constitución Nacional.-

En el sistema de fuentes del nuevo Código Civil y Comercial se destaca la Constitución Nacional, respondiendo a la tendencia de la "constitucionalización del derecho privado", y estableciendo una comunidad de principios entre la Constitución, el derecho público y el derecho privado. También, en consonancia con la Constitución Nacional, el nuevo Código regula los derechos individuales e innova al darle una importancia relevante a los derechos de incidencia colectiva.

De los *Fundamentos* surge que la ley que se aplique debe ser conforme a la Constitución Nacional y que se impone la regla de no declarar la invalidez de una disposición legislativa si ésta puede ser interpretada cuando menos en dos sentidos posibles, siendo uno de ellos conforme con la Constitución.

Ello implica la exigencia de no pronunciarse por la inconstitucionalidad de una ley que pueda ser interpretada en armonía con la Constitución. Este criterio (que constituye una restricción al quehacer judicial), es reiteradamente recordado por la CSJN, cuando expresa que la declaración de inconstitucionalidad constituye la última ratio del orden jurídico, por lo que sólo será pronunciada siempre que no haya forma de integrar la norma a fin de su coincidencia con la Carta Magna (Fallos 288:325; 290:83; 292:190; 301:962; 324:3345, 4404; 325:645, entre otros).

c) Los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte.-

Los tratados internacionales (por el art. 31 de la CN) son ley suprema de la Nación; y por el art. 75 inc. 22 de la CN varios tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional. Pero, tengan o no jerarquía constitucional, los tratados de derechos humanos son fuente del derecho.

d) Los usos, prácticas y costumbres.-

Son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho.

LA COSTUMBRE.-

Concepto.-

Cuando la generalidad de las personas que integran la sociedad actúa de una manera determinada y uniforme por un período largo de tiempo, podemos decir

que existe una costumbre. Se la puede definir como: *la forma de actuar uniforme y sin interrupciones que, por un largo período de tiempo, adoptan los miembros de una comunidad, con la creencia de que dicha forma de actuar responde a una necesidad jurídica, y es obligatoria*.

Elementos y caracteres.-

La existencia de la costumbre depende de la presencia de dos elementos:

1) **Elemento objetivo** (o material).- Para que se dé este elemento, la costumbre debe reunir los siguientes caracteres:

- a) ser *uniforme*: que el hecho o comportamiento tenga siempre las mismas características;
- b) ser *constante*: que se lleve a cabo sin interrupciones;
- c) *largo uso*: que se practique por un período de tiempo más o menos prolongado. (Llambías cita el ejemplo del Derecho Canónico, en el cual se exigían 10 años de uso para la costumbre *praeter legem*, y 40 para la costumbre *contra legem*);
- d) *generalidad*: que el hecho sea practicado por toda la comunidad o por la mayoría de ella;
- e) *publicidad*: que el hecho sea conocido por todos.

2) **Elemento subjetivo** (o psicológico o espiritual).- Se da cuando existe la firme creencia por parte de la comunidad de que el hecho practicado es una necesidad jurídica, y que, por tanto, es obligatorio.

Valor de la Costumbre.

Sistema de Derecho Escrito y Sistema de Common law.-

En la antigüedad, las sociedades jurídicamente poco evolucionadas, se regían por costumbres y tradiciones que se transmitían de generación en generación. A este sistema de Derecho, basado en la costumbre, se lo denomina *Derecho consuetudinario*.

A medida que las sociedades crecen y las relaciones humanas se tornan más complejas, se va haciendo más difícil identificar cuál es la conducta establecida por la costumbre o cuál no, o cuál es la conducta correcta cuando aparecen dos o más costumbres contradictorias. Surge entonces la necesidad de recurrir a las normas escritas, y así fue que el derecho consuetudinario fue cediendo terreno al derecho escrito, cuyo más alto grado de desarrollo fue la codificación.

Actualmente, en la mayoría de los países el Derecho se manifiesta por escrito y, por lo general, es codificado. Sin embargo, en algunos países (Inglaterra, Canadá, Australia, Estados Unidos.) rige el sistema jurídico del "*common law*", que es un sistema de Derecho no escrito, no codificado, basado fundamentalmente en la costumbre (derecho consuetudinario) y en los fallos precedentes.

Así como en los sistemas de *derecho escrito* la fuente más importante es la ley escrita, en los sistemas del *common law* la fuente predominante es la costumbre. Los jueces del common law, para dictar sentencia en un caso determinado, deben

fundarse en la costumbre imperante en el país respecto de ese caso; pero no citan directamente la costumbre, sino los fallos anteriores que la aplicaron, denominados *precedentes judiciales*, de modo que éstos funcionan como prueba de la existencia de la costumbre vigente. Para facilitar el conocimiento de los precedentes, ellos se recopilan en libros o repertorios denominados "*records*".

Por excepción, los países del *common law* recurren a veces a normas escritas, especialmente de Derecho Público, algunas de carácter administrativo (como los estatutos o "*statute-law*"), otras tendientes a reglamentar las libertades de los ciudadanos (como los edictos y actas: "*bills*" y "*acts*").

En los países de *derecho escrito*, si bien la fuente primordial es la ley, no obstante es indiscutible el papel de la costumbre como *fuerza material*, ya que con el tiempo puede dar lugar a normas que adopten las conductas establecidas por ella; pero además, el Derecho moderno la considera *fuerza formal*, si bien en plano secundario con relación a la ley.

Distintos tipos de costumbre.-

Para determinar en qué medida se puede recurrir a la costumbre como *fuerza formal* del Derecho, se la clasifica en 3 tipos diferentes según su relación con la ley:

- 1) Costumbre *secundum legem* (según la ley).- Es la costumbre reconocida por la ley, de manera que está *de acuerdo* con ella.
- 2) Costumbre *praeter legem* (al margen de la ley).- Es la que crea una norma consuetudinaria con relación a una situación *no contemplada* por la ley.
- 3) Costumbre *contra legem* (contra la ley o "desuetudo").- Se genera *en contra* de lo que establece la ley, y por tanto intenta derogarla.

La Costumbre en nuestro Derecho.-

El Código Civil de Vélez se refería a la costumbre en su art. 17, y establecía: "*Los usos y costumbres no pueden crear derechos sino cuando las leyes se refieran a ellos o en situaciones no regladas legalmente*".

De manera que sólo aceptaba la costumbre *secundum legem* y *praeter legem*.

El nuevo Código Civil y Comercial sigue la misma idea, ya que el art. 1 expresa: "*Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho*".

De manera que, en el nuevo Código:

- Se acepta la costumbre *secundum legem* ("*...cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos...*");
- Se acepta la costumbre *praeter legem* ("*...en situaciones no regladas legalmente...*"); y
- No se admite la costumbre *contra legem* ("*...siempre que no sean contrarios a derecho.*").

DERECHO

Concepto

Para que la convivencia de los hombres en la sociedad sea armoniosa, el Estado crea un ordenamiento jurídico estableciendo un sistema de reglas y normas a las cuales, *obligatoriamente*, el hombre debe ajustar su conducta. Este sistema de reglas y normas jurídicas que regulan la conducta del hombre y sus relaciones, es lo que se denomina *Derecho*.

Derecho Objetivo y Derecho Subjetivo

El Derecho es

- por un lado, un conjunto de normas, de reglas, que regulan la conducta humana en la sociedad (**Derecho Objetivo**); y
- por otro lado, el derecho otorga facultades o poderes al hombre para que pueda lograr sus fines (**Derecho Subjetivo**).

Estos dos conceptos (objetivo y subjetivo) no se excluyen sino que, por el contrario, coexisten.

Derecho y orden religioso social y moral

- Las normas jurídicas son obligatorias: el Estado las impone coactivamente al individuo, y si éste no las cumple se lo puede obligar a cumplir o se le pueden imponer sanciones.
- Las normas morales no son obligatorias: el individuo las cumple si quiere. Si no las cumple, a lo sumo podrá sufrir el rechazo de sus semejantes o el remordimiento de su conciencia.

Derecho natural y Derecho Positivo

Derecho Natural

Es el conjunto de reglas universales e inmutables, fundadas en la naturaleza humana, en la voluntad de Dios o reveladas por la recta razón. Se traduce en pautas muy genéricas que permanecen inmutables a través de todos los tiempos.

Derecho Positivo

Es el derecho objetivo que rige en un Estado determinado, en un momento dado. Se puede distinguir así: derecho argentino, derecho español, derecho alemán, etc.

Cuando esos derechos no coinciden, ¿cuál prevalece?
Diferentes posturas:
"positivismo"
≠
"iusnaturalismo"

Ramas del Derecho Positivo

♦ **Derecho Público**: abarca las ramas del Derecho en las cuales uno de los sujetos es el Estado actuando como poder público, y en las que se regula su organización, funcionamiento, atribuciones y deberes, y sus relaciones con los particulares. Son ramas del Derecho Público, por ejemplo, el Derecho Constitucional; el Derecho Administrativo; el Derecho Penal; etc.

♦ **Derecho Privado**: comprende las ramas que regulan las relaciones de los particulares entre sí, y eventualmente de los particulares con el Estado, pero cuando éste actúa como persona de Derecho Privado (y no como poder público). Son ramas del Derecho Privado, por ejemplo, el Derecho Civil; el Derecho Comercial; el Derecho Agrario o Rural; etc.

DERECHO CIVIL

- Actualmente el Derecho Civil sólo comprende una parte residual del Derecho Privado: **comprende lo que no está específicamente regulado por las ramas desmembradas**.
- Sin embargo, dado su carácter de tronco común, las ramas separadas recurrirán a él para obtener determinados principios fundamentales que siempre serán de aplicación supletoria.
- El contenido actual del Derecho Civil abarca todo lo relativo a la persona como tal, sus relaciones con otras personas (familiares, crediticias, etc.) y su vinculación con los bienes, desde su concepción hasta después de su muerte (derechos reales y sucesiones).

FUENTES DEL DERECHO

Concepto

"Fuentes del Derecho" son los distintos modos de creación o de expresión del derecho positivo.

LAS FUENTES EN EL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL

Los casos deben ser resueltos conforme a un sistema de fuentes en el que (conf. al art. 1) se reconocen las siguientes fuentes:

A LA LEY

* Es la principal fuente formal del Derecho (pero no es la única).

* Tiene dos acepciones:

- **en sentido amplio** (o material): ley es toda norma general dictada por autoridad competente. Ej: un decreto presidencial.
- **en sentido estricto** (o formal): leyes son sólo aquellas que emanan del Poder Legislativo y de acuerdo con los procedimientos y formalidades establecidos en la Constitución.

Caracteres

- 1) Es **obligatoria y coactiva**: dado que existe la obligación de obedecer lo que mande la ley, y que, en caso contrario, habrá lugar a las sanciones que ella establezca.
- 2) **Generalidad**: contempla un número indeterminado de hechos; se aplica a cualquier persona que los realice.
- 3) **Origen público**: la ley es establecida por la autoridad pública competente.

B LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

En el nuevo Código es manifiesta la tendencia de la "constitucionalización del derecho privado". En consonancia con la CN, el nuevo Código regula los derechos individuales e innova al darle una importancia relevante a los derechos de incidencia colectiva. La ley que se aplique debe ser conforme a la CN y no se debe declarar la invalidez de una disposición legislativa si ésta puede ser interpretada cuando menos en dos sentidos posibles, siendo uno de ellos conforme con la Constitución. La declaración de inconstitucionalidad constituye la última ratio del orden jurídico.

C LOS TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS

(en los que la República sea parte)

Los tratados internacionales (por el art. 31 de la CN) son ley suprema de la Nación; y por el art. 75 inc. 22 de la CN, varios tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional. Pero, tengan o no jerarquía constitucional, los tratados de derechos humanos son fuente del derecho.

D LOS USOS, PRÁCTICAS Y COSTUMBRES

Son vinculantes (obligan) cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos (*secundum legem*) o en situaciones no regladas legalmente (*praeter legem*), **siempre que no sean contrarios a derecho**. No se admite la costumbre "contra legem".

COSTUMBRE

Forma de actuar uniforme y sin interrupciones que, por un largo período de tiempo, adoptan los miembros de una comunidad, con la creencia de que dicha forma de actuar responde a una necesidad jurídica, y es obligatoria.

Elementos

- 1) **Elemento objetivo**: a) ser *uniforme*; b) ser *constante*; c) *largo uso*; d) *generalidad*; e) *publicidad*.
- 2) **Elemento subjetivo**: cuando existe la firme creencia por parte de la comunidad de que el hecho practicado es una necesidad jurídica, y que, por tanto, es obligatorio.

Valor

- en el Common law: es fuente predominante.
- en el Derecho escrito: es fuente formal sólo en algunos casos.

Regulación Art. 1

- 1) Costumbre *secundum legem* (según la ley). Se admite.
- 2) Costumbre *praeter legem* (al margen de la ley). Se admite.
- 3) Costumbre *contra legem* (contra la ley o "desuetudo"). No se admite.

CAPÍTULO II INTERPRETACIÓN DE LA LEY

Concepto.-

Los jueces deben aplicar la ley a los casos que se someten a su decisión. Pero antes de aplicar una norma a un caso determinado, el juez deberá interpretarla, es decir, establecer qué es lo que quiere decir la norma, y luego, ver si ella se refiere o no, al caso que debe juzgar. Como vemos, la aplicación y la interpretación están en íntima relación: no habrá correcta aplicación, si no hay correcta interpretación.

"Interpretar" es buscar el verdadero sentido y alcance de una norma jurídica. "Interpretar, es buscar el sentido y valor de la norma para medir su extensión precisa..." (conf. Llambías). La ley es la manifestación de una idea, y la interpretación consiste en reconstruir el pensamiento del autor de la norma; por eso Hugo Alsina nos dice que: "interpretar es repensar un pensar".

La interpretación será necesaria, no sólo cuando una norma sea oscura e insuficiente, sino también en el caso de que se trate de una norma de contenido claro y concreto. Siempre hay que saber con exactitud cuál es el verdadero sentido y alcance de la ley.

El nuevo Código Civil y Comercial se refiere a la "interpretación" en su art. 2:

Art. 2°.- "Interpretación. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento".

En dicho artículo vemos las siguientes reglas de interpretación:

- 1) las palabras de la ley;
- 2) las finalidades de la ley;
- 3) las leyes análogas;
- 4) las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos;
- 5) los principios y valores jurídicos; y
- 6) la coherencia con todo el ordenamiento jurídico.

Especies de Interpretación.-

Si bien la interpretación es función esencial del Juez, también puede estar a cargo de distintas personas, y según quién sea el intérprete, la interpretación podrá ser:

• **Interpretación legislativa**: es la que está a cargo del Poder Legislativo. Ejemplo: el Congreso dicta una ley, y posteriormente dicta otra ley aclaratoria, interpretando la primera. Esta interpretación es de carácter obligatorio, para todos los destina-

rios de la ley. Se la suele denominar *interpretación auténtica o propia* porque es realizada por el mismo órgano que dictó la ley.

• **Interpretación judicial:** es la que realizan los jueces al aplicar las leyes. Ella es obligatoria para las partes del pleito, salvo que la interpretación surja de un fallo plenario, en cuyo caso su obligatoriedad se extiende a la Cámara que lo dictó, a sus salas, y a los tribunales de primera instancia que dependan de ella.

• **Interpretación doctrinaria:** es la que realizan los juristas en sus obras (tratados, manuales, monografías, etc.). Esta interpretación NO tiene fuerza obligatoria, pero tiene gran influencia en los jueces y legisladores. Ella se impone por la fuerza de convicción que encierra.

Métodos y escuelas de Interpretación. Evolución.-

A) TRADICIONALES.-

Históricamente, el primer método de interpretación fue el **gramatical**: se analizaba etimológicamente cada palabra empleada en la norma, a fin de determinar su significado real, y poder luego, en conjunto, saber qué quiso comunicar el legislador.

Con la sanción del Código Civil Francés, surge la **Escuela de la Exégesis** (fundada por Delvincourt, Proudhon y Toullier, decanos, respectivamente, de las Facultades de París, Dijón y Rennes), que agrupó a los principales juristas del Siglo XIX, y que basó la interpretación en el culto al texto de la ley.

Entendían que *todo el Derecho* estaba contenido en la ley, de modo que la tarea del intérprete consistiría en establecer el *sentido del texto* de la ley; para ello debían indagar la *voluntad o intención del legislador*, buscando en las *palabras* de la ley o en su *espíritu*.

Consideraban que la única *fuentes* del Derecho era la ley y que en ella estaban previstas todas las soluciones posibles; de modo que si la solución no surgía de la norma específica, habría que buscarla en las leyes análogas o bien en los principios generales del Derecho.

La **Escuela de la Exégesis** usó como método de interpretación el **exegético**, que tuvo tres variantes; a saber:

a) **exegético puro:** consiste en analizar minuciosamente cada uno de los artículos del Código, en el orden en que se presentan; en doctrina suele manifestarse en lo que hoy conocemos como "código comentado" o "ley comentada". Lo utilizaron, en Francia, Marcadé y Troplong; y en nuestro país, Llerena y Segovia.

b) **exegético dogmático:** es menos rígido y más completo que el anterior. No sigue el orden del articulado, sino que por medio de las operaciones lógicas de inducción y deducción, va elaborando construcciones jurídicas que en la actualidad han dado lugar a novedosas doctrinas, como la teoría del patrimonio, la del enriquecimiento sin causa, etc. El método funciona así: de diversas

normas aisladas, por inducción, se llega a formular un principio general, que luego se aplica, por deducción, a diversos casos particulares concretos. Esta variante fue utilizada en Francia por Zachariae (en su "*Manual sobre el Código de Napoleón*") y por Aubry et Rau.

c) **exegético ecléctico:** combinó el puro con el dogmático del siguiente modo: respetó el orden de los Libros, Secciones, Títulos y Capítulos, pero dentro de ellos elaboró construcciones jurídicas sin ceñirse al orden de los artículos. Lo emplearon Demolombe y Marcadé en Francia, y Laurent en Bélgica.

Críticas a la Escuela de la Exégesis.- Al considerar a la ley como única fuente del Derecho y, por tanto, que todo el Derecho está contenido en la ley, frena la evolución del Derecho y automatiza la función de los jueces.

B) MODERNOS.-

1) **La Escuela Científica.**- En el siglo XIX (como reacción contra la Escuela de la Exégesis) surge la Escuela Científica, que parte de considerar que el Derecho no se agota en la ley escrita y que, a los efectos de su interpretación, el juez no puede estar limitado a investigar la "voluntad del legislador", que en definitiva es un cuerpo integrado por hombres de diversas ideas políticas, sociales y jurídicas, y que no siempre suelen compartir una misma voluntad. En esta escuela se distinguen dos métodos:

a) **de la evolución histórica:** sostuvo que la ley no es producto de la voluntad del legislador, sino de las necesidades de una comunidad en un momento determinado, las cuales suelen cambiar a través del tiempo; por ello el juez no debe buscar la voluntad del legislador, sino interpretar la norma de acuerdo a las necesidades actuales. De este modo, los textos legales siguen la evolución y transformación de las necesidades sociales, y el juez tiene mayor libertad para evaluar las circunstancias de hecho.

b) **de la libre investigación científica:** Francisco Gény introdujo en Francia un nuevo método de interpretación. Gény reconocía como fuente principal del Derecho, a la ley; pero también sostenía que ella no era la única fuente del Derecho.

En cuanto a la interpretación, Gény consideraba que lo primero que se debía tener en cuenta, era la ley; pero que, cuando la ley no diese una interpretación clara al conflicto que se presentaba, era necesario aplicar las otras fuentes del Derecho que él llamaba fuentes formales: la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Por último, si aún no se hubiese encontrado la solución, el juez deberá llevar a cabo un procedimiento que Gény denominó de la "*libre investigación científica*", procedimiento éste que tendría como fin encontrar las fuentes reales del Derecho, que son aquellas que proporcionen la sustancia o la materia sobre la que ha de versar la ley.

Debemos destacar que lo importante en el pensamiento de Gény, es la distinción entre fuentes reales y fuentes formales: las primeras dan la sustancia

sobre la cual ha de versar la norma; las segundas, son las que expresan o manifiestan el contenido que reciben de las fuentes reales.

El método se denomina de la *libre investigación científica*, porque el intérprete tiene cierta *libertad* para evaluar su decisión, sin atarse ciegamente al texto de la ley ni a la voluntad del legislador; sin embargo, no puede decidir arbitrariamente, sino dentro de los marcos que le provee la *ciencia* del Derecho a través del estudio de sus fuentes.

2) La Escuela del Derecho Libre.- Se origina en Alemania y parte de la base de otorgar una amplia libertad a los jueces en su tarea interpretativa; los márgenes de dicha libertad varían según los diversos expositores:

- para algunos, el juez puede apartarse de la ley cuando la norma no fuese clara;
- otros entienden que no sólo puede apartarse, sino también sentenciar en contra de la ley, cuando ella fuera injusta;
- otros consideran que puede apartarse de la ley según su libre criterio.

Reichel, uno de sus expositores, considera que el juez podrá fallar contra la ley: a) cuando la ley haya sido derogada por la costumbre; b) cuando la norma sea contraria a la moral reinante en una determinada época; c) cuando la norma no pueda alcanzar los fines para los cuales se dictó.

LA INTERPRETACIÓN EN NUESTRO CÓDIGO. ELEMENTOS.-

Teoría de la hermenéutica.-

El conjunto de medios, reglas prácticas o principios de interpretación de que se vale el intérprete para llevar a cabo su tarea, es denominado en doctrina "teoría de la hermenéutica".

Elementos interpretativos.-

Según la doctrina, el intérprete se puede valer de los siguientes elementos interpretativos:

- El elemento gramatical es aquel que permite establecer el sentido y alcance de la ley haciendo uso del tenor de las propias palabras de la ley, es decir, al significado de los términos y frases de que se valió el legislador para expresar y comunicar su pensamiento. A esta interpretación se refiere el art. 2 del nuevo Código Civil y Comercial, cuando recurre a "*las palabras de la ley*" como primer medio de interpretación.

- El elemento histórico permite interpretar el derecho legislado aludiendo, para ello, a la historia del texto legal que se trata de interpretar. Esta historia se ve reflejada en cada una de las historias o etapas del proceso de formación de la ley.

- El elemento lógico es aquel que para establecer el o los sentidos o alcances de una ley se vale del análisis intelectual de las conexiones que las normas de una misma ley guardan entre sí, o bien con otras leyes que versen sobre la misma materia.

- El elemento sistemático permite interpretar la ley atendiendo a las conexiones de la misma con la totalidad del ordenamiento jurídico del cual forma parte, incluidos los principios generales del derecho. Este método es un grado más avanzado del método lógico. A esta interpretación se refiere el art. 2 del nuevo Código Civil y Comercial, cuando dice "*coherencia con todo el ordenamiento jurídico*".

- El elemento teleológico busca establecer el sentido o alcance de la ley atendiendo a su finalidad, es decir, a los objetivos que se buscaron conseguir a través de ella. A esta interpretación se refiere el art. 2 del nuevo Código Civil y Comercial, cuando dice "*sus finalidades*" como segundo medio de interpretación.

La interpretación en el Código de Vélez.-

El Código Civil de Vélez se refería a la interpretación y decía:

Art. 16 (CC Vélez Sarsfield).- "Si una cuestión civil no puede resolverse, ni por las palabras, ni por el espíritu de la ley, se atenderá a los principios de leyes análogas; y si aún la cuestión fuere dudosa, se resolverá por los principios generales del Derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso".

La interpretación en el nuevo Código Civil y Comercial.-

Como ya vimos, el nuevo Código Civil y Comercial fija las reglas de interpretación en su artículo 2, el cual establece que la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta: 1) sus palabras; 2) sus finalidades; 3) las leyes análogas; 4) las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos; 5) los principios y valores jurídicos; y 6) la coherencia con todo el ordenamiento jurídico.

Sobre las reglas de interpretación en los *Fundamentos* se dice: "*Se propone incorporar un artículo relacionado con reglas de interpretación, a fin de aportar coherencia con el sistema de fuentes.*"

1) De conformidad con lo que señala la mayoría de la doctrina, la decisión jurídica comienza por las **palabras de la ley**.

2) También, incluimos sus **finalidades**, con lo cual dejamos de lado la referencia a la intención del legislador. De ese modo la tarea no se limita a la intención histórica u originalista, sino que se permite una consideración de las finalidades objetivas del texto en el momento de su aplicación.

3) Se mencionan las **leyes análogas**, que tradicionalmente han sido tratadas como fuente y aquí se las incluye como criterios de interpretación, para dar libertad al Juez en los diferentes casos. Ello tiene particular importancia en supuestos en los que pueda haber discrepancias entre la ley análoga y la costumbre, como sucede en el ámbito de los contratos comerciales.

4) Con relación a los tratados internacionales, cabe señalar que todos los que ha suscripto el país y resultan obligatorios, deben ser tenidos en cuenta para decidir un caso. Esa es la función que tienen como fuentes de derecho referida en el artículo primero. Pero además, cundo se interpreta una norma, tienen especial relevancia

los tratados de derechos humanos, porque tienen un contenido valorativo que se considera relevante para el sistema. Esta es la función que tienen en materia hermenéutica a la que se refiere el artículo segundo.

5) También deben tenerse en cuenta los conceptos jurídicos indeterminados que surgen de los principios y valores jurídicos, los cuales no sólo tienen un carácter supletorio, sino que son normas de integración y de control axiológico. Esta solución es coherente con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que reiteradamente ha hecho uso de los principios que informan el ordenamiento y ha descalificado decisiones manifiestamente contraria a valores jurídicos. No consideramos conveniente hacer una enumeración de principios ni de valores, por su carácter dinámico.

Cabe aclarar que el nuevo Código Civil y Comercial no menciona a los "principios generales del Derecho" (que para algunos eran principios generales de la legislación positiva; en tanto que, para otros, eran los principios superiores de Justicia).

6) Se hace una referencia a la coherencia con todo el ordenamiento jurídico, lo que permite superar la limitación derivada de una interpretación meramente exegética y dar facultades al juez para recurrir a las fuentes disponibles en todo el sistema. Ello es conforme con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuanto afirma que la interpretación debe partir de las palabras de la ley, pero debe ser armónica, conformando una norma con el contenido de las demás, pues sus distintas partes forman una unidad coherente y que, en la inteligencia de sus cláusulas debe cuidarse de no alterar el equilibrio del conjunto.

Por último, queremos referirnos a los adagios para aclarar que no tienen valor legal. Los adagios son aforismos, preceptos o principios de dialéctica jurídica que, a veces, los abogados o los jueces utilizan para dar mayor fuerza a los argumentos que invocan. Ejemplo: "el que tiene derecho a lo más, tiene derecho a lo menos"; o "donde la ley no distingue, nosotros no debemos distinguir"; o "cesando la razón de la ley, cesa lo que ella dispone"; etc. Estos dichos (generalmente en latín) parecen, en principio, encerrar toda una fuente de sabiduría jurídica; pero en la realidad, no pasan de ser simples dichos y no tienen valor legal; y a veces, son contradictorios entre ellos o resultan ser falsos. Es un error tomar como base de interpretación un simple aforismo jurídico, razón por la cual el nuevo Código Civil y Comercial no hace referencia a ellos.

Deber de resolver.-

Art. 3º.- "Deber de resolver. El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada".

El Código define las fuentes del derecho, brinda reglas de interpretación, suministra guías para el ejercicio de los derechos, reconoce distintos principios generales (buena fe, abuso, fraude, etc.) y, luego establece un deber ineludible del juez: el juez tiene el deber de resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción.

Este deber del juez es tradicional en la legislación argentina. En el Código de Vélez, el art. 15 expresaba: "Los jueces no pueden dejar de juzgar bajo el pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes".

El nuevo Código Civil y Comercial sigue la misma idea: el juez no puede dejar de juzgar poniendo algún pretexto, tiene el deber de resolver la cuestión y se agrega que debe hacerlo mediante una decisión "razonablemente fundada" es decir que no sea arbitraria, lo cual se ajusta a la doctrina de la arbitrariedad.

INTERPRETACIÓN DE LA LEY

Interpretar es buscar el verdadero sentido y alcance de una norma jurídica.

Especies de Interpretación	Métodos y escuelas de Interpretación
• Interpretación legislativa • Interpretación judicial • Interpretación doctrinaria	A) TRADICIONALES • Método gramatical • Escuela de la Exégesis B) MODERNOS 1) La Escuela Científica 2) La Escuela del Derecho Libre a) <i>exegético puro</i> b) <i>exegético dogmático</i> c) <i>exegético ecléctico</i>

LA INTERPRETACIÓN EN NUESTRO CÓDIGO

Teoría de la hermenéutica

Conjunto de medios, reglas prácticas o principios de interpretación de que se vale el intérprete para llevar a cabo su tarea.

El intérprete se puede valer de los siguientes elementos interpretativos:

- **Gramatical:** permite establecer el sentido y alcance de la ley haciendo uso del tenor de las propias palabras de la ley (art. 2 del nuevo CCC).
- **Histórico:** permite interpretar el derecho legislado aludiendo, para ello, a la historia del texto legal que se trata de interpretar.
- **Lógico:** aquel que se vale del análisis intelectual de las conexiones que las normas de una misma ley guardan entre sí, o con otras leyes sobre la misma materia.
- **Sistemático:** permite interpretar la ley atendiendo a las conexiones de la misma con la totalidad del ordenamiento jurídico del cual forma parte, incluidos los principios generales del derecho (art. 2 del nuevo CCC).
- **Teleológico:** busca establecer el alcance de la ley atendiendo a su finalidad, es decir, a los objetivos que se buscaron conseguir a través de ella (art. 2 del nuevo CCC).

Nuevo Código Civil y Comercial

Art. 2

La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta:

- 1) sus palabras; 2) sus finalidades; 3) las leyes análogas; 4) las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos; 5) los principios y valores jurídicos; y 6) la coherencia con todo el ordenamiento jurídico.

Fundamentos → "Se propone incorporar un artículo relacionado con reglas de interpretación, a fin de aportar coherencia con el sistema de fuentes."

- 1) La decisión jurídica comienza por las palabras de la ley.
- 2) También, incluimos sus finalidades, con lo cual dejamos de lado la referencia a la intención del legislador.
- 3) Se mencionan las leyes análogas, que tradicionalmente han sido tratadas como fuente y aquí se las incluye como criterios de interpretación.
- 4) Con relación a los tratados internacionales, todos los que ha suscripto el país y resultan obligatorios, deben ser tenidos en cuenta para decidir un caso. Tienen especial relevancia los tratados de derechos humanos.
- 5) También deben tenerse en cuenta los conceptos jurídicos indeterminados que surgen de los principios y valores jurídicos.
- 6) Se hace una referencia a la coherencia con todo el ordenamiento jurídico.

Deber de resolver

Art. 3

Este deber del juez es tradicional en la legislación argentina. El juez no puede dejar de juzgar poniendo algún pretexto, tiene el deber de resolver la cuestión; y debe hacerlo mediante una decisión "razonablemente fundada" es decir que no sea arbitraria, lo cual se ajusta a la doctrina de la arbitrariedad.

CAPÍTULO III LA LEY

Concepto.-

La ley es la regla social obligatoria, establecida por la autoridad pública (Salvat). Es la fuente principal del Derecho. La ley tiene dos acepciones:

- **en sentido amplio** (o material): ley es toda norma general dictada por autoridad competente. Ej: un decreto presidencial.
- **en sentido estricto** (o formal): leyes son sólo aquellas que emanan del Poder Legislativo y de acuerdo con los procedimientos y formalidades establecidos en la Constitución.

Caracteres.-

La ley presenta los siguientes caracteres:

- 1) **Es obligatoria y coactiva:** dado que existe la obligación de obedecer lo que mande la ley, y que, en caso contrario, habrá lugar a las sanciones que ella establezca.
- 2) **Generalidad:** contempla un número indeterminado de hechos, y se aplica a cualquier persona que los realice.
- 3) **Origen público:** la ley es establecida por la autoridad pública competente.

Clasificación de las leyes.-

Las leyes, en sentido amplio, pueden clasificarse en:

- 1) **Nacionales y provinciales:** según que sean dictadas por el Congreso Nacional para regir en todo el país; o por las Legislaturas Provinciales para regir en el territorio de la provincia.
- 2) **Prohibitivas y dispositivas:** las primeras prohíben la realización de algún acto; las segundas, imponen la realización de algún acto.
- 3) **Imperativas y supletorias:** las imperativas son aquellas cuya aplicación es obligatoria, y prevalecen sobre cualquier otra norma o sobre los acuerdos de los particulares. Su contenido, generalmente, es de orden público (es el Legislador quien habrá de determinar si una ley es imperativa y de orden público, o si por el contrario, no lo es). Las supletorias, son aquellas leyes a las cuales se recurre, en ausencia de otra ley o de un acuerdo de los particulares. Ej: los problemas laborales se solucionan por las leyes laborales, pero supletoriamente se recurre al Derecho Civil.
- 4) **Perfectas e imperfectas:** las primeras establecen la nulidad de lo hecho si hay incumplimiento (ej: art. 344); las segundas, no contienen sanción para el caso de incumplimiento.

Proceso de formación de las leyes.-

El proceso de formación de las leyes está establecido en los arts. 77 a 84 de la Constitución Nacional (en adelante CN). Los pasos básicos necesarios para que una ley entre en vigencia son: a) presentación del proyecto; b) discusión; c) sanción; d) promulgación; e) publicación.

a) **Presentación del proyecto.**- Cualquier miembro del Poder Legislativo o bien el Poder Ejecutivo, pueden presentar el proyecto ante cualquiera de las Cámaras del Congreso, salvo las excepciones previstas; así, por ejemplo, las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas deben presentarse exclusivamente ante la Cámara de Diputados (arts. 77 y 52, CN). Los ciudadanos pueden presentar proyectos pero sólo ante la Cámara de Diputados, y no podrán versar sobre reformas constitucionales, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal (art. 39, CN).

b) **Discusión.**- En esta etapa pueden darse diversas alternativas contempladas en los arts. 79 a 83 de la CN; pero en líneas generales, el procedimiento es el siguiente: el proyecto se discute en la cámara de origen (es decir, aquella ante la cual se presentó el proyecto), y una vez aprobado, pasa para su discusión a la otra cámara; si ésta también lo aprueba, recibe sanción.

c) **Sanción.**- Es el acto por el cual el Poder Legislativo da fuerza de ley a un proyecto, empleando la fórmula establecida en el art. 84, CN: "...El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso... decretan o sancionan con fuerza de ley". La sanción debe ser expresa: la sanción tácita carece de validez (art. 82, CN). Una vez sancionada la ley, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.

d) **Promulgación.**- Es el acto por el cual el Poder Ejecutivo dispone el cumplimiento de la ley. Si el Poder Ejecutivo está de acuerdo con el contenido de la ley, procede a su promulgación; en caso contrario, puede proceder al veto total o parcial (conf. art. 83, CN).

La promulgación puede ser expresa (el P. Ejecutivo dicta un Decreto promulgando la ley) o tácita (si el P. Ejecutivo no devuelve el proyecto al Congreso en el término de 10 días hábiles). Las diversas alternativas que pueden ocurrir en cuanto a la aprobación o no del P. Ejecutivo, están contempladas en los arts. 80 a 83, CN.

e) **Publicación.**- Es el acto por el cual la ley llega a conocimiento de la población; de su cumplimiento depende la entrada en vigencia de la ley.

El Código Civil y Comercial establece que las leyes rigen después del octavo día de su publicación oficial, o desde el día que ellas determinen (conf. art. 5).

El medio en el cual se procede a la publicación, es el Boletín Oficial de la República Argentina, a cargo de la Dirección Nacional del Registro Oficial, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación.

EFECTOS DE LA LEY

El efecto primordial de la ley es su obligatoriedad: lo que ella dispone, es de aplicación obligatoria. Pero, dicha obligatoriedad tiene límites con relación al territorio y al tiempo.

EFECTOS DE LA LEY CON RELACIÓN AL TERRITORIO.

Diferentes sistemas.-

La ley es obligatoria, pero nos podemos preguntar: ¿Para quién es obligatoria? ¿En dónde es obligatoria? A esto responden dos sistemas:

a) Sistema de la **Territorialidad de la ley.**- Consiste en que las leyes que dicte un país, habrán de aplicarse (exclusivamente) en el territorio de ese país, y a todos los que habiten en él, sean nacionales o extranjeros. Este sistema se basa en el "ius soli": el derecho del suelo. Este fue el sistema adoptado por el Código de Vélez y ahora por el nuevo Código Civil y Comercial en su art. 4.

b) Sistema de la **Personalidad de la ley** (también conocido como Sistema de la Nacionalidad).- Consiste en que las leyes de un país determinado se apliquen a todos sus ciudadanos; o sea, a todos aquellos que tengan su nacionalidad sea que se encuentren en el país, o en el extranjero. Este sistema se basa en el "ius sanguinis": se aplica la ley de la raza o sangre a la cual pertenece la persona.

Sistema del nuevo Código Civil y Comercial.-

Art. 4º.- "Ambito subjetivo. Las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio de la República, sean ciudadanos o extranjeros, residentes, domiciliados o transeúntes, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales."

Se adopta el sistema de la "territorialidad de la ley", y en consecuencia, las leyes argentinas sólo son obligatorias dentro de nuestro territorio (suelo, subsuelo, espacio aéreo, mar territorial, zonas submarinas, embajadas de nuestro país en el extranjero, islas en el mar territorial, etc.); fuera de él carecen de obligatoriedad. Del mismo modo, las leyes extranjeras tienen eficacia en el territorio extranjero para el cual se dictaron, y en general carecen de eficacia en nuestro territorio.

EFECTOS DE LA LEY CON RELACIÓN AL TIEMPO

Vigencia de la ley.-

¿Desde cuando es obligatoria una ley? Las leyes entran en vigencia y son obligatorias luego de su publicación, pero ¿desde qué día? Las leyes rigen después del 8vo. día de su publicación oficial, o desde el día que ellas determinen (art. 5). Por lo tanto:

a) Si la propia ley designa fecha: entra en vigencia el día que ella determine;

b) Si no designa fecha: es obligatoria y entra en vigencia, luego de los 8 días posteriores al de su publicación (ej: si una ley se publicó el día 20 de enero, y no dice cuándo entra en vigor, será obligatoria a partir de las cero horas del día 29 de enero).

¿Hasta cuándo es obligatoria una ley? Hasta su derogación. La derogación puede ocurrir por alguna de las siguientes formas:

- **Por la propia ley:** a veces la misma ley establece su período de vigencia, cumplido el cual deja de regir.
- **Por otra ley:** en la mayoría de los casos, una ley o parte de ella es derogada por otra en forma expresa o en forma tácita (cuando las normas nuevas hacen inaplicables a las anteriores).

Principio de inexcusabilidad.-

Art. 8°.- "Principio de inexcusabilidad. La ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento, si la excepción no está autorizada por el ordenamiento jurídico."

La ley se presume conocida por todos. Se mantiene el principio del derecho romano (ignorantia iuris non excusat) por el cual la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. En efecto, una vez que la ley entra en vigencia, es obligatoria para todos, y nadie puede excusar su cumplimiento amparándose en la ignorancia de lo prescrito por la norma.

Eficacia temporal de la ley.-

Art. 7°.- "Eficacia temporal. A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes."

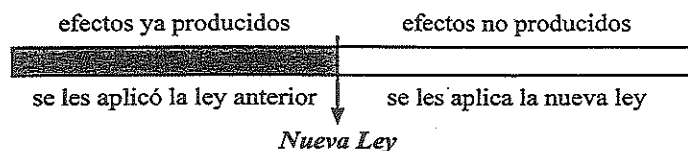
La ley no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales.

Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo."

Cuando se dicta una ley que reemplaza a otra anterior, se debe establecer cuál será el campo de aplicación de la nueva ley.

Las situaciones (ej: estado de padre, estado de hijo, etc) o relaciones jurídicas (ej: un contrato) producen efectos o consecuencias, y cuando estos efectos se producen con posterioridad a la nueva ley, ella se habrá de aplicar a dichos efectos, pero no podrá aplicarse a los efectos producidos antes de su sanción, pues ellos ya han sido regulados por la ley anterior.

Relación jurídica



Efecto inmediato.- Se suele afirmar que las leyes tienen efecto inmediato, lo cual significa que ellas se habrán de aplicar a todo hecho posterior o futuro que

se produzca a partir de la fecha de su entrada en vigencia. En cuanto al alcance de este principio, diremos que la nueva ley se habrá de aplicar:

- a) A todas las consecuencias de las relaciones jurídicas nuevas;
- b) y también a "las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes", cuando dichas consecuencias sean posteriores a la entrada en vigencia de la nueva ley.

Irretroactividad de las leyes.- El principio general es que las leyes son irretroactivas. No se pueden aplicar para atrás, es decir, a hechos o consecuencias ya producidos; sólo se aplican a hechos o consecuencias futuros.

El art. 7 expresamente dice que: "*Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario.*"

Carece de importancia que la ley sea de orden público o no. Sean o no de orden público, son irretroactivas, "*excepto disposición en contrario.*"

Esta última frase ("*excepto disposición en contrario.*") está abriendo una posibilidad a la aplicación retroactiva de la ley: la ley podrá ser retroactiva, cuando ella misma así lo disponga en su texto.

• Requisitos para la aplicación retroactiva de la ley:

- 1) Que la misma ley disponga su aplicación retroactiva;
- 2) Que la retroactividad no afecte derechos amparados por garantías constitucionales.

Por lo tanto, el límite de la aplicación retroactiva es *no afectar derechos amparados por garantías constitucionales*. Se refiere (por ejemplo) a los derechos enumerados en el art. 14 de la Constitución Nacional y, especialmente, al derecho a la propiedad, garantizado en el art. 17.

Las leyes supletorias y los contratos en curso de ejecución.- Vimos que las leyes se aplican a todo hecho posterior o futuro (efecto inmediato). Pero este principio tiene una excepción que surge del art. 7, en su parte final:

"Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo."

O sea que, la ley NO se aplicará a los efectos de un contrato:

- a) cuando la ley sea supletoria; y
- b) el contrato esté en curso de ejecución (es decir: cuando su ejecución aún no ha sido concluida). En estos casos hay "ultraactividad" de la ley anterior.

• **Excepción:** cuando se trata de una relación de consumo en curso de ejecución sí le son aplicables las nuevas leyes supletorias que se sancionen, siempre que ellas sean *más favorables al consumidor*. La excepción se debe a que en los contratos de consumo (en especial los de larga duración) es casi segura la inexistencia de una voluntad común de remitirse a normas supletorias.

Modo de contar los intervalos del derecho.-

El nuevo Código Civil y Comercial, en el art. 6, fija las reglas a seguir para computar el tiempo:

Art. 6°.- "Modo de contar los intervalos del derecho. El modo de contar los intervalos del derecho es el siguiente: día es el intervalo que corre de medianoche a medianoche. En los plazos fijados en días, a contar de uno determinado, queda éste excluido del cómputo, el cual debe empezar al siguiente. Los plazos de meses o años se computan de fecha a fecha. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entiende que el plazo expira el último día de ese mes. Los plazos vencen a la hora veinticuatro del día del vencimiento respectivo. El cómputo civil de los plazos es de días completos y continuos, y no se excluyen los días inhábiles o no laborables. En los plazos fijados en horas, a contar desde una hora determinada, queda ésta excluida del cómputo, el cual debe empezar desde la hora siguiente. Las leyes o las partes pueden disponer que el cómputo se efectúe de otro modo."

Plazos de días.- Día es el intervalo que corre de medianoche a medianoche. En los plazos fijados en días, a contar de uno determinado, queda éste excluido del cómputo, el cual debe empezar al siguiente.

Ejemplo: si el 3 de enero me obligo a pagar una deuda, dentro de un plazo de 10 días, el plazo comienza a correr el día 4, y vencerá el día 13 a las 24 horas.

No obstante, como estas normas son supletorias las partes pueden convenir que los plazos se computen de otro modo (conf. art. 6 in fine).

Plazos de horas.- En los plazos fijados en horas, a contar desde una hora determinada, queda ésta excluida del cómputo, el cual debe empezar desde la hora siguiente. Las leyes o las partes pueden disponer que el cómputo se efectúe de otro modo.

Plazos de meses o de años.- Los plazos de meses o años se computan de fecha a fecha. Ejemplo: un plazo que comienza el 15 de un mes, terminará el 15 del mes correspondiente, cualquiera que sea el número de días que tengan los meses o el año.

Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entiende que el plazo expira el último día de ese mes.

Ejemplo: si el 30 de noviembre me obligo a pagar una deuda a los tres meses, el plazo vence el 28 de febrero (o el 29 de febrero, si fuese año bisiesto).

- El cómputo de los plazos es de días **completos y continuos**. Los plazos vencen a la medianoche (hora 24) del último día del vencimiento respectivo.

- En los plazos no se excluyen los días inhábiles o no laborables, o sea que esos días también se cuentan.

- Estas normas tienen **carácter supletorio**, ya que el art. 6 in fine expresa: "Las leyes o las partes pueden disponer que el cómputo se efectúe de otro modo.". O sea que, sólo se aplicarán en caso de que en las leyes o por las partes no se haya dispuesto algo diferente.

LA LEY

Concepto

La ley es la regla social obligatoria, establecida por la autoridad pública (Salvat). Es la fuente principal del Derecho.

Caracteres

- 1) **Es obligatoria y coactiva** → existe la obligación de obedecer lo que mande la ley y, en caso contrario, habrá lugar a las sanciones que ella establezca.
- 2) **Generalidad** → contempla un número indeterminado de hechos, y se aplica a cualquier persona que los realice.
- 3) **Origen público** → es establecida por la autoridad pública competente.

Clasificación

1) Nacionales / Provinciales	2) Prohibitivas / Dispositivas
3) Imperativas / Supletorias	4) Perfectas / Imperfectas

Proceso de formación de las leyes

Arts. 77 a 84
Constitución
Nacional

Pasos básicos

- a) Presentación del proyecto.-** Cualquier miembro del Poder Legislativo o bien el Poder Ejecutivo, pueden presentar el proyecto ante cualquiera de las Cámaras del Congreso, salvo las excepciones previstas. Los ciudadanos pueden presentar proyectos pero sólo ante la Cámara de Diputados.
- b) Discusión.-** En líneas generales, el proyecto se discute en la cámara de origen, y una vez aprobado pasa para su discusión a la otra cámara; si ésta también lo aprueba, recibe sanción.
- c) Sanción.-** Es el acto por el cual el Poder Legislativo *da fuerza de ley a un proyecto*, empleando la fórmula establecida en el art. 84, CN. La sanción debe ser *expresa*. Una vez sancionada la ley, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.
- d) Promulgación.-** Es el acto por el cual el Poder Ejecutivo *dispone el cumplimiento de la ley*. Si el Poder Ejecutivo está de acuerdo con el contenido de la ley, procede a su promulgación; en caso contrario, puede proceder al veto *total o parcial* (conf. art. 83, CN). La promulgación puede ser *expresa o tácita*.
- e) Publicación.-** Es el acto por el cual la ley llega a conocimiento de la población; de su cumplimiento depende la entrada en vigencia de la ley. Las leyes rigen después del octavo día de su publicación oficial, o desde el día que ellas determinen (conf. art. 5). El medio en el cual se procede a la publicación, es el Boletín Oficial de la República Argentina.

EFECTOS DE LA LEY

El **efecto primordial** de la ley es su **obligatoriedad**: lo que ella dispone, es de aplicación obligatoria. Pero, dicha obligatoriedad tiene **límites** con relación al territorio y al tiempo.

EFECTOS CON RELACIÓN AL TERRITORIO

Diferentes Sistemas

La ley es obligatoria, pero nos podemos preguntar: ¿Para quién es obligatoria? ¿En dónde es obligatoria? A esto responden **dos sistemas**:

a) Sistema de la Territorialidad de la ley.

Consiste en que las leyes que dicte un país, habrán de aplicarse (exclusivamente) en el territorio de ese país, y a todos los que habiten en él, sean nacionales o extranjeros. Se basa en el "ius soli".

b) Sistema de la Personalidad de la ley.

Consiste en que las leyes de un país determinado se apliquen a todos sus ciudadanos; sea que se encuentren en el país, o en el extranjero. Se basa en el "ius sanguinis".

Sistema del nuevo Código Civil y Comercial

Art. 4° → Sistema de la **Territorialidad de la ley**.

- Las leyes argentinas **sólo son obligatorias dentro de nuestro territorio**; fuera de él carecen de obligatoriedad.
- Del mismo modo, las leyes extranjeras tienen eficacia en el territorio extranjero para el cual se dictaron, y en general carecen de eficacia en nuestro territorio.

EFECTOS CON RELACIÓN AL TIEMPO

Vigencia de la ley

¿Desde cuándo es obligatoria una ley?	¿Hasta cuándo es obligatoria una ley?
Es obligatoria (luego de su publicación): a) Si la ley designa fecha: desde el día que ella determine; b) Si no designa fecha: luego de los 8 días posteriores al de su publicación.	Hasta su derogación. La derogación puede ocurrir: • Por la propia ley. • Por otra ley.

Principio de inexcusabilidad → Art. 8°

- La ley se presume conocida por todos.
- La ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento.
- Una vez que la ley entra en vigencia, es obligatoria para todos, y nadie puede excusar su cumplimiento amparándose en la ignorancia de lo prescrito por la norma.

Eficacia temporal de la ley →

Cuando se dicta una ley que reemplaza a otra anterior, se debe establecer cuál será el campo de aplicación de la nueva ley.

Las situaciones o relaciones jurídicas producen **efectos o consecuencias**:

- Cuando estos efectos se producen con posterioridad a la nueva ley, ella se aplica a dichos efectos;
- Pero la nueva ley no podrá aplicarse a los efectos producidos antes de su sanción, pues ellos ya han sido regulados por la ley anterior.

Efecto inmediato	Irretroactividad de las leyes	Las leyes supletorias y los contratos en curso de ejecución
La nueva ley se habrá de aplicar: a) A todas las consecuencias de las relaciones jurídicas nuevas; b) y también a "las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes", cuando dichas consecuencias sean posteriores a la entrada en vigencia de la nueva ley.	Las leyes no se pueden aplicar para atrás, es decir, a hechos o consecuencias ya producidos; sólo se aplican a hechos o consecuencias futuros (conf. art. 7). • <u>Requisitos para la aplicación retroactiva de la ley:</u> 1) Que la misma ley disponga su aplicación retroactiva; 2) Que la retroactividad no afecte derechos amparados por garantías constitucionales.	La nueva ley NO se aplicará a los efectos de un contrato: a) cuando la ley sea supletoria; y b) el contrato esté en curso de ejecución. En estos casos hay "ultraactividad" de la ley anterior. • <u>Excepción:</u> cuando se trata de una relación de consumo en curso de ejecución si le son aplicables las nuevas leyes supletorias, siempre que sean más favorables al consumidor.

Modos de contar los intervalos de derecho → Art. 6°

Plazos de días	Plazos de horas	Plazos de meses o de años
Día es el intervalo que corre de medianoche a medianoche. En los plazos fijados en días, a contar de uno determinado, queda éste excluido del cómputo, el cual debe empezar al siguiente.	En los plazos fijados en horas, a contar desde una hora determinada, queda ésta excluida del cómputo, el cual debe empezar desde la hora siguiente.	Los plazos de meses o años se computan de fecha a fecha. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entiende que el plazo expira el último día de ese mes.
• El cómputo de los plazos es de días completos y continuos. Los plazos vencen a la medianoche (hora 24) del último día del vencimiento respectivo.		
• En los plazos no se excluyen los días inhábiles o no laborables (esos días también se cuentan).		
• Estas normas tienen carácter supletorio, sólo se aplicarán en caso de que las leyes o las partes no hayan dispuesto que el cómputo se efectúe de otro modo		

CAPÍTULO IV
EJERCICIO DE LOS DERECHOS

Introducción.-

Mientras los Capítulos 1 y 2 del Título Preliminar ("Derecho" y "Ley" respectivamente) contienen guías dirigidas a los jueces, el Capítulo 3 referido al "Ejercicio de los derechos" contiene principios generales que están dirigidos principalmente a los ciudadanos.

En efecto, en este Capítulo se dan principios generales para regular el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, y en consecuencia se regula: buena fe (art. 9), abuso del derecho (art. 10), abuso de posición dominante (art. 11), fraude a la ley (art. 12), renuncia (art. 13) y abuso de un derecho individual en perjuicio del ambiente o de derechos de incidencia colectiva (art. 14).

En los *Fundamentos*, los autores del nuevo Código Civil y Comercial explican que estos principios "primero fueron utilizados en obligaciones, contratos y derechos reales específicos, luego se extendió su aplicación a las obligaciones, los contratos, los derechos reales, de familia y de sucesiones en general, y finalmente fueron adoptados como principios generales en todo el derecho privado". Por ello, el nuevo Código los incluye en el Título Preliminar como pautas generales para el ejercicio de los derechos.

Principio de buena fe.-

Art. 9°.- "Principio de buena fe. Los derechos deben ser ejercidos de buena fe."

La buena fe (del latín *bona fides*) es un principio rector del Derecho, aplicable al ejercicio de todos los derechos y a cualquier relación jurídica, que determina que un sujeto deba obrar con honradez, honestidad, veracidad, lealtad (buena fe objetiva), lo que lleva implícita la apariencia, es decir, la creencia de que se está actuando correctamente (buena fe subjetiva).

La buena fe significa que cada uno debe guardar fidelidad a la palabra empeñada y no defraudar la confianza o abusar de ella. La buena fe es el principio supremo de las relaciones obligatorias, de forma que todas deben medirse por él (C. Fed Cba., Sala Civ y Com, 28/07/79, LL, 1979-A-201).

ABUSO DEL DERECHO.-

La ley concede derechos subjetivos (o sea, facultades) a las personas; así, por ejemplo, al acreedor, el derecho de exigir el pago; al propietario, el derecho de

usar y gozar de las cosas de su propiedad, y de exigir que nadie lo turbe en dicho uso y goce.

Cuando la ley otorga estas facultades, lo hace teniendo en mira un fin determinado, útil y justo; y por lo tanto, las personas que ejerciten dichas facultades, no podrán apartarse de los fines perseguidos por la ley al reconocerlos, pues si así lo hicieren, ya no estaríamos ante un uso o ejercicio del derecho, sino ante un abuso del mismo. Como vemos, los derechos subjetivos no son absolutos o ilimitados, sino que, por el contrario, son relativos o limitados.

La "Teoría del abuso del Derecho", sostiene que los derechos subjetivos no son, en cuanto a su uso, absolutos, sino relativos; es decir que se deben ejercer dentro de determinados límites, como ser: los fines que tuvo el ordenamiento jurídico al reconocer el derecho subjetivo; los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres; no afectar al ambiente ni a los derechos de incidencia colectiva en general, etc. Otros signos de estar en presencia de un abuso en el ejercicio del derecho pueden ser: el ejercer el derecho sin necesidad, sin interés o de una manera irrazonable o excesiva; ejercerlo con dolo con la sola intención de perjudicar.

Principios del Código Civil de Vélez (Art. 1071).-

En sus orígenes, el Código Civil se oponía a la teoría del abuso del derecho pues el art. 1071 decía:

"El ejercicio de un derecho propio, o el cumplimiento de una obligación legal, no puede constituir como ilícito ningún acto".

La reforma constitucional de 1949, incorporó la teoría del abuso del derecho en el art. 35 de la Constitución:

"Los derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio, pero tampoco amparan a ningún habitante de la Nación en perjuicio, detrimento o menoscabo de otro. Los abusos de estos derechos que perjudiquen a la comunidad o que lleven a cualquier forma de explotación del hombre por el hombre, configuran delitos que serán castigados por las leyes."

Con este artículo de la Constitución del 49, se había introducido la teoría del abuso del derecho, la cual comenzó a ser aplicada por los tribunales. En varios fallos, distintas Cámaras de Apelaciones sostuvieron que había abuso de derecho, por ejemplo cuando se destruían adornos de una construcción vecina porque que se introducían unos pocos centímetros sobre el jardín del demandante, o cuando un inquilino -a pesar de tener ya otra vivienda- pedía indemnización para dejar la casa alquilada, o cuando se trababan embargos reiterados e indebidos sobre bienes del deudor con el único fin de perjudicarlo.

Pero en el año 1956 se derogó la reforma constitucional del 49 y, por lo tanto, la situación volvió a ser la misma que antes de la reforma: sólo regía el art. 1071 del Código Civil, el cual no admitía a la teoría del abuso del derecho.

Reformas de la Ley 17.711: Aceptación de la Teoría.-

Con la Ley 17.711 se modificó el Código, y se le dio otro texto al art. 1071.

Art. 1071 (CC Vélez Sarsfield).- "El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto.

La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considerará tal al que contrarie los fines que aquella tuvo en mira al reconocerlos o al que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres."

Como vemos, el titular de un derecho lo podía ejercer, pero debía hacerlo en forma normal, regular, lo cual significaba que debía hacerlo sin abusar de su derecho. Podía usar, pero no abusar. Había abuso, según la norma:

a) si el ejercicio del derecho era contrario a los fines que la ley tuvo en mira al reconocer dicho derecho; o

b) si el ejercicio excedía los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres.

También estaba expresamente aplicada la *teoría del abuso de derecho* en otras normas que disponían que el propietario gozaba de los derechos inherentes a la propiedad (como ser poseer, disponer, usar y gozar de la cosa) pero que el ejercicio de estos derechos debía ser un ejercicio regular. En otras normas se establecía que las facultades del propietario no podían ser restringidas, salvo el caso de que fuese abusivo su ejercicio (conf: arts. 2513 y 2514 del Código de Vélez).

En la legislación comparada observamos que muchos países aceptan la teoría del abuso pero con diferentes matices. Así, algunos lo hacen expresamente en sus normas (por ej: Código de Venezuela, C. de Brasil, C. Soviético, etc); otros, aceptan la teoría del abuso de derecho, pero sin llegar a definir en qué consiste dicho abuso (por ej: los Códigos Suizo y Peruano). También hay países en los cuales sus normas no se refieren expresamente a la teoría del abuso de derecho, pero ésta se aplica en virtud de la actividad jurisprudencial, tal es el caso de España, Francia, Inglaterra, etc. Así, por ejemplo, años atrás los tribunales franceses declararon que había abuso de derecho en el caso del dueño de un terreno vecino a un campo de aviación que hizo levantar altos postes de madera, con el fin de dificultar la actividad de las aeronaves, y obligar al dueño del campo de aviación a que le comprara su terreno; también declararon que había abuso de derecho, cuando un vecino colocó una chimenea falsa sobre el techo de su casa, para impedir que su vecino recibiera la luz del día.

Posición del nuevo Código Civil y Comercial.-

El nuevo Código Civil y Comercial, al regular el "Ejercicio de los derechos" (Título Preliminar, Capítulo 3), se refiere expresamente al abuso del derecho por parte de su titular y también a otros supuestos de abuso, tal el caso de la situación jurídica abusiva, del abuso de posición dominante y abuso del derecho que afecta al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general, destacándose que

en este tema rige un principio general que es el siguiente: *"los derechos deben ser ejercidos de buena fe"*. Veamos qué expresan al respecto los arts. 9, 10, 11 y 14 del nuevo Código Civil y Comercial:

Art. 9°.- "Principio de buena fe. Los derechos deben ser ejercidos de buena fe."

Art. 10.- "Abuso del derecho. El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto."

La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres.

El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización."

Art. 11.- "Abuso de posición dominante. Lo dispuesto en los artículos 9 y 10 se aplica cuando se abuse de una posición dominante en el mercado, sin perjuicio de las disposiciones específicas contempladas en leyes especiales."

Art. 14.- "Derechos individuales y de incidencia colectiva. En este Código se reconocen:

- a) derechos individuales;
- b) derechos de incidencia colectiva.

La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general."

Como vemos, en la nueva normativa se contempla el clásico *abuso en el ejercicio de un derecho por parte de su titular*; pero además, se incluyen otros casos de abuso, tales los supuestos de: a) situación jurídica abusiva; b) abuso de posición dominante en el mercado; y c) abuso del derecho individual que afecta al ambiente y/o a los derechos de incidencia colectiva en general.

a) **Situación jurídica abusiva:** caso en el cual los derechos ejercidos (si bien pueden no ser abusivos si se ejercen en forma aislada), al ejercerlos junto a otros derechos que surgen de otras cláusulas del contrato o de otros contratos que vinculen a las partes, pueden dar lugar a una situación jurídica abusiva caracterizada generalmente por un significativo desequilibrio entre los derechos y las obligaciones de las partes.

Ejemplo: en un contrato de viaje de turismo la empresa tiene derecho a recibir (aparte del precio del viaje) una suma para gastos adicionales; pero en otra cláusula se dispone que habiéndose iniciado el viaje la empresa no tendrá obligación de restituir ni de acreditar en que se utiliza dicha suma.

Para el Código, una cláusula es abusiva cuando tiene por objeto o por efecto provocar un desequilibrio significativo entre los derechos y las obligaciones de las partes, en perjuicio del consumidor (conf. art. 1119); y "situación jurídica abusiva" es aquella en que el abuso o desequilibrio se alcanza a través de la predisposición de una pluralidad de actos jurídicos conexos (conf. art. 1120).

b) **Abuso de posición dominante en el mercado:** consiste en que una empresa (o varias) que tiene una posición de dominio en el mercado (ej: monopolio, oligopolio,

etc.) abusa de esa situación de superioridad sobre sus competidores o clientes (ej: es el único comprador o es el único vendedor) para imponerles excesivas condiciones comerciales, fijarle precios de venta a los consumidores, limitarle su producción, exigirles formas de venta determinada, etc., de manera tal que los hace perder su independencia comercial y vulnera la libertad de competencia.

c) **Abuso del derecho individual que afecta el ambiente y/o a los derechos de incidencia colectiva en general:** el derecho individual no puede afectar al ambiente ni a los derechos de incidencia colectiva en general (conf. art. 14). El ejercicio de un derecho individual no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, etc. (conf. art. 240).

El nuevo Código Civil y Comercial también tiene numerosas normas que hacen referencia a casos de abuso.

Ejemplos: en materia de contratos se legisla sobre cláusulas abusivas en los contratos de adhesión (arts. 988 y 989); en los contratos de consumo varias normas se ocupan de proteger al consumidor de las cláusulas, situaciones y prácticas abusivas (arts. 1117 a 1122).

ORDEN PÚBLICO. FRAUDE A LA LEY.

Art. 12.- "Orden público. Fraude a la ley. Las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia está interesado el orden público."

El acto respecto del cual se invoque el amparo de un texto legal, que persiga un resultado sustancialmente análogo al prohibido por una norma imperativa, se considera otorgado en fraude a la ley. En ese caso, el acto debe someterse a la norma imperativa que se trata de eludir."

La primera parte del artículo es similar al art. 21 del Código de Vélez que establecía que *"las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia estén interesados el orden público y las buenas costumbres"*, pero en el nuevo Código Civil y Comercial se ha suprimido la referencia a las buenas costumbres.

Leyes de orden público.-

Cuando se habla de **leyes de orden público** se hace referencia a normas jurídicas indispensables para el mantenimiento del orden jurídico-social establecido, que hacen al interés colectivo o al bienestar general, y que pueden estar referidas a distintos temas, sea seguridad o defensa nacional, salud pública, emergencia económica, etc., temas que en el tiempo pueden variar según los cambios políticos, sociales y económicos que se produzcan en la vida de la sociedad. Las leyes de orden público son leyes irrenunciables e imperativas y en consecuencia, las partes no pueden dejarlas sin efecto. La norma de orden público debe prevalecer sobre la voluntad individual. Ejemplos de leyes de orden público: ley de contrato de trabajo; ley de

protección integral de la infancia; ley de protección integral del niño; legislación previsional; leyes blásticas; etc.

Fraude a la ley.-

El *fraude a la ley* consiste en burlar la aplicación (o prohibición) de una norma imperativa y obtener por medio de otra disposición un resultado análogo al que la ley imperativa prohíbe. Se trata de burlar la ley, obteniendo un fin ilícito a través de un medio lícito. Si existe fraude a la ley, el acto está viciado de nulidad y prevalece la aplicación de la norma imperativa que se trató de eludir.

Desde ya que cuando se habla de *fraude a la ley* se está haciendo referencia a una cuestión diferente a la del *fraude a los acreedores* (concepto que veremos en el Capítulo XIX de esta obra: "*Vicios de los actos jurídicos*").

RENUNCIA GENERAL DE LAS LEYES.

Art. 13.- "Renuncia. Está prohibida la renuncia general de las leyes. Los efectos de la ley pueden ser renunciados en el caso particular, excepto que el ordenamiento jurídico lo prohíba."

La renuncia general de las leyes carece de valor, porque de lo contrario se afectaría la obligatoriedad de la ley. Lo que sí puede renunciarse son los efectos de las leyes en el caso particular cuando lo que se renuncia es en el interés exclusivo del renunciante y la renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico.

DERECHOS INDIVIDUALES Y DE INCIDENCIA COLECTIVA.

Art. 14.- "En este Código se reconocen:

- a) derechos individuales;*
- b) derechos de incidencia colectiva.*

La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general."

En su mayoría, los códigos del derecho privado comparado regulan sólo los derechos individuales. El nuevo Código Civil y Comercial da una importancia relevante a los derechos de incidencia colectiva, en consonancia con la Constitución Nacional (arts. 41, 42 y 43).

- En los *Derechos individuales*: el interés es individual y la legitimación para reclamar también es individual. Cada titular inicia una acción y obtiene sentencia en un proceso bilateral.

- En los *Derechos de incidencia colectiva*: el bien afectado es colectivo, el titular del interés es el grupo y no un individuo en particular. En estos supuestos puede existir una legitimación difusa en cabeza de uno de los sujetos que integran el grupo (interés difuso) o de una asociación con representatividad en el tema (interés colectivo) o del Estado (interés público).

La Corte Suprema, en el caso "Halabi" (Halabi, Ernesto c/Poder Ejecutivo Nacional), refiriéndose a la legitimación para ejercer los derechos dijo que "*los derechos sobre bienes jurídicos individuales son ejercidos por su titular ... y los derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos (art. 43 CN) son ejercidos por el Defensor de la Nación, las asociaciones que concentran el interés colectivo y el afectado*".

En armonía con los arts. 10 y 11 referentes al "abuso del derecho", el art. 14 dispone "*la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general*". En definitiva, si hay coalición entre un derecho individual y el derecho al ambiente sano o un derecho de incidencia colectiva, la ley hace prevalecer a estos últimos.

EJERCICIO DE LOS DERECHOS

En el Capítulo 3 del Título Preliminar se dan principios generales para regular el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, y en consecuencia se regula: buena fe (art. 9), abuso del derecho (art. 10), abuso de posición dominante (art. 11), fraude a la ley (art. 12), renuncia (art. 13) y abuso de un derecho individual en perjuicio del ambiente o de derechos de incidencia colectiva (art. 14).

Principio de buena fe (Art. 9)

Es un principio rector del Derecho, aplicable al ejercicio de todos los derechos y a cualquier relación jurídica, que determina que un sujeto deba obrar con honradez, honestidad, veracidad, lealtad (buena fe objetiva), lo que lleva implícita la apariencia, es decir, la creencia de que se está actuando correctamente (buena fe subjetiva).

ABUSO DEL DERECHO → Art. 10

• La "Teoría del abuso del Derecho", sostiene que los derechos subjetivos no son, en cuanto a su uso, absolutos, sino relativos.

Se deben ejercer dentro de determinados límites, como ser: los fines que tuvo el ordenamiento jurídico al reconocer el derecho subjetivo; los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres; no afectar al ambiente ni a los derechos de incidencia colectiva en general, etc.

Otros signos de estar en presencia de un abuso en el ejercicio del derecho pueden ser: el ejercer el derecho sin necesidad, sin interés o de una manera irrazonable o excesiva; ejercerlo con dolo con la sola intención de perjudicar.

• En el nuevo Código se contempla el clásico *abuso en el ejercicio de un derecho por parte de su titular*; pero además, se incluyen *otros casos de abuso*.

a) Situación jurídica abusiva

Art. 10, 3er párr.

b) Abuso de posición dominante en el mercado

Art. 11

c) Abuso del derecho individual que afecta el ambiente y/o a los derechos de incidencia colectiva en general

Art. 14

ORDEN PÚBLICO. FRAUDE A LA LEY.

→ Art. 12

Leyes de orden público

- Son normas jurídicas indispensables para el mantenimiento del orden jurídico-social establecido, que hacen al interés colectivo o al bienestar general.
- Son irrenunciables e imperativas y en consecuencia, *las partes no pueden dejarlas sin efecto*.
- Deben prevalecer sobre la voluntad individual.

Fraude a la ley

- Consiste en burlar la aplicación (o prohibición) de una norma imperativa y obtener por medio de otra disposición un resultado análogo al que la ley imperativa prohíbe. Se burla la ley; obteniendo un fin ilícito a través de un medio lícito.
- Si existe fraude a la ley, el acto está viciado de nulidad y prevalece la aplicación de la norma que se trató de eludir.

RENUNCIA GENERAL DE LAS LEYES

- La renuncia general de las leyes carece de valor, porque de lo contrario se afectaría la obligatoriedad de la ley.
- Lo que sí puede renunciarse son los efectos de las leyes en el caso particular cuando lo que se renuncia es en el interés exclusivo del renunciante y la renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico (conf. art. 13).

DERECHOS INDIVIDUALES Y DE INCIDENCIA COLECTIVA

→ Art. 14

"En este Código se reconocen:

- a) derechos individuales;
- b) derechos de incidencia colectiva.

La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general."

CAPÍTULO V DERECHOS Y BIENES

Introducción.-

En los *Fundamentos* se dice que el nuevo Código Civil y Comercial expresa un nuevo paradigma en materia de bienes, y ello se debe a que la mayoría de los códigos del siglo XIX han quedado desactualizados. La concepción patrimonialista de que bienes son los que tienen un valor económico cambió porque existen bienes que, siendo de la persona, no tienen un valor económico, aunque sí una utilidad, como sucede con el cuerpo, órganos, genes, etc., contemplados en el art. 17.

La relación exclusiva entre los bienes y la persona también ha mutado, y aparecen las comunidades, como ocurre con los pueblos originarios. Todo ello requiere una concepción más amplia, que ha sido receptada en el nuevo Código Civil y Comercial.

Titularidad de los derechos.-

Art. 15.- "Titularidad de derechos. Las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio conforme con lo que se establece en este Código."

La persona es titular de los bienes y derechos reales o creditorios que integran su patrimonio.

BIENES Y COSAS.-

Art. 16.- "Bienes y cosas. Los derechos referidos en el primer párrafo del artículo 15 pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor económico. Los bienes materiales se llaman cosas. Las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre."

En los *Fundamentos* (punto 7.3) se expresa que: "Las nociones jurídicas de bien, cosa y patrimonio están sometidas a tensiones derivadas de los cambios socioeconómicos de nuestro tiempo".

Conceptos.-

- **Bienes:** son todos los objetos materiales e inmateriales susceptibles de tener un valor o utilidad. Dentro de la expresión bienes quedan incluidos los derechos.
- **Cosas:** son los objetos materiales susceptibles de tener un valor. Las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre.

En base a estas definiciones, podemos ver que la relación de género-especie (donde "bien" es el género, y "cosa" es la especie) se mantiene en este nuevo Código Civil y Comercial.

A continuación, veremos en mayor detalle estos dos conceptos.

Bienes.-

• Concepción en el Código de Vélez: en relación al bien, como dijimos, la tradición legislativa identifica a los bienes con la valoración económica. Para este fin, no es determinante si los bienes son materiales (cosas) o inmateriales, porque lo que interesa es que tengan valor, y este elemento, para la letra del Código de Vélez y en su interpretación para la mayoría de la doctrina, es económico y no afectivo.

Para aportar mayor claridad a esta cuestión habría que señalar que, desde el punto de vista económico, los objetos pueden tener o no valor patrimonial. Si tienen valor económico, pueden (a su vez) entrar en el comercio y tener precio, que surge de la oferta y la demanda.

En el Código Civil de Vélez, la noción de "bien" estaba estrechamente vinculada a este enfoque económico. Por lo tanto, si se hubiera seguido utilizando este vocablo en su sentido técnico tradicional, no podría aplicarse a los bienes ambientales o al cuerpo o partes del cadáver.

• Concepción en el nuevo Código Civil y Comercial: en el nuevo Código, esa concepción patrimonialista de los bienes (que asocia a los bienes con un valor económico) ha cambiado, ya que existen bienes que, siendo de la persona, no tienen un valor económico, aunque sí una utilidad, como sucede con el cuerpo, órganos, genes, etc.

Cosas.-

En relación a las cosas, el nuevo Código Civil y Comercial da una definición muy precisa: "*...Los bienes materiales se llaman cosas*" (conf. art. 16).

Desde el *punto de vista físico*, cosa es todo lo que existe; no sólo los objetos que pueden ser propiedad del hombre, sino también todo lo que en la naturaleza escapa a esta apropiación exclusiva: el mar, el aire, el sol, etc. (conf. nota al art. 2311, Código de Vélez).

Desde el *punto de vista jurídico*, esta noción se ha circunscripto para no abarcar toda la materialidad ni la utilidad, y por ello "debemos limitar la extensión de esta palabra a todo lo que tiene un valor entre los bienes de los particulares" (nota citada).

En cuanto al vocablo "patrimonio", da lugar al distingo entre bienes patrimoniales y extrapatrimoniales. Habitualmente se considera que el patrimonio es un atributo de la persona, y está integrado por bienes, es decir, que tienen valor económico.

Estos conceptos tienen un campo de aplicación específico que deseamos mantener por su tradición y grado de conocimiento, pero también debemos agregar

otras categorías que contemplen los nuevos supuestos (fuente: Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación).

Sin perjuicio de lo visto hasta aquí, profundizaremos en los conceptos de "bienes" y "cosas" más adelante, en el Capítulo XV.

DERECHOS SOBRE EL CUERPO HUMANO.-

Art. 17.- "Derechos sobre el cuerpo humano. Los derechos sobre el cuerpo humano o sus partes no tienen un valor comercial, sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social y sólo pueden ser disponibles por su titular siempre que se respete alguno de esos valores y según lo dispongan las leyes especiales."

El nuevo Código Civil y Comercial protege rigurosamente los derechos personalísimos y entre ellos se encuentra el derecho a la integridad física de la persona, que incluye al cuerpo humano y sus partes, los cuales no tienen un valor económico pero sí pueden tener un valor afectivo, terapéutico (útil para prevenir o curar enfermedades), científico (útil para experimentos o investigación médica), humanitario o social (útil para el conjunto de la humanidad).

Dado su carácter de derechos personalísimos, los derechos sobre el cuerpo humano o sus partes no tienen un valor económico o comercial y no son disponibles. Pero teniendo en cuenta el avance de la ciencia (transplantes de órganos, depósitos de células, etc.) y la utilidad de partes del cuerpo de una persona para salvar vidas de otras personas o para prevenir y curar enfermedades, el nuevo Código Civil y Comercial admite que se pueda disponer de ellos siempre que se respete alguno de esos valores (ej: terapéutico) y según lo dispongan las leyes especiales (ej: ley de transplantes de órganos; ley de donación de sangre, etc).

DERECHOS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS.-

Artículo 18 del Código y Art. 75, inc. 17 de la Constitución Nacional.-

Art. 18.- "Derechos de las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo establezca la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional."

Este artículo debe ser analizado junto con el art. 75, inc. 17 de la Constitución Nacional, incluido por la reforma constitucional de 1994, el cual reconoce la propiedad comunitaria indígena:

Art. 75, CN: "Corresponde al Congreso:...

17. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en

la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones."

Con esta norma surge un **nuevo tipo de propiedad**: la de las comunidades indígenas con **personería jurídica**, reconociéndoles la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y estableciendo que dichas tierras no serán enajenables, ni transmisibles, ni susceptibles de gravámenes o embargos.

Aparte de la Constitución Nacional y del art. 18 del nuevo Código Civil y Comercial, los derechos de las comunidades indígenas están receptados en tratados internacionales (ej: la Convención Americana de Derechos Humanos y los Convenios 107 y 169 de la OIT) y en las leyes nacionales, tal el caso de la Ley 26.160 sobre "Comunidades indígenas".

Propiedad indígena en el Anteproyecto.-

En el Anteproyecto del Código Civil y Comercial se redactó un art. 18 que reconocía la propiedad indígena, la cual se regulaba dentro de los **derechos reales** en los arts. 2028 al 2036 (Título V del Libro Cuarto).

Se la definía como el derecho real que recae sobre un inmueble rural destinado a la preservación de la identidad cultural y el hábitat de las comunidades indígenas, y el titular de este derecho era la comunidad indígena registrada como persona jurídica (conf. arts. 2028 y 2029). Se establecía que la propiedad indígena era exclusiva y perpetua, indivisible e imprescriptible por parte de un tercero, inembargable e inejecutable por deudas y no podía ser gravada con derechos reales de garantía. Se le aplicaban supletoriamente las disposiciones referidas al derecho real de dominio (conf. arts. 2032 a 2036).

Dada las críticas de gran parte de la doctrina, y de algunos sectores de las mismas comunidades indígenas (consideraban que este tipo de propiedad debería vincularse más con cuestiones de *derecho público*, que de *derechos reales*), se suprimió el Título V del Libro Cuarto que la regulaba, y se modificó el art. 18 del proyecto de Código Civil y Comercial finalmente sancionado.

Art. 9 de la Ley 26.994.-

En la Ley 26.994 que sancionó al nuevo Código, el art. 9 (en su primera parte) dispuso que: "Los derechos de los pueblos indígenas, en particular la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, **serán objeto de una ley especial**".

En definitiva, ante la eliminación del Título V del Libro Cuarto, la propiedad comunitaria indígena quedó prevista en el art. 18 que reitera lo dicho en la Constitución, pero dejó a la propiedad comunitaria indígena sujeta a una ley futura que la regule.

DERECHOS Y BIENES

• El Código Civil y Comercial expresa un **nuevo paradigma en materia de bienes**. → La concepción patrimonialista de que bienes son los que tienen un valor económico cambió porque existen bienes que, siendo de la persona, no tienen un valor económico, aunque sí una utilidad (por ej, el cuerpo, órganos, genes, etc.).

Titularidad de los derechos

→ Art. 15 →

La persona es titular de los bienes y derechos reales o creditorios que integran su patrimonio.

BIENES Y COSAS

Art. 16 →

"Los derechos referidos en el primer párrafo del artículo 15 pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor económico. Los bienes materiales se llaman cosas. Las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre."

Bienes

• Son todos los objetos materiales e inmateriales susceptibles de tener un valor o utilidad. Dentro de la expresión bienes quedan incluidos los derechos.

Cosas

Art. 16 → "...Los bienes materiales se llaman cosas".

• Son los objetos materiales susceptibles de tener un valor.
• Las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la **energía** y a las **fuerzas naturales** susceptibles de ser puestas al servicio del hombre.

DERECHOS SOBRE EL CUERPO HUMANO

Art. 17 →

"Los derechos sobre el cuerpo humano o sus partes no tienen un valor comercial, sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social y sólo pueden ser disponibles por su titular siempre que se respete alguno de esos valores y según lo dispongan las leyes especiales."

• Dado su carácter de derechos personalísimos, los derechos sobre el cuerpo humano o sus partes no tienen un valor económico o comercial y no son disponibles.
• Pero teniendo en cuenta el avance de la ciencia (transplantes de órganos, depósitos de células, etc.) y la utilidad de partes del cuerpo de una persona para salvar vidas de otras personas o prevenir y curar enfermedades, el Código Civil y Comercial admite que se pueda disponer de ellos siempre que se respete alguno de esos valores (ej: terapéutico) y según lo dispongan las leyes especiales (ej: ley de transplantes de órganos; ley de donación de sangre, etc.).

DERECHOS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

Art. 18 →

"Las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo establezca la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional."

Este artículo debe ser analizado junto con el art. 75, inc. 17 de la CN ("Corresponde al Congreso... 17. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos...").

• Con esta norma surge un **nuevo tipo de propiedad**: la de las comunidades indígenas con **personería jurídica**, reconociéndoles la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y estableciendo que dichas tierras no serán enajenables, ni transmisibles, ni susceptibles de gravámenes o embargos.

• Art. 9 de la Ley 26.994 → "Los derechos de los pueblos indígenas, en particular la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, **serán objeto de una ley especial**".

CAPÍTULO VI PERSONA HUMANA

Concepto.-

La Parte General del nuevo Código Civil y Comercial comienza con el Título Primero dedicado a la "Persona humana".

En el Código de Vélez la "persona" se definía por su capacidad y se establecía que "son personas todos los entes susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones" (art. 30 del Código de Vélez).

El nuevo Código Civil y Comercial (siguiendo la idea del Proyecto de 1998) no habla de "persona" sino de "persona humana". No da una definición de persona ni las características de la misma porque persona es todo ser humano por el hecho de serlo. En cuanto a su existencia, se determina que comienza con la concepción (el Anteproyecto decía "con la concepción en el seno materno", pero al pasar por el Congreso la Comisión Bicameral eliminó la expresión "seno materno").

Método del nuevo Código Civil y Comercial.-

El método utilizado es el siguiente:

CAPÍTULOS

TÍTULO I Persona humana

- 1 - Comienzo de la existencia (arts. 19 a 21)
- 2 - Capacidad (arts. 22 a 50)
- 3 - Derechos y actos personalísimos (arts. 51 a 61)
- 4 - Nombre (arts. 62 a 72)
- 5 - Domicilio (arts. 73 a 78)
- 6 - Ausencia (arts. 79 a 84)
- 7 - Presunción de fallecimiento (arts. 85 a 92)
- 8 - Fin de la existencia de las personas (arts. 93 a 95)
- 9 - Prueba del nacimiento/muerte y edad (arts. 96 a 99)
- 10 - Representación y asistencia. Tutela /Curatela (arts. 100 a 140)

COMIENZO DE LA EXISTENCIA DE LA PERSONA HUMANA.

Art. 19.- "Comienzo de la existencia. La existencia de la persona humana comienza con la concepción."

Algunas legislaciones extranjeras consideran que el comienzo de la existencia de las personas físicas tiene lugar cuando se produce el nacimiento.

En cambio, en el Código de Vélez y en el nuevo Código Civil y Comercial se considera que el comienzo de la persona humana tiene lugar desde la concepción. En otras palabras: se es persona desde que se está concebido, aún cuando todavía no se haya nacido.

La concepción dentro o fuera del seno materno.-

¿Qué es la concepción? Es la fecundación del óvulo femenino por el espermatozoide masculino, momento en que se produce una nueva célula (cigoto).

En el Código de Vélez (art. 70) se hablaba de la concepción en el “seno materno”, ello se debía a que en la época de Vélez era impensado que hubiera formas de concebir fuera del seno materno. Hoy en día, el desarrollo de las ciencias (en especial la química, la biología, la medicina y la genética) ha hecho posible que existan técnicas modernas de concepción aceptadas y utilizadas habitualmente en todo el mundo, tal el caso de la inseminación artificial y de la fecundación in vitro.

- La *inseminación artificial* se realiza dentro del seno materno y consiste en introducir espermatozoides (del marido o de un tercero donante) en el útero de la mujer con el fin de lograr la fecundación.

- La *fecundación in vitro* se realiza fuera del seno materno y consiste en tomar óvulos de la mujer, cultivarlos in vitro o probetas para luego agregarle los espermatozoides; obtenida así la fertilización externa se coloca el embrión dentro del útero.

En la actualidad rige el principio de que “*la existencia de la vida humana comienza desde la concepción*”, sea ésta dentro o fuera del seno materno, principio reconocido por ejemplo en tratados con jerarquía constitucional, tal el caso del Pacto de San José de Costa Rica (art. 4), en el Proyecto de unificación del Código Civil con el Código Comercial de 1998 (art. 15) y en el fallo de la Corte Suprema “Portal de Belén s/ amparo” de 2002, en el cual se sostuvo que “*el comienzo de la vida humana tiene lugar con la unión de los dos gametos, es decir con la fecundación; en ese momento, existe un ser humano en estado embrionario*”.

El comienzo de la existencia en el Anteproyecto.-

El Anteproyecto de Código Civil y Comercial, en su art. 19 original, establecía: “*La existencia de la persona humana comienza con la concepción en el seno materno. En el caso de técnicas de reproducción humana asistida, comienza con la implantación del embrión en la mujer, sin perjuicio de lo que prevea la ley especial para la protección del embrión no implantado.*”

La parte de la norma referida a *técnicas de reproducción humana asistida* trajo controversias. Hizo nacer la distinción entre “embriones implantados” en la mujer, los cuales serían considerados personas y los “embriones no implantados” (que serían considerados personas recién cuando fueran implantados) y que estarían protegidos por una ley especial. El tema controvertido era si los embriones no implantados eran o no personas, ya que si no lo eran carecerían de protección, podrían

ser considerados objetos desechables, y (como tales) ser eliminados o utilizados para experimentación.

- Una postura sostiene que no son personas porque no existe la posibilidad de desarrollo de un embrión fuera del cuerpo de la mujer. Se cita como sustento de esta posición el fallo “Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual la Corte dijo que el embrión sólo puede considerarse persona luego de la implantación en el útero ya que si no se implanta sus posibilidades de desarrollo son nulas, razón por la cual consideró que antes de este evento no procede aplicar el artículo 4 (protección del derecho a la vida) de la Convención Americana.

- Otra posición considera que los embriones no implantados también son personas y que por lo tanto tienen derecho a nacer, a la integridad física, a la identidad, etc, con lo cual es inadmisibles la posibilidad de eliminar o usar embriones humanos para investigación o experimentación. En cuanto al fallo “Artavia Murillo” no lo consideran obligatorio para la Argentina, porque los fallos de la Corte Interamericana son obligatorios para los Estados que hayan sido partes en el caso, y en dicho fallo era parte Costa Rica y no nuestro país.

Cuando el Anteproyecto pasó por el Congreso sufrió varias modificaciones. Una de ellas consistió en que al art. 19 se le quitó lo referente al “*seno materno*” y también el párrafo que expresa “*En el caso de técnicas de reproducción humana asistida...*”, con lo cual el art. 19 actual (siguiendo el texto del Proyecto de 1998) sólo determina que “*La existencia de la persona humana comienza con la concepción.*”

Ley 26.862 (“Reproducción Médicamente Asistida”).-

En los últimos años, los avances de la ciencia médica han determinado que sea habitual que la mujer que no puede quedar embarazada en forma natural recurra (para lograr su embarazo) a procedimientos y técnicas de reproducción asistida.

La Ley 26.862 de “*Reproducción Médicamente Asistida*” (BO: 26/6/2013) garantiza el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida. El sector público de salud, las obras sociales e incluso las entidades de medicina prepaga deben brindar a sus afiliados o beneficiarios, la cobertura integral e interdisciplinaria del tratamiento, cubriendo el diagnóstico, los medicamentos, las terapias de apoyo y los procedimientos y las técnicas de reproducción médicamente asistida (como ser: la inducción de ovulación; la estimulación ovárica; el desencadenamiento de la ovulación; las técnicas de reproducción asistida -TRA-; y la inseminación intrauterina, intracervical o intravaginal, con gametos del cónyuge, pareja conviviente o no, o de un donante, etc).

También quedan comprendidos en la cobertura de esta ley, los servicios de guarda de gametos o tejidos reproductivos. Las disposiciones de Ley 26.862 son de orden público y de aplicación en todo el territorio de la República.

DURACIÓN DEL EMBARAZO. ÉPOCA DE LA CONCEPCIÓN.-

Art. 20.- "Duración del embarazo. Época de la concepción. Época de la concepción es el lapso entre el máximo y el mínimo fijados para la duración del embarazo. Se presume, excepto prueba en contrario, que el máximo de tiempo del embarazo es de trescientos días (300) y el mínimo de ciento ochenta días (180), excluyendo el día del nacimiento."

El nuevo Código Civil y Comercial mantiene, en este tema, el sistema del Código de Vélez (arts. 76 y 77).

Conceptos generales.-

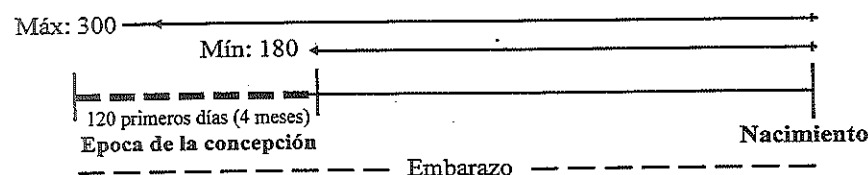
- **Período de embarazo:** es el período que transcurre entre la concepción hasta el momento del nacimiento de la persona.
- **Concepción:** es el hecho de la formación de un nuevo ser.
- **Época de la concepción:** lapso entre el máximo y el mínimo fijados para la duración del embarazo. La época en que se produce la concepción es de gran importancia práctica, pues de ella dependen el estado de familia del concebido y la suerte de determinados derechos. A continuación veremos más en detalle este concepto.

Época de la concepción.-

La época de la concepción nos permitirá saber si un hijo es extramatrimonial (si la época de la concepción es anterior al día en que se celebró el matrimonio) o si un hijo pertenece al primero o al segundo matrimonio, en el caso de que una viuda contraiga nuevo matrimonio antes de los 300 días de la muerte de su primer marido. También es importante por los efectos que produce sobre los *derechos adquiridos*.

Ejemplo: si se le hizo una donación antes de la época de la concepción, la persona por nacer no habrá podido adquirir ningún derecho. Lo mismo ocurriría si, siendo destinatario de una sucesión, ésta se abrió antes de la época de la concepción.

A raíz de esta importancia, el Código Civil y Comercial ha fijado una época dentro de la cual se considera que se produjo la concepción, basándose en que no hay embarazo que dure más de 300 días (10 meses), ni menos de 180 días (6 meses). Por tanto, entre el máximo y el mínimo nos queda un período de 120 días, en el cual se presume que ha ocurrido la concepción.



Se presume entonces que la concepción ocurrió dentro de los primeros 120 días de los 300 anteriores al parto.

¿Esta presunción admite prueba en contrario? Originariamente, el Código de Vélez establecía que no admitía prueba en contra. Pero con el correr del tiempo quedó demostrado que podía haber embarazos de menos de 180 días o de más de 300 días; además los análisis de ADN permiten saber con certeza si alguien es o no hijo de determinada persona. En consecuencia, ya durante la vigencia del Código de Vélez, la Ley 23.264 modificó el art. 77 y se estableció expresamente que la presunción admita prueba en contrario.

El mismo criterio sigue el nuevo Código Civil y Comercial al establecer expresamente: "*Se presume, excepto prueba en contrario...*" (conf. art. 20).

NACIMIENTO CON VIDA.

Art. 21.- "Nacimiento con vida. Los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida.

Si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió.

El nacimiento con vida se presume."

Las personas que aún no han nacido ("personas por nacer" en el Código de Vélez o los "concebidos o implantados en la mujer" en la terminología del art. 21 del nuevo Código Civil y Comercial) son "personas" y pueden adquirir derechos, pero dicha personalidad está sujeta a una condición: que nazcan con vida.

- Si nace con vida, aunque fuera por instantes, el nacido adquiere irrevocablemente los derechos.
- Si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió (art. 21) y, por lo tanto, pierde retroactivamente los derechos que había adquirido bajo condición.

El nacimiento consiste en que el niño sea separado completamente de la madre. El nacimiento con vida consiste en que al ser separado de la madre el niño comience a vivir por sí mismo.

Presunción del nacimiento con vida.-

El nacimiento con vida se presume (art. 21). Es una presunción "iuris tantum" (es decir, admite prueba en contrario). Si hay duda acerca de si ha nacido o no con vida, se presume que nació vivo, incumbiendo la prueba al que alegare lo contrario.

Sirve para corroborar el nacimiento con vida si, por ejemplo, las personas que asistieron al parto hubiesen oído la respiración o el llanto de los nacidos, o hubiesen observado otros signos de vida. Actualmente, la ciencia médica tiene pruebas muy concretas, para saber si hubo nacimiento con vida o sin vida. Así, es de fundamental importancia, determinar si la criatura ha respirado o no, lo cual se prueba de la siguiente manera: se realiza la autopsia de la criatura, y se coloca el tejido pulmonar, en un recipiente con agua: si dicho tejido flota, es porque respiró, y por lo tanto, nació con vida; si, por el contrario no flota, significa que no hubo vida, pues no llegó a respirar.

Representación.-

Las personas por nacer pueden adquirir derechos; pero dado que se trata de un incapaz de ejercicio (art. 24 inc. a) es lógico que, para ejercerlos, deba existir alguien que la represente legalmente, representación que recae sobre sus padres (conf. art. 101 inc. a).

Adquisición de derechos.-

¿Qué derechos pueden adquirir las personas por nacer? En el Código de Vélez, el art. 64 decía que podían adquirir bienes "*por donación o herencia*"; pero la doctrina y la jurisprudencia ampliaron el criterio y se aceptó que pudieran adquirir bienes por medio de legados, alimentos, cargos impuestos a terceros, indemnizaciones a raíz de daños contra ellos o sus parientes, acciones de estado, seguros, etc.

El nuevo Código Civil y Comercial no dice expresamente los derechos que la persona por nacer puede adquirir pero seguramente se continuará con el criterio amplio fijado por la doctrina y la jurisprudencia.

Lo que hayan adquirido lo conservarán si nacen con vida; en caso contrario, lo pierden pues se considera que la persona nunca existió (art. 21).

Posibles fraudes.-

Existen distintos fraudes con relación al embarazo:

a) Ocultación o supresión de parto: consiste en ocultar o en dar muerte al recién nacido.

Ejemplo: muere el marido y quedan como herederos la madre y el hijo por nacer; la madre, para heredar sola, oculta o mata al hijo cuando nace.

b) Suposición de parto: consiste en simular un parto que, en realidad, no ha tenido lugar.

Ejemplo: muere el marido y la mujer debe heredar junto con los padres de él. Si hay hijos, la mujer hereda con ellos y no con los padres del muerto, los cuales quedan así desplazados. Por lo tanto la mujer simula tener un parto, y hace pasar un hijo ajeno, por hijo suyo.

c) Sustitución de parto: consiste en sustituir el propio hijo muerto, por otro recién nacido ajeno. Caso similar al anterior, la diferencia está en que, en el anterior, se fingió el embarazo y el parto; en cambio, en este caso, el embarazo y el parto existieron, pero el hijo nació muerto.

Cuestión de la viabilidad.-

Algunas legislaciones exigen, para conceder el carácter de persona al recién nacido, la "*viabilidad*": capacidad física para prolongar su vida; o sea, para sobrevivir luego del nacimiento (así, el Código Civil francés, italiano, uruguayo, etc.). Otras legislaciones, no piden la viabilidad propiamente dicha, pero exigen que, por lo menos,

haya *vivido durante 24 hs.* (Código Civil español, boliviano, peruano, etc.). Las legislaciones modernas no exigen la viabilidad.

El Código Civil de Vélez no exigía viabilidad, ya que el art. 72 establecía: "*tampoco importará que los nacidos con vida tengan imposibilidad de prolongarla, o que mueran después de nacer, por un vicio orgánico interno, o por nacer antes de tiempo*", y Vélez daba los fundamentos de esta posición, en la nota al art. 72.

El nuevo Código Civil y Comercial no exige la viabilidad para conceder el carácter de persona al recién nacido.

LOS ATRIBUTOS DE LA PERSONA**Concepto.-**

Tradicionalmente, bajo la denominación de "*Atributos de la persona*", la doctrina hace referencia a cualidades jurídicas que son inseparables de la persona (ya sea persona humana o persona jurídica), porque ellas hacen a la base y esencia de la personalidad. Dichos atributos son :

- a) Nombre,
- b) Capacidad,
- c) Domicilio,
- d) Patrimonio,
- e) Estado civil (este último atributo sólo puede corresponder a las personas humanas).

Los veremos y analizaremos a lo largo de esta obra.

Caracteres.-

A los atributos de la persona se le adjudican los siguientes caracteres:

- 1) **necesarios**: ninguna persona puede prescindir de ellos;
- 2) **inseparables**: no se pueden separar de la persona;
- 3) **inalienables**: no pueden ser enajenados;
- 4) **imprescriptibles**: no son susceptibles de prescripción;
- 5) **únicos**: sólo se puede tener uno de cada clase.

PERSONA HUMANA

Concepto

- En el Código de Vélez la "persona" se definía por su capacidad: "son personas todos los entes susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones" (art. 30 del Código de Vélez).
- El nuevo Código Civil y Comercial no habla de "persona" sino de "persona humana". No da una definición de persona ni las características de la misma porque **persona es todo ser humano por el hecho de serlo.**

COMIENZO DE LA EXISTENCIA

Art. 19 → "La existencia de la persona humana comienza con la concepción."

- Se es persona desde que se está concebido, aún cuando todavía no se haya nacido.

¿Qué es la concepción?

Es la fecundación del óvulo femenino por el espermatozoide masculino, momento en que se produce una nueva célula (cigoto).

- En la actualidad rige el principio de que "la existencia de la vida humana comienza desde la concepción", sea ésta dentro o fuera del seno materno, principio reconocido en tratados con jerarquía constitucional

Ley 26.862 de

Reproducción Médicamente Asistida

Garantiza el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida.

DURACIÓN DEL EMBARAZO. ÉPOCA DE LA CONCEPCIÓN

Conceptos Generales

- **Período de embarazo:** es el período que transcurre entre la concepción hasta el momento del nacimiento de la persona.
- **Concepción:** es el hecho de la formación de un nuevo ser.
- **Época de la concepción:** lapso entre el máximo y el mínimo fijados para la duración del embarazo.

Época de la concepción

- El Código Civil y Comercial ha fijado una época dentro de la cual se considera que se produjo la concepción, basándose en que no hay embarazo que dure **más de 300 días (10 meses), ni menos de 180 días (6 meses)**.
- Entre el máximo y el mínimo nos queda un período de 120 días, en el cual **se presume** que ha ocurrido la concepción. **Esta presunción admite prueba en contrario**

Importancia

- ❖ Nos permitirá saber si un hijo es extramatrimonial; o si pertenece al primero o al segundo matrimonio.
- ❖ También es importante por los efectos que produce sobre los **derechos adquiridos**.

NACIMIENTO CON VIDA

• Personas que aún no han nacido ("personas por nacer" en el CC o "concebidos o implantados en la mujer" en el art. 21 del nuevo Código Civil y Comercial)

son "personas", y pueden adquirir derechos, pero dicha personalidad está sujeta a una condición: **que nazcan con vida.**

- ❖ Si nace con vida, aunque fuera por instantes, el nacido **adquiere irrevocablemente los derechos**.
- ❖ Si no nace con vida, se considera que **la persona nunca existió** (art. 21).

Presunción

- El nacimiento con vida **se presume** (art. 21). Es una presunción "*iuris tantum*" (es decir, admite prueba en contrario).

Representación

- La persona por nacer puede adquirir derechos; pero para ejercerlos, debe existir alguien que la represente legalmente, representación que recae sobre sus padres (art. 101 inc. a).

Posibles fraudes

- a) Ocultación o supresión de parto / b) Suposición de parto / c) Sustitución de parto.

Viabilidad

- El nuevo Código Civil y Comercial **no exige la viabilidad** (capacidad física para prolongar su vida) para conceder el carácter de persona al recién nacido.

CAPÍTULO VII CAPACIDAD

Concepto.-

La "capacidad" es la aptitud de la persona, por un lado, para ser titular de derechos y deberes jurídicos, y por otro, para ejercer por sí mismo los derechos o el cumplimiento de los deberes.

Art. 22.- "Capacidad de derecho. Toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. La ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, simples actos, o actos jurídicos determinados."

Art. 23.- "Capacidad de ejercicio. Toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en este Código y en una sentencia judicial."

Tipos de capacidad.-

Hay dos tipos de capacidad:

1) **Capacidad de derecho:** aptitud para ser titular de un derecho o de un deber jurídico (también se la denomina capacidad "de goce"). La ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, simples actos, o actos jurídicos determinados.

2) **Capacidad de ejercicio:** aptitud para ejercer por sí misma sus derechos o el cumplimiento de sus deberes (es la denominada "capacidad de hecho" del Código de Vélez.).

Estas capacidades tienen limitaciones que se denominan *incapacidades* (incapacidad de derecho e incapacidad de ejercicio).

La capacidad es la regla; la incapacidad es la excepción.

INCAPACIDAD DE DERECHO.-

Concepto.-

Se habla de incapacidad de derecho, cuando la ley prohíbe a una persona ser titular de un derecho. Las personas humanas son capaces de derecho, y sólo dejan de serlo cuando la ley se los prohíbe.

La incapacidad de derecho está fundada en razones morales, pues las prohibiciones recaen sobre actos que, de realizarse, serían contrarios a la moral (ej: el art. 1002, prohíbe a los funcionarios públicos, contratar en interés propio respecto de bienes de cuya administración o enajenación están o han estado encargados). En

virtud de este fundamento, cuando un incapaz de derecho celebra el acto que le está prohibido, la ley considera nulo dicho acto.

La incapacidad de derecho no puede ser salvada por medio de un representante.

La incapacidad de derecho nunca es absoluta, siempre es relativa. Esto significa que la prohibición de ser titular de un derecho estará siempre referida a un derecho determinado, pero nunca a todos los derechos. Si alguien careciera totalmente de la capacidad para ser titular de derechos, no sería "persona", sería un esclavo o un muerto civil, y ello no se admite en el derecho moderno.

Excepcionalidad de la incapacidad de derecho.-

Los casos de incapacidad de derecho son excepcionales, están establecidos específicamente por la ley y se los debe interpretar restrictivamente.

Esto significa dos cosas:

- a) que no se los puede extender (por analogía) a casos no previstos; y
- b) que en caso de duda (si la persona es capaz o incapaz) debe estarse a favor de la capacidad.

Incapacidad de derecho en el Código de Vélez.-

Las incapacidades de derecho están dispersas a través de todo el ordenamiento jurídico. En el Código Civil de Vélez había una norma que se refería genéricamente a las incapacidades de derecho. Era el art. 1160, que establecía que no podían contratar:

- los que están excluidos de poderlo hacer con personas determinadas (ej: *los esposos entre sí o los tutores o curadores con sus representados*)
- respecto de cosas especiales (ej: *los mandatarios* no podían adquirir los bienes objeto del mandato),
- aquellos a quienes les fuese prohibido en las disposiciones relativas a cada uno de los contratos,
- los religiosos profesos sino cuando comprasen bienes muebles a dinero de contado, o contratasen por sus conventos;
- los comerciantes fallidos sobre bienes que correspondan a la masa del concurso, si no estipularen concordatos con sus acreedores.

Incapacidad de derecho en el nuevo Código Civil y Comercial.-

En el nuevo Código Civil y Comercial, las incapacidades de derecho también están dispersas a través de todo el ordenamiento jurídico. A modo de ejemplo podemos citar el art. 1002 que bajo la denominación de "*inhabilidades especiales*" fija incapacidades de derecho para contratar en interés propio.

Art. 1002.- "Inhabilidades especiales. No pueden contratar en interés propio:

- a) *los funcionarios públicos, respecto de bienes de cuya administración o enajenación están o han estado encargados;*

b) *los jueces, funcionarios y auxiliares de la justicia, los árbitros y mediadores, y sus auxiliares, respecto de bienes relacionados con procesos en los que intervienen o han intervenido;*

c) *los abogados y procuradores, respecto de bienes litigiosos en procesos en los que intervienen o han intervenido;*

d) *los cónyuges, bajo el régimen de comunidad, entre sí.*

Los albaceas que no son herederos no pueden celebrar contrato de compraventa sobre los bienes de las testamentarias que estén a su cargo."

INCAPACIDAD DE EJERCICIO

Concepto.-

La capacidad de ejercicio es la aptitud para ejercer por sí mismo los derechos. Pero, en ciertos casos, la ley limita esa capacidad (incapacidad de hecho o de ejercicio) con el fin de proteger al incapaz y no le permite ejercer por sí mismo sus derechos; sólo le permite actuar por medio de su representante legal (padres, tutor, curador, etc.).

Ejemplo: un menor es propietario de una casa, y la ley, en razón de su minoridad (causal de incapacidad de ejercicio) y con el fin de protegerlo no le permite ejercer por sí mismo el derecho de propiedad sobre ella, es decir, no le permite venderla, donarla, alquilarla, etc; sólo lo podrá hacer por medio de su representante legal.

Incapacidad de ejercicio en el Código de Vélez.-

En el Código de Vélez, la incapacidad de hecho o de ejercicio podía ser absoluta (cuando se le prohibía ejercer todos sus derechos, ej: persona por nacer y menores impúberes) o relativa (cuando tenía capacidad sólo para determinados actos que las leyes le autorizaban a realizar, ej: los menores adultos de 14 a 18 años).

Incapacidad de ejercicio en el nuevo Código Civil y Comercial.-

El nuevo Código Civil y Comercial suprimió la distinción entre incapacidad de ejercicio absoluta e incapacidad de ejercicio relativa, y en el art. 24 establece quiénes son incapaces de ejercer sus derechos por sí mismos.

Art. 24.- "Personas incapaces de ejercicio. Son incapaces de ejercicio:

- a) *la persona por nacer;*
- b) *la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente con el alcance dispuesto en la Sección 2ª de este Capítulo (los menores de edad);*
- c) *la persona declarada incapaz por sentencia judicial, en la extensión dispuesta en esa decisión."*

PERSONA POR NACER

Ya nos hemos referido a ellas. Son las personas que aún no han nacido y cuya situación va desde la concepción hasta el parto. Son "personas" y pueden adquirir derechos, pero dicha personalidad está sujeta a una condición: que nazcan con vida. Si se nace con vida, aunque fuera por instantes, el nacido adquiere irrevocablemente

cablemente los derechos. Si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió (art. 21) y, por lo tanto, pierde retroactivamente los derechos que había adquirido bajo condición.

Las personas por nacer pueden adquirir derechos; pero no pueden ejercerlos por sí mismos (art. 24 inc. a). Esta incapacidad se suple mediante una representación legal, representación que recae sobre sus padres (conf. art. 101 inc. a).

Con respecto a los derechos que pueden adquirir, en el Código de Vélez el art. 64 decía que podían adquirir "*por donación o herencia*"; pero la doctrina y la jurisprudencia ampliaron el criterio aceptando que pudieran adquirir bienes por medio de legados, alimentos, cargos impuestos a terceros, indemnizaciones a raíz de daños contra ellos o sus parientes, acciones de estado, seguros, etc.

LOS MENORES DE EDAD

En el Código de Vélez, según la época a considerar, se era menor de edad hasta los 22 años, luego (con la Ley 17.711) hasta los 21 años y, por último, con la Ley 26.579 se era menor hasta los 18 años. A la vez, entre los menores se distinguía entre los menores impúberes (de 0 a 14 años) que tenían incapacidad absoluta y los menores adultos (de 14 a 18 años) con incapacidad relativa.

El nuevo Código Civil y Comercial eliminó estas distinciones entre menores impúberes y menores adultos, y entre incapacidad absoluta y relativa.

Los menores de edad en el nuevo Código Civil y Comercial.-

• **Menor de edad:** es la persona que no ha cumplido 18 años (conf. art. 25). Es incapaz de ejercicio si no tiene la edad y madurez suficiente para realizar los actos que el Código autoriza. En estos casos, el menor actúa por medio de sus representantes legales.

• **Adolescente:** es el menor que cumplió los 13 años, es decir se es adolescente desde los 13 a los 18 años (conf. art. 25).

Art. 26.- "Ejercicio de los derechos por la persona menor de edad.

La persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada.

La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne así como a participar en las decisiones sobre su persona.

Se presume que el adolescente entre 13 y 16 años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física.

Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores; el conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior, sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico.

A partir de los 16 años el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo.

El nuevo Código Civil y Comercial, siguiendo las ideas de la Convención de los Derechos del Niño y otras normas internacionales, estableció un sistema de adquisición de la capacidad de ejercicio en forma gradual y flexible que toma en cuenta la "edad y grado de madurez" del menor. Así se puede diferenciar:

a) Menores que no cuentan con edad y grado de madurez suficiente: no pueden ejercer por sí mismos sus derechos, y sólo pueden hacerlo por medio de sus representantes legales (los padres o tutores, según el caso).

b) Menores que cuentan con edad y grado de madurez suficiente: podrán ejercer por sí mismos los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. Ejemplos: en materia de apellido puede pedir agregarse el apellido del otro progenitor (art. 64); en materia de adopción tiene derecho a conocer los datos relativos a su origen y puede acceder al expediente en el que se tramitó su adopción (art. 596); puede demandar a sus progenitores por prestación de alimentos y también por sus propios intereses (arts. 661 y 679); etc.

En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada.

Todo menor tiene derecho a:

- **ser oído** en los procesos judiciales que le conciernan; y
- **participar en las decisiones sobre su persona.**

Esto constituye una adecuación normativa a la Convención de los Derechos del Niño. Son numerosos los artículos del nuevo Código Civil y Comercial que hacen aplicación del derecho del menor a ser oído (ejemplos: arts. 26, 113, 117, 595 inc. f, 598, 608, 613, 617, 639, 646, 677 a 680, etc.).

La decisión del adolescente en los tratamientos médicos.-

Aquí debemos distinguir según se trate de un adolescente que haya cumplido o no los 16 años de edad:

• Adolescente entre los 13 y 16 años:

a) Respecto a someterse a **tratamientos no invasivos**, ni que comprometan su salud o provoquen un riesgo grave para su vida o integridad física, se presume que goza de **aptitud para decidir por sí**.

b) Respecto a someterse a **tratamientos invasivos** que comprometan su estado de salud o está en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento pero con la **asistencia de sus progenitores**. El conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta el interés superior del menor, sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico.

• Adolescente a partir de los 16 años: es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo.

Los menores y los "pequeños contratos".-

Los "pequeños contratos" celebrados cotidianamente por los menores (como ser: comprar cosas en quioscos, almacenes, tiendas, etc.; adquirir entradas para cines o teatros; celebrar contrato de transporte al viajar y pagar su boleto, etc.) son válidos, porque se presumen realizados con la conformidad de los progenitores (conf. art. 684).

Menor de edad con título profesional habilitante.-

La persona menor de edad que ha obtenido título habilitante para el ejercicio de una profesión puede ejercerla por cuenta propia sin necesidad de previa autorización. Tiene la administración y disposición de los bienes que adquiere con el producto de su profesión y puede estar en juicio civil o penal por cuestiones vinculadas a ella (conf. art. 30).

MAYORIA DE EDAD Y EMANCIPACIÓN

Tanto la *mayoría de edad* como la *emancipación* son institutos que permiten que la persona no tenga restringida su capacidad.

Mayoría de edad.-

¿Cuándo se es mayor de edad? Al cumplir 18 años. Se es mayor de edad desde la 0 hora del día en que se cumplen los 18 años.

¿Y qué efectos produce? La persona pasa a ser plenamente capaz y está habilitada para el ejercicio de todos los actos de la vida civil, sin depender de formalidad alguna o autorización de los padres, tutores, o jueces. Incluso los actos que realice durante el día de su cumpleaños, serán realizados con plena capacidad, y perfectamente válidos.

¿Hay que llenar alguna formalidad? No, la plena capacidad se adquiere de pleno derecho, es decir, automáticamente, sin llenar ninguna formalidad. Para realizar cualquier acto le bastará con acreditar su edad.

Antes de la ley 17.711, la mayoría de edad se alcanzaba a los 22 años. Con la Ley 17.711 se estableció la mayoría de edad a los 21 años. Actualmente, la mayoría de edad se alcanza a los 18 años, en concordancia con la Convención de los Derechos del Niño (incorporada a la Constitución Nacional por la reforma del año 1994), la cual indirectamente también fija este límite de edad, al definir en su art. 1 como "niño" a toda persona menor de 18 años.

Cabe destacar que si bien se es mayor de edad a los 18 años, por la Ley 26.774 (BO: 2/11/2012) a partir de los 16 años se puede votar.

Emancipación por matrimonio.-

La emancipación es la institución en virtud de la cual los menores pueden adquirir plena capacidad, aún antes de llegar a la mayoría de edad. La emancipación por matrimonio se produce cuando el menor de edad se casa.

En el Código de Vélez la emancipación podía tener lugar: 1) por matrimonio; o 2) por habilitación de edad; pero en los últimos años sólo había quedado vigente la emancipación por matrimonio ya que cuando se dispuso la mayoría de edad a los 18 años la emancipación por habilitación de edad perdió sentido.

La celebración del matrimonio antes de los 18 años emancipa a la persona menor de edad. Dado que la edad legal para contraer matrimonio es a los 18 años (conf. art. 403), para poder casarse antes de esa edad el menor necesita autorización de sus representantes legales o del juez (conf. art. 404):

- Si tiene menos de 16 años necesita autorización judicial.
- Si tiene más de 16 años le basta con la autorización de sus representantes legales. A falta de ésta, puede pedir autorización judicial.

Sin embargo, si logra casarse sin autorización igual la emancipación subsiste para el cónyuge de buena fe (conf. art. 27).

Al emanciparse, el menor deja de estar bajo la "responsabilidad parental" de los padres (o bajo la "patria potestad", como se denominaba en el Código Civil de Vélez), y pasa a gozar de plena capacidad de ejercicio (ej: puede administrar y disponer de sus bienes, celebrar contratos y actos jurídicos en general), pero con las limitaciones previstas en este Código que establece qué actos no puede realizar (art. 28) y qué actos requieren autorización.

Art. 27.- "Emancipación. La celebración del matrimonio antes de los 18 años emancipa a la persona menor de edad.

La persona emancipada goza de plena capacidad de ejercicio con las limitaciones previstas en este Código.

La emancipación es irrevocable. La nulidad del matrimonio no deja sin efecto la emancipación, excepto respecto del cónyuge de mala fe para quien cesa a partir del día en que la sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada.

Si algo es debido a la persona menor de edad con cláusula de no poder percibirlo hasta la mayoría de edad, la emancipación no altera la obligación ni el tiempo de su exigibilidad."

Actos prohibidos al emancipado.-

Art. 28.- "Actos prohibidos a la persona emancipada. La persona emancipada no puede, ni con autorización judicial:

- a) aprobar las cuentas de sus tutores y darles finiquito;
- b) hacer donación de bienes que hubiese recibido a título gratuito;
- c) afianzar obligaciones."

Si el emancipado estaba bajo tutela no puede aprobar lo hecho por su tutor (ej: la gestión o las cuentas del tutor). Se le prohíbe donar los bienes que hubiese reci-

bido a título gratuito, pero puede donar los adquiridos a título oneroso. No puede ser fiador. Si realizara alguno de los actos prohibidos en el art. 28, el acto estaría viciado de nulidad.

Actos del emancipado sujetos a autorización judicial.-

Art. 29.- "Actos sujetos a autorización judicial. El emancipado requiere autorización judicial para disponer de los bienes recibidos a título gratuito. La autorización debe ser otorgada cuando el acto sea de toda necesidad o de ventaja evidente."

Los bienes recibidos a título gratuito no los puede donar ni con autorización judicial (conf. art. 28), pero sí los puede vender si cuenta con autorización del juez (conf. art. 29).

El juez dará la autorización para disponer si el acto es:

- necesario para el emancipado; o
- evidentemente ventajoso para el emancipado.

La emancipación no es estrictamente igual a la mayoría de edad, por ello si alguien le debe algo al menor de edad con una cláusula de que el menor no pueda percibirlo hasta la mayoría de edad, la emancipación no altera la obligación ni el tiempo de su exigibilidad.

Efectos de la anulación del matrimonio.-

¿Qué sucede si el matrimonio se anula? La emancipación es irrevocable. Si el matrimonio se anula por alguna causa, la emancipación subsiste para el cónyuge de buena fe. Por el contrario, para el que sea de mala fe cesa a partir del día en que la sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada (conf. art. 27).

El caso de los progenitores adolescentes.-

En el nuevo Código Civil y Comercial, los progenitores adolescentes, estén o no casados, ejercen la responsabilidad parental de sus hijos pudiendo decidir y realizar por sí mismos las tareas necesarias para su cuidado, educación y salud. Pero en algunas situaciones (ej: decidir sobre su adopción, intervenciones quirúrgicas, etc), en beneficio del interés superior del niño, lo que decida el progenitor adolescente debe integrarse con el consentimiento de sus propios progenitores (conf. art. 644). Estos pueden actuar en beneficio del niño, ya sea oponiéndose a cualquier acto que sea perjudicial para el niño, o interviniendo.

Art. 644.- "Progenitores adolescentes. Los progenitores adolescentes, estén o no casados, ejercen la responsabilidad parental de sus hijos pudiendo decidir y realizar por sí mismos las tareas necesarias para su cuidado, educación y salud. Las personas que ejercen la responsabilidad parental de un progenitor adolescente que tenga un hijo bajo su cuidado pueden oponerse a la realización de actos que resulten perjudiciales para el niño; también pueden intervenir cuando el progenitor omite realizar las acciones necesarias para preservar su adecuado desarrollo."

El consentimiento del progenitor adolescente debe integrarse con el asentimiento de cualquiera de sus propios progenitores si se trata de actos trascendentes para la vida del niño, como la decisión libre e informada de su adopción, intervenciones quirúrgicas que ponen en peligro su vida, u otros actos que pueden lesionar gravemente sus derechos. En caso de conflicto, el juez debe decidir a través del procedimiento más breve previsto por la ley local.

La plena capacidad de uno de los progenitores no modifica este régimen."

Emancipaciones que dejaron detener vigencia.-

Los siguientes tipos de emancipación han dejado de tener vigencia:

• **Emancipación por habilitación de edad (emancipación dativa).**- Era la emancipación que podía obtener el menor cuando llegaba a los 18 años (la mayoría de edad era a los 21 años), mediante autorización de quienes ejercían sobre él la patria potestad o mediante habilitación del juez, si se encontrase bajo tutela (conf. art. 131, 3er párr., Código de Vélez). Actualmente este instituto carece de sentido, ya que al llegar a los 18 años la persona es plenamente capaz y no necesita de ninguna autorización.

• **Emancipación comercial (autorización para ejercer el comercio).**- Consistía en habilitar al menor (a partir de los 18 años) para ejercer el comercio. El Código Civil de Vélez se refería a ella (art. 131) y remitía a las disposiciones del Código de Comercio (arts. 10, 11 y 12). La autorización para ejercer el comercio podía ser expresa o tácita (expresa: cuando existía la autorización expresa de los padres o del juez; tácita: cuando el hijo mayor de 18 años era asociado al comercio del padre). Actualmente este instituto carece de sentido, ya que al llegar a los 18 años la persona es capaz y no necesita ninguna autorización para ejercer el comercio.

Además, la persona menor de edad que ha obtenido título habilitante para el ejercicio de una profesión puede ejercerla por cuenta propia sin necesidad de previa autorización. Tiene la administración y disposición de los bienes que adquiere con el producto de su profesión y puede estar en juicio civil o penal por cuestiones vinculadas a ella (conf. art. 30).

PERSONAS CON CAPACIDAD RESTRINGIDA Y PERSONAS CON INCAPACIDAD

Reglas generales.-

En toda decisión que limite la capacidad de ejercicio de una persona (sea persona con capacidad restringida o persona con incapacidad) se deben observar las reglas generales que establece el art. 31 del nuevo Código Civil y Comercial:

- a) La capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume, aún cuando se encuentre internada en un establecimiento asistencial;
- b) Las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de la persona;
- c) La intervención estatal tiene siempre carácter interdisciplinario, tanto en el tratamiento como en el proceso judicial (esto significa que el tratamiento y la eva-

luación de la persona deben ser abordadas por medio de distintas disciplinas -como por ejemplo psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional, etc.- y no a través de una sola de ellas);

d) La persona tiene derecho a recibir información a través de medios y tecnologías adecuadas para su comprensión;

e) La persona tiene derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada, que debe ser proporcionada por el Estado si carece de medios;

f) Deben priorizarse las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos y libertades.

Restricción de la capacidad.-

Art. 32.- "Persona con capacidad restringida y con incapacidad. El juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de trece años que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada, de suficiente gravedad, siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes.

En relación con dichos actos, el juez debe designar el o los apoyos necesarios que prevé el artículo 43, especificando las funciones con los ajustes razonables en función de las necesidades y circunstancias de la persona.

El o los apoyos designados deben promover la autonomía y favorecer las decisiones que respondan a las preferencias de la persona protegida.

Por excepción, cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interactuar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado y el sistema de apoyos resulte ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad y designar un curador."

Siguiendo un criterio biológico-jurídico, el nuevo Código Civil y Comercial establece que el juez puede restringir la capacidad de ejercicio de una persona (mayor de 13 años) que por sufrir una adicción o alteración mental permanente o prolongada [*criterio biológico*], de suficiente gravedad, corre peligro de causar un daño a su persona o a sus bienes [*criterio jurídico*].

Según el padecimiento, puede declararlo "con capacidad restringida" para realizar algunos actos, o persona "con incapacidad".

D) Persona con capacidad restringida.-

En este supuesto, la persona que por padecer una adicción (ej: embriaguez habitual, toxicómano) o alteración mental (demencia, manías parciales, senilidad, etc) permanente o prolongada, de suficiente gravedad, corre peligro de causar un daño a su persona o a sus bienes. El juez puede:

- restringirle la capacidad para ejercitar por sí mismo determinados actos; y
- designarle los apoyos necesarios para que lo asistan en la toma de decisiones.

Se trata de una persona capaz a la cual se le restringe la capacidad para realizar por sí mismo algunos actos. Debe ser mayor de 13 años (porque el menor de esa

edad ya tiene incapacidad y tiene un representante legal). Es una incapacidad relativa porque se refiere sólo a la incapacidad para ejercitar por sí mismo determinados actos. ¿Cuáles actos?. Los que se indiquen en la sentencia.

La sentencia que declare la capacidad restringida debe determinar la extensión y alcance de la restricción, y especificar las funciones y actos que se limitan, procurando que la afectación de la autonomía personal sea la menor posible.

El juez debe designar los apoyos necesarios (por "apoyo" debe entenderse cualquier medida de carácter judicial o extrajudicial que facilite, a quien lo necesite, la toma de decisiones para dirigir su persona, administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos en general). Las medidas de apoyo no deben anular la voluntad del protegido sino todo lo contrario, deben tener como función la de promover la autonomía y facilitar la comunicación, la comprensión y la manifestación de voluntad de la persona protegida. Se trata de una incapacidad relativa porque se refiere sólo a la incapacidad para ejercitar determinados actos.

II) Persona con incapacidad.-

Para que el juez pueda declarar la incapacidad de la persona, deben cumplirse los siguientes 2 requisitos:

- Que la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interactuar con su entorno y de expresar su voluntad por algún modo, medio o formato adecuado; y
- Que el sistema de apoyos resulte ineficaz para la persona.

En dicho caso, el juez puede declarar su incapacidad y designarle un curador (arts. 138 a 140). Se trata de un incapaz absoluto.

Solicitud de la declaración de incapacidad o capacidad restringida.-

¿Quiénes pueden solicitar la declaración de incapacidad o de capacidad restringida? Lo responde el art. 33, al expresar que están legitimados para solicitarla:

- el propio interesado;
- el cónyuge no separado de hecho y el conviviente mientras la convivencia no haya cesado;
- los parientes dentro del cuarto grado; si fueran por afinidad, dentro del segundo grado;
- el Ministerio Público.

Esta enumeración en principio es taxativa, o sea que no podrá pedir la declaración ninguna persona que no esté enumerada (ej: no podrán solicitarla los socios, acreedores, novios, parientes muy lejanos, amigos, empleados, etc.). Sin embargo, nada impide que cualquier persona se presente ante el Ministerio Público para que éste evalúe la situación y pida la declaración.

El proceso de declaración.-

El proceso de declaración de incapacidad o capacidad restringida puede ser iniciado por los legitimados del art. 33, aportando toda clase de pruebas para acreditar los hechos invocados (ej: certificados médicos).

Incluso el propio interesado puede iniciarlo ante el juez competente que es el de su domicilio o el del lugar de su internación. El interesado es parte en el proceso y puede aportar todas las pruebas que hagan a su defensa; y en caso de haber comparecido sin abogado, se le debe nombrar uno para que lo represente y le preste asistencia letrada en el juicio (conf. art. 36).

Durante el proceso, el juez debe ordenar las medidas cautelares necesarias para garantizar los derechos patrimoniales y personales de la persona (ej: inhibiciones, inventario y resguardo de determinados bienes, designación de una persona para que lo asista o represente o de un curador, exámenes de médicos psiquiatras o legistas etc), indicando qué actos requieren la asistencia de uno o varios apoyos, y cuáles la representación de un curador. También puede designar redes de apoyo y personas que actúen con funciones específicas según el caso. .

Antes de dictar resolución alguna el juez tiene la obligación de tomar contacto con la persona, debiendo entrevistar personalmente al interesado (lo hace comparecer al juzgado, o el juez se traslada al lugar donde esté el interesado). El Ministerio Público y, al menos, un letrado que preste asistencia al interesado, deben estar presentes en las audiencias.

La sentencia.-

El art. 37 deja en claro cuáles son las cuestiones sobre las que debe pronunciarse la sentencia:

Art. 37.- "Sentencia. La sentencia se debe pronunciar sobre los siguientes aspectos vinculados a la persona en cuyo interés se sigue el proceso:

- a) diagnóstico y pronóstico;*
- b) época en que la situación se manifestó;*
- c) recursos personales, familiares y sociales existentes;*
- d) régimen para la protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía posible. Para expedirse, es imprescindible el dictamen de un equipo interdisciplinario."*

• **Alcance de la sentencia.-** La sentencia, además, debe:

- 1) determinar la extensión y alcance de la restricción;
- 2) especificar las funciones y actos que se limitan, procurando que la afectación de la autonomía personal sea la menor posible;
- 3) designar una o más personas de apoyo o curadores, y señalar las condiciones de validez de los actos específicos sujetos a la restricción (indicando a las personas intervinientes y la modalidad de su actuación).

• **Dictamen interdisciplinario.-** Para expedirse la sentencia, es imprescindible el dictamen de un equipo interdisciplinario (evaluaciones de distintos profesio-

nales, como ser: médicos psiquiatras, psicólogos, peritos en alguna especialidad, enfermeros, visitadores sociales, etc).

• **Fallo de la sentencia.-** La sentencia puede:

- a) rechazar el pedido (por considerarlo sano);
- b) restringir la capacidad; o
- c) declarar la incapacidad.

• **Registración de la sentencia.-** La sentencia debe ser inscripta en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas y se debe dejar constancia al margen del acta de nacimiento.

La restricción de actos tendrá efectos contra terceros recién a partir de la fecha de inscripción en el registro, sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 45 para los actos anteriores al registro. Si desaparecen las restricciones, se procede a la inmediata cancelación registral (conf. art. 39).

La internación de la persona.-

El nuevo Código Civil y Comercial regula las "internaciones" en los arts. 41 y 42.

Art. 41.- "Internación. La internación sin consentimiento de una persona, tenga o no restringida su capacidad, procede sólo si se cumplen los recaudos previstos en la legislación especial y las reglas generales de esta Sección. En particular:

- a) debe estar fundada en una evaluación de un equipo interdisciplinario de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 37, que señale los motivos que la justifican y la ausencia de una alternativa eficaz: menos restrictiva de su libertad;*
- b) sólo procede ante la existencia de riesgo cierto e inminente de un daño de entidad para la persona protegida o para terceros;*
- c) es considerada un recurso terapéutico de carácter restrictivo y por el tiempo más breve posible; debe ser supervisada periódicamente;*
- d) debe garantizarse el debido proceso, el control judicial inmediato y el derecho de defensa mediante asistencia jurídica;*
- e) la sentencia que aprueba la internación debe especificar su finalidad, duración y periodicidad de la revisión.*

Toda persona con padecimientos mentales, se encuentre o no internada, goza de los derechos fundamentales y sus extensiones."

La internación, en líneas generales, consiste en que la persona quede recluida o alojada día y noche en un establecimiento de salud bajo el control de las autoridades del mismo, sea para hacerle un examen médico o como medida de prevención para evitar que la persona se dañe a sí misma o dañe a terceros.

• La internación es **voluntaria** cuando es decisión del propio afectado, el cual expresa su consentimiento libremente y por escrito para quedarse en el establecimiento.

• La internación es **involuntaria** cuando el afectado, por alguna causa, no ha dado su consentimiento (ejemplos: sea porque no quiere internarse, porque no está en condiciones de rechazar la internación o de expresar válidamente su voluntad,

o porque es menor de 18 años, o porque se le ha dictado sentencia que restringe su capacidad, etc.).

A estas internaciones sin consentimiento (involuntarias) se refiere el nuevo Código Civil y Comercial. Las regula por medio de los arts. 41 y 42, los cuales establecen una base de reglas mínimas que se deben cumplir en caso de internación sin consentimiento de una persona. Estas reglas complementan lo dispuesto por la "legislación especial" (es decir, la Ley 26.657 sobre "salud mental", que trata el tema de las internaciones).

Las reglas mínimas para la internación sin consentimiento son:

a) debe estar fundada en una evaluación de un equipo interdisciplinario de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 37, que señale los motivos que la justifican y la ausencia de una alternativa eficaz menos restrictiva de su libertad;

b) sólo procede ante la existencia de riesgo cierto e inminente de un daño de entidad para la persona protegida o para terceros;

c) es considerada un recurso terapéutico de carácter restrictivo y por el tiempo más breve posible; debe ser supervisada periódicamente;

d) debe garantizarse el debido proceso, el control judicial inmediato y el derecho de defensa mediante asistencia jurídica;

e) la sentencia que aprueba la internación debe especificar su finalidad, duración y la periodicidad de la revisión.

Es importante destacar que toda persona con padecimientos mentales (se encuentre o no internada) goza de los derechos fundamentales y sus extensiones.

El art. 42, por su parte, regula el traslado, evaluación e internación de la persona:

Art. 42.- "Traslado dispuesto por autoridad pública. Evaluación e internación. La autoridad pública puede disponer el traslado de una persona cuyo estado no admita dilaciones y se encuentre en riesgo cierto e inminente de daño para sí o para terceros, a un centro de salud para su evaluación. En este caso, si fuese admitida la internación, debe cumplirse con los plazos y modalidades establecidos en la legislación especial. Las fuerzas de seguridad y servicios públicos de salud deben prestar auxilio inmediato."

Como medida de prevención se contempla el traslado de una persona (ej: posible demente) a un centro de salud, para su evaluación y eventual internación. Debe tratarse de una persona cuyo estado no admita demoras por existir riesgo cierto e inminente de causar daños a sí mismo o a terceros.

El Código de Vélez (art. 482) facultaba a la autoridad policial a disponer la internación (dando inmediata cuenta al juez) de las personas que por padecer enfermedades mentales o ser alcohólicos crónicos o toxicómanos pudieran dañar su salud o la de terceros o afectar la tranquilidad pública. La internación sólo podía ordenarse previo dictamen del médico oficial y debía darse inmediata cuenta al juez.

El art. 42 autoriza a la "autoridad pública" a ordenar el traslado. El término "autoridad pública" es amplio, y comprensivo no sólo de la policía o fuerzas de

seguridad, sino también de cualquier funcionario público. Dada la amplitud del término, la norma aclara que "las fuerzas de seguridad y servicios públicos de salud deben prestar auxilio inmediato".

El traslado es al sólo efecto de la evaluación. Si en el centro de salud se considera procedente la internación se le debe dar aviso al juez para el control de la misma.

Actos de la persona declarada incapaz o con capacidad restringida.-

• Actos posteriores a la inscripción de la sentencia.- Los actos de la persona incapaz o con capacidad restringida, que contrarían lo dispuesto en la sentencia, realizados con posterioridad a su inscripción en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, son nulos (conf. art. 44).

• Actos anteriores a la inscripción (conf. art. 45).- Los actos realizados con anterioridad a la inscripción son válidos. Sin embargo, pueden ser declarados nulos, si perjudican a la persona incapaz o con capacidad restringida, y se cumple alguno de los siguientes extremos:

- a) la enfermedad mental era ostensible a la época de la celebración del acto;
- b) quien contrató con él era de mala fe;
- c) el acto es a título gratuito.

• Persona fallecida.- Luego del fallecimiento de la persona protegida, los actos entre vivos anteriores a la inscripción de la sentencia no pueden impugnarse, excepto en los siguientes supuestos (conf. art. 46):

- que la enfermedad mental resulte del acto mismo;
- que la muerte haya acontecido después de promovida la acción para la declaración de incapacidad o capacidad restringida;
- que el acto sea a título gratuito; o
- que se pruebe que quien contrató con dicha persona actuó de mala fe (conf. art. 46).

La revisión de la sentencia declarativa.-

La sentencia que restringe la capacidad debe ser revisada por el juez en un plazo no superior a tres años, sobre la base de nuevos dictámenes interdisciplinarios y mediando la audiencia personal con el interesado. Es deber del Ministerio Público fiscalizar el cumplimiento efectivo de la revisión judicial. Pero, si la pide el interesado, la revisión puede tener lugar en cualquier momento (conf. art. 40).

Si una nueva sentencia deja sin efecto las restricciones se procede a la inmediata cancelación registral (conf. arts. 39, 40 y 47).

Cese de la incapacidad y de las restricciones a la capacidad.-

El art. 47 del nuevo Código Civil y Comercial regula el procedimiento para que el juez haga cesar la incapacidad o las restricciones a la capacidad de la persona:

Art. 47.- "Procedimiento para el cese. El cese de la incapacidad o de la restricción a la capacidad debe decretarse por el juez que la declaró, previo examen de un equipo interdisciplinario integrado conforme a las pautas del artículo 37, que dictamine sobre el restablecimiento de la persona.

Si el restablecimiento no es total, el juez puede ampliar la nómina de actos que la persona puede realizar por sí o con la asistencia de su curador o apoyo."

Si desaparecen o se modifican las causas que permitieron decretar la declaración de incapacidad o de restricciones a la capacidad se debe promover un nuevo proceso, solicitando la rehabilitación o cese de dichas restricciones.

Se pide ante el mismo juez que decretó las restricciones. Lo pueden solicitar:

- los legitimados en el art. 33;
- el curador de la persona; o
- quienes hayan sido designados para brindar asistencia o apoyo a la persona.

Antes de decidir sobre el cese de las restricciones es necesario un nuevo examen interdisciplinario, que dictamine sobre el restablecimiento de la persona.

Ante el pedido, el juez puede:

a) Mantener las restricciones (ej: mantiene la declaración de incapacidad o de capacidad restringida);

b) Modificar las restricciones (ampliarlas o disminuirlas): así, si el restablecimiento no es total, el juez puede ampliar la nómina de actos que la persona puede realizar por sí o con la asistencia de su curador o apoyo.

En el caso de que la persona tenga declaración de incapacidad, el juez puede declararlo con "capacidad restringida" indicando cuales son las restricciones y el sistema de apoyos necesarios.

c) Hacer cesar totalmente las restricciones.

INHABILITADOS. LOS PRÓDIGOS.

En el Código de Vélez los inhabilitados estaban previstos en el art. 152 bis, y comprendía a: a) los ebrios habituales y los toxicómanos; b) los disminuidos en sus facultades, que no llegaban a ser dementes; y c) los pródigos.

En el nuevo Código Civil y Comercial, la figura de los "inhabilitados" queda limitada a los pródigos, y su finalidad es la protección del patrimonio familiar (arts. 48 a 50).

Art. 48.- "Pródigos. Pueden ser inhabilitados quienes por la prodigalidad en la gestión de sus bienes expongan a su cónyuge, conviviente o a sus hijos menores de edad o con discapacidad a la pérdida del patrimonio. A estos fines, se considera persona con discapacidad, a toda persona que padece una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implica desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. La acción sólo corresponde al cónyuge, conviviente y a los ascendientes y descendientes."

Pródigos.-

El pródigo es la persona que, imprudentemente, dilapida, gasta alocadamente sus bienes, exponiéndose (él y su familia) a la pérdida del patrimonio y, en consecuencia, a la miseria. La inhabilitación del pródigo tiene como fin la protección de la familia y del patrimonio familiar.

Para que proceda la inhabilitación del pródigo es necesario:

a) Que tenga cónyuge o conviviente; o hijos menores de edad; o hijos con discapacidad. A estos fines, se considera "persona con discapacidad" a toda persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral.

b) Que por sus actos de prodigalidad los expusiere a la pérdida del patrimonio.

c) Que la acción sea interpuesta por el cónyuge; el conviviente; los ascendientes o descendientes.

Como vemos, los legitimados para interponer la acción no coinciden con las personas protegidas por la norma (cónyuge/conviviente o hijos menores o con discapacidad) ya que se agrega a los ascendientes, y con relación a los descendientes no se distingue la edad o discapacidad. Además no se le reconoce legitimación para pedir la inhabilitación al propio posible pródigo.

Efectos de la inhabilitación.-

El art. 49 del nuevo Código Civil y Comercial regula los efectos de la inhabilitación del pródigo:

Art. 49.- "Efectos. La declaración de inhabilitación importa la designación de un apoyo, que debe asistir al inhabilitado en el otorgamiento de actos de disposición entre vivos y en los demás actos que el juez fije en la sentencia."

En el Código de Vélez, al inhabilitado se le designaba un curador.

En el nuevo Código Civil y Comercial al pródigo se le designa un apoyo para que lo asista en el otorgamiento de actos de disposición entre vivos y en los demás actos que el juez fije en la sentencia. El designado como "apoyo" no reemplaza ni representa al pródigo, sólo lo asiste y lo asesora en la realización de esos actos.

La inhabilitación deberá ser inscripta en el Registro, momento a partir del cual los actos del inhabilitado contrariando la sentencia serán considerados nulos.

Cabe plantearse, ¿el pródigo es capaz o incapaz? Técnicamente, el pródigo es una persona capaz, que puede administrar sus bienes y en general realizar todo tipo de actos, pero a la cual el juez (en la sentencia) le restringe la capacidad para ejercer por sí actos de disposición entre vivos u otros actos que el juez considere que requieren apoyo para realizarlos. A estos efectos, deberá contar con un apoyo que lo asista en la realización de dichos actos. No se le prohíben los actos de

última voluntad ni tampoco los actos de administración (salvo los que el juez mencione en la sentencia).

Cese de la inhabilitación.-

Para hacer cesar la inhabilitación será necesario que el peticionante (sea el propio inhabilitado, los familiares, el apoyo, el Ministerio Público, etc.) lo solicite ante el mismo juez que declaró la inhabilitación, y aporte un nuevo examen interdisciplinario que dictamine sobre el restablecimiento de la persona.

Ante el pedido, el juez puede (conf. art. 50):

- mantener las restricciones; o
- ampliar la nómina de actos que la persona puede realizar por sí o con apoyo; o
- resolver que está restablecido y que tiene plena capacidad.

CAPACIDAD

Concepto

La "capacidad" es la aptitud de la persona, por un lado, para ser titular de derechos y deberes jurídicos, y por otro, para ejercer por sí mismo los derechos o el cumplimiento de los deberes.

Tipos de Capacidad

- 1) Capacidad de derecho: aptitud para ser titular de un derecho o de un deber jurídico. → Art. 22
- 2) Capacidad de ejercicio: aptitud para ejercer por sí misma sus derechos o sus deberes. → Art. 23

Estas capacidades tienen limitaciones que se denominan

INCAPACIDADES

INCAPACIDAD DE DERECHO

Concepto

Se habla de incapacidad de derecho, cuando la ley prohíbe a una persona ser titular de un derecho. Las personas humanas son capaces de derecho, y sólo dejan de serlo cuando la ley se los prohíbe.

- La incapacidad de derecho está fundada en razones morales.
- Cuando un incapaz de derecho celebra el acto que le está prohibido, la ley considera nulo dicho acto.
- La incapacidad de derecho no puede ser salvada por medio de un representante.
- La incapacidad de derecho nunca es absoluta, siempre es relativa (la prohibición de ser titular de un derecho estará siempre referida a un derecho determinado, pero nunca a todos los derechos).

Excepcionalidad

Los casos de incapacidad de derecho son excepcionales, están establecidos específicamente por la ley y se los debe interpretar restrictivamente.

Esto significa que:

- no se los puede extender a casos no previstos; y
- en caso de duda debe estarse a favor de la capacidad.

Los casos de incapacidad de derecho están dispersos a través de todo el Código Civil y Comercial.
Ej: Art. 1002 → "Inhabilitades especiales"

INCAPACIDAD DE EJERCICIO

Concepto

La capacidad de ejercicio es la aptitud para ejercer por sí mismo los derechos. Pero, en ciertos casos, la ley limita esa capacidad (incapacidad de hecho o de ejercicio) con el fin de proteger al incapaz y no le permite ejercer por sí mismo sus derechos; sólo le permite actuar por medio de su representante legal (padres, tutor, curador, etc.).

Art. 24

Son incapaces de ejercicio

- la persona por nacer;
- la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente con el alcance dispuesto en la Sección 2ª de este Capítulo (los menores de edad);
- la persona declarada incapaz por sentencia judicial, en la extensión dispuesta en esa decisión.

A PERSONA POR NACER

Son las personas que aún no han nacido y cuya situación va desde la concepción hasta el parto.

Son "personas" y pueden adquirir derechos, pero dicha personalidad está sujeta a una condición: que nazcan con vida.

Las personas por nacer pueden adquirir derechos; pero no pueden ejercerlos por sí mismos. Esta incapacidad se suple mediante una representación legal, que recae sobre sus padres.

- Si se nace con vida, el nacido adquiere irrevocablemente los derechos.
- Si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió, y pierde retroactivamente los derechos que había adquirido bajo condición.

B MENORES DE EDAD

En el nuevo Código Civil y Comercial

- **Menor de edad:** es la persona que no ha cumplido 18 años.
- **Adolescente:** es el menor que cumplió los 13 años, es decir se es adolescente desde los 13 a los 18 años (conf. art. 25).

Se establece un sistema de adquisición de la capacidad de ejercicio en forma **gradual y flexible** que toma en cuenta la **"edad y grado de madurez"** del menor.

Así se puede diferenciar:

- Menores que no cuentan con edad y grado de madurez suficiente:** no pueden ejercer por sí mismos sus derechos, y sólo pueden hacerlo por medio de sus representantes legales (los padres o tutores, según el caso).
- Menores que cuentan con edad y grado de madurez suficiente:** podrán ejercer por sí mismos los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. Ejemplos: en materia de apellido puede pedir agregarse el apellido del otro progenitor (art. 64); etc.

En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con **asistencia letrada**.

Todo menor tiene derecho a:

- ser oído en los procesos judiciales que le conciernan; y
- participar en las decisiones sobre su persona.

La decisión del adolescente en los tratamientos médicos

- **Adolescente entre los 13 y 16 años**

- **Adolescente a partir de los 16 años**

Es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo.

- Respecto a **tratamientos no invasivos**, ni que comprometan su salud o provoquen un riesgo grave para su vida o integridad física, se presume que goza de aptitud para decidir por sí.
- Respecto a **tratamientos invasivos** que comprometan su salud o esté en riesgo su integridad o vida, el adolescente debe prestar su consentimiento, con la asistencia de sus progenitores.

Pequeños contratos

los "pequeños contratos" celebrados cotidianamente por los menores son **válidos**, porque se presumen realizados con la conformidad de los progenitores.

Menor de edad con título profesional habilitante

- Puede ejercer su profesión por cuenta propia sin previa autorización.
- Tiene la administración y disposición de los bienes que adquiere con el producto de su profesión y puede estar en juicio por cuestiones vinculadas a ella.

Mayoría de edad y Emancipación

Son dos institutos que permiten que la persona no tenga restringida su capacidad.

• **Mayoría de edad**

¿Cuándo se es mayor de edad? Al cumplir 18 años.

¿Y qué efectos produce? La persona pasa a ser plenamente capaz y está habilitada para el ejercicio de todos los actos de la vida civil.

• **Emancipación por matrimonio**

La emancipación es la institución en virtud de la cual los menores pueden adquirir plena capacidad, aún antes de llegar a la mayoría de edad. La emancipación por matrimonio se produce cuando el menor de edad se casa.

- Si tiene menos de 16 años necesita autorización judicial / • Si tiene más de 16 años le basta con la autorización de sus representantes legales.

Si se casa **sin autorización**, la emancipación subsiste para el cónyuge de buena fe. Al emanciparse, **deja de estar** bajo la **"responsabilidad parental"** de los padres.

• **Actos prohibidos al emancipado** → Art. 28

• **Actos del emancipado sujetos a autorización** → Art. 29

¿Qué sucede si el matrimonio se anula? La emancipación subsiste para el cónyuge de buena fe.

INCAPACIDAD DE EJERCICIO

C PERSONAS CON CAPACIDAD RESTRINGIDA Y PERSONAS CON INCAPACIDAD

El juez puede restringir la capacidad de ejercicio de una persona (mayor de 13 años) que por sufrir una adicción o alteración mental, corre peligro de causar un daño a su persona o a sus bienes.

Reglas generales para ambos casos

Art. 31

Según el padecimiento, puede declararlo:

- "con **capacidad restringida**" para algunos actos, o
- persona "**con incapacidad**".

- La capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume.
- Las limitaciones a la capacidad son de carácter **excepcional** y se imponen en **beneficio** de la persona.
- La intervención estatal tiene carácter **interdisciplinario** (en el tratamiento y en el proceso judicial).
- La persona tiene derecho a **recibir información**.
- La persona tiene derecho a **participar en el proceso judicial** con asistencia letrada.
- Deben priorizarse las alternativas terapéuticas **menos restrictivas** de los derechos y libertades.

Persona con capacidad restringida

Es aquella persona capaz a la cual (por padecer una adicción o alteración mental permanente o prolongada, de suficiente gravedad, y que corre peligro de causar un daño a su persona o a sus bienes) el juez le restringe la capacidad para ejercer por sí mismo **determinados actos** y le designa los **apoyos necesarios**.

La sentencia que declare la capacidad restringida debe determinar la **extensión y alcance** de la restricción, y especificar las **funciones y actos** que se limitan, procurando que la afectación de la autonomía personal sea la menor posible.

Por "**apoyo**" debe entenderse cualquier medida de carácter judicial o extrajudicial que facilite, a quien lo necesite, la toma de decisiones para dirigir su persona, administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos en general.

Persona con incapacidad

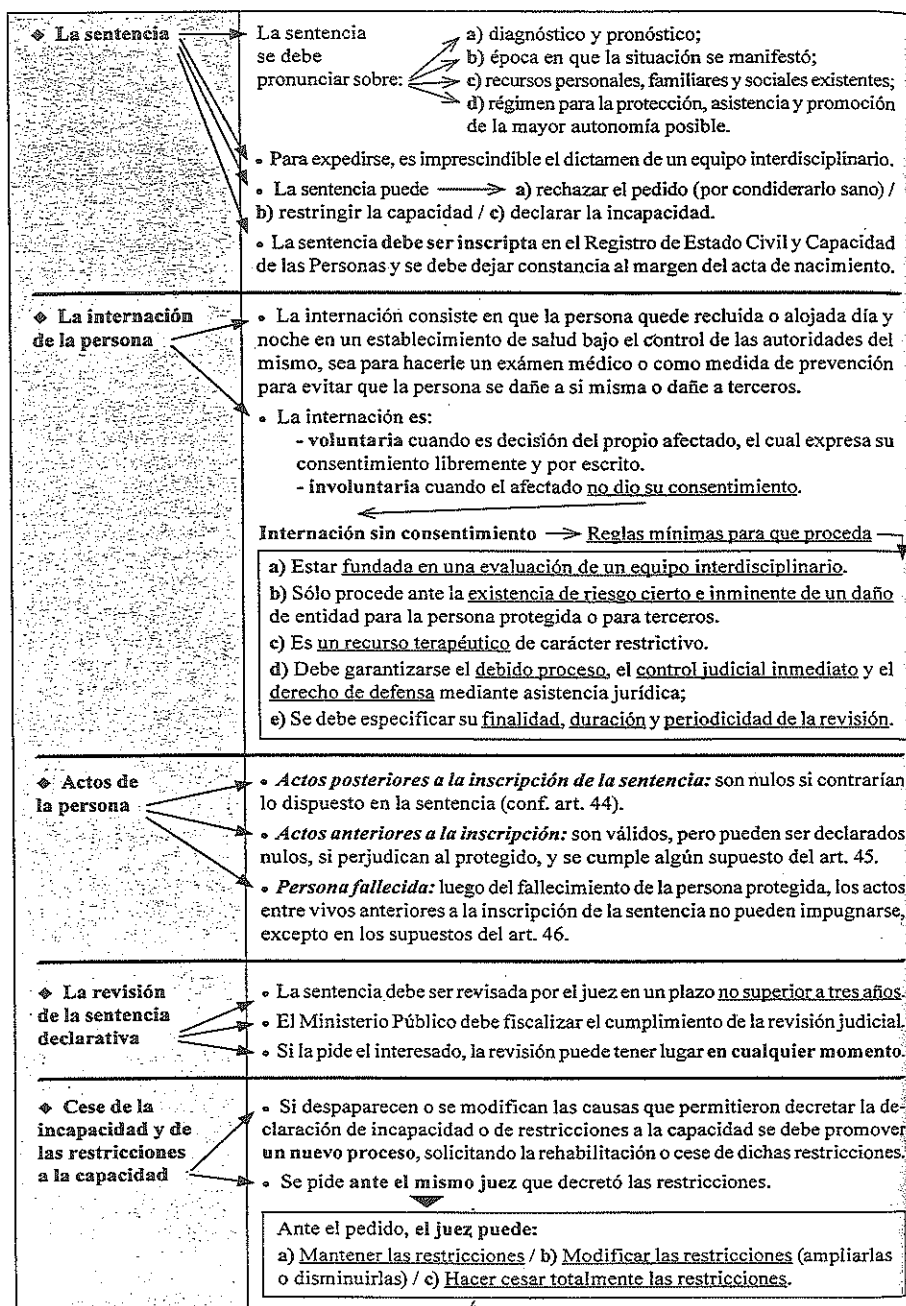
Para que el juez pueda declarar la incapacidad de la persona → **2 requisitos**

- Que la persona esté absolutamente imposibilitada de interactuar con su entorno y de expresar su voluntad; y
- Que el sistema de apoyos resulte ineficaz para la persona.

El juez puede declarar su incapacidad y designarle un **curador**. Se trata de un incapaz absoluto.

♦ Solicitud de la declaración (Art. 33)	¿Quiénes pueden solicitar la declaración de incapacidad o de capacidad restringida? Esta enumeración en principio es taxativa.	- el propio interesado; - el cónyuge no separado de hecho y el conviviente mientras la convivencia no haya cesado; - los parientes dentro del cuarto grado; si fueran por afinidad, dentro del segundo grado; - el Ministerio Público.
♦ El proceso de declaración	- El proceso de declaración de incapacidad o capacidad restringida puede ser iniciado por los legitimados del art. 33, aportando toda clase de pruebas. Incluso el propio interesado puede iniciarlo. - Durante el proceso, el juez debe ordenar las medidas cautelares necesarias para garantizar los derechos patrimoniales y personales de la persona (ej: inhibiciones, inventario, etc), indicando qué actos requieren la asistencia de uno o varios apoyos, y cuáles la representación de un curador. - Antes de dictar resolución alguna el juez tiene la obligación de tomar contacto con la persona, debiendo entrevistar personalmente al interesado (lo hace comparecer al juzgado, o el juez se traslada al lugar donde esté el interesado). El Ministerio Público y, al menos, un letrado que preste asistencia al interesado, deben estar presentes en las audiencias.	

INCAPACIDAD DE EJERCICIO



INHABILITADOS / LOS PRÓDIGOS

- ♦ En el nuevo Código Civil y Comercial, la figura de los "inhabilitados" queda limitada a los pródigos.
- ♦ Su finalidad es la protección del patrimonio familiar (arts. 48 a 50).

Art. 48

"Pueden ser inhabilitados quienes por la prodigalidad en la gestión de sus bienes expongan a su cónyuge, conviviente o a sus hijos menores de edad o con discapacidad a la pérdida del patrimonio..."

Pródigos

El pródigo es la persona que, imprudentemente, dilapida, gasta alocadamente sus bienes, exponiéndose (él y su familia) a la pérdida del patrimonio y, en consecuencia, a la miseria.

Requisitos para que proceda la inhabilitación

- a) Que tenga cónyuge o conviviente; o hijos menores de edad; o hijos con discapacidad.
- b) Que por sus actos de prodigalidad los expusiere a la pérdida del patrimonio.
- c) Que la acción sea interpuesta por el cónyuge; el conviviente; ascendientes o descendientes.

La inhabilitación del pródigo tiene como fin la protección de la familia y del patrimonio familiar.

Efectos de la inhabilitación

- Al pródigo se le designa un apoyo para que lo asista en el otorgamiento de actos de disposición entre vivos y en los demás actos que el juez fije en la sentencia.
- El designado como "apoyo" no reemplaza ni representa al pródigo, sólo lo asiste y lo asesora en la realización de esos actos.
- La inhabilitación deberá ser inscripta en el Registro. A partir de ese momento, los actos del inhabilitado contrariando la sentencia serán considerados nulos.
- El pródigo es una persona capaz, que puede administrar sus bienes y en general realizar todo tipo de actos, pero a la cual el juez (en la sentencia) le restringe la capacidad para ejercer por sí actos de disposición entre vivos u otros actos que el juez considere que requieren apoyo para realizarlos.

Cese de la inhabilitación

- Para hacer cesar la inhabilitación será necesario que:
 - el peticionante (sea el propio inhabilitado, los familiares, el apoyo, el Ministerio Público, etc) lo solicite ante el mismo juez que declaró la inhabilitación; y
 - aporte un nuevo examen interdisciplinario que dictamine sobre el restablecimiento de la persona.
- Ante el pedido, el juez puede
 - a) mantener las restricciones; o
 - b) ampliar la nómina de actos que la persona puede realizar por sí o con apoyo; o
 - c) resolver que está restablecido y que tiene plena capacidad.

CAPÍTULO VIII

LOS DERECHOS SUBJETIVOS

DERECHOS Y ACTOS PERSONALÍSIMOS

LOS DERECHOS SUBJETIVOS

Como habíamos adelantado, el Derecho, por un lado, se presenta como un conjunto de normas, de reglas, que regulan la conducta humana en la sociedad, obligando al hombre a actuar de una manera determinada (*"Derecho Objetivo"*); pero por otro lado, el derecho otorga facultades o poderes al hombre, para que pueda lograr sus fines (*"Derecho Subjetivo"*).

Concepto.-

Los derechos subjetivos son prerrogativas, facultades, que las normas jurídicas reconocen a las personas, para que puedan satisfacer sus necesidades y exigir de las demás personas un determinado comportamiento.

Llambías define al derecho subjetivo como la *"facultad reconocida por el ordenamiento jurídico, para exigir de las demás personas un determinado comportamiento"*.

Frente a todo derecho subjetivo, existe, correlativamente, un deber jurídico, un deber subjetivo. Por ejemplo, el acreedor tiene el derecho subjetivo de exigir el pago, y el deudor, el deber subjetivo de pagar; el propietario de un bien tiene derecho a gozar de él, en tanto que los demás miembros de la comunidad tienen el deber subjetivo (u obligación) de no turbarlo o de no impedirle dicho goce.

NATURALEZA JURÍDICA DE LOS DERECHOS SUBJETIVOS. DISTINTAS TEORÍAS.-

1) Teorías que niegan los derechos subjetivos.-

a) Kelsen, sostiene que el derecho sólo puede imponer a las personas un determinado deber jurídico. Para él no existen los derechos subjetivos: sólo existen los deberes jurídicos; y cuando se produce un hecho que viola la ley, el Estado concede fuerza al particular damnificado, para que se restablezca la norma violada. De esta forma, Kelsen equipara el derecho subjetivo con el derecho objetivo.

b) Duguit, sostiene que en la sociedad, el hombre debe someterse al ordenamiento jurídico de carácter objetivo, y cumplir con los deberes que dicho ordenamiento le impone, como así también con la función social que le corresponde. Según la concepción de Duguit, *"el hombre no tiene derechos subjetivos, sólo tiene deberes y funciones que debe cumplir"*.

2) Teorías que reconocen los derechos subjetivos.-

a) Para Savigny y Windscheid, el derecho subjetivo era "*un poder, una facultad atribuida a una voluntad*"; en otras palabras, solían decir que era "*un señorio del querer*".

b) Para Ihering, "*los derechos son intereses jurídicamente protegidos*". Ihering toma en cuenta el interés o utilidad que el derecho subjetivo otorga al hombre, los intereses que el derecho protege.

Cuestionamiento.- A ambas teorías se le critica que conceden los derechos subjetivos tomando en cuenta al hombre individualmente (su voluntad o su interés), y dejan de lado todo lo que se refiera a la sociedad en conjunto y a la función social de los derechos subjetivos.

c) **Posición ecléctica:** toma algo de ambas posturas y sostiene que el derecho subjetivo es un poder conferido a la persona para que pueda satisfacer sus necesidades y exigir a los demás un determinado comportamiento. La mayor parte de la doctrina, reconoce la existencia de los derechos subjetivos y se enrola en esta posición.

CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS SUBJETIVOS

Tradicionalmente, según tengan o no valor económico, los derechos subjetivos pueden clasificarse en: patrimoniales y extrapatrimoniales.

1) Derechos Patrimoniales.-

Los Derechos Patrimoniales son aquellos derechos susceptibles de tener un valor económico (son apreciables en dinero), e integran el patrimonio. Se clasifican en: a) Derechos Reales; b) Derechos Personales (o creditorios); y c) Derechos Intelectuales.

a) **Derechos Reales:** son los que otorgan facultad o poder sobre una cosa, sea para disponer de ella, usarla, aprovechar sus frutos, etc. Están tratados en el *Libro Cuarto* del nuevo Código Civil y Comercial.

Son derechos reales (conf. art. 1887): a) el dominio; b) el condominio; c) la propiedad horizontal; d) los conjuntos inmobiliarios; e) el tiempo compartido; f) el cementerio privado; g) la superficie; h) el usufructo; i) el uso; j) la habitación; k) la servidumbre; l) la hipoteca; m) la anticresis; n) la prenda.

Si bien la mayoría de estos "derechos reales" ya estaban regulados en el Código de Vélez, otros fueron incorporados por el nuevo Código Civil y Comercial, tal el caso de los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido, los cementerios privados y la superficie.

El derecho real se ejerce siempre sobre una cosa (ej: un campo, un departamento, un auto). La cosa puede ser *propia* o *ajena*, distinguiéndose entonces entre: 1) Derechos reales *sobre cosa propia* (ej: dominio, condominio y superficie forestal); y 2) Derechos reales *sobre cosa ajena* (ej: los demás derechos reales).

b) **Derechos Personales** (o creditorios): son aquellos derechos que otorgan a su titular (*acreedor*) la facultad de exigir de otra persona (*deudor*) el cumplimiento de una determinada obligación (de dar, de hacer, o de no hacer).

Los derechos personales crean un vínculo jurídico, no entre la persona y la cosa (como sucede en los derechos reales), sino entre personas determinadas. Este vínculo jurídico es el que se denomina obligación, y constituye para el sujeto activo, un crédito, y para el sujeto pasivo, una deuda. Están tratados en el *Libro Tercero* del nuevo Código Civil y Comercial.

c) **Derechos Intelectuales:** son aquellos derechos que corresponden al autor de una obra artística, literaria o científica, para explotar o disponer de la misma, y para impedir que otros la copien o reproduzcan. Los derechos intelectuales integran el patrimonio. Están regulados por la Ley 11.723.

Naturaleza jurídica: se los asimila a los derechos reales y, dentro de éstos, a la propiedad o dominio. Tanto la Constitución Nacional (art. 17) como la Ley 11.723, tratan al titular del derecho intelectual asimilándolo al "propietario".

2) Derechos Extrapatrimoniales.-

Los Derechos Extrapatrimoniales son aquellos derechos que no son susceptibles de apreciación económica, y no integran el patrimonio. Son derechos extrapatrimoniales:

a) los **Derechos de Familia:** son facultades concedidas a determinadas personas, en razón de un vínculo familiar. Reciben el nombre de "potestades". Ejemplo: la "responsabilidad parental" (a la que antes se le llamaba "patria potestad").

b) los **Derechos Personalísimos:** son derechos que protegen la personalidad humana en sus distintos aspectos. Ejemplos: derecho a la vida, a la integridad física, al honor, a la libertad, etc.

DERECHOS PERSONALÍSIMOS

Concepto.-

Los derechos personalísimos son aquellos derechos extrapatrimoniales cuyo fin consiste en proteger la personalidad humana en sus distintos aspectos. Son libertades y derechos propios del hombre, sin los cuales no sería posible su existencia como tal. Ejemplos de estos derechos son: el derecho a la vida, a la integridad física, al honor, a la libertad, a la intimidad y a la privacidad, etc.

Regulación normativa.-

En nuestra legislación, la protección de estos derechos no se había realizado en forma ordenada e integral (que sería lo correcto) sino en forma dispersa a través de diferentes leyes que tutelaron directa o indirectamente algún derecho personalísimo en particular. Así, por ejemplo, la Ley de Propiedad Intelectual (Ley 11.723) que

en sus artículos 31 a 35 protegió el derecho a la imagen; la Ley 18.248 que reguló el derecho al nombre; la Ley 21.173 que incorporó al Código Civil el artículo 1071 bis protegiendo el derecho a la intimidad; la Ley 23.592 que protege de actos discriminatorios, etc.

Con la reforma constitucional de 1994 mucho se avanzó en la protección de los derechos personalísimos y en general de los derechos humanos al incorporar a nuestra legislación diversos tratados internacionales con jerarquía constitucional y que implican una clara protección de diversos derechos de la persona.

Ejemplos: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio, Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, etc.

En los últimos años, se fueron dictando leyes muy vinculadas a los derechos humanos y personalísimos, tal el caso de la Ley de Transplantes de Organos (Ley 24.193), la Ley de Protección de los Datos Personales (Ley 25.326), la Ley de Derechos del Paciente (Ley 26.529), etc.

Los Derechos Personalísimos en el nuevo Código Civil y Comercial.-

El nuevo Código Civil y Comercial regula de manera integral y sistemática la materia de los derechos de la personalidad (en el Capítulo 3, del Título I, del Libro Primero, arts. 51 a 61) destacándose en esta regulación lo siguiente:

- El Capítulo se inicia con una declaración acerca de la dignidad de la persona humana y reconoce expresamente los derechos a la intimidad, honor, imagen e identidad.
- Regula el derecho a disponer del propio cuerpo con limitaciones fundadas en principios bioéticos.
- Se prohíben las prácticas destinadas a alterar la constitución genética de la descendencia (excepto las que tiendan a prevenir enfermedades genéticas o la predisposición a ellas).
- Se fijan requisitos claros para la investigación médica experimental con seres humanos.
- Se define el "consentimiento informado", necesario para actos médicos e investigaciones de salud.
- Se reitera el principio básico en materia de bioética de que el consentimiento es libremente revocable.
- Se prevén las "directivas médicas anticipadas".
- Se establece un régimen sobre la disposición del cadáver, siguiendo los criterios de la jurisprudencia.

INVIOABILIDAD DE LA PERSONA HUMANA. DIGNIDAD.

Art. 51.- "Invioabilidad de la persona humana. La persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad."

No hay una definición de los derechos personalísimos, pero esta declaración de que la persona humana es inviolable y que debe ser respetada en su dignidad significa que todo ser humano por el solo hecho de serlo tiene derecho a que se le reconozcan una serie de derechos relacionados a su dignidad física (vida y salud), a su dignidad espiritual (imagen, intimidad, identidad, honor, reputación, etc.) y a su libertad.

Art. 52.- "Afectaciones a la dignidad. La persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos, conforme a lo dispuesto en el Libro Tercero, Título V, Capítulo 1."

La norma protege los derechos de la dignidad espiritual que se señalan: imagen, intimidad, identidad, honor o reputación; pero la expresión "o que de cualquier modo" hace que la enumeración no sea taxativa. La agresión a estos derechos permite que el agredido reclame la prevención del ataque o la reparación de los daños sufridos si el ataque ya se produjo.

Derecho a la imagen y a la voz.-

La imagen es la representación física de la persona (ej: una foto, un film). La Ley 11.723 (sobre propiedad intelectual) en su art. 31 protege la imagen, disponiendo que no se podrá publicar o poner en el comercio el retrato fotográfico de una persona, salvo que exista autorización de ella o de sus descendientes. La prohibición no existe si la publicación del retrato tiene un fin científico, didáctico, cultural o de interés público.

El nuevo Código Civil y Comercial se refiere al derecho a la imagen en el art. 53, ampliando el régimen de la Ley 11.723, ya que se refiere a "captar o reproducir" y no sólo a la imagen sino también a la voz de una persona. Para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona siempre se requiere su consentimiento, salvo en los casos que indica la norma. La protección post mortem se extiende por 20 años.

Art. 53.- "Derecho a la imagen. Para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona, de cualquier modo que se haga, es necesario su consentimiento, excepto en los siguientes casos:

- a) *que la persona participe en actos públicos;*
- b) *que exista un interés científico, cultural o educacional prioritario, y se tomen las precauciones suficientes para evitar un daño innecesario;*
- c) *que se trate del ejercicio regular del derecho de informar sobre acontecimientos de interés general..."*

• Protección post mortem por 20 años.- En caso de personas fallecidas pueden prestar el consentimiento sus herederos o el designado por el causante en una dis-

posición de última voluntad. Si hay desacuerdo entre herederos de un mismo grado, resuelve el juez. Pasados 20 años desde la muerte, la reproducción no ofensiva es libre (art. 53, último párrafo).

Derecho a la intimidad.-

Es el derecho a gozar de vida privada, sin que nadie se entrometa o de a publicidad los hechos que la conforman, salvo que exista un interés público en hacerlo. La Constitución Nacional, en el art. 19 establece que:

"Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados..."

El Código Civil de Vélez protegía el derecho a la intimidad en el art. 1071 bis.

El nuevo Código Civil y Comercial en general reproduce esa norma en el art. 1770, pero además (en el art. 52) hace referencia a la "intimidad personal o familiar".

Art. 1770.- "Protección de la vida privada. El que arbitrariamente se entromete en la vida ajena y publica retratos, difunde correspondencia, mortifica a otros en sus costumbres o sentimientos, o perturba de cualquier modo su intimidad, debe ser obligado a cesar en tales actividades, si antes no cesaron, y a pagar una indemnización que debe fijar el juez, de acuerdo con las circunstancias. Además, a pedido del agraviado, puede ordenarse la publicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar, si esta medida es procedente para una adecuada reparación."

En el caso *Ponzetti de Balbín c/ Editorial Atlántida, S.A.* se consideró vulnerado el derecho a la intimidad por la publicación sin autorización de una foto del Dr. Balbín cuando estaba internado en terapia intensiva, sobre la base de lo dispuesto por el art. 1071 bis del Código de Vélez.

El uso o la divulgación sin autorización de los datos personales de una persona puede constituir violación del derecho a la intimidad de la persona, en especial cuando se trata de datos referidos a sus ideas religiosas, ideas políticas, conducta sexual, enfermedades padecidas, etc.

Para la reparación resulta aplicable lo dispuesto por el art. 1770 del nuevo Código Civil y Comercial según el caso: cese del acto que viola la intimidad, indemnización, y (si corresponde) publicación de la sentencia en un diario.

Con la reforma constitucional de 1994, se incorporó en el texto de la Constitución Nacional (en el art. 43, tercer párr.) el llamado "*Habeas data*", que es un instituto procesal, por el cual una persona puede acceder a un registro o banco de datos, sea público o privado, para controlar su veracidad, pudiendo llegar a suprimir la información si fuera falsa, o a evitar que sea utilizada con fines distintos a los de creación del almacenamiento o con fines discriminatorios. Este derecho fue reglamentado con la sanción de la Ley 25.326 en el año 2000.

Derecho a la vida.-

Nuestro ordenamiento jurídico protege la vida humana, no sólo desde el nacimiento, sino también desde que el individuo está concebido. Así es que el Código Penal castiga el homicidio, el aborto y cualquier otro atentado contra la vida ajena.

Esta protección también se nota en el nuevo Código Civil y Comercial, por ejemplo, en el art. 1741 al disponer que si de un hecho resulta la muerte están legitimados para reclamar la indemnización los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivían con el fallecido.

En algunas legislaciones especiales, como la del Trabajo, la indemnización por muerte es tarifada.

• **Eutanasia.**- Una cuestión importante con relación al derecho a la vida es la de la eutanasia, consistente en provocar la muerte de quien padece grandes sufrimientos (por ejemplo, por enfermedades dolorosas, terminales e incurables) para evitarle dichos sufrimientos.

En algunos países se admite la eutanasia cuando los tratamientos médicos probablemente carecen de eficacia y sólo sirven para prolongar la vida y los sufrimientos. En Argentina, la eutanasia no está autorizada, por lo cual quien ocasione la muerte de otro aunque sea a pedido del paciente y para evitarle sufrimientos incurre en el delito de homicidio.

El nuevo Código Civil y Comercial, en el art. 56, prohíbe los actos de disposición sobre el propio cuerpo; y en el art. 60 dispone que "las directivas que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas se tienen por no escritas".

Derecho a la integridad física.-

La integridad física está protegida por el ordenamiento jurídico, así ocurre en el Código Penal al tipificar el delito de lesiones, o en el Código Civil y Comercial, cuando se fijan las indemnizaciones en base a los daños sufridos por las lesiones.

• **Operaciones quirúrgicas.**- Las operaciones quirúrgicas implican lesiones sobre la integridad física del paciente, pero ellas estarán plenamente justificadas cuando sean realizadas por un profesional médico y se haya contado con el consentimiento informado del paciente o de sus parientes para realizarla.

El paciente es quien tiene derecho sobre su propio cuerpo, por lo cual los cirujanos para someterlo a una cirugía necesitan la autorización del mismo. La falta de consentimiento sólo puede justificarse si existe un estado de necesidad, es decir, si se realiza la operación para evitar un mal mayor para el paciente.

Las cirugías estéticas exigen inevitablemente el consentimiento del paciente ya que en ellas no puede invocarse un estado de necesidad. La jurisprudencia ha consagrado la reparación económica a favor de quien sea víctima de un daño a su integridad física, tal el caso de los daños estéticos.

• La integridad física en el nuevo Código Civil y Comercial. - El nuevo Código Civil y Comercial trae una serie de normas que protegen la integridad física en diversas situaciones:

1) A través del art. 56 se prohíben los actos de disposición sobre el propio cuerpo (ej: automutilarse) cuando causen una disminución permanente de su integridad, o sean contrarios a la ley, la moral y las buenas costumbres, salvo que sean requeridos para el mejoramiento de la salud propia y excepcionalmente de otra persona (ej: le extraen un riñón para implantárselo a su padre), de conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. Para los actos no comprendidos en la prohibición se requiere el consentimiento de la persona; dicho consentimiento no puede ser suplido y es libremente revocable.

2) Para la ablación de órganos a ser implantados a otra persona, el art. 56 remite a la legislación especial (Ley 24.193 de Transplantes de Organos y Tejidos).

3) No es exigible (conf. art. 54) el cumplimiento del contrato que tenga por objeto la realización de actos peligrosos para la vida o la integridad de una persona, salvo que correspondan a su actividad habitual y que se tomen medidas de prevención y seguridad adecuadas a las circunstancias (ej: trabaja de "doble de riesgo" en el cine).

4) En el art. 57 se prohíben las prácticas destinadas a producir alteración genética del embrión que se transmita a los descendientes (ej: modificación de genes para cambiar los caracteres físicos o raciales de los hijos). El art. 57 en su versión original, como excepción, permitía las prácticas genéticas cuando eran para prevenir enfermedades genéticas o la predisposición a ellas. La Comisión Bilateral eliminó esta excepción.

5) El art. 58 se refiere a los actos médicos e investigaciones sobre seres humanos (tratamientos, métodos de prevención, etc) cuya eficacia o seguridad no estén comprobadas; y exige para su realización una serie de requisitos, como ser: contar con el consentimiento previo (libre, escrito e informado) del paciente o persona que se sujeta a la investigación; que no implique para el participante riesgos y molestias desproporcionados en relación con los beneficios que se espera obtener de la investigación; asegurar al participante la atención médica pertinente, durante y finalizada la investigación; contar con la autorización previa del organismo público correspondiente, etc.

6) El art. 59 define el "consentimiento informado" para dichos actos médicos e investigaciones de la siguiente forma: "...es la declaración de voluntad expresada por el paciente, emitida luego de recibir información clara, precisa y adecuada, respecto a:

- a) su estado de salud;
- b) el procedimiento propuesto, con especificación de los objetivos perseguidos;
- c) los beneficios esperados del procedimiento;
- d) los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles;

e) la especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios en relación con el procedimiento propuesto;

f) las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los alternativos especificados;

g) en caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable, o cuando se encuentre en estado terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, el derecho a rechazar procedimientos quirúrgicos, de hidratación, alimentación, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital, cuando sean extraordinarios o desproporcionados en relación a las perspectivas de mejoría, o produzcan sufrimiento desmesurado, o tengan por único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible e incurable;

h) el derecho a recibir cuidados paliativos integrales en el proceso de atención de su enfermedad o padecimiento..."

7) Además, el art. 59 establece que *nadie puede ser sometido a exámenes o tratamientos clínicos o quirúrgicos sin su consentimiento libre e informado*, excepto disposición legal en contrario.

Si el paciente no está en condiciones físicas o psíquicas para expresar su voluntad al tiempo de la atención médica ni la ha expresado anticipadamente, el consentimiento puede ser otorgado por otros, como ser: el representante legal, el cónyuge, el conviviente, el pariente o el allegado que acompañe al paciente. En ausencia de todos ellos, el médico puede prescindir del consentimiento si su actuación es urgente y tiene por objeto evitar un mal grave al paciente.

8) El art. 60 dispone que la persona capaz puede dar directivas médicas anticipadas y también designar a las personas que han de expresar el consentimiento para los actos médicos y para ejercer su curatela. Las directivas que impliquen desarrollar prácticas eutanasias se tienen por no escritas. Esta declaración de voluntad puede ser libremente revocada en todo momento.

Derecho al honor.-

El Código Penal castiga la injuria, la calumnia y todo hecho contra el honor o el pudor ajeno.

El nuevo Código Civil y Comercial, por su parte, en el art. 52 protege genéricamente al honor al referirse a la "honra o reputación", y autoriza al agredido a reclamar la prevención y reparación de los daños. La misma solución (cese de la agresión o indemnización) surge del art. 1770.

Sobre la responsabilidad del que hace una acusación calumniosa, el art. 1771 establece algunas limitaciones:

Art. 1771.- "Acusación calumniosa. En los daños causados por una acusación calumniosa sólo se responde por dolo o culpa grave.

El denunciante o querellante responde por los daños derivados de la falsedad de la denuncia o de la querrela si se prueba que no tenía razones justificables para creer que el damnificado estaba implicado.

Derecho a la identidad y derecho a la identidad sexual.-

El derecho a la identidad es el derecho a gozar de un conjunto de atributos y calidades que determinan cómo es la persona y que la identifican e individualizan dentro de la sociedad. Podemos sintetizarlo diciendo que es el derecho que tiene toda persona "a ser uno mismo y no otro", derecho que se complementa con el reconocimiento y protección brindado por el Estado del mismo modo que lo hace con otros derechos personales, tales como la libertad, la vida o la integridad física.

El tema del derecho a la identidad nos lleva a referirnos a la cuestión del "*derecho a la identidad sexual*", los *trans* (transexuales, travestis, etc.), la "*reasignación de sexo*" y el "*cambio de nombre*", cuestiones que a raíz de la evolución de las ideas, del derecho y de la jurisprudencia están en boga estos últimos años.

Es sabido que cuando una persona nace se le asigna un sexo. Esta asignación legal o registral del sexo tradicionalmente se hace en base a los genitales del recién nacido. Efectivamente, al nacer, en base a la simple observación de los genitales del recién nacido, inmediatamente se le asigna un sexo (masculino o femenino) y en caso de duda sobre los genitales se recurre a establecer el sexo mediante la fórmula cromosómica (XY para el varón y XX para la mujer).

Pero la vida nos muestra que a veces esa asignación legal o registral del sexo no coincide con la realidad sexual del individuo. En algunos casos porque el cuerpo de la persona evoluciona en sentido contrario al sexo que se le asignó; en otros casos, no hay un cambio biológico pero sí un cambio psíquico y social, porque nos encontramos con un individuo que no se identifica con el sexo con el cual se lo registró, sino que por el contrario tiene un profundo sentimiento íntimo de pertenecer al otro sexo. En estos casos hay un quiebre de la identidad sexual del individuo que escapa a su voluntad, que afecta su salud y que no le permite disfrutar de un equilibrado bienestar general. Es el caso de los llamados *trans* o *transexuales*.

- *Trans*: es una denominación genérica que engloba a travestis, transexuales y transgéneros. Estas categorías, si bien se diferencian, no son excluyentes entre sí.

- *Transexual*: es la persona que tiene una identidad de género (sentimientos, actitudes, comportamientos, vestimenta, etc.) diferente a la que le fue asignada en su nacimiento (tal el caso de transexual masculino que biológicamente tiene cuerpo de hombre, pero se siente, comporta y vive como una mujer; o del transexual femenino, que si bien tiene cuerpo de mujer, se comporta y vive como un hombre). El *trans* siente un deseo incontrolable de vivir como miembro del otro sexo, adoptando el papel social acorde con su deseo y en muchos casos adquiriendo su aspecto físico mediante tratamientos con hormonas, implantes o intervenciones quirúrgicas sobre sus genitales.

- *Transgénero*: es la persona cuya identidad y/o expresión de género no se corresponde necesariamente con el género asignado al nacer, sin que esto implique la necesidad de cirugías de reasignación u otras intervenciones de modificación

corporal. En algunos casos, no se identifican con ninguno de los géneros convencionales (masculino y femenino).

- *Travesti*: en general, es la persona a la cual le fue asignada una identificación sexual masculina al nacer, pero que construye su identidad de género según diferentes expresiones de feminidad, incluyendo en muchos casos modificaciones corporales a partir de prótesis, hormonas, siliconas, etc., aunque, en general, sin una correspondencia femenina en lo genital.

Las personas *trans* (travestis o transexuales) tienen en sus documentos un nombre diferente de aquel por el que todo el mundo las conoce, y figuran inscriptas con una asignación de sexo o género (varón o mujer) que se contradice con su identidad. Sin dudas, esa contradicción entre su vida y lo que figura en registros y documentos les acarrea incontables inconvenientes en cualquier lugar donde les pidan documentos, ya sea viajar, inscribirse en una universidad o en un club, internarse, votar, etc.

Las personas *trans* hace años que vienen luchando por el derecho de ser quien realmente son, y en consecuencia vienen reclamando que se les reconozca su identidad sexual y que se les autorice el cambio de sexo y de nombre en su documentación.

En esta lucha hubo fallos favorables pero que le exigían al *trans* diversos requisitos, como ser: la presentación de diagnósticos médicos o psiquiátricos, someterse a operaciones de reasignación de sexo, controles médicos periódicos, etc., lo cual vulneraba el derecho que todas las personas tienen de definir su propio proyecto de vida en forma autónoma y sin la intervención del Estado.

El caso de *Florencia de la V* (famosa travesti, actriz y vedette argentina) marca un antes y un después en esta lucha, ya que por medio de una acción de amparo logró el reconocimiento de su identidad sexual, cambiando legalmente (en el DNI y en la partida de nacimiento) su nombre de varón -Roberto Carlos Trinidad- por el de Florencia Trinidad sin necesidad de presentar diagnósticos médicos o psiquiátricos, ni de someterse a intervenciones quirúrgicas.

Ley de Identidad de Género (Ley 26.743; BO: 24/5/2012).- Como fruto de esta lucha constante por lograr el reconocimiento de la identidad sexual, en Mayo de 2012 se promulgó la Ley 26.743 de "*Identidad de género de las personas*".

Esta ley, mediante un trámite rápido, sencillo y sin la intervención de juzgados, médicos o psicólogos permite hacer el cambio de nombre y de género en la partida de nacimiento y en el DNI. Para hacer el cambio de identidad, las personas simplemente deberán manifestar ante el Registro Nacional de las Personas que su identidad de género difiere de la que consta en sus documentos y manifestar su voluntad de cambiar de nombre. Además, la ley permite a las personas acceder a intervenciones quirúrgicas y/o tratamientos hormonales para adecuar su cuerpo (incluidos sus genitales) a la identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa, y en forma gratuita en los hospitales públicos o a través de su obra social.

En la ley se define a la *identidad de género* como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales (conf. art. 2).

En el art. 1 establece que toda persona tiene derecho:

- a) Al reconocimiento de su identidad de género;
- b) Al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género;
- c) A ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada.

Para hacer realidad este derecho a la identidad de género *"toda persona podrá solicitar la rectificación registral del sexo, y el cambio de nombre de pila e imagen, cuando no coincidan con su identidad de género autopercebida"*.

Para ello, debe cumplir los siguientes requisitos (conf. art. 4):

- a) Tener como mínimo 18 años de edad (si tiene menos de esa edad deberá contar con el consentimiento de los representantes legales o en su caso, del juez correspondiente);
- b) Presentar la solicitud ante el Registro Nacional de las Personas, pidiendo la rectificación registral de la partida de nacimiento y que se le extienda un nuevo documento nacional de identidad, conservándose el número original;
- c) Expresar el nuevo nombre de pila elegido con el que solicita inscribirse.

Cumplidos estos requisitos, el oficial público notificará la rectificación de sexo y el cambio de nombre al Registro Civil de la jurisdicción donde fue asentada el acta de nacimiento, para que proceda a emitir una nueva partida de nacimiento y un nuevo documento nacional de identidad que refleje la rectificación registral del sexo y el nuevo nombre de pila.

Se prohíbe cualquier referencia a la presente ley en la partida de nacimiento rectificada y en el documento nacional de identidad expedido en virtud de la misma (conf. arts. 6 y 7). Estos trámites gozan de confidencialidad, ya que "sólo tendrán acceso al acta de nacimiento original quienes cuenten con autorización del titular de la misma o con orden judicial por escrito y fundada" (conf. arts. 6, 7 y 9).

• Intervenciones quirúrgicas y tratamientos hormonales de adecuación al género (art. 12).- Todas las personas mayores de 18 años podrán acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercebida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa.

Para acceder a los tratamientos integrales hormonales, no será necesario acreditar la voluntad en la intervención quirúrgica de reasignación genital total o parcial. En

ambos casos (intervención quirúrgica y tratamiento hormonal) sólo se requiere el consentimiento informado de la persona. (Si se trata de un menor edad deberá contar con el consentimiento de los representantes legales, y si se trata de una intervención quirúrgica se requiere además la conformidad de la autoridad judicial competente de la jurisdicción, la cual debe expedirse en un plazo no mayor de 60 días contados a partir del pedido de conformidad).

Los efectores (prestadores de salud) del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, deberán garantizar en forma permanente los derechos que esta ley reconoce. Todas las prestaciones de salud contempladas en el presente artículo quedan incluidas en el Plan Médico Obligatorio, o el que lo reemplace, conforme lo reglamente la autoridad de aplicación (conf. art. 11).

Derecho a la no discriminación.-

La Constitución Nacional, en el art. 75 incs. 17 y 19, se refiere a los pueblos indígenas y a la promoción de la igualdad de oportunidades y posibilidades, sin discriminación alguna. Asimismo, el art. 43 de la Constitución Nacional, concede la acción de amparo contra cualquier forma de discriminación.

Los comportamientos mas comunes violatorios del derecho a no ser discriminado se refieren a raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social, color de piel u otras características físicas.

• La Ley 23.592 sobre "Actos Discriminatorios", establece:

Art. 1.- "Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados."

A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos."

Art. 2.- "Elévase en un tercio el mínimo y en un medio el máximo de la escala penal de todo delito reprimido por el Código Penal o Leyes complementarias cuando sea cometido por persecución u odio a una raza, religión o nacionalidad, o con el objeto de destruir en todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. En ningún caso se podrá exceder del máximo legal de la especie de pena de que se trate."

DERECHOS PERSONALÍSIMOS EN EL PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA.-

La Convención Americana de Derechos Humanos (conocida como Pacto de San José de Costa Rica) posee jerarquía constitucional (conf. art. 75 inc. 22, CN), forma parte de nuestro derecho positivo y contempla diversos derechos personalísimos, como ser:

Art. 4. Derecho a la vida.-

1) Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente...”

Art. 5. Derecho a la integridad personal.-

1) Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.

2) Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

Art. 6. Prohibición de la esclavitud y la servidumbre.-

1) Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas...”

Art. 7. Derecho a la libertad personal.-

1) Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.

2) Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas...”

Art. 11. Protección de la honra y de la dignidad.-

1) Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.

2) Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.

3) Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Art. 12. Libertad de conciencia y de religión.-

1) Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado.

2) Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias.

3) La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescriptas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás...”

Art. 13. Libertad de pensamiento y de expresión.-

1) Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas

de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2) El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

- a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
- b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas...”

Art. 14. Derecho de rectificación o respuesta.-

1) Toda persona afectada por informaciones inexactas o agravantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.

2) En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.

3) Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial.

NATURALEZA JURÍDICA DE LOS DERECHOS PERSONALÍSIMOS.-

Son derechos subjetivos, pues ellos otorgan la facultad de ejercitar dichos derechos, y existe, correlativamente, el deber subjetivo o jurídico de respetarlos. Estos derechos son “erga omnes”, es decir, se pueden hacer valer frente a toda la comunidad. Esta es la opinión que prevalece en la doctrina.

CARACTERES DE LOS DERECHOS PERSONALÍSIMOS.

1) Son **Innatos**, porque corresponden a la persona desde su nacimiento, por el solo hecho de ser humano.

2) Son **Vitalicios**, porque su titular los tiene durante toda su vida.

3) Son **Necesarios**, porque no pueden faltar en el hombre, aunque circunstancialmente puedan estar limitados.

4) Son **Extrapatrimoniales**, porque no son valorables económicamente, a pesar de que cuando ellos son lesionados puede surgir un derecho de índole patrimonial (ej: derecho a la indemnización por daños y perjuicios cuando se ha lesionado la vida, el honor, la intimidad, etc).

5) Son **Inalienables**, porque están fuera del comercio, no pudiendo ser enajenados de ninguna manera, ni por venta, ni por cesión, etc.

6) Son **Imprescriptibles**, porque el transcurso del tiempo no determina que ellos se adquieran ni se pierdan.

7) Son **Absolutos**, porque se ejercen y se oponen contra cualquiera que los afecte, es decir, se ejercen “erga omnes”.

DERECHOS SUBJETIVOS

Concepto → Son prerrogativas, facultades, que las normas jurídicas reconocen a las personas, para que puedan satisfacer sus necesidades y exigir de las demás personas un determinado comportamiento.

Clasificación → 1) Derechos Patrimoniales → a) D. Reales / b) D. Personales / c) D. Intelectuales.
2) Derechos Extrapatrimoniales → a) Derechos de Familia / b) **Derechos Personalísimos**

DERECHOS PERSONALÍSIMOS

Concepto Los derechos personalísimos son aquellos derechos extrapatrimoniales cuyo fin consiste en proteger la personalidad humana en sus distintos aspectos. Son libertades y derechos propios del hombre, sin los cuales no sería posible su existencia como tal. Ejemplos de estos derechos son: el derecho a la vida, a la integridad física, al honor, a la libertad, a la intimidad y a la privacidad, etc.

Regulación normativa → • En nuestra legislación, la protección de estos derechos se hacía en forma dispersa a través de diferentes leyes que tutelaron directa o indirectamente algún derecho personalísimo en particular.
• Con la reforma constitucional de 1994 mucho se avanzó en la protección de los derechos personalísimos y en general de los derechos humanos al incorporar a nuestra legislación diversos **tratados internacionales con jerarquía constitucional** y que implican una clara protección de diversos derechos de la persona (Ej: Pacto de San José de Costa Rica).
• El nuevo Código Civil y Comercial regula de manera **integral y sistemática** la materia de los derechos de la personalidad (en el Capítulo 3, del Título I, del Libro Primero, arts. 51 a 61).

Inviolabilidad de la persona humana. Dignidad → • **Art. 51** → **Inviolabilidad de la persona humana.**
• **Art. 52** → **Afectaciones a la dignidad** → El agredido podrá reclamar la prevención del ataque o la reparación de los daños si el ataque ya se produjo.

Derecho a la imagen y a la voz → • **Art. 53** → Para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona **siempre se requiere su consentimiento**, salvo en los casos (3) que indica el artículo.

Derecho a la intimidad → Es el derecho a gozar de **vida privada**, sin que nadie se entrometa o de a publicidad los hechos que la conforman, salvo que exista un interés público en hacerlo (art. 19, CN).
• **Art. 52** → "intimidad personal o familiar" / • **Art. 1770** → "protección de la vida privada"

Derecho a la vida → • **Art. 1741** → si de un hecho resulta la muerte están legitimados para reclamar la indemnización los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivían con el fallecido.
• En Argentina la eutanasia no está autorizada (arts. 56 y 60).

Derecho a la integridad física → El nuevo Código trae una serie de normas que protegen la integridad física → **Arts. 56, 54, 57, 58, 59, 60.**

Derecho al honor → • **Art. 52** → protege genéricamente al honor al referirse a la "**honra o reputación**", y autoriza al agredido a reclamar la prevención y reparación de los daños. • **Art. 1770** → La misma solución.
• **Art. 1771** → responsabilidad del que hace una acusación calumniosa → limitaciones.

Derecho a la identidad y a la identidad sexual → • **Derecho a la identidad** → derecho a gozar de un conjunto de atributos y calidades que determinan cómo es la persona y que la identifican e individualizan dentro de la sociedad. / • **Identidad sexual** → **Ley de Identidad de Género (Ley 26.743).**

Derecho a la no discriminación → • Constitución Nacional → Art. 75 (incs. 17 y 19) y Art. 43.
• Ley 23.592 → "**Actos Discriminatorios**".

• **Naturaleza Jurídica** → Los Derechos Personalísimos son **derechos subjetivos**. Son "**erga omnes**".

• **Caracteres** → 1) Innatos / 2) Vitalicios / 3) Necesarios / 4) Extrapatrimoniales / 5) Inalienables / 6) Imprescriptibles / 7) Absolutos.

CAPÍTULO IX
EL NOMBRE

Concepto.-

El nombre de la persona humana se compone por prenombre y apellido y sirve para individualizar a cada persona dentro de la sociedad.

Elementos.-

El nombre tiene dos elementos:

- a) el **prenombre**, también denominado nombre propiamente dicho o "nombre de pila", en alusión a que es frecuente a que se lo elija en la pila bautismal.
- b) el **apellido**, también denominado "nombre de familia".

Regulación normativa.-

El Código Civil de Vélez no traía reglas sobre el nombre, por lo tanto, fue la costumbre la que estableció reglas sobre él. En 1969, la Ley 18.248 (Ley de Nombre) reguló todo lo relativo al nombre y apellido, y fue la que rigió (con algunas modificaciones introducidas por las leyes de adopción, de patria potestad y de matrimonio) hasta la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, que regula lo relativo al nombre en los arts 62 a 73.

Es importante agregar que la Ley 26.994 (aprobatoria del nuevo Código Civil y Comercial), a través de su art. 3, **derogó a la Ley 18.248.**

En doctrina encontramos diferentes opiniones acerca de la naturaleza del nombre. Así, para algunos *es un derecho de propiedad* de quien lo lleva; para otros *es un derecho de la personalidad*; otros lo ven como *una institución de policía civil* cuya función es individualizar a la persona y bajo este punto de vista, el nombre, más que un derecho, es una obligación. Para otra opinión es una *institución mixta* (derecho y deber): por un lado el individuo tiene el **derecho** a usar un nombre y defenderlo, y por otro lado tiene el **deber** de tenerlo para ser individualizado dentro de la sociedad.

Esta última fue la posición de la Ley 18.248, y es la que adopta también el nuevo Código Civil y Comercial en el art. 62.

Art. 62.- "Derecho y deber. La persona humana tiene el derecho y el deber de usar el prenombre y el apellido que le corresponden."

Caracteres del nombre.-

- 1) Es **Obligatorio**: todo individuo necesariamente debe llevar un nombre.
- 2) Es **Unico**: sólo se puede tener un nombre y apellido.

- 3) Es **Inalienable**: está fuera del comercio.
- 4) Es **Imprescriptible**: no se adquiere ni se pierde por transcurso del tiempo.
- 5) Es **Inembargable**: no es susceptible de embargo, por estar fuera del comercio.
- 6) Es **Inmutable**: sólo se puede cambiar cuando existan ciertas causas graves.

Evolución histórica del nombre.-

En la antigüedad, cada persona llevaba un solo nombre (ej: Abraham, Salomón, etc.). Al aumentar las poblaciones, estos nombres resultaron insuficientes y producían confusiones. Debido a ello, se comenzó a agregar una cualidad al nombre (ej: Tarquino el Antiguo, Alejandro el Magno, etc.).

En Roma, el nombre estaba formado por distintos elementos:

- 1) el "*proenomen*", o nombre individual (ej: Pluvius).
- 2) el "*nomen*", o nombre de familia (ej: Cornelius).
- 3) el "*cognomen*", que indicaba la rama de la familia (ej: Escipión).
- 4) el "*agnomen*", especie de sobrenombre, dado en virtud de alguna característica o cualidad (ej: el Africanus).

De esta forma quedaba integrado el nombre de un romano. En el ejemplo dado, el nombre completo era: Pluvius Cornelius Escipión "el Africanus".

Los romanos llevaron este sistema a las Galias y a España; pero, producida la invasión de los bárbaros, se volvió a utilizar simplemente el nombre individual, pero agregándole alguna cualidad de la persona (ej: Fernando "el Católico", Juan "sin Tierra", etc.), o algo referente a su oficio (ej: Juan Armero, Pablo Alcalde, etc.), o al lugar donde vivía o había nacido (ej: Pedro de Córdoba, Juan de Toledo, etc.).

También era frecuente individualizar a la persona por el nombre de su padre: Luis, Hijo de Fernando; Domingo, Hijo de Gonzalo; etc. Con el tiempo, la expresión "hijo de", se reemplazó por la terminación "ez", surgiendo los apellidos tan abundantes como "Fernández" (Hijo de Fernando), "González" (Hijo de Gonzalo), etc.

EL NOMBRE INDIVIDUAL

Concepto.-

El nombre individual ("nombre de pila" o "proenomen"), es el elemento que sirve para identificar a una persona, dentro de la familia.

¿Cómo se adquiere el nombre? Según establecía la Ley 18.248 (art. 2), el nombre se adquiría por la inscripción en el acta de nacimiento, en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas. El nuevo Código Civil y Comercial nada dice al respecto, por lo cual creemos razonable que se mantendrá el régimen de la inscripción en el acta de nacimiento, en el Registro.

Elección del prenombre.-

Conforme al art. 63 inc. a), la elección del prenombre corresponde a:

- los padres (o a las personas a quienes ellos den su autorización para tal fin);
- a falta o impedimento de uno de los padres, la elección (o dar la autorización) corresponde al otro;
- en defecto de todos, debe hacerse por los guardadores, el Ministerio Público o el funcionario del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.

El nombre se elige libremente, es decir, se podrá elegir el nombre que se quiera, salvo aquellos nombres que la ley establezca que no pueden inscribirse (nombres prohibidos).

RÉGIMEN DE LA LEY 18.248.-

La Ley 18.248 (derogada por la Ley 26.994) establecía que no podían inscribirse:

1) Los nombres que fueran extravagantes, ridículos, contrarios a nuestras costumbres, que expresaran tendencias políticas o ideológicas, o que suscitaran equívocos respecto del sexo de la persona a quien se impone (ejemplos: serían extravagantes, ridículos o contrarios a nuestras costumbres, nombres como Soroastro, Vereingetoris, Sardanapo, Ateo, Caín, Judas, etc.; expresarían tendencias políticas o ideológicas, los nombres Anárquico, Radical, Peroncho, etc). Tampoco se le podría poner María a un hombre; sin embargo, se aceptaba su combinación con un primer nombre, como por ejemplo, José María, Carlos María, etc. Idem, para la mujer, por ejemplo, se admitía María José.

2) Los nombres extranjeros, salvo los castellanizados por el uso o cuando se tratare de los nombres de los padres del inscripto, si fuesen de fácil pronunciación y no tuvieran traducción en el idioma nacional. Queda exceptuado de esta prohibición el nombre que se quisiera imponer a los hijos de los funcionarios o empleados extranjeros de las representaciones diplomáticas o consulares acreditadas ante nuestro país, y de los miembros de misiones públicas o privadas que tengan residencia transitoria en el territorio de la República.

3) Los apellidos como nombre (Ej: González como nombre).

4) Primeros nombres idénticos a los de hermanos vivos (Ej: ponerle Atilio a un hijo si ya había un hermano vivo con ese nombre).

5) Más de tres nombres. (Ej: José Jorge Pedro Atilio).

Podían inscribirse los nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes autóctonas y latinoamericanas (Ej: Atahualpa, Kanki, etc.). Los nombres extranjeros en principio estaban prohibidos, salvo que estuvieran castellanizados por el uso o cuando se tratare de los nombres de los padres del inscripto, fuesen de fácil pronunciación y no tuvieran traducción en el idioma nacional. La prohibición no regía para los hijos de funcionarios extranjeros de las representaciones diplomáticas o consulares acreditadas ante nuestro país.

RÉGIMEN DEL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL.-

El nuevo Código Civil y Comercial regula lo relativo al "Nombre" en su Libro Primero, Título I (Persona Humana), Capítulo 4 (Nombre), arts. 62 a 72.

En general sigue los lineamientos de la ley anterior (Ley 18.248), pero se la actualiza con modificaciones que ajustan la regulación a principios constitucionales que priorizan el derecho a la identidad, a la autonomía de la voluntad y a la igualdad. Así, en respeto por las minorías, se permite poner nombres indígenas. También se introducen modificaciones sustanciales en el apellido de las personas casadas permitiendo a cualquiera de los dos tomar el apellido del otro, acompañado o no de la preposición "de". Se recepta el llamado "apellido de familia" con la limitación de que todos los hijos deben llevar el mismo apellido, etc.

• Prohibiciones (conf. art. 63 inc. b).- No pueden inscribirse:

- más de tres prenombres (Ej: José Jorge Pedro Atilio);
- apellidos como prenombres (Ej: González como prenombre);
- primeros prenombres idénticos a primeros prenombres de hermanos vivos (Ej: ponerle Carlos a un hijo habiendo otro hijo también llamado Carlos);
- prenombres extravagantes.

Por "extravagantes" entendemos aquellos nombres que puedan provocar rechazo, risa, burla o que puedan dañar el honor de la persona que lo lleva.

Se admite expresamente poner nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes autóctonas y latinoamericanas (ej: Tupac) en respeto a las minorías y a los pueblos originarios.

El nuevo Código Civil y Comercial ha eliminado varias prohibiciones que existían en la Ley 18.248, tal el caso de los nombres contrarios a nuestras costumbres, o que expresaran tendencias políticas o ideológicas, o que suscitaban equívocos respecto del sexo de la persona a quien se impone. También eliminó la prohibición de poner nombres extranjeros.

EL APELLIDO.-

Concepto.-

El apellido (también denominado "nombre patronímico" o "nombre de familia") sirve para individualizar al grupo familiar de la persona. Se transmite de padres a hijos.

Distintos casos de adquisición.-

La adquisición del apellido puede ser:

- 1) Originaria: cuando el apellido se adquiere en virtud de la filiación, por ejemplo, hijo matrimonial, extramatrimonial, etc.

- 2) Derivada: cuando el apellido se adquiere a raíz del cambio de estado civil (ej: la persona, que al casarse, agrega a su apellido el de su cónyuge).

A continuación los analizamos en detalle.

1) CASOS DE ADQUISICIÓN ORIGINARIA

a) Hijos matrimoniales.-

Art. 64.- "Apellido de los hijos. El hijo matrimonial lleva el primer apellido de alguno de los cónyuges; en caso de no haber acuerdo, se determina por sorteo realizado en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.

A pedido de los padres, o del interesado con edad y madurez suficiente, se puede agregar el apellido del otro.

Todos los hijos de un mismo matrimonio deben llevar el apellido y la integración compuesta que se haya decidido para el primero de los hijos..."

Los hijos matrimoniales (sean de matrimonio heterosexual u homosexual) llevan el primer apellido de alguno de los cónyuges. Los padres deben ponerse de acuerdo acerca de si lo anotan con el primer apellido de uno de los cónyuges, o el primer apellido del otro, o con los dos. Si no se ponen de acuerdo, se lo anota con el apellido resultante de un sorteo efectuado por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Claramente se deja de lado la costumbre de poner el apellido paterno.

A pedido de los padres (ambos) o del interesado (con edad y madurez suficiente), se puede agregar el apellido del otro. Tratándose del menor, al hacer el pedido deberá acreditar que goza de madurez suficiente.

Elegido un apellido, todos los hijos del matrimonio deberán llevar el mismo apellido (simple o compuesto) que se le haya puesto al primer hijo.

b) Hijos extramatrimoniales.-

Art. 64.- "Apellido de los hijos. ...

... El hijo extramatrimonial con un solo vínculo filial lleva el apellido de ese progenitor. Si la filiación de ambos padres se determina simultáneamente, se aplica el primer párrafo de este artículo. Si la segunda filiación se determina después, los padres acuerdan el orden; a falta de acuerdo, el juez dispone el orden de los apellidos, según el interés superior del niño."

Respecto a los hijos extramatrimoniales (es decir, los concebidos fuera del matrimonio) debemos diferenciar 3 supuestos:

- Cuando hay un solo vínculo filial (reconocido solo por un progenitor) lleva el apellido de ese progenitor.
- Cuando ambos lo reconocen simultáneamente, la solución es igual que para los hijos matrimoniales: lleva el primer apellido de alguno de los cónyuges. En este caso, los padres deben ponerse de acuerdo acerca de si lo anotan con el primer apellido de uno de los cónyuges, o el primer apellido del otro, o con los dos.
- Cuando uno de los cónyuges lo reconoce posteriormente al otro, los padres deberán acordar el orden de los apellidos que llevará el hijo. En este caso, si no

se ponen de acuerdo, será el juez quien decida el orden de los apellidos, según el interés superior del niño.

c) Hijos no reconocidos por ninguno de sus padres (filiación desconocida).-

La persona menor de edad sin filiación determinada debe ser anotada por el oficial del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas con el apellido que está usando, o en su defecto, con un apellido común (conf. art. 65).

• **Caso especial.**- En el art. 66 se contempla la situación de aquella persona que carece de apellido inscripto (ej: mal hecha la inscripción) y que tiene edad y grado de madurez suficiente. En este caso se le permite pedir la inscripción del apellido que está usando.

d) Hijo adoptivo.-

Art. 68.- "Nombre del hijo adoptivo. El nombre del hijo adoptivo se rige por lo dispuesto en el Capítulo 5, Título VI del Libro Segundo de este Código."

De acuerdo a esta remisión, debemos distinguir 3 supuestos (según el tipo de adopción de que se trate):

• **Adopción plena** (es la que confiere al adoptado la condición de hijo y extingue los vínculos jurídicos con la familia de origen, con la excepción de que subsisten los impedimentos matrimoniales. El adoptado tiene en la familia adoptiva los mismos derechos y obligaciones de todo hijo). En este caso, debemos diferenciar si se trata de una adopción unipersonal o conjunta (conf. art. 626):

a) si se trata de una adopción unipersonal (sólo una persona es la que adoptó), el hijo adoptivo lleva el apellido del adoptante; si el adoptante tiene doble apellido, puede solicitar que éste sea mantenido;

b) si se trata de una adopción conjunta (adoptaron los dos cónyuges o convivientes), se aplican las reglas generales relativas al apellido de los hijos matrimoniales.

En todos los casos, si el adoptado cuenta con la edad y grado de madurez suficiente, el juez debe valorar especialmente su opinión.

• **Adopción simple** (es la que confiere el estado de hijo al adoptado, pero no crea vínculos jurídicos con los parientes ni con el cónyuge del adoptante). En este caso, el adoptado (si cuenta con la edad y grado de madurez suficiente) o los adoptantes, pueden solicitar se mantenga el apellido de origen, sea adicionándole o anteponiéndole el apellido del adoptante o uno de ellos. A falta de petición expresa, la adopción simple se rige por las mismas reglas de la adopción plena (conf. art. 627).

• **Adopción de integración** (se configura cuando se adopta al hijo del cónyuge o del conviviente; mantiene el vínculo filiatorio entre el adoptado y su progenitor de origen, cónyuge o conviviente del adoptante). En este caso hay que distinguir:

a) si el adoptado tiene un solo vínculo filial de origen, se inserta en la familia del adoptante con los efectos de la adopción plena (con los efectos correspondientes respecto del apellido);

b) si el adoptado tiene doble vínculo filial de origen, se aplica lo dispuesto en el art. 621. Es decir, el juez otorga la adopción plena o simple según las circunstancias, atendiendo fundamentalmente al interés superior del niño; y de acuerdo a qué tipo de adopción otorgue, surtirán los efectos correspondientes sobre el apellido.

Revocación de la adopción.- Revocada la adopción, el adoptado pierde el apellido de adopción. Sin embargo, con fundamento en el derecho a la identidad, puede ser autorizado por el juez a conservarlo (conf. arts. 629 y 633). Esto es aplicable a la adopción simple y a la de integración, pero no a la adopción plena porque ella es irrevocable (conf. art. 624).

2) CASOS DE ADQUISICIÓN DERIVADA

Estos casos se dan cuando hay casamiento, viudez, separación, divorcio o nulidad del matrimonio.

a) **Casamiento:** cualquiera de los cónyuges puede optar por usar el apellido del otro, con la preposición "de" o sin ella.

b) **Viudez:** el cónyuge viudo puede seguir usando el apellido del otro cónyuge mientras no contraiga nuevas nupcias, ni constituya unión convivencial.

c) **Divorcio/nulidad de matrimonio:** la persona divorciada o cuyo matrimonio ha sido declarado nulo no puede usar el apellido del otro cónyuge, excepto que, por motivos razonables, el juez la autorice a conservarlo.

CAMBIO DE NOMBRE O APELLIDO

Inmutabilidad. Excepciones.-

Uno de los caracteres del nombre es su inmutabilidad: una vez inscripto, ya no puede cambiarse. ¿Por qué? Porque si pudiese cambiarse arbitrariamente se produciría un desorden en la sociedad, ya que dejaría de cumplir la función de identificar a las personas.

Por excepción se pueden cambiar o modificar, si el juez lo autoriza y si median justos motivos (art. 69).

a) **Autorización judicial.**- Es requisito que el juez autorice el cambio, modificación, adición o rectificación del nombre. Será juez competente el del lugar en que se encuentra la inscripción original que se pretende cambiar, rectificar, etc., o el del domicilio del interesado.

b) **Justos motivos para el cambio.**- En general, tienen que ser causas serias, y queda a criterio judicial si el motivo es justo o no. El art. 69 enumera diversos "justos motivos", pero ello no es taxativo ya que la norma dice "entre otros".

Art. 69.- "Cambio de nombre. El cambio de prenombre o apellido sólo procede si existen justos motivos a criterio del juez."

Se considera justo motivo, de acuerdo a las particularidades del caso, entre otros, a:

- a) el seudónimo, cuando hubiese adquirido notoriedad;
- b) la raigambre cultural, étnica o religiosa;
- c) la afectación de la personalidad de la persona interesada, cualquiera sea su causa, siempre que se encuentre acreditada.

Se consideran justos motivos, y no requieren intervención judicial, el cambio de prenombre por razón de identidad de género y el cambio de prenombre y apellido por haber sido víctima de desaparición forzada, apropiación ilegal o alteración o supresión del estado civil o de la identidad."

La parte final de la norma menciona algunos "justos motivos" que no requieren intervención judicial. Son los siguientes:

- **Cambios por razón de identidad de género.** - En este supuesto habrá que tener en cuenta los trámites que establezca la vigente Ley 26.743 de "Identidad de Género" (BO: 24/5/2012) que autoriza a las personas a solicitar el cambio de nombre de pila y la modificación registral de su sexo, cuando no coincidan con la identidad de género que el sujeto autopercebe.

- **Cambios por haber sido víctima de desaparición forzada, apropiación ilegal o alteración o supresión del estado civil o de la identidad.** - En estos supuestos creemos que para hacer el cambio será indispensable, por lo menos, presentar la documentación que acredite haber sido víctima de esos delitos.

Proceso (art. 70).-

Todos los cambios de prenombre o apellido deben tramitarse por el proceso más abreviado que prevea la ley local (ej: proceso sumarísimo), con intervención del Ministerio Público.

El pedido debe publicarse en el diario oficial una (1) vez por mes, en el lapso de dos (2) meses. Los que se vean afectados por dicho trámite pueden formular oposición dentro de los 15 días hábiles contados desde la última publicación.

Debe requerirse información sobre medidas precautorias existentes respecto del interesado.

La sentencia es oponible a terceros desde su inscripción en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Deben rectificarse todas las partidas, títulos y asientos registrales que sean necesarios.

PROTECCIÓN JURÍDICA DEL NOMBRE

El nombre recibe protección jurídica mediante estas 3 acciones:

- a) **Acción de reclamación de nombre** (art. 71, inc. a): tiene lugar cuando a alguien se le desconoce el nombre que lleva o se le niega el derecho a usarlo (ej: en una nota periodística alguien niega a otro el derecho a llevar determinado nombre);

- b) **Acción de usurpación de nombre** (art. 71, inc. b): tiene lugar cuando alguien usa el nombre y/o apellido (o el seudónimo) de otra persona, sin tener derecho a ello.

- c) **Acción de defensa del buen nombre** (art. 71, inc. c): igual que el caso anterior, pero el nombre ajeno es utilizado maliciosamente para la designación de cosas o personajes de fantasía, causando perjuicio moral o material.

El objeto de estas acciones es, según el caso, que se reconozca el nombre o que cese el uso indebido del mismo, y además, que se reparen los daños y perjuicios que hubiere. El juez puede disponer la publicación de la sentencia.

Las demandas tendientes a la protección del nombre podrán ser promovidas exclusivamente por el interesado; si ha fallecido, por sus descendientes, cónyuge o conviviente, y a falta de éstos, por los ascendientes o hermanos (conf. art. 71).

EL SOBRENOMBRE

El "sobrenombre" es la designación con la cual se conoce a una persona dentro del círculo de su familia y de sus amistades íntimas (ej: Lito, Pochi, Nacho).

Su importancia es ínfima en el aspecto jurídico, ya que las personas sólo se identifican por el nombre y apellido con que figuran inscriptas en el Registro Civil. Sin embargo, puede tener cierta importancia en algunos casos, tal el supuesto de que en un testamento se designara al beneficiario por su sobrenombre y dicha designación no dejara dudas sobre la persona instituida.

EL SEUDÓNIMO

Es la designación que una persona elige para realizar determinada actividad, generalmente artística (ej: Pinky). Etimológicamente, significa nombre falso.

¿Cómo se adquiere? Para algunos, por la simple elección; para otros, por la elección y un largo período de uso. En general es suficiente que la persona que se lo atribuye hubiere adquirido con él alguna notoriedad. Es la postura del nuevo Código Civil y Comercial en el art.72:

Art. 72.- "Seudónimo. El seudónimo notorio goza de la tutela del nombre."

Tiene importancia jurídica, ya que si alcanzó notoriedad puede ser defendido igual que el nombre.

La Ley de Propiedad Intelectual (Ley 11.723; E-0175), en su art. 3 protege los derechos de los que tuvieren obras registradas bajo seudónimo, y establece que podrán registrarlos, adquiriendo la propiedad de los mismos.

EL NOMBRE

Concepto

El nombre de la persona humana se compone por prenombre y apellido y sirve para individualizar a cada persona dentro de la sociedad.

Elementos

a) Prenombre / b) Apellido.

Caracteres

- 1) Obligatorio
- 2) Único
- 3) Inalienable
- 4) Imprescriptible
- 5) Inembargable
- 6) Inmutable

EL NOMBRE INDIVIDUAL

Concepto → El nombre individual ("nombre de pila" o "prenomen"), es el elemento que sirve para identificar a una persona, dentro de la familia.

Elección → corresponde a → • los padres (o al autorizado por ellos);
• a falta o impedimento de uno de los padres, la elección (o dar la autorización) corresponde al otro;
• en defecto de todos, debe hacerse por los guardadores, el Ministerio Público o el funcionario del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.

¿Cómo se adquiere?

Con la inscripción en el acta de nacimiento, en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas.

Se elige libremente

Es decir, se podrá elegir el nombre que se quiera, salvo las prohibiciones del art. 63, inc. b.

No pueden inscribirse

- más de tres prenombrs
- apellidos como prenombrs
- primeros prenombrs idénticos a primeros prenombrs de hermanos vivos
- prenombrs extravagantes.

- El nuevo Código Civil y Comercial ha eliminado varias prohibiciones que existían en la Ley 18.248, tal el caso de los nombres contrarios a nuestras costumbres, o que expresaran tendencias políticas o ideológicas, o que suscitaban equívocos respecto del sexo de la persona a quien se impone.
- También eliminó la prohibición de poner nombres extranjeros.

EL APELLIDO

Concepto → El apellido (también denominado "nombre patronímico" o "nombre de familia") sirve para individualizar al grupo familiar de la persona. Se transmite de padres a hijos.

Distintos casos de adquisición

- 1) **Originaria**: el apellido se adquiere en virtud de la filiación.
- 2) **Derivada**: el apellido se adquiere a raíz del cambio de estado civil.

CASOS DE ADQUISICIÓN ORIGINARIA

a) Hijos matrimoniales

- Llevan el primer apellido de alguno de los cónyuges.
- Si no se ponen de acuerdo → sorteo en el Registro.
- A pedido de los padres o del interesado (con edad y madurez suficiente), se puede agregar el apellido del otro.
- Elegido un apellido, todos los hijos del matrimonio deberán llevar el mismo apellido que se le haya puesto al primer hijo.

b) Hijos extramatrimoniales

- Si hay un solo vínculo filial (reconocido solo por un progenitor), lleva el apellido de ese progenitor.
- Si ambos lo reconocen simultáneamente, lleva el primer apellido de alguno de los cónyuges.
- Si el reconocimiento no es simultáneo, y no se ponen de acuerdo, decide el juez el orden de los apellidos, según el interés superior del niño.

c) Hijos no reconocidos por ninguno de sus padres

- Debe ser anotado por el oficial del Registro con el apellido que está usando, o en su defecto, con un apellido común.
- **Caso especial** → Persona que carece de apellido inscripto y que tiene edad y grado de madurez suficiente → Se le permite pedir la inscripción del apellido que está usando.

d) Hijo adoptivo

Adopción plena

Debemos diferenciar

- a) **Adopción unipersonal** → el hijo lleva el apellido del adoptante; si el adoptante tiene doble apellido, puede solicitar que sea mantenido;
- b) **Adopción conjunta** → se aplican las reglas generales relativas al apellido de los hijos matrimoniales.

Adopción simple

El adoptado o los adoptantes, pueden solicitar mantener el apellido de origen, sea adicionándolo o anteponiéndolo el apellido del adoptante o uno de ellos.

A falta de petición expresa, la adopción simple se rige por las reglas de la adopción plena.

Adopción de integración

Hay que distinguir:

- a) si el adoptado tiene un solo vínculo filial de origen, se inserta en la familia del adoptante con los efectos de la adopción plena.
- b) si el adoptado tiene doble vínculo filial de origen, se aplica lo dispuesto en el art. 621 (el juez otorga la adopción plena o simple según las circunstancias y atendiendo fundamentalmente al interés superior del niño).

Revocación de la adopción → Revocada la adopción, el adoptado pierde el apellido de adopción. Sin embargo, puede ser autorizado por el juez a conservarlo. Esto es aplicable a la adopción simple y a la de integración, pero no a la adopción plena porque ella es irrevocable.

CASOS DE ADQUISICIÓN DERIVADA

a) Casamiento

Cualquiera de los cónyuges puede optar por usar el apellido del otro, con la preposición "de" o sin ella.

b) Viudez

El cónyuge viudo puede seguir usando el apellido del otro cónyuge mientras no contraiga nuevas nupcias, ni constituya unión convivencial.

c) Divorcio / Nulidad de matrimonio

La persona divorciada o cuyo matrimonio ha sido declarado nulo no puede usar el apellido del otro cónyuge, excepto que, por motivos razonables, el juez la autorice a conservarlo.

CAMBIO DE NOMBRE O APELLIDO

Inmutabilidad → Es uno de los caracteres del nombre → Una vez inscripto, ya no puede cambiarse.

- Por **excepción** se puede cambiar, si → a) el juez lo autoriza; y b) median justos motivos (conf. art. 69).

No requieren autorización judicial → • cambios por razón de identidad de género / • cambios por haber sido víctima de desaparición forzada, apropiación ilegal o alteración o supresión del estado civil o de la identidad

- **Proceso** → Todos los cambios de prenombre o apellido deben tramitarse por el proceso más abreviado que prevea la ley local (ej: proceso sumarísimo), con intervención del Ministerio Público.

PROTECCIÓN JURÍDICA DEL NOMBRE

El nombre recibe protección jurídica mediante estas 3 acciones

- a) **Acción de reclamación de nombre**: cuando a alguien se le desconoce el nombre que lleva o se le niega el derecho a usarlo.
- b) **Acción de usurpación de nombre**: cuando alguien usa el nombre y/o apellido (o el seudónimo) de otra persona, sin tener derecho a ello.
- c) **Acción de defensa del buen nombre**: cuando el nombre ajeno es utilizado maliciosamente para la designación de cosas o personajes, causando perjuicio.

SOBRENOMBRE

- El "sobrenombre" es la designación con la cual se conoce a una persona dentro del círculo de su familia y de sus amistades íntimas (ej: Lito, Pochi, Nacho).
- Su importancia es ínfima, excepto en algunos casos (ej: supuesto de que en un testamento se designara al beneficiario por su sobrenombre).

SEUDÓNIMO

- El "seudónimo" es la designación que una persona elige para realizar determinada actividad, generalmente artística (ej: Pinky). Etimológicamente, significa nombre falso.
- **¿Cómo se adquiere?** Es suficiente que la persona que se lo atribuye hubiere adquirido con él alguna notoriedad (conf. art. 72).
- Tiene importancia jurídica, ya que si alcanzó notoriedad puede ser defendido igual que el nombre.

CAPÍTULO X DOMICILIO

Concepto.-

En sentido jurídico, "domicilio" *es el asiento jurídico de una persona* (conf. Salvat); o en otras palabras, el lugar donde podrá encontrarse a la persona, para hacerle saber o hacerle soportar cualquier efecto legal (ej: para exigirle el pago de una obligación, para citarlo a declarar como testigo, para notificarle una demanda, etc.).

En cuanto a su naturaleza jurídica, ya hemos dicho que tradicionalmente la doctrina lo trata como un atributo de la persona.

Conviene distinguirlo de otras situaciones, tales como:

- "Residencia": es el lugar donde normalmente habita la persona, junto con su familia. Puede coincidir o no con el "domicilio".
- "Habitación": es el lugar donde, accidentalmente, reside una persona; o sea: no vive ahí normalmente, sino que lo hace en forma momentánea (ej: está 3 días en un hotel de Córdoba).

Importancia.-

El domicilio es de gran importancia práctica, ya que:

- 1) Sirve para determinar la ley aplicable (ej: la capacidad de ejercicio se rige por la ley del domicilio de la persona; las sucesiones se rigen por la ley del domicilio del causante).
- 2) Fija la competencia de los jueces (ej: declaración de ausencia: es competente el juez del domicilio del desaparecido; juicio sucesorio: el juez del domicilio del causante; declaración de demencia o de sordomudez: juez del domicilio del incapaz; etc.).
- 3) Sirve para hacer las notificaciones, ya que las mismas se deben efectuar en el domicilio del notificado.

Caracteres.-

El domicilio presenta los siguientes caracteres:

- 1) Es legal: pues está fijado por la ley.
- 2) Es necesario: ya que ninguna persona puede carecer de un domicilio general; primero, porque es un atributo de la persona; y segundo, porque es indispensable su existencia para ubicar rápidamente a una persona, sea para exigirle el cumplimiento de sus obligaciones, o para atribuirle sus derechos. La ley fija un lugar de domicilio para todas las personas, aún para aquellas que no tengan un lugar de residencia fijo.

3) Es único: pues a los efectos legales, sólo se puede tener un domicilio general. Se evitan así dificultades (ej: la capacidad de ejercicio se rige por la ley del domicilio de la persona, por lo tanto, si ésta tuviese domicilio en el Uruguay y también en la Argentina, habría dos leyes distintas que regularían su capacidad).

Especies.-

Se suele diferenciar entre:

Domicilio general: es el que se aplica a todas las relaciones jurídicas de una persona. Se subdivide en: *real* y *legal*.

Domicilio especial: es el que se establece sólo para ciertas relaciones jurídicas determinadas. En el art. 75 se regula como domicilio especial al "domicilio contractual".

El nuevo Código Civil y Comercial distingue 3 clases de domicilio:

- a) Domicilio real (art. 73)
- b) Domicilio legal (art. 74)
- c) Domicilio especial (art. 75).

A) DOMICILIO REAL

Concepto.-

El domicilio real es lugar en el cual la persona tiene su residencia habitual. Es un domicilio real en todo el sentido de la palabra, ya que está constituido en el lugar donde realmente vive la persona o donde tiene el centro principal de sus actividades.

Art. 73.- "Domicilio real. La persona humana tiene domicilio real en el lugar de su residencia habitual.

Si ejerce actividad profesional o económica lo tiene en el lugar donde la desempeña para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de dicha actividad."

Requisitos.-

Para que exista el domicilio real es necesario:

- a) un elemento material (corpus): que tenga la residencia efectiva en ese lugar;
- b) un elemento intencional (animus): que tenga la intención de permanecer en el lugar en que reside.

Características.-

El domicilio real presenta las siguientes características:

- 1) Es voluntario, porque lo fija voluntariamente la persona; no se puede obligar a alguien a residir en un lugar determinado o no (esto lo diferencia del domicilio legal que es forzoso).

2) Es mutable, porque el individuo puede cambiarlo de un lugar a otro (art. 77).

3) Es inviolable (Constitución Nacional, art. 18).

Constitución, conservación, cambio y extinción.-

• **Constitución:** se produce cuando se reúnen los dos elementos que integran el domicilio real: a) que la persona resida habitual y efectivamente en el lugar; b) que tenga intención de permanecer en él, en forma estable.

• **Conservación:** el domicilio real dura mientras no se cambie.

• **Cambio y extinción del domicilio (art. 77):** el domicilio puede cambiarse de un lugar a otro. Esta facultad no puede ser coartada por contrato, ni por disposición de última voluntad. El cambio de domicilio se verifica instantáneamente por el hecho de trasladar la residencia de un lugar a otro con ánimo de permanecer en ella.

Para que se produzca el cambio, es necesario que se den los dos elementos, no bastando uno solo de ellos. Operado el cambio de domicilio, el nuevo domicilio extingue automáticamente al anterior.

Domicilio ignorado.-

Cuando el domicilio de una persona no es conocido, lo tendrá en el lugar donde se encuentra. Si el lugar donde se encuentra también es desconocido, su domicilio será su último domicilio conocido (conf. art. 76).

B) DOMICILIO LEGAL

Concepto y características.-

El domicilio legal es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una persona determinada reside de una manera permanente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones (conf. art. 74). Ej: la ley presume que un funcionario público tiene su domicilio en el lugar donde debe cumplir sus funciones.

El domicilio legal presenta las siguientes características:

1) Es forzoso: solo la ley puede establecerlo y lo hace independientemente de la voluntad de la persona. No puede ser cambiado mientras dura la hipótesis en la cual él se basa.

2) Es excepcional: sólo se aplica en los casos enumerados por la ley.

Art. 74.- "Domicilio legal. El domicilio legal es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Sólo la ley puede establecerlo, y sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales:

- a) los funcionarios públicos, tienen su domicilio en el lugar en que deben cumplir sus funciones, no siendo éstas temporarias, periódicas, o de simple comisión;
- b) los militares en servicio activo tienen su domicilio en el lugar en que lo están prestando;

- c) los transeúntes o las personas de ejercicio ambulante, como los que no tienen domicilio conocido, lo tienen en el lugar de su residencia actual;
 d) las personas incapaces lo tienen en el domicilio de sus representantes."

Casos enumerados en el art. 74.-

El art. 74 del nuevo Código Civil y Comercial establece cuáles serán los domicilios legales en algunos casos específicos. A saber:

a) los funcionarios públicos, tienen su domicilio en el lugar en que deben cumplir sus funciones.

El cumplimiento de la función debe ser permanente, ya que quedan excluidos los que cumplan funciones temporarias, periódicas, o de simple comisión.

b) los militares en servicio activo, tienen su domicilio en el lugar en que lo están prestando.

Entendemos que esta disposición comprende también a los incorporados a las fuerzas armadas como auxiliares (ej: médicos, abogados, ingenieros, odontólogos, etc.); y que quedan excluidos los militares retirados, pues el inciso habla de "activos".

c) los transeúntes o las personas de ejercicio ambulante, como los que no tienen domicilio conocido, tienen su domicilio en el lugar de su residencia actual.

- *Transeúntes*: son personas que no tienen asiento fijo, que hoy se encuentran en un lugar y mañana en otro.

- *Personas de ejercicio (profesión) ambulante*: son aquellas que viajan de una zona a otra, para realizar operaciones comerciales; tales son los "mercachifles", y viajantes de comercio.

- *Personas que no tienen domicilio conocido*: son aquellas cuyo domicilio fue siempre ignorado; ej: un vagabundo.

d) las personas incapaces, tienen su domicilio en el domicilio de sus representantes legales.

Así, distinguiendo según el art. 24:

1) Las personas por nacer, tendrán el domicilio de sus padres.

2) Las personas que no cuentan con la edad y grado de madurez suficientes (los menores no emancipados), tendrán el domicilio de sus padres o del tutor que se le haya designado.

Cuando los progenitores no conviven (conf. arts. 649 y 650), el domicilio del menor será el del progenitor que tenga la tenencia. Y a este efecto, habrá que determinar si la tenencia le corresponde sólo a uno de ellos o a ambos (compartida). En este último caso, habrá que distinguir si el cuidado es alternado (el hijo pasa períodos de tiempo con cada uno de los progenitores) o indistinto (el hijo reside de manera principal en el domicilio de uno de los progenitores, pero ambos comparten las decisiones y se distribuyen de modo equitativo las labores atinentes a su cuidado). De la determinación de esas circunstancias surgirá cuál es el domicilio del menor.

Para el supuesto de progenitores domiciliados en distintos países, si la responsabilidad parental es plural, las personas menores de edad se consideran domiciliadas donde tienen su residencia habitual (conf. art. 2614).

Tratándose de hijos extramatrimoniales, si hay un solo vínculo filial, tendrá el domicilio del progenitor que lo reconoció; si hay doble vínculo filial, dependerá de la modalidad del cuidado personal adoptado.

3) La persona declarada incapaz por sentencia judicial, tendrá el domicilio del curador designado.

El art. 2615, refiriéndose al "domicilio de otras personas incapaces", dice: "*El domicilio de las personas sujetas a curatela u otro instituto equivalente de protección es el lugar de su residencia habitual*".

Casos enumerados taxativamente en el Código Civil de Vélez.-

En el Código de Vélez (art. 90) se enumeraban taxativamente 8 casos de domicilio legal. Aparte de los 4 casos que regula el nuevo Código Civil y Comercial que ya vimos (funcionarios públicos; militares en servicio activo; transeúntes, personas de ejercicio ambulante, como los que no tienen domicilio conocido; y los incapaces) se regulaban otros casos, como ser: el domicilio de las personas jurídicas y sus sucursales (incs. 3 y 4), el domicilio de las personas que sirven o trabajan en casa de otros (inc. 8) y el domicilio que tenía el difunto para determinar el de la sucesión (inc. 7).

• El domicilio de las personas jurídicas.- El domicilio de las personas jurídicas era el lugar donde estaba situada su dirección o administración, salvo que en sus estatutos tuviesen señalado otro domicilio (conf. inc. 3).

El inc. 4, contemplaba el caso de que la persona jurídica tuviera muchas sucursales y establecía que, en ese caso, ella tendría domicilio especial en el lugar donde se estuviera cada una de las sucursales. Se trataba de un caso de domicilio especial.

Estos casos se suprimieron debido a que lo relativo al domicilio de las personas jurídicas y sus sucursales está regulado en el art. 152 del nuevo Código Civil y Comercial que establece un régimen similar al del Código de Vélez.

Art. 152.- "Domicilio y sede social. El domicilio de la persona jurídica es el fijado en sus estatutos o en la autorización que se le dio para funcionar. La persona jurídica que posee muchos establecimientos o sucursales tiene su domicilio especial en el lugar de dichos establecimientos sólo para la ejecución de las obligaciones allí contraídas. El cambio de domicilio requiere modificación del estatuto. El cambio de sede, si no forma parte del estatuto, puede ser resuelto por el órgano de administración."

Art. 153.- "Alcance del domicilio. Notificaciones. Se tienen por válidas y vinculantes para la persona jurídica todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta."

• El domicilio de las personas que sirven o trabajan en casa de otros (inc. 8).- Este inciso establecía: "*Los mayores de edad que sirven o trabajan, o que están agregados*

en casa de otros, tienen el domicilio de la persona a quien sirven o para quien trabajan, siempre que residan en la misma casa, o en habitaciones accesorias...

La hipótesis comprendía a los que "servían en casa de otro" (ej: los porteros, mucamos, cocineros, etc.); a los que "trabajaban en casa de otro" (ej: los secretarios, escribientes, institutrices, etc.); y a los "agregados en casa de otro" (ej: son los que simplemente residen allí, como ser, amigos o familiares).

El inciso exigía que todas estas personas residieran en la casa o en habitaciones accesorias, y que fueran mayores de edad.

En el nuevo Código Civil y Comercial este caso se suprimió por innecesario, ya que todas las personas mencionadas tienen su domicilio (en este caso real) en el lugar que la ley indica que es el de su residencia habitual.

- El domicilio del difunto, para determinar el lugar de apertura de la sucesión (inc. 7).- "El domicilio que tenía el difunto determina el lugar en que se abre su sucesión". En el nuevo Código Civil y Comercial se suprimió, ya que en realidad no se trataba de un caso de domicilio, sino de determinación del juez competente para iniciar la sucesión.

C) DOMICILIO ESPECIAL

Concepto.-

Domicilio especial es el que se establece sólo para ciertas relaciones jurídicas determinadas. Ej: domicilio contractual; domicilio procesal, domicilio conyugal, etc.

En el nuevo Código Civil y Comercial sólo se regula el "domicilio contractual" (art. 75), sin grandes diferencias a como lo regulaba el Código de Vélez en el art. 101.

Art. 75.- "Domicilio especial. Las partes de un contrato pueden elegir un domicilio para el ejercicio de los derechos y obligaciones que de él emanan."

- Domicilio contractual: es el que fija una persona en un contrato, para todos los efectos legales derivados de ese acto jurídico, como ser el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

En general, en casi todos los contratos las partes manifiestan cuál es su domicilio real, y además constituyen especialmente un domicilio contractual para que en él se produzcan todos los efectos legales relacionados a ese contrato.

El domicilio contractual es voluntario, pues las partes pueden o no fijarlo. El efecto principal de este domicilio es la "prórroga de la jurisdicción": el Juez que normalmente debía ser competente, deja de serlo, pasando a ser competente el Juez del domicilio elegido.

- Domicilio procesal (constituido o "ad litem"): es el que está obligado a constituir toda persona que intervenga en un juicio; lo debe constituir en la primera presentación que haga en el juicio (ej: al presentar la demanda, al contestar demanda,

etc). Su constitución es obligatoria. Normalmente la parte constituye domicilio en el estudio de su abogado. Sólo tiene valor en el juicio para el cual ha sido constituido.

Está previsto en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, art. 40. Si no se fijase el domicilio procesal, el mismo quedará constituido en los estrados del tribunal; y en dicho tribunal se practicarán las notificaciones de los actos procesales que correspondan (art. 41). Los efectos de este domicilio se limitan a todo lo relacionado con el juicio (notificaciones, intimaciones de pago, etc.). El domicilio procesal subsiste hasta la terminación del juicio; finalizado éste, el domicilio procesal caduca. También caduca si el juicio fuese archivado, o si se constituye o denuncia otro domicilio procesal.

- Domicilio conyugal (lugar donde viven los cónyuges): el nuevo Código Civil y Comercial no lo regula, a pesar de que lo menciona en varias normas (ej: arts. 717 y 719).

DOMICILIO

Concepto.	Importancia	Especies	Caracteres
"Domicilio" es el <i>asiento jurídico de una persona</i> (conf. Salvat). Es el lugar donde podrá encontrarse a la persona, para hacerle saber o hacerle soportar cualquier efecto legal.	1) Sirve para determinar la ley aplicable 2) Fija la competencia de los jueces 3) Sirve para hacer las notificaciones	a) Domicilio real (art. 73) b) Domicilio legal (art. 74) c) Domicilio especial (art. 75)	1) Es legal 2) Es necesario 3) Es único

A DOMICILIO REAL

El domicilio real es lugar en el cual la persona tiene su residencia habitual (conf. art. 73). Está constituido en el lugar donde realmente vive la persona o donde tiene el centro principal de sus actividades.

Requisitos

- a) Elemento material (corpus): residencia efectiva en ese lugar;
- b) Elemento intencional (animus): intención de permanecer en el lugar en que reside.

Características

- 1) Es voluntario / 2) Es mutuable / 3) Es invariable.
- *Constitución* → cuando se reúnen los dos elementos que integran el domicilio real.
- *Conservación* → el domicilio real dura mientras no se cambie.

• *Cambio y extinción del domicilio* → el domicilio puede cambiarse de un lugar a otro. Operado el cambio, el nuevo domicilio extingue automáticamente al anterior.

• *Domicilio ignorado* → Cuando el domicilio de una persona no es conocido, lo tendrá en el lugar donde se encuentra. Si el lugar donde se encuentra también es desconocido, su domicilio será su último domicilio conocido (conf. art. 76).

B DOMICILIO LEGAL

El domicilio legal es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una persona determinada reside de una manera permanente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones (conf. art. 74).

Características

- 1) Es forzoso
- 2) Es excepcional

Se establece cuáles serán los domicilios legales en algunos casos específicos

Casos enumerados en el art. 74

- a) *Funcionarios públicos* → lugar en que deben cumplir sus funciones.
- b) *Militares en servicio activo* → lugar en que lo están prestando.
- c) *Transeúntes; personas de ejercicio ambulante; los que no tienen domicilio conocido* → lugar de su residencia actual.
- d) *Personas incapaces* → domicilio de sus representantes legales.

C DOMICILIO ESPECIAL

El domicilio especial es el que se establece sólo para ciertas relaciones jurídicas determinadas.

Ej: domicilio contractual; domicilio procesal, domicilio conyugal, etc.

En el nuevo Código Civil y Comercial sólo se regula el "domicilio contractual" → Art. 75

• *Domicilio contractual* → Es el que fija una persona en un contrato, para todos los efectos legales derivados de ese acto jurídico, como ser el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. El domicilio contractual es voluntario, (las partes pueden o no fijarlo). Efecto principal → "prórroga de la jurisdicción".

• *Domicilio procesal* → Es el que está obligado a constituir toda persona que intervenga en un juicio (Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, art. 40).

• *Domicilio conyugal* → Es el lugar donde viven los cónyuges. El nuevo Código Civil y Comercial no lo regula, a pesar de que lo menciona en varias normas.

CAPÍTULO XI AUSENCIA SIMPLE Y AUSENCIA CON PRESUNCIÓN DE FALLECIMIENTO.

La ausencia simple y la ausencia con presunción de fallecimiento estaban reguladas por la Ley 14.394. El nuevo Código Civil y Comercial regula la ausencia simple (arts. 79 a 84) y la "ausencia con presunción de fallecimiento" (arts. 85 a 92). La normativa de la Ley 14.394 quedó derogada.

AUSENCIA SIMPLE

Concepto.-

La desaparición de una persona del lugar de su domicilio real, sin que se tengan noticias de ella y sin que haya dejado apoderado que se ocupe de administrar sus bienes, da lugar a la declaración de ausencia simple, por la cual se le nombra un curador al ausente a fin de asegurar la conservación de sus bienes. La función del curador terminará si el ausente se presenta, si el ausente fallece o si se declara su fallecimiento presunto.

Art. 79.- "Ausencia simple. Si una persona ha desaparecido de su domicilio, sin tenerse noticias de ella, y sin haber dejado apoderado, puede designarse un curador a sus bienes si el cuidado de éstos lo exige. La misma regla se debe aplicar si existe apoderado, pero sus poderes son insuficientes o no desempeña convenientemente el mandato."

Requisitos.-

La ausencia simple se configura cuando una persona:

- a) desapareció de su domicilio real, sin tenerse noticias de ella (nótese que la norma no fija término de desaparición para pedir la declaración de ausencia simple);
- b) tiene bienes que requieren ser administrados o protegidos;
- c) no dejó apoderado, o el apoderado que dejó tiene poderes insuficientes, o no desempeña convenientemente el mandato.

Legitimación para solicitarla.-

¿Quiénes están legitimados para pedir la declaración de ausencia y el consiguiente nombramiento de un curador?. La respuesta la da el art. 80: el Ministerio Público y toda persona que tenga interés legítimo respecto de los bienes del ausente (Ej: los herederos del ausente, sus socios, sus acreedores, etc.).

Gran parte de la doctrina considera que la intervención del Ministerio Público sólo se justifica cuando represente a un incapaz que tenga interés legítimo en los bienes del ausente.

Juez competente.-

Es competente el juez del domicilio del ausente. Si éste no tuvo domicilio en el país, o no es conocido, es competente el juez del lugar en donde existan bienes cuyo cuidado es necesario; si existen bienes en distintas jurisdicciones, el juez que haya prevenido, es decir, el juez que haya intervenido (conf. art. 81).

Procedimiento.-

Pedida la declaración de ausencia simple ante el juez competente, al presunto ausente se lo cita por edictos durante 5 días (ej: en el Boletín Oficial), y si vencido el plazo no comparece, para garantizar la defensa en juicio se da intervención al defensor oficial o, en su defecto, se le nombra un defensor al ausente. El Ministerio Público es parte necesaria en el juicio.

Si antes de la declaración de ausencia se promueven acciones contra el ausente, debe representarlo el defensor. En caso de urgencia, el juez puede designar un administrador provisional o adoptar las medidas que las circunstancias aconsejan para conservar los bienes (conf. art. 82).

Sentencia.-

Una vez oído el defensor, y si concurren los extremos legales, se declara la ausencia y se nombra un curador. Para la designación se debe estar a lo previsto para el discernimiento de curatela (ver arts. 138 a 140).

El curador sólo puede realizar los actos de conservación y administración ordinaria de los bienes (ej: pagar deudas, impuestos, etc). Todo acto que exceda la administración ordinaria (ej: venta de un bien) debe ser autorizado por el juez; la autorización debe ser otorgada sólo en caso de necesidad evidente e impostergable.

Los frutos de los bienes administrados deben ser utilizados para el sostenimiento de los descendientes, cónyuge, conviviente y ascendientes del ausente (conf. art. 83).

Conclusión de la curatela.-

La curatela termina si el ausente se presenta (personalmente o por apoderado); si fallece; o si se declara judicialmente su fallecimiento presunto (conf. art. 84).

AUSENCIA CON PRESUNCIÓN DE FALLECIMIENTO

Concepto.-

La ausencia con presunción de fallecimiento, comprende aquellos casos en que una persona desaparece de su domicilio y del lugar de sus actividades, por un período

de tiempo bastante prolongado, y sin que se tengan noticias sobre su existencia o paradero. En estos casos, la desaparición del domicilio, la falta de noticias, y el transcurso de un tiempo más o menos largo, hacen surgir la duda acerca de si la persona está viva, muerta, oculta, etc., duda a la cual pone punto final la ley, estableciendo que en estos casos se habrá de presumir el fallecimiento. El tiempo que debe transcurrir varía según se trate del caso ordinario o de los casos extraordinarios.

Distintos casos.-

1) **Caso ordinario (3 años)**: consiste en que la persona haya desaparecido de su domicilio sin que se tengan noticias de ella. En esta hipótesis, pasados 3 años sin que se tengan noticias, la ley presume su muerte, aunque haya dejado apoderado. Los 3 años se cuentan desde la fecha de la última noticia que se tuvo de la existencia del ausente (conf. art. 85).

2) **Caso extraordinario genérico (2 años)**: contempla circunstancias extraordinarias de desaparición, y por ello se reduce el tiempo (por ej: haberse encontrado en un lugar donde hubo un incendio, o un terremoto, o acciones de guerra, etc.). El art. 86 establece:

Art. 86.- "Casos extraordinarios. Se presume también el fallecimiento de un ausente: a) si por última vez se encontró en el lugar de un incendio, terremoto, acción de guerra u otro suceso semejante, susceptible de ocasionar la muerte, o participó de una actividad que implique el mismo riesgo, y no se tiene noticia de él por el término de dos años, contados desde el día en que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido;..."

3) **Caso extraordinario específico (6 meses)**: contempla los casos especiales de naufragio o pérdida de un buque o aeronave. El art. 86, inc. b, establece:

Art. 86.- "Casos extraordinarios. Se presume también el fallecimiento de un ausente: ...b) Si encontrándose en un buque o aeronave naufragados o perdidos, no se tuviere noticia de su existencia por el término de seis meses desde el día en que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido".

El fundamento de las diferencias de plazo entre el extraordinario genérico y el específico, es que en el último hay una mayor probabilidad de que se haya producido la muerte.

Cómputo de los términos.-

Los términos se cuentan:

- si se trata del **caso ordinario**, desde la fecha de la última noticia;
- si se trata de los **casos extraordinarios**, desde el día en que el suceso ocurrió, o pudo haber ocurrido.

Legitimación para solicitarla.-

¿Quiénes pueden pedir la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento? Todos los que tuvieren algún derecho subordinado a la muerte del ausente, así

por ejemplo, el cónyuge, el conviviente, los herederos, los legatarios e incluso el Fisco, pues percibirá impuestos por la sucesión. Por el contrario, no podrán pedir la declaración, los amigos o los familiares sin derecho a heredar.

Los requisitos para que el pedido sea admitido son:

- 1) Presentarlo ante el juez competente (el del domicilio del ausente);
- 2) Acreditar ser titular de un derecho subordinado a la muerte del ausente (ej.: ser el cónyuge, heredero legítimo, etc.).
- 3) Acreditar que la persona falta de su domicilio y la realización de diligencias tendientes a la averiguación de la existencia del ausente.

Procedimiento.-

- 1) Reunidos los requisitos para que el pedido sea viable, se abre el juicio.
- 2) El juez nombra un defensor al ausente, o le da intervención al Defensor Oficial.
- 3) El juez le designa curador a los bienes (siempre que no hubiese mandatario con poderes suficientes, o que habiéndolo, no desempeñase convenientemente el mandato).
- 4) Se cita por edictos al ausente (una vez por mes, durante 6 meses).
- 5) Pasados los 6 meses de citación, se produce la recepción de prueba.

Se debe probar:

- a) la ausencia y la falta de noticias, durante los plazos legales (3 o 2 años, o 6 meses, según los casos);
 - b) que se han realizado diligencias tendientes a averiguar la existencia y paradero del ausente (la prueba de la realización de estas diligencias, puede ser llevada a cabo por testigos o por cualquier otro medio de prueba);
 - c) si se tratase de uno de los casos extraordinarios, se deberá probar el hecho (ej: el incendio, terremoto, naufragio, etc.), y que la persona se encontraba en el suceso.
- 6) Luego se oye al defensor (se expide sobre el mérito de las pruebas producidas).
 - 7) Si procede, se declara el fallecimiento presunto, se fija el día presuntivo de la muerte, y se ordena la inscripción de la sentencia en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas.

La declaración de simple ausencia no constituye presupuesto necesario para la declaración de fallecimiento presunto, ni suple la comprobación de las diligencias realizadas para conocer la existencia del ausente.

La sentencia declarando el fallecimiento presunto, **no hace cosa juzgada**; por lo tanto, cualquiera de los interesados podría dejarla sin efecto, demostrando la existencia del ausente en la actualidad o con posterioridad al día en que se presumió su muerte.

En el Código de Vélez, antes de la Ley 17.711, el art. 54 inc. 5 declaraba incapaces de hecho absoluto a los ausentes declarados tales en juicio. La Ley 17.711, con buen criterio derogó este inciso ya que nada impide que estas personas lleven a cabo actos jurídicos válidos (ej: una compraventa) en el lugar donde se encuentren.

Día presuntivo del fallecimiento.-

El juez debe establecer el día que se presume que ocurrió el fallecimiento. Conforme al art. 90, debe fijarse como día presuntivo del fallecimiento:

- a) en el caso ordinario, el último día del primer año y medio;
- b) en el primero de los casos extraordinarios, el día del suceso (ej: el día del incendio), y si no está determinado el día del suceso (ej: un tsunami que duró varios días), el día del término medio de la época en que ocurrió o pudo haber ocurrido;
- c) en el segundo caso extraordinario, el último día en que se tuvo noticia del buque o aeronave perdidos;

Cuando fuere posible, la sentencia determinará también la hora presuntiva del fallecimiento. En caso contrario, se tendrá por sucedido a la expiración del día declarado como presuntivo del fallecimiento (a las 24 horas).

Efectos de la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento.-

a) **Efectos sobre el Matrimonio.**- La sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento es causal de disolución del matrimonio (conf. art. 435, inc. b).

b) **Efectos sobre los Bienes.**- La declaración de ausencia con presunción de fallecimiento permite abrir la sucesión del ausente. Previo inventario de los bienes del ausente los mismos se entregarán a los herederos y legatarios (los bienes se inscriben en el registro con la prenotación del caso). Los herederos y legatarios no tendrán un dominio pleno sobre los bienes ya que, si bien pueden hacer la partición de los mismos, durante un tiempo (período de prenotación) no podrán enagenarlos ni gravarlos, salvo con autorización judicial.

Si entregados los bienes reaparece el ausente o se tiene noticia cierta de su existencia, queda sin efecto la declaración de fallecimiento, procediéndose a la devolución de aquéllos a petición del interesado (conf. art. 91).

Si el ausente reaparece durante el periodo de prenotación, el sucesor poseedor deberá devolver todos los bienes.

Prenotación.-

La "prenotación" consiste en que cuando los bienes registrables se inscriben en el registro, se deje aclarado que dichos bienes provienen de una sucesión abierta a raíz de una declaración de fallecimiento presunto. Garantiza la no enajenación de los bienes, pues los terceros que intenten comprarlos, en virtud de la prenotación en el registro, estarán advertidos de que corren el riesgo de perderlos si llegase a aparecer el presunto muerto.

La prenotación es una garantía con respecto a los bienes inmuebles o a los muebles registrables (ej.: automotores), pero no respecto de los muebles no registrables (ej.: televisor, heladera, etc.).

Conclusión de la prenotación. Dominio pleno.-

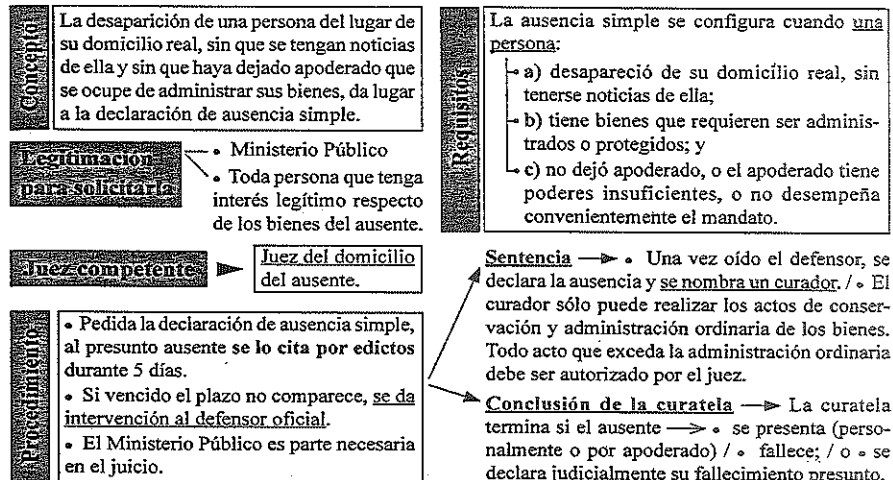
Según el art. 92 del nuevo Código Civil y Comercial, transcurridos 5 años desde el día presuntivo del fallecimiento u 80 años desde el nacimiento de la persona, queda sin efecto la prenotación prescripta, pudiendo, desde ese momento, disponerse libremente de los bienes.

Si el ausente reaparece, puede reclamar:

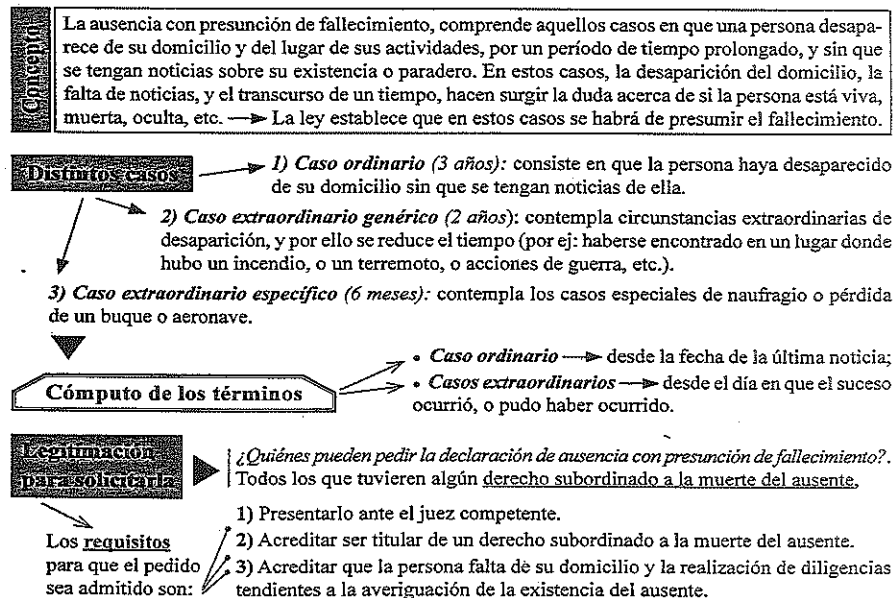
- la entrega de los bienes que existiesen, en el estado en que se hallasen;
- los adquiridos con el valor de los que faltan;
- el precio adeudado de los enajenados;
- los frutos no consumidos.

- El nuevo Código Civil y Comercial regula → "Ausencia simple" (arts. 79 a 84); y
→ "Ausencia con presunción de fallecimiento" (arts. 85 a 92).
- La normativa anterior que las regulaba (Ley 14.394) quedó derogada.

AUSENCIA SIMPLE



AUSENCIA CON PRESUNCIÓN DE FALLECIMIENTO



ProcedimientoArt.
90

- 1) Reunidos los requisitos, se abre el juicio.
- 2) El juez nombra un defensor al ausente, o le da intervención al Defensor Oficial.
- 3) El juez le designa curador a los bienes.
- 4) Se cita por edictos al ausente.
- 5) Pasados los 6 meses de citación, se produce la recepción de prueba.
- 6) Se oye al defensor.
- 7) Si procede, se declara el fallecimiento presunto, se fija el día presuntivo de la muerte, y se ordena la inscripción de la sentencia en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas.

• La sentencia declarando el fallecimiento presunto —> **no hace cosa juzgada**. Por lo tanto, cualquiera de los interesados podría dejarla sin efecto, demostrando la existencia del ausente en la actualidad o con posterioridad al día en que se presumió su muerte.

Día presuntivo del fallecimiento

- a) En el **caso ordinario** —> el último día del primer año y medio;
- b) En el **primer caso extraordinario** —> el día del suceso; y si no está determinado el día del suceso, el día del término medio de la época en que ocurrió o pudo haber ocurrido;
- c) En el **segundo caso extraordinario** —> el último día en que se tuvo noticia del buque o aeronave perdidos.

Efectos de la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento:

a) Efectos sobre el Matrimonio	➤ Es causal de disolución del matrimonio (conf. art. 435, inc. b).
b) Efectos sobre los Bienes	➤ Permite <u>abrir la sucesión</u> del ausente. Si entregados los bienes <u>reaparece el ausente</u> o se tiene noticia cierta de su existencia, queda sin efecto la declaración de fallecimiento, procediéndose a la devolución de aquéllos a petición del interesado (conf. art. 91).

Prenotación

- La "prenotación" consiste en que cuando los bienes registrables se inscriben en el registro, se deje aclarado que dichos bienes provienen de una sucesión abierta a raíz de una declaración de fallecimiento presunto.
- **Conclusion de la prenotación. Dominio pleno** —> Transcurridos 5 años desde el día presuntivo del fallecimiento u 80 años desde el nacimiento de la persona, queda sin efecto la prenotación prescripta, pudiendo, desde ese momento, disponerse libremente de los bienes.

Si el ausente
reaparece.

puede reclamar:

- a) la entrega de los bienes que existiesen, en el estado en que se hallasen;
- b) los adquiridos con el valor de los que faltan;
- c) el precio adeudado de los enajenados;
- d) los frutos no consumidos.

CAPÍTULO XII**FIN DE LA EXISTENCIA DE LA PERSONA HUMANA****Concepto.-**

El fin de la existencia de la persona humana es determinada por su muerte. Así lo expresa el art. 93.

Art. 93.- "Principio general. La existencia de la persona humana termina por su muerte."

En el nuevo Código Civil y Comercial, el fin de la existencia de la persona se trata sólo en tres artículos (arts. 93 a 95).

"Muerte civil" y "Muerte natural".-

El Código de Vélez trataba el fin de la existencia de la persona física a través de varios artículos (arts. 103 a 109). En el art. 103 decía: "*Termina la existencia de las personas por la muerte natural de ellas. La muerte civil no tendrá lugar en ningún caso, ni por pena, ni por profesión en las comunidades religiosas.*"

En los artículos siguientes se refería a distintos casos de muerte y al modo de probar los fallecimientos según el fallecido se encontrara en el país, en alta mar o en el extranjero, fuera un militar en combate o en campaña, un fallecido en un convento, cuartel, prisión, etc.

El nuevo Código Civil y Comercial (a diferencia del Código de Vélez) **no habla de la "muerte civil"**, porque sería redundante hacerlo ya que esa institución no es admitida en la legislación moderna y sería violatoria de nuestra Constitución.

Vale aclarar que en las antiguas legislaciones, como la española, existía la "muerte civil", institución por la cual cuando una persona cometía determinados delitos, o ingresaba en una comunidad religiosa haciendo votos de pobreza, obediencia y castidad, dicha persona debía ser considerada muerta para la vida civil y se la privaba de todos los derechos civiles.

Tampoco usa la expresión "muerte natural" que Vélez utilizó para distinguirla de la "muerte civil", porque carecería de importancia ya que la muerte es un hecho biológico y objetivo que pone fin a la vida de la persona sin importar que esa muerte se haya producido por vejez, por enfermedad, por accidente, o por el hecho de otro (como sería un homicidio).

Comprobación de la muerte.-

Producida la muerte, termina la existencia de la persona humana y se desencadena una serie de efectos: se disuelve el matrimonio; se abre la sucesión del difunto y se transmiten los derechos patrimoniales a sus herederos; etc.

Pero, para que todos estos efectos se produzcan, será necesario comprobar la muerte es decir, tener seguridad de que la muerte se ha producido y es irreversible.

Art. 94.- "Comprobación de la muerte. La comprobación de la muerte queda sujeta a los estándares médicos aceptados, aplicándose la legislación especial en el caso de ablación de órganos del cadáver."

Si la persona está muerta irreversiblemente, es tarea de la ciencia médica determinarlo. Por ello, la norma dice que la comprobación de la muerte queda sujeta a los "estándares médicos aceptados".

• El caso de la ablación de órganos del cadáver.- En el caso de la *ablación de órganos* de un cadáver, en donde muchas veces el éxito del trasplante depende de que la extracción de órganos se haga inmediatamente después de la muerte, hay que extremar los recaudos; y por ello el art. 94 remite (en este caso) a la legislación especial, que actualmente es la Ley 24.193 sobre Trasplantes.

La Ley 24.193 (Sanc: Marzo de 1993; Prom: Abril de 1993) indica cómo diagnosticar la muerte bajo criterios neurológicos en sus arts. 23 y 24.

Por el art. 23 de la ley, se considerará que una persona ha fallecido cuando, de modo acumulativo, se verifiquen los siguientes signos, que deberán persistir ininterrumpidamente seis (6) horas después de su constatación conjunta:

- a) Ausencia irreversible de respuesta cerebral, con pérdida absoluta de conciencia;
- b) Ausencia de respiración espontánea;
- c) Ausencia de reflejos cefálicos y constatación de pupilas fijas no reactivas;
- d) Inactividad encefálica corroborada por medios técnicos y/o instrumentales adecuados a las diversas situaciones clínicas, cuya nómina será periódicamente actualizada por el Ministerio de Salud y Acción Social con el asesoramiento del Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI).

La verificación de los signos referidos en el inciso d) no será necesaria en caso de paro cardiorespiratorio total e irreversible.

Por el art. 24 de la ley, la *certificación del fallecimiento* deberá ser suscripta por dos (2) médicos, entre los que figurará por lo menos un neurólogo o neurocirujano. Ninguno de ellos será el médico o integrará el equipo que realice ablaciones o implantes de órganos del fallecido.

La hora del fallecimiento será aquella en que por primera vez se constataron los signos previstos en el artículo 23.

Lo visto es para comprobar la muerte desde el punto de vista médico, pero para acreditar jurídicamente la muerte hay que atenerse a lo dispuesto por los arts. 96 a 99. Por lo tanto, jurídicamente, la muerte de una persona fallecida en nuestro país se prueba con la partida del Registro Civil.

Conmoriencia.-

Art. 95.- "Conmoriencia. Se presume que mueren al mismo tiempo las personas que perecen en un desastre común o en cualquier otra circunstancia, si no puede determinarse lo contrario."

Imaginemos que, ocurrido un accidente, mueran en él varias personas de las cuales una es heredera de otra; así por ejemplo, en un viaje mueren un padre y su hijo casado y no se sabe quien murió primero. Esto último es de gran importancia, dado que el último en morir, habrá de heredar al otro, y transmitir los bienes a sus parientes.

La cuestión de saber quién murió primero, dio lugar a diferentes teorías:

• Teoría de los premorientes.- Seguida por el Código Francés, establece un orden de fallecimientos basándose en que determinadas personas por su edad o por su sexo fallecen antes que otras (Ej: si muere una persona de 16 años y otra de 60 años, se considera que murió primero el mayor, pues se presume que el más joven tiene más resistencia).

• Teoría de los conmorientes.- Seguida por el Código de Vélez en el art. 109 y por el nuevo Código Civil y Comercial en el art. 95, considera que si varias personas mueren en un desastre común, sin que pueda saberse cuál de ellas murió primero, se presume que todas fallecieron al mismo tiempo, y por lo tanto no habrá transmisión de derechos entre ellas.

PRUEBA DEL NACIMIENTO, DE LA MUERTE Y DE LA EDAD.

En el nuevo Código Civil y Comercial, las reglas sobre prueba del nacimiento y fallecimiento de una persona se han modernizado y simplificado. Cualquiera de esos hechos (nacimiento o fallecimiento) y sus circunstancias de tiempo y lugar, sexo, nombre y filiación de la persona, se prueba con las partidas del Registro Civil.

Art. 96.- "Medio de prueba. El nacimiento ocurrido en la República, sus circunstancias de tiempo y lugar, el sexo, el nombre y la filiación de las personas nacidas, se prueba con las partidas del Registro Civil.

Del mismo modo se prueba la muerte de las personas fallecidas en la República.

La rectificación de las partidas se hace conforme a lo dispuesto en la legislación especial."

PARTIDAS DEL REGISTRO CIVIL.-

Concepto.-

Las *Partidas del Registro Civil* son los asientos que se llevan en los libros de dicho Registro, y las copias que de ellos se saquen según el procedimiento que indica la ley.

Carácter y eficacia probatoria.-

Las partidas (y sus copias) son "instrumentos públicos", pues ellas son extendidas por funcionarios públicos (los funcionarios del Registro) y con los requisitos que indica la ley (ver art. 289 inc. b).

Dado este carácter, ellas hacen plena fe: a) de su contenido en cuanto a los hechos ocurridos en presencia del oficial público, hasta que sea declarado falso en juicio; b) del contenido de las declaraciones... y enunciaciones de hechos relacionados con el objeto del acto instrumentado, hasta que se produzca prueba en contrario (conf. art. 296).

Las partidas del Registro Civil son el medio de prueba de los hechos relativos al estado civil que se hayan producido en la Argentina. Con relación a esto, corresponde aclarar lo siguiente:

a) antes de la creación de los Registros Civiles: los actos relativos al estado civil se probaban por las partidas parroquiales, e incluso se les reconocía carácter de instrumentos públicos y se presumía la veracidad de su contenido.

b) después de la creación de los Registros Civiles: la función probatoria corresponde a las "partidas del Registro Civil", aunque el art. 98 admite otros medios de prueba.

Requisitos de las partidas.-

Las partidas, dado que son instrumentos públicos, deben reunir los requisitos de estos (capacidad y competencia del funcionario público que otorga el acto y observancia de las formalidades que indica la ley).

Pero, además, debe reunir otros requisitos propios, como ser: registrarse en los libros correspondientes, una después de otra, en orden numérico y cronológico; ser firmada por el oficial público y las personas intervinientes, previa lectura del texto; consignar nombre, apellido, domicilio y número de documento de identidad de los intervinientes, etc.

Ley 26.413 ("Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas").-

Todo lo relativo al *Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas* está regulado por la Ley 26.413, la cual establece que este Registro será organizado por los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y estará a cargo de un director general, el que deberá poseer título de abogado (conf. art. 2).

En el art. 23 se establece que los testimonios, copias, certificados, libretas de familia o cualesquiera otros documentos expedidos por la dirección general, son instrumentos públicos y crean la presunción legal de la verdad de su contenido en los términos prescritos por el Código Civil. Esta documentación no podrá retenerse por autoridad judicial o administrativa ni por entidades o personas privadas.

En general, las partidas una vez asentadas y firmadas (por el oficial del Registro, las partes y los testigos) ya no se podrán modificar. Sin embargo, si en ellas existen fallas, errores u omisiones podrán anularse o rectificarse.

Nulidad de las partidas.-

Respecto de las partidas, ellas serán nulas, por ej, si el oficial público carece de capacidad o de competencia para el acto; o si no se han observado las formalidades legales.

Respecto a las omisiones o errores, debemos diferenciar:

- Habrá nulidad si ellos son sustanciales. Ej: si faltan las firmas del oficial público, de las partes o de los testigos; si la partida en cuestión no está registrada en el libro correspondiente; cuando el hecho asentado es falso, tal el caso de la partida de defunción de una persona que, en la realidad, no ha fallecido.

- No habrá nulidad si ellos son susceptibles de subsanarse. Ej: si hay errores en la edad, en los nombres, en el estado civil, etc., de los intervinientes, y ellos no hacen a la validez del acto que se asienta; si las inscripciones se registraran sin el orden correlativo, numérico y cronológico; etc.

Rectificación de las partidas.-

Conforme al art. 96 in fine, la rectificación de las partidas se hace conforme a lo dispuesto en la legislación especial (Ley 26.413), la cual en el art. 15 dispone que "*Registrada una inscripción, la misma no podrá ser modificada sino en virtud de resolución o disposición de autoridad competente.*"

La rectificación procede (por orden judicial) cuando se trate de errores u omisiones susceptibles de subsanar. Así, por ejemplo, procede la rectificación: si hay errores en la edad, en los nombres, en el estado civil, etc. de los intervinientes, y ellos no hacen a la validez del acto que se asienta; si las inscripciones se registraran sin el orden correlativo, numérico y cronológico; etc.

La Ley 26.413, en el art. 85 dice que la Dirección General, cuando compruebe la existencia de omisiones o errores materiales en las inscripciones de sus libros, que surjan evidentes del propio texto o de su cotejo con otros instrumentos públicos, podrá, de oficio o a petición de parte interesada, ordenar la modificación de dichas inscripciones previo dictamen letrado y mediante resolución o disposición fundada.

NACIMIENTO O MUERTE OCURRIDOS EN EL EXTRANJERO.-

Prueba.-

El nacimiento o muerte en país extranjero se prueba con la documentación extendida por el país extranjero donde ocurrió el nacimiento o muerte, la cual debe estar legalizada o autenticada del modo que dispongan las convenciones internacionales y, a falta de convenciones, por las disposiciones consulares de la República.

El nacimiento de los hijos de argentinos y la muerte de los ciudadanos argentinos, se prueban por los certificados de los asientos practicados en los registros consulares argentinos.

Art. 97.- "Nacimiento o muerte ocurridos en el extranjero. El nacimiento o la muerte ocurridos en el extranjero se prueban con los instrumentos otorgados según las leyes del lugar donde se producen, legalizados o autenticados del modo que disponen las convenciones internacionales, y a falta de convenciones, por las disposiciones consulares de la República.

Los certificados de los asientos practicados en los registros consulares argentinos son suficientes para probar el nacimiento de los hijos de argentinos y para acreditar la muerte de los ciudadanos argentinos."

Inscripción en el Registro.-

Conforme a la Ley 26.413 (arts. 74 y 75), la inscripción de estos documentos en el Registro se hace en un libro especial. Para inscribir estos documentos es fundamental que estén legalizados por la autoridad competente, de lo contrario no se inscriben. Si están en idioma extranjero, se debe acompañar la traducción hecha por traductor público matriculado. La Ley 26.413 establece que "Las inscripciones de documentos de extraña jurisdicción se asentarán en libros especiales que a tal efecto habilite la dirección general, consignando todos los datos que ellos contengan. No se registrará ningún documento que no se hallare debidamente legalizado por autoridad competente."

FALTA DE REGISTRO O NULIDAD DEL ASIENTO.-

La norma admite la prueba supletoria. La prueba fundamental la constituyen las partidas pero cuando es imposible presentarlas (sea porque no hay Registros públicos, o porque el asiento falta o es nulo), se admite acreditar el nacimiento y la muerte por otros medios de prueba, como ser: las partidas parroquiales; la libreta de familia; el pasaporte extranjero; testigos; pericias médicas; presunciones; etc. Es importante para que se admita la prueba supletoria, acreditar que es imposible presentar la partida.

En los casos en que el cadáver de una persona no fue hallado o no pudo ser identificado, el juez igual puede tener por comprobada la muerte y disponer la pertinente inscripción si la desaparición se produjo en circunstancias tales que la muerte debe ser tenida como cierta.

Art. 98.- "Falta de registro o nulidad del asiento. Si no hay registro público o falta o es nulo el asiento, el nacimiento y la muerte pueden acreditarse por otros medios de prueba. Si el cadáver de una persona no es hallado o no puede ser identificado, el juez puede tener por comprobada la muerte y disponer la pertinente inscripción en el registro, si la desaparición se produjo en circunstancias tales que la muerte debe ser tenida como cierta."

DETERMINACIÓN DE LA EDAD.-

En aquellos casos en que sea imposible determinar la edad de una persona (ya sea por no existir la partida, o por ser imposible conseguirla, o por no poder acreditar la edad a través de otros medios de prueba, etc), debe determinarla el juez, previo dictamen de peritos.

Art. 99.- "Determinación de la edad. Si no es posible establecer la edad de las personas por los medios indicados en el presente Capítulo, se la debe determinar judicialmente previo dictamen de peritos."

FIN DE LA EXISTENCIA DE LA PERSONA HUMANA

Principio general → "La existencia de la persona humana termina por su muerte." (conf. art. 93).

Producida la muerte, termina la existencia de la persona humana y se desencadena una serie de efectos → se disuelve el matrimonio; se abre la sucesión del difunto y se transmiten los derechos patrimoniales; etc.

Pero, para que todos estos efectos se produzcan, será necesario comprobar la muerte, es decir, tener seguridad de que la muerte se ha producido y es irreversible.

Art. 94 → "Comprobación de la muerte. La comprobación de la muerte queda sujeta a los estándares médicos aceptados, aplicándose la legislación especial en el caso de ablación de órganos del cadáver."

• Si la persona está muerta irreversiblemente, es tarea de la ciencia médica determinarlo. Por ello, la norma dice que la comprobación de la muerte queda sujeta a los "estándares médicos aceptados".

Ablación de órganos del cadáver → Ley 24.193 indica cómo diagnosticar la muerte bajo criterios neurológicos

- a) Ausencia irreversible de respuesta cerebral
- b) Ausencia de respiración espontánea;
- c) Ausencia de reflejos cefálicos, y pupilas fijas no reactivas;
- d) Inactividad encefálica corroborada por medios técnicos y/o instrumentales adecuados.

Comorienza

En caso de muerte de varias personas en un desastre común ¿quien murió primero?

2 Teorías

- **Teoría de los premorientes** → Establece un orden de fallecimientos → Determinadas personas por su edad o por su sexo fallecen antes que otras.
- **Teoría de los comorientes** → Si varias personas mueren en un desastre común, sin saberse cuál murió primero, presume que todas fallecieron al mismo tiempo → no habrá transmisión de derechos entre ellas (seguida por el CC de Vélez, y por el nuevo Código Civil y Comercial, art. 95).

PRUEBA DEL NACIMIENTO, DE LA MUERTE Y DE LA EDAD

Cualquiera de estos hechos (nacimiento o fallecimiento) y sus circunstancias de tiempo y lugar, sexo, nombre y filiación de la persona, se prueba con las partidas del Registro Civil (art. 96).

PARTIDAS DEL REGISTRO CIVIL → Son los asientos que se llevan en los libros de dicho Registro, y las copias que de ellos se saquen. → Son instrumentos públicos. → Hacén plena fe:

- a) de su contenido en cuanto a hechos ocurridos en presencia del oficial público, hasta que sea declarado falso en juicio;
- b) del contenido de las declaraciones... y anunciations de hechos relacionados con el objeto del acto instrumentado, hasta que se produzca prueba en contrario (conf. art. 296).

NACIMIENTO O MUERTE OCURRIDOS EN EL EXTRANJERO → Se prueba con la documentación extendida por el país extranjero donde ocurrió el nacimiento o muerte, la cual debe estar legalizada o autenticada del modo que dispongan las convenciones internacionales.

FALTA DE REGISTRO O NULIDAD DEL ASIENTO → La norma admite la prueba supletoria → Art. 98.

- La prueba fundamental la constituyen las partidas pero cuando es imposible presentarlas (sea porque no hay Registros públicos, o porque el asiento falta o es nulo), se admite acreditar el nacimiento y la muerte por otros medios de prueba, como ser: las partidas parroquiales; la libreta de familia; el pasaporte extranjero; testigos; pericias médicas; presunciones, etc.

DETERMINACIÓN DE LA EDAD → **Art. 99** → En aquellos casos en que sea imposible determinar la edad de una persona (ya sea por no existir la partida, o por ser imposible conseguirla, o por no poder acreditar la edad a través de otros medios de prueba, etc), debe determinarla el juez, previo dictamen de peritos.

CAPÍTULO XIII REPRESENTACIÓN Y ASISTENCIA TUTELA Y CURATELA

REPRESENTACIÓN Y ASISTENCIA

Ambos institutos tienen como fin superar las restricciones a la capacidad de ejercicio de que adolecen algunas personas, pero mientras en la *representación* se reemplaza la voluntad del representado (ej: el padre decide por el hijo menor), en el sistema de *asistencia por apoyos* sólo se asiste, se brinda ayuda a la persona con algún padecimiento para que tome la mejor decisión.

El apoyo no debe anular la voluntad del protegido sino todo lo contrario, debe tener como función la de promover la autonomía y facilitar la comunicación, la comprensión y la manifestación de voluntad de la persona protegida. La persona designada como apoyo sólo podrá representar al incapaz en determinados actos cuando así se disponga en la sentencia.

REPRESENTACIÓN.-

El art. 24 establece que no pueden ejercer por sí mismos sus derechos (incapaces de ejercicio):

- a) la persona por nacer;
- b) la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente, con el alcance dispuesto en la Sección 2ª de este Capítulo (*Menores de edad*);
- c) la persona declarada incapaz por sentencia judicial, en la extensión dispuesta en esa decisión.

El art. 100 fija como principio general que: "*Las personas incapaces ejercen por medio de sus representantes los derechos que no pueden ejercer por sí.*"

¿Quiénes son los representantes de esas personas? Lo dice el art. 101:

- a) de las personas por nacer, sus padres;
- b) de las personas menores de edad no emancipadas, sus padres. Si faltan los padres, o ambos son incapaces, o están privados de la responsabilidad parental, o suspendidos en su ejercicio, el tutor que se les designe;
- c) la persona declarada incapaz por sentencia judicial, en la extensión dispuesta en esa decisión. Así:
 - si es persona con capacidad restringida, el o los apoyos designados cuando, conforme a la sentencia, éstos tengan representación para determinados actos;
 - si es persona declarada incapaz, el curador que se les nombre.

Características.-

La representación de los incapaces es legal (la impone la ley), es necesaria (para la protección de la persona y bienes del incapaz), es dual (la actuación del representante se complementa con la actuación del Ministerio Público en el ámbito judicial y extrajudicial) y controlada (hay actos del representante legal que están bajo control judicial).

SISTEMA DE APOYOS (ASISTENCIA).-**Concepto.-**

El sistema de apoyos consiste en brindar asistencia en la toma de decisiones. Por "apoyo" debe entenderse cualquier medida de carácter judicial o extrajudicial que facilite la toma de decisiones a aquella persona que lo necesite, para dirigir su persona, administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos en general. El sistema de apoyos no reemplaza la voluntad del protegido sino que, por el contrario, respeta la voluntad, los deseos y preferencias del protegido, asistiéndolo para que tome la mejor decisión.

Art. 102.- "Asistencia. Las personas con capacidad restringida y las inhabilitadas son asistidas por los apoyos designados en la sentencia respectiva y en otras leyes especiales."

Actuación del Ministerio Público.-

La actuación del Ministerio Público respecto de personas menores de edad, incapaces y con capacidad restringida, y de aquellas cuyo ejercicio de capacidad requiera de un sistema de apoyos puede darse en el ámbito judicial o extrajudicial (conf. art. 103).

- En el ámbito judicial, puede ser complementaria o principal:

a) Es complementaria en todos los procesos en los que se encuentran involucrados intereses de personas menores de edad, incapaces y con capacidad restringida; la falta de intervención causa la nulidad relativa del acto.

b) Es principal:

- i) cuando los derechos de los representados están comprometidos, y existe inacción de los representantes;
- ii) cuando el objeto del proceso es exigir el cumplimiento de los deberes a cargo de los representantes;
- iii) cuando carecen de representante legal y es necesario proveer la representación.

- En el ámbito extrajudicial, el Ministerio Público actúa ante la ausencia, carencia o inacción de los representantes legales, cuando están comprometidos los derechos sociales, económicos y culturales (ej: derecho a recibir educación).

TUTELA**Concepto.-**

La **tutela** es la institución destinada a proteger la persona y bienes del menor que no ha alcanzado la plenitud de su capacidad civil, cuando no haya personas que ejerzan la responsabilidad parental (patria potestad en la terminología del código derogado), sea por no tener padres vivos, o porque estos tienen perdida o suspendida la responsabilidad parental. El tutor es el representante legal del menor en todas aquellas cuestiones patrimoniales que atañen al menor.

Art. 104.- "Concepto y principios generales. La tutela está destinada a brindar protección a la persona y bienes de un niño, niña o adolescente que no ha alcanzado la plenitud de su capacidad civil cuando no haya persona que ejerza la responsabilidad parental. Se aplican los principios generales enumerados en el Título VII del Libro Segundo. Si se hubiera otorgado la guarda a un pariente de conformidad con lo previsto en el Título de la responsabilidad parental, la protección de la persona y bienes del niño, niña y adolescente puede quedar a cargo del guardador por decisión del juez que otorgó la guarda, si ello es más beneficioso para su interés superior; en igual sentido, si los titulares de la responsabilidad parental delegaron su ejercicio a un pariente. En este caso, el juez que homologó la delegación puede otorgar las funciones de protección de la persona y bienes de los niños, niñas y adolescentes a quienes los titulares delegaron su ejercicio. En ambos supuestos, el guardador es el representante legal del niño, niña o adolescente en todas aquellas cuestiones de carácter patrimonial."

Características de la tutela.-

La tutela presenta las siguientes características:

- a) Es **representativa**: el tutor es el representante legal del menor en todos los actos civiles.
- b) Es **personalísima**: el cargo de tutor no es transmisible ni pasa a los herederos (conf. art. 105).
- c) Puede ser **unipersonal o dual**: puede ser ejercida por una o mas personas, conforme aquello que sea más beneficioso al menor. Si es ejercida por más de una persona y hay diferencias de criterio, las mismas serán dirimidas por el juez con la debida intervención del Ministerio Público (conf. art. 105).
- d) Es **controlada** por los jueces y el Ministerio Público.
- e) Puede ser **general o especial**. Es "general" la que está destinada a proteger, en general, la persona y bienes del menor que no ha alcanzado la plenitud de su capacidad civil (conf. art. 104). La tutela general puede ser: dada por los padres (por testamento o escritura pública) o dada por el juez (tutela dativa). Es "especial" la que se establece para administrar bienes determinados o para representar al menor en algún acto específico. En el nuevo Código se eliminó la "tutela legal".
- f) No es una **carga pública**: a diferencia del Código de Vélez, en el cual el ser tutor era una carga pública (el designado como tutor no podía excusarse de serlo,

salvo que tuviera una causa que lo justificara), en el nuevo Código Civil y Comercial, ser tutor no es una carga pública.

Tutela dada por los padres (por testamento o escritura pública).-

Conf. al art. 106, cualquiera de los padres que no se encuentre privado o suspendido del ejercicio de la responsabilidad parental puede nombrar tutor o tutores a sus hijos menores de edad, sea por testamento o por escritura pública. Esta designación debe ser aprobada judicialmente.

Se tienen por no escritas las disposiciones que eximen al tutor de hacer inventario, lo autorizan a recibir los bienes sin cumplir ese requisito, o lo liberan del deber de rendir cuentas.

Si los padres hubieran delegado el ejercicio de la responsabilidad parental en un pariente, se presume la voluntad de que se lo nombre tutor de sus hijos menores de edad, designación que debe ser discernida por el juez que homologó la delegación o el del centro de vida del niño, niña o adolescente, a elección del pariente.

Si existen disposiciones de ambos progenitores, se aplican unas y otras conjuntamente en cuanto sean compatibles. De no serlo, el juez debe adoptar las que considere fundadamente más convenientes para el tutelado.

Tutela dativa.-

Conf. al art. 107 es la que otorga el juez ante la ausencia de designación paterna de tutor o tutores o ante la excusación, rechazo o imposibilidad de ejercicio de aquellos designados. En este supuesto, el juez designa como tutor a la persona que sea más idónea para brindar protección al niño, niña o adolescente, debiendo fundar razonablemente los motivos que justifican dicha idoneidad.

Para evitar que el juez pueda verse favorecido con la designación del tutor, el Código establece que el juez no puede nombrar como tutor (conf. art. 108) a las siguientes personas:

- a) a su cónyuge, conviviente, o parientes (dentro del cuarto grado, o segundo por afinidad);
- b) a sus amigos íntimos, ni a los parientes de ellos (dentro del cuarto grado, o segundo por afinidad);
- c) a las personas con quienes tiene intereses comunes (ej: socios);
- d) a sus deudores o acreedores;
- e) a los integrantes de los tribunales nacionales o provinciales que ejercen sus funciones en el lugar del nombramiento; ni a los que tienen con ellos intereses comunes, ni a sus amigos íntimos o los parientes de éstos, dentro del cuarto grado, o segundo por afinidad;
- f) a quien es tutor de otro menor de edad, a menos que se trate de hermanos menores de edad, o existan causas que lo justifiquen.

Tutela especial.-

Es la que se establece para administrar bienes determinados o para representar al menor en algún acto específico. Así, conforme al art. 109, corresponde la designación judicial de tutores especiales en los siguientes casos:

- a) cuando existe conflicto de intereses entre los representados y sus representantes; si el representado es un adolescente puede actuar por sí, con asistencia letrada, en cuyo caso el juez puede decidir que no es necesaria la designación del tutor especial;
- b) cuando los padres no tienen la administración de los bienes de los hijos menores de edad;
- c) cuando existe oposición de intereses entre diversas personas incapaces que tienen un mismo representante legal, sea padre, madre, tutor o curador; si las personas incapaces son adolescentes, rige lo dispuesto en el inciso a);
- d) cuando la persona sujeta a tutela hubiera adquirido bienes con la condición de ser administrados por persona determinada o con la condición de no ser administrados por su tutor;
- e) cuando existe necesidad de ejercer actos de administración sobre bienes de extraña jurisdicción al juez de la tutela y no pueden ser convenientemente administrados por el tutor;
- f) cuando se requieren conocimientos específicos o particulares para un adecuado ejercicio de la administración por las características propias del bien a administrar;
- g) cuando existen razones de urgencia, hasta tanto se tramite la designación del tutor que corresponda.

Personas excluidas.-

Conf. el art. 110, no pueden ser tutores las personas:

- a) que no tienen domicilio en la República;
- b) quebradas no rehabilitadas;
- c) que han sido privadas o suspendidas en el ejercicio de la responsabilidad parental, o han sido removidas de la tutela o curatela o apoyo de otra persona incapaz o con capacidad restringida, por causa que les era atribuible;
- d) que deben ejercer por largo tiempo o plazo indefinido un cargo o comisión fuera del país;
- e) que no tienen oficio, profesión o modo de vivir conocido, o tienen mala conducta notoria;
- f) condenadas por delito doloso a penas privativas de la libertad;
- g) deudoras o acreedoras por sumas considerables respecto de la persona sujeta a tutela;
- h) que tienen pleitos con quien requiere la designación de un tutor. La prohibición se extiende a su cónyuge, conviviente, padres o hijos;
- i) que, estando obligadas, omiten la denuncia de los hechos que dan lugar a la apertura de la tutela;

j) inhabilitadas, incapaces o con capacidad restringida;

k) que hubieran sido expresamente excluidas por el padre o la madre de quien requiere la tutela, excepto que según el criterio del juez resulte beneficioso para el niño, niña o adolescente (conf. art. 110).

Los fundamentos para que no se les permita ser tutores son variados, en algunos casos se debe a una falta de idoneidad (ej: inc. k), en otros a la oposición de intereses (ej: incs. g y h). La prohibición también puede deberse a causas morales (ej: incs c, f, etc).

Obligados a denunciar.-

Cuando un menor (niño, niña o adolescente) carece de un adulto que lo proteja, dicha situación de vulnerabilidad debe ser denunciada a la autoridad dentro de los 10 días de conocida.

Están obligados a denunciar:

- a) Los parientes obligados a prestar alimentos al menor.
- b) El guardador o la persona a quien los padres designaron tutor o le delegaron el ejercicio de la responsabilidad parental.
- c) Los oficiales públicos del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas y otros funcionarios públicos (ej: del área policial, sanitaria, educativa, etc.) que en ejercicio de su cargo, tengan conocimiento de cualquier hecho que dé lugar a la necesidad de la tutela.

El obligado debe hacer la denuncia ante la autoridad competente (un juez, el Ministerio Público, la autoridad policial, etc.) dentro del plazo 10 días de haber conocido esta circunstancia. Al obligado que omite hacer la denuncia se lo priva de la posibilidad de ser designado tutor y se lo hace responsable de los daños y perjuicios que su omisión de denunciar le ocasione al niño, niña o adolescente.

Art. 111.- "Obligados a denunciar. Los parientes obligados a prestar alimentos al niño, niña o adolescente, el guardador o quienes han sido designados tutores por sus padres o éstos les hayan delegado el ejercicio de la responsabilidad parental, deben denunciar a la autoridad competente que el niño, niña o adolescente no tiene referente adulto que lo proteja, dentro de los diez días de haber conocido esta circunstancia, bajo pena de ser privados de la posibilidad de ser designados tutores y ser responsables de los daños y perjuicios que su omisión de denunciar le ocasione al niño, niña o adolescente. Tienen la misma obligación los oficiales públicos encargados del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas y otros funcionarios públicos que, en ejercicio de su cargo, tengan conocimiento de cualquier hecho que dé lugar a la necesidad de la tutela. El juez debe proveer de oficio lo que corresponda, cuando tenga conocimiento de un hecho que motive la apertura de una tutela."

Discernimiento de la tutela.-

• Concepto.- Para que el tutor pueda desempeñar su función no basta con su designación (ej: por los padres del menor), sino que además será necesario el dis-

cernimiento de la tutela. Se trata del acto por el cual el juez pone en posesión de su cargo al tutor designado.

• Juez competente.- En el Código de Vélez, el discernimiento de la tutela correspondía al juez del domicilio de los padres; en el nuevo Código Civil y Comercial (respondiendo al principio de inmediación) se establece que es competente el juez del lugar donde el menor tiene su centro de vida, es decir, donde reside habitualmente.

• Intervención del menor.- De acuerdo al art. 113, para el discernimiento de la tutela (como para cualquier otra decisión relativa a la persona menor de edad) el juez debe:

- a) oír previamente al menor,
- b) tener en cuenta sus manifestaciones en función de su edad y madurez;
- c) decidir atendiendo primordialmente a su interés superior.

• Actos anteriores al discernimiento.- Los actos del tutor anteriores al discernimiento de la tutela en principio no son válidos, pero quedan confirmados por el nombramiento, si de ello no resulta perjuicio para el niño, niña o adolescente (conf. art. 114).

Entrega de bienes, previo inventario y avalúo.-

Discernida la tutela, los bienes del tutelado deben ser entregados al tutor, previo inventario y avalúo que realiza quien el juez designa.

Si el tutor tiene un crédito contra la persona sujeta a tutela, debe hacerlo constar en el inventario; si no lo hace, no puede reclamarlo luego, excepto que al omitirlo haya ignorado su existencia.

Hasta tanto se haga el inventario, el tutor sólo puede tomar las medidas que sean urgentes y necesarias (ej: llamar un cerrajero, un plomero, etc).

Los bienes que el niño, niña o adolescente adquiera por sucesión u otro título deben inventariarse y tasarse de la misma forma (conf. art. 115).

Rendición de cuentas.-

El tutor tiene la obligación de rendir cuentas sobre la administración de bienes del menor, con todos los gastos debidamente justificados y documentados. La rendición de cuentas es una obligación ineludible de la cual ni siquiera los padres del menor pueden eximirlo (conf. art. 106). Si el tutor sucede a alguno de los padres o a otro tutor anterior, debe pedir inmediatamente, al sustituido o a sus herederos, rendición judicial de cuentas y entrega de los bienes del tutelado.

¿Cuando debe hacer la rendición de cuentas el tutor? Debe hacerla al término de cada año, al cesar en el cargo, y cuando el juez lo ordena (sea de oficio o a petición del Ministerio Público. Nada impide que sea el propio tutelado el que pida al juez o al Ministerio Público que su tutor rinda cuentas).

Rendición de cuentas final.-

Al terminar la tutela se debe hacer una rendición de cuentas final, y quien ejerza la tutela (o sus herederos) deben entregar los bienes de inmediato, e informar de la gestión dentro del plazo que el juez señale, aunque el tutelado en su testamento lo exima de ese deber. Las cuentas deben rendirse judicialmente con intervención del Ministerio Público (conf. arts. 130 y 131).

Los gastos para hacer efectiva la rendición de cuentas los adelanta el tutor, pero deben ser reembolsados por el tutelado.

Los gastos de gestión (gastos para ejercer la tutela protegiendo la persona y bienes del pupilo), si son razonables, deben ser restituidos al tutor aunque de ellos no resulte utilidad al tutelado (conf. arts. 133 y 134).

Actos del tutor.-

El tutor es el representante legal del menor en todas las cuestiones de carácter patrimonial; tiene a su cargo la protección de la persona y de los bienes del menor y a estos efectos hay actos que podrá realizar libremente, otros para los cuales necesitará autorización judicial y otros que tendrá prohibidos realizar. El juez fija las sumas requeridas para la educación y alimentos del menor, ponderando el valor de los bienes y la renta que producen.

Podrá realizar libremente actos ordinarios de administración relacionados con la protección del menor (ej: gastos de comida, ropa, educación, etc.) o con la protección de sus bienes (ej: reparaciones en inmuebles, pagos de impuestos, etc.).

Actos que requieren autorización judicial.-

Conf. art. 121, además de los actos para los cuales los padres necesitan autorización judicial (ej: actos de disposición sobre bienes de los hijos, conf. art. 692), el tutor debe requerirla para los siguientes actos:

- a) adquirir inmuebles o cualquier bien que no sea útil para satisfacer los requerimientos alimentarios del tutelado;
- b) prestar dinero de su tutelado. La autorización sólo debe ser concedida si existen garantías reales suficientes;
- c) dar en locación los bienes del tutelado o celebrar contratos con finalidad análoga por plazo superior a tres años. En todos los casos, estos contratos concluyen cuando el tutelado alcanza la mayoría de edad;
- d) tomar en locación inmuebles que no sean la casa habitación;
- e) contraer deudas, repudiar herencias o donaciones, hacer transacciones y remitir créditos aunque el deudor sea insolvente;
- f) hacer gastos extraordinarios que no sean de reparación o conservación de los bienes;

g) realizar todos aquellos actos en los que los parientes del tutor dentro del cuarto grado o segundo de afinidad, o sus socios o amigos íntimos están directa o indirectamente interesados.

Actos prohibidos.-

Según el art. 121, quien ejerce la tutela no puede, ni con autorización judicial, celebrar con su tutelado aquellos actos prohibidos a los padres respecto de sus hijos menores de edad (supuestos del art. 689, como por ej. obligar al tutelado como fiador suyo o de terceros).

Antes de aprobada judicialmente la cuenta final, el tutor no puede celebrar contrato alguno con el pupilo, aunque haya cesado la incapacidad.

El objetivo que persigue el Código al establecer estos "actos prohibidos" es evitar que se produzca un conflicto de intereses entre el tutor y el tutelado, viéndose perjudicado o demasiado expuesto el patrimonio de este último.

Responsabilidad.-

El tutor es responsable del daño causado al tutelado por su culpa, por acción u omisión, en el ejercicio o en ocasión de sus funciones.

¿Quiénes pueden solicitar las medidas judiciales necesarias para remediar ese daño? El tutelado, cualquiera de sus parientes, o el Ministerio Público, sin perjuicio de que sean adoptadas de oficio (conf. art. 118).

Además, el art. 134 establece que si el tutor no rinde cuentas, no lo hace debidamente o se comprueba su mala administración atribuible a dolo o culpa, debe indemnizar el daño causado a su tutelado. La indemnización no debe ser inferior a lo que los bienes han podido razonablemente producir.

Causas de terminación de la tutela.-

Según el art. 135, la tutela termina por las siguientes causas:

- Causas relativas al tutelado: por la muerte del tutelado, su emancipación o la desaparición de la causa que dio lugar a la tutela (ej: llegó a la mayoría de edad).
- Causas relativas al tutor: por la muerte, incapacidad, declaración de capacidad restringida, remoción o renuncia aceptada por el juez, de quien ejerce la tutela.

Si la tutela es dual (ejercida por 2 personas), la causa de terminación de una de ellas no afecta a la otra, que se debe mantener en su cargo, excepto que el juez estime conveniente su cese, por motivos fundados.

En caso de muerte del tutor, el albacea, heredero o el otro tutor si lo hubiera, debe ponerlo en conocimiento inmediato del juez de la tutela.

En su caso, debe adoptar las medidas urgentes para la protección de la persona y de los bienes del pupilo.

Remoción del tutor.-

Conf. art. 136, son causas de remoción del tutor:

- a) quedar comprendido en alguna de las causales que impide ser tutor;
- b) no hacer el inventario de los bienes del tutelado, o no hacerlo fielmente;
- c) no cumplir debidamente con sus deberes o tener graves y continuados problemas de convivencia.

¿Quiénes pueden pedir la remoción? El propio tutelado y el Ministerio Público. También puede disponerla el juez de oficio.

CURATELA**Concepto.-**

La *curatela* es la institución destinada a proteger la persona y bienes del que (por sus afecciones) ha sido declarado judicialmente incapaz, y que está fundamentalmente orientada a que la persona protegida recupere su salud.

Tutela y curatela tienen gran similitud ya que ambos institutos están destinados a la protección de la persona y sus bienes, diferenciándose básicamente por el sujeto, que en la curatela es una persona mayor declarada incapaz. Dada esta similitud la curatela se rige por las reglas de la tutela, salvo lo establecido específicamente para la curatela.

Art. 138.- "Normas aplicables. La curatela se rige por las reglas de la tutela no modificadas en esta Sección.

La principal función del curador es la de cuidar a la persona y los bienes de la persona incapaz, y tratar de que recupere su salud. Las rentas de los bienes de la persona protegida deben ser destinadas preferentemente a ese fin."

Función principal del curador.-

La función principal del curador es la de cuidar a la persona y los bienes del incapaz y tratar de que recupere su salud. Por ello, las rentas de los bienes de la persona protegida deben ser destinadas preferentemente a ese fin (conf. art. 138). Ejemplos: si se trata de una persona que padece alteraciones mentales, se tratará de que recupere su salud mental; si se trata de un inhabilitado por adicción al alcohol o las drogas, se tratará de que supere la adicción, etc.

¿Quién puede ser curador? De acuerdo al art. 139, puede ser curador:

- a) La persona que haya designado el propio protegido: en efecto, la propia persona (en la época de su capacidad plena), previendo una afección mental futura, puede designar, mediante una directiva anticipada, la persona o personas que habrán de ejercer su curatela. Esta designación debe ser aprobada por el juez.

Esta solución guarda relación con el art. 60 relativo a *directivas médicas anticipadas*, en el cual se expresa que: "La persona plenamente capaz puede anticipar

directivas y conferir mandato respecto de su salud y en previsión de su propia incapacidad. Puede también designar a la persona o personas que han de expresar el consentimiento para los actos médicos y para ejercer su curatela..."

b) La persona que hayan designado los padres (curatela dativa), pues los padres pueden nombrar curadores y apoyos de sus hijos incapaces o con capacidad restringida, en los casos y con las formas en que pueden designarles tutores. Por esta remisión a las normas sobre tutela, cualquiera de los padres, siendo capaces, pueden nombrar curador a sus hijos incapaces o con capacidad restringida, sea por testamento o por escritura pública. Esta designación debe ser aprobada por el juez. Si existen disposiciones de ambos progenitores, se aplican unas y otras conjuntamente en cuanto sean compatibles. De no serlo, el juez debe adoptar las que considere fundadamente más convenientes para el tutelado (conf. art. 106).

A falta de estas previsiones (no hay curador designado por el protegido ni por sus padres, o cuando los designados no pueden o no quieren asumir la función) el juez puede nombrar al cónyuge no separado de hecho, al conviviente, a los hijos, padres o hermanos de la persona a proteger, según quien tenga mayor aptitud.

Entre los mencionados no hay orden de preferencia para desempeñar la función, y será el juez quien elija teniendo en cuenta la idoneidad moral y económica de ellos.

Persona protegida con hijos.-

En el art. 140 se contempla el caso de que la persona protegida tenga hijos menores. Al respecto, se dispone que el curador de la persona (incapaz o con capacidad restringida) también sea el tutor de los hijos menores.

No obstante, también se admite que el juez otorgue la guarda del hijo menor de edad a un tercero (guardador), designándolo tutor para que lo represente en las cuestiones patrimoniales.

En esta norma se destaca que es admisible la posibilidad de coexistencia de diferentes figuras, como la de curador, tutor y guardador.

Terminación de la curatela.-

Por la remisión del art. 138, la curatela finaliza por las mismas causas que finaliza la tutela. Por ej: por la muerte del protegido; por la muerte, incapacidad, remoción o renuncia (aceptada por el juez) del curador (conf. art. 135); etc.

REPRESENTACIÓN Y ASISTENCIA

Ambos institutos tienen como fin superar las restricciones a la capacidad de ejercicio de que adolecen algunas personas.

- En la **representación** se reemplaza la voluntad del representado.
- En el sistema de **asistencia por apoyos** sólo se asiste, se brinda ayuda a la persona con algun padecimiento para que tome la mejor decisión.

REPRESENTACIÓN

Las personas incapaces ejercen sus derechos por medio de sus representantes, que son:

- a) de las personas por nacer → sus padres;
- b) de las personas menores de edad no emancipadas → sus padres; o (en su caso) el tutor designado;
- c) de la persona declarada incapaz por sentencia judicial, en la extensión dispuesta. Así:
 - si tiene **capacidad restringida** → el apoyo;
 - si es **declarada incapaz** → el curador.

SISTEMA DE APOYOS (ASISTENCIA)

"Apoyo" → cualquier medida de carácter judicial o extrajudicial que facilite la toma de decisiones a aquella persona que lo necesite, para dirigir su persona, administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos en general.

No reemplaza la voluntad del protegido, sino que se respetan sus deseos y preferencias, asistiéndolo para que tome la mejor decisión.

• Art. 102.- "Asistencia. Las personas con capacidad restringida y las inhabilitadas son asistidas por los apoyos designados en la sentencia respectiva y en otras leyes especiales.

TUTELA Y CURATELA

TUTELA

La **tutela** es la institución destinada a proteger la persona y bienes del menor que no ha alcanzado la plenitud de su capacidad civil, cuando no haya personas que ejerzan la responsabilidad parental.

Características

- a) Es representativa / b) Es personalísima / c) Puede ser unipersonal o dual / d) Es controlada / e) Puede ser general o especial / f) No es una carga pública.

Tutela dada por los padres

- Art. 106 → cualquiera de los padres que no se encuentre privado o suspendido del ejercicio de la responsabilidad parental puede nombrar tutor o tutores a sus hijos menores de edad, sea por testamento o por escritura pública.
- Esta designación debe ser aprobada judicialmente.

Tutela dativa

- La **tutela dativa** es la que otorga el juez ante la ausencia de designación paterna de tutor o tutores o ante la excusación, rechazo o imposibilidad de ejercicio de aquellos designados.
- En este supuesto, el juez designa como tutor a la persona que sea más idónea para brindar protección al niño, niña o adolescente, debiendo fundar razonablemente los motivos que justifican dicha idoneidad.
- Personas a las que el juez **no puede nombrar como tutor** → Art. 108.

Tutela especial

- Es la que se establece para administrar bienes determinados o para representar al menor en algún acto específico.
- El art. 109 enumera casos en los que corresponde la designación judicial de tutores especiales.

Personas excluidas

- Art. 110 → personas que **no pueden ser tutores**.
- Los fundamentos para que no se les permita ser tutores son variados, en algunos casos se debe a una **falta de idoneidad**, en otros a la **oposición de intereses**. La prohibición también puede deberse a **causas morales**.

Obligados a denunciar

Quando un menor carece de un adulto que lo proteja, dicha situación debe ser denunciada a la autoridad dentro de los 10 días de conocida.

- a) Los parientes obligados a prestarle alimentos;
- b) El guardador (o a quien los padres designaron tutor o le delegaron la responsabilidad parental);
- c) Los oficiales públicos del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas y **otros funcionarios** que conozcan la necesidad de la tutela.

• Están obligados a denunciar:

Discernimiento de la tutela

Para que el tutor pueda desempeñar su función no basta con su designación, sino que además será necesario el discernimiento de la tutela → Se trata del acto por el cual el juez pone en posesión de su cargo al tutor designado. Esto le compete al juez del lugar donde el menor tiene su centro de vida, es decir, donde reside habitualmente.

Entrega de bienes

Discernida la tutela, los bienes del tutelado deben ser entregados al tutor, previo inventario y avalúo que realiza quien el juez designa.

Rendición de cuentas

- El tutor tiene la **obligación** de rendir cuentas sobre la administración de bienes del menor, con todos los gastos debidamente justificados y documentados.
- Al **terminar la tutela** se debe hacer una rendición de cuentas final, y quien ejerza la tutela debe entregar los bienes de inmediato, e informar de la gestión en el plazo que el juez señale.

Actos del tutor

- El tutor es el representante legal del menor en todas las cuestiones patrimoniales; tiene a su cargo la protección de la persona y de los bienes del menor.
- Actos que podrá realizar libremente → actos ordinarios de administración relacionados con la **protección del menor** o con la **protección de sus bienes**.
- Actos para los cuales necesitará **autorización judicial** → actos para los cuales los padres necesitan autorización judicial + casos del art. 121 (7 supuestos).
- Actos que tendrá prohibidos → celebrar con su tutelado aquellos actos prohibidos a los padres respecto de sus hijos menores. Antes de aprobada judicialmente la cuenta final, el tutor no puede celebrar contrato con el pupilo, aunque haya cesado la incapacidad.

Responsabilidad

- El tutor es responsable del daño causado al tutelado por su culpa, por acción u omisión, en el ejercicio o en ocasión de sus funciones.
- Si el tutor no rinde cuentas, no lo hace debidamente o se comprueba su mala administración atribuible a dolo o culpa, debe **indemnizar el daño** causado a su tutelado.

Causas de terminación de la tutela

- **Relativas al tutelado:** muerte, emancipación o desaparición de causa que dio lugar a la tutela.
- **Relativas al tutor:** muerte, incapacidad, declaración de capacidad restringida, remoción o renuncia.

Causas de remoción del tutor (3) → Art. 136

CURATELA

La **curatela** es la institución destinada a proteger la persona y bienes del que ha sido declarado judicialmente incapaz, y que está orientada a que la persona protegida recupere su salud.

- Tutela y curatela tienen gran similitud ya que ambos institutos están destinados a la protección de la persona y sus bienes, diferenciándose básicamente por el sujeto, que en la curatela es una persona mayor declarada incapaz.
- La **curatela se rige por las reglas de la tutela**, salvo lo establecido específicamente para la curatela.

Función del curador

► Cuidar a la persona y los bienes del incapaz y tratar de que recupere su salud.

¿Quién puede ser curador?

- a) La persona que haya designado el propio protegido.
- b) La persona que hayan designado los padres (curatela dativa).

• A falta de estas previsiones, el juez puede nombrar al cónyuge no separado de hecho, al conviviente, a los hijos, padres o hermanos de la persona a proteger, según quien tenga mayor aptitud.

Persona protegida con hijos

- Se dispone que el **curador** de la persona (incapaz o con capacidad restringida) **también sea el tutor de los hijos menores**.
- También se admite que el juez otorgue la **guarda** del hijo menor de edad a un tercero (guardador), designándolo tutor para que lo represente en las cuestiones patrimoniales.

CAPÍTULO XIV PERSONAS JURÍDICAS

Introducción.-

El nuevo Código Civil y Comercial trata de las personas jurídicas en el Título II del Libro Primero, regulando el tema en tres capítulos dedicados a:

- Parte General (arts. 141 a 167)
- Asociaciones Civiles (arts. 168 a 192)
- Fundaciones (arts. 193 a 224)

Se utiliza sólo el término “personas jurídicas”, a diferencia del Código de Vélez que empleaba los términos “personas de existencia ideal o personas jurídicas” (lo cual originaba la discusión acerca de si eran lo mismo o si había una relación de género a especie entre ellas).

Definición.-

En el Código de Vélez, la definición de persona jurídica surgía por oposición a la de persona de existencia visible (ser humano), pues el art. 32 decía: “*Todos los entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones, que no son personas de existencia visible (física), son personas de existencia ideal o personas jurídicas*”. Era una definición por descarte: si podía adquirir derechos y contraer obligaciones y no era una persona física (ser humano), era una persona jurídica.

En el nuevo Código Civil y Comercial se abandona esa definición residual y se hace una definición descriptiva de la persona jurídica.

Art. 141.- “Definición. *Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación.*”

Es de destacar que a diferencia de la persona humana que “goza” de personalidad por derecho propio (art. 22) y a la cual la legislación simplemente le reconoce personalidad (porque de no hacerlo se violaría la dignidad del ser humano), en el caso de las personas jurídicas es la legislación la que “les confiere” personalidad cuando el ente es útil o necesario, pero limita esa personalidad conferida al cumplimiento del objeto y fines de su creación.

Comienzo de la existencia.-

Art. 142.- “Comienzo de la existencia. *La existencia de la persona jurídica privada comienza desde su constitución. No necesita autorización legal para funcionar, excepto disposición legal en contrario. En los casos en que se requiere autorización estatal, la persona jurídica no puede funcionar antes de obtenerla.*”

La persona jurídica comienza a existir desde su constitución y en principio no necesita autorización del Estado para funcionar, excepto en los casos que la ley establezca que necesita autorización estatal, pues en este caso no puede funcionar antes de obtenerla y comienza a existir cuando el Estado le aprueba sus estatutos y las autoriza a funcionar.

Acto constitutivo.-

Toda persona jurídica requiere, como primera medida, un acto constitutivo creador de la misma, el cual recibirá distinta denominación (acto conjunto, acto fundacional, contrato social, etc.) según cuál sea la persona jurídica de que se trate.

En el acto constitutivo se establecerán los “estatutos” de la persona jurídica. La existencia de estatutos es un requisito indispensable cuando se trata de personas jurídicas tales como las asociaciones, fundaciones, sociedades anónimas, etc. Las sociedades civiles o comerciales (excepto las sociedades anónimas) no requieren un estatuto, pues para existir legalmente les basta el “contrato social”.

Estatuto.-

El “estatuto” son las reglas fundamentales que organizan y rigen la vida de la persona jurídica. En el estatuto se establece el nombre, el domicilio y el fin u objeto de la persona jurídica; cómo se forma e invierte el patrimonio, y cuál será el destino de éste en caso de disolución. Se establecen además, los órganos de gobierno, el modo de tomar las decisiones, la forma de votar, los derechos y obligaciones de cada miembro, los requisitos para ingresar en la entidad, etc. Los estatutos deben ser aprobados por la Inspección General de Personas Jurídicas.

Personalidad diferenciada.-

La persona jurídica, es una persona distinta de cada uno de los miembros que la componen.

Las obligaciones y derechos que la persona jurídica pueda tener, son absolutamente independientes de los derechos y obligaciones de sus miembros.

La persona jurídica tiene un patrimonio distinto al patrimonio de sus miembros. La persona jurídica estará obligada a satisfacer sus propias deudas, y los miembros de ella no estarán obligados a pagar las deudas de la entidad (salvo que expresamente hubiesen ofrecido su patrimonio como garantía, es decir: que se hubiesen obligado como fiadores de la entidad).

Art. 143.- “Personalidad diferenciada. La persona jurídica tiene una personalidad distinta de la de sus miembros.

Los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica, excepto en los supuestos que expresamente se prevén en este Título y lo que disponga la ley especial.”

Inoponibilidad de la personalidad jurídica.-

La persona jurídica es una persona distinta de los socios que la integran y tiene un patrimonio propio, independiente del patrimonio de los socios, razón por la cual sus miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica.

Pero hay casos en que esta distinta personalidad jurídica no se puede oponer. Así ocurre cuando la persona jurídica ha sido utilizada (como una pantalla, como un medio o como un velo) para:

- conseguir fines ajenos a la persona jurídica; o
- violar la ley, el orden público, la buena fe, o para frustrar derechos de terceros,

En estos casos, el juez puede “romper el velo” de esa persona jurídica, dejar de lado la personalidad y “penetrar” en la realidad, considerando inoponible la distinta personalidad y atribuyendo a los hombres que actúan detrás de la persona jurídica (ej: socios, asociados, miembros o controlantes directos o indirectos), la responsabilidad solidaria e ilimitada por los perjuicios causados.

Art. 144.- “Inoponibilidad de la personalidad jurídica. La actuación que esté destinada a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica, constituya un recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de cualquier persona, se imputa a quienes a título de socios, asociados, miembros o controlantes directos o indirectos, la hicieron posible quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. Lo dispuesto se aplica sin afectar los derechos de los terceros de buena fe y sin perjuicio de las responsabilidades personales de que puedan ser pasibles los participantes en los hechos por los perjuicios causados.”

Esta doctrina (conocida como “teoría de la penetración”) fue aplicada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos “Parque Davis” y “Swift-Deltec”; y fue aceptada por el art. 54 de la Ley de Sociedades, cuyo texto es similar al del art. 144 del nuevo Código Civil y Comercial.

Art. 54 (Ley General de Sociedades).- “... La actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios, constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a los controlantes que la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados”.

Clasificación.-

El art. 145 se encarga de clasificar a las personas jurídicas:

Art. 145.- “Clases. Las personas jurídicas son públicas o privadas.”

La clasificación en públicas y privadas es tradicional en nuestra legislación, por ello la encontramos en el Código de Vélez (art. 33), en el Proyecto de 1998 y la mantiene el nuevo Código Civil y Comercial (art. 145), enumerando a cada una en los artículos 146 y 147.

• **Personas jurídicas públicas:** son aquellas en cuya creación, existencia y funcionamiento interviene el Estado. Se rigen por el derecho público, aún cuando parte de su actividad esté bajo regulación del derecho privado.

• **Personas jurídicas privadas:** son aquellas en cuya creación, existencia y funcionamiento intervienen los particulares. Se rigen por el derecho privado aún cuando requieran autorización para funcionar.

PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS.-

Enumeración.-

Son personas jurídicas públicas (conf. art. 146):

a) El Estado nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, las entidades autárquicas y las demás organizaciones constituidas en la República a las que el ordenamiento jurídico atribuya ese carácter.

• El Estado es el representante de toda la sociedad, y organiza al país jurídica, política y económicamente. Por ende es primordial reconocer su personalidad jurídica; y en conformidad a nuestro sistema federal de gobierno, se debe reconocer la personalidad jurídica de las provincias y de los municipios, integrantes de la Nación. El nuevo Código Civil y Comercial agregó "*la Ciudad Autónoma de Buenos Aires*" (conf. art. 129 CN), la cual tiene un status intermedio entre el de una provincia y un municipio.

• Las entidades autárquicas son organismos que se han desprendido o descentralizado del Estado, y que llevan a cabo funciones propias de aquél, es decir, servicios públicos. Son autárquicas, porque tienen un gobierno propio. Ejemplos de entidades autárquicas: el Banco Central, el Banco de la Nación Argentina, el Banco Hipotecario Nacional; Instituto Nacional de Salud Mental, las Universidades Nacionales; el Mercado de Valores; el Consejo Nacional de Educación, etc.

• El nuevo Código Civil y Comercial también agregó a "*las demás organizaciones constituidas en la República a las que el ordenamiento jurídico atribuya ese carácter*" (ej: las empresas del Estado, las obras sociales, los sindicatos, los partidos políticos, etc).

b) Los Estados extranjeros (Ej: Brasil, Uruguay, etc), las organizaciones a las que el derecho internacional público reconozca personalidad jurídica (Ej: OIT, OEA, ONU, Mercosur) y toda otra persona jurídica constituida en el extranjero cuyo carácter público resulte de su derecho aplicable (Ejemplos: Cruz Roja Internacional, etc).

c) La Iglesia Católica. El carácter de persona jurídica de carácter público que se reconoce a la Iglesia Católica (Apostólica Romana) proviene del hecho de que es el culto sostenido por la Nación (Constitución Nacional, art. 2) y el profesado por la mayoría de los habitantes.

En cuanto a otras religiones, sus iglesias (si reúnen los requisitos necesarios) pueden llegar a ser personas jurídicas de carácter privado, o (si no reuniesen dichos requisitos) simples asociaciones religiosas.

Ley aplicable.-

Las personas jurídicas públicas se rigen en cuanto a su reconocimiento, comienzo, capacidad, funcionamiento, organización y fin de su existencia, por las leyes y ordenamientos de su constitución (conf. art. 147).

PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS.-

Enumeración.-

Son personas jurídicas privadas (conf. art. 148):

- las sociedades;
- las asociaciones civiles;
- las simples asociaciones;
- las fundaciones;
- las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas;
- las mutuales;
- las cooperativas;
- el consorcio de propiedad horizontal;
- toda otra contemplada en disposiciones de este Código o en otras leyes y cuyo carácter de tal se establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento.

Participación del Estado.-

La participación del Estado en personas jurídicas privadas no modifica el carácter de éstas. Sin embargo, la ley o el estatuto pueden prever derechos y obligaciones diferenciados, considerando el interés público comprometido en dicha participación (conf. art. 149).

El Estado puede actuar como poder público y también (en igualdad con los particulares) en el ámbito del derecho privado, tal el caso de las *sociedades de economía mixta*, en las que el Estado (nacional, provincial o municipal) participa en una empresa privada (por ej: aportando capital, tecnología, exención impositiva, etc).

Esta participación del Estado en una empresa privada no transforma a ésta en persona jurídica pública. Pero, considerando el interés público comprometido en dicha participación, la norma admite que se establezcan diferencias a favor del Estado (por ej: una mayor participación en las utilidades).

Leyes aplicables.-

De acuerdo al art. 150, las personas jurídicas privadas que se constituyen en la República, se rigen:

- por las normas imperativas de la ley especial o, en su defecto, de este Código;
- por las normas del acto constitutivo con sus modificaciones y de los reglamentos, prevaleciendo las primeras en caso de divergencia;

c) por las normas supletorias de leyes especiales, o en su defecto, por las de este Título.

Las personas jurídicas privadas que se constituyen en el extranjero se rigen por lo dispuesto en la Ley General de Sociedades (arts. 118 a 124).

EFFECTOS Y ATRIBUTOS DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA.-

Efectos.-

El hecho de reconocer a un ente personalidad jurídica da lugar a una serie de consecuencias jurídicas, como ser:

- 1) La persona jurídica es una persona distinta de los socios que la integran;
- 2) Tiene nombre y domicilio propios;
- 3) Las personas jurídicas carecen de capacidad de ejercicio: sólo pueden actuar por medio de sus representantes. La capacidad de derecho está limitada por el principio de especialidad: sólo puede para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación.
- 4) Tiene un patrimonio propio, independiente del de los miembros (si bien el patrimonio del ente se forma con los bienes aportados por los miembros, luego de aportados estos bienes ya no pertenecen a los miembros, sino que pertenecen exclusivamente a la persona jurídica);
- 5) Los deudores de la persona jurídica, son deudores de ella, y no de los miembros;
- 6) Un miembro puede actuar como testigo, en un pleito en el cual la persona jurídica es parte;
- 7) Un miembro puede celebrar (en calidad de tercero) un contrato con la persona jurídica.

Atributos.-

Las personas jurídicas tienen los mismos atributos o aptitudes que las personas físicas: nombre, domicilio, patrimonio y capacidad; obviamente no tienen estado civil (o de familia) pues el mismo es privativo de las personas físicas.

1) **Nombre** (conf. art. 151).- A efectos de su identificación, la persona jurídica debe tener un nombre. Puede tratarse de un nombre de fantasía o el nombre de algún miembro. Al nombre elegido libremente se le debe agregar la forma jurídica adoptada (Ej: Electron SRL), lo cual permite saber la naturaleza y sistema de responsabilidad de la persona jurídica. Si está en liquidación se debe aclarar esta circunstancia en la utilización de su nombre (Ej: Electron SRL en liquidación).

El nombre se elige libremente pero debe satisfacer recaudos de: veracidad, novedad y aptitud distintiva, tanto respecto de otros nombres, como de marcas, nombres de fantasía u otras formas de referencia a bienes o servicios, se relacionen o no con el objeto de la persona jurídica.

No puede contener términos o expresiones contrarios a la ley, el orden público o las buenas costumbres ni inducir a error sobre la clase u objeto de la persona

jurídica. La inclusión en el nombre de la persona jurídica del nombre de personas humanas requiere la conformidad de éstas, que se presume si son miembros. Sus herederos pueden oponerse a la continuación del uso, si acreditan perjuicios materiales o morales.

2) **Domicilio y sede social** (conf. art. 152).- La persona jurídica tiene su domicilio en el fijado en su estatuto o en la autorización que se le dio para funcionar.

Si posee muchas sucursales tiene su domicilio especial en el lugar de dichos establecimientos, pero sólo para la ejecución de las obligaciones allí contraídas.

El cambio de domicilio requiere modificación del estatuto.

El cambio de sede, si no forma parte del estatuto, puede ser resuelto por el órgano de administración.

Las notificaciones que se hagan en la sede social inscripta son válidas y vinculantes para la persona jurídica (conf. art. 153).

3) **Patrimonio**.- La persona jurídica debe tener un patrimonio propio (conjunto de bienes de la cual sea titular), ya que se trata de un atributo de ella sin el cual carecería de autonomía. Cuando está en formación puede inscribir preventivamente a su nombre los bienes registrables.

Art. 154.- "Patrimonio. La persona jurídica debe tener un patrimonio. La persona jurídica en formación puede inscribir preventivamente a su nombre los bienes registrables."

4) **Capacidad**.- Las personas jurídicas pueden adquirir derechos y contraer obligaciones, pero actúan por medio de sus representantes (ej: el presidente de la persona jurídica).

Su capacidad está limitada por el objeto y fin del ente, ya que sólo podrá adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento del objeto y los fines de su creación (conf. art. 141).

Duración y objeto.-

Si bien no se trata de "atributos" de la personalidad jurídica, el nuevo Código Civil y Comercial hace referencia, dentro del parágrafo "Efectos y atributos de la personalidad jurídica", a dos elementos de suma importancia como son la duración y el objeto de la persona jurídica.

• **Duración**.- En principio, la duración de la persona jurídica es perpetua, no tiene un límite, salvo que la ley o el estatuto dispongan lo contrario.

Art. 155.- "Duración. La duración de la persona jurídica es ilimitada en el tiempo, excepto que la ley o el estatuto dispongan lo contrario."

Si tiene un plazo determinado de duración, el mismo puede ser prorrogado siempre que:

- así lo decidan sus miembros (por las mayorías que correspondan); y
- el pedido a la autoridad de contralor se haga antes del vencimiento del plazo (conf. art. 165).

• **Objeto.-** El objeto de la persona jurídica es la actividad a la que ésta se va a dedicar. El objeto debe ser indicado con claridad y exactitud (ej: compraventa de automotores, operaciones inmobiliarias, fabricación de electrodomésticos, instalación de cámaras de vigilancia, etc.), evitando indicaciones ambiguas (por ej: "actividades comerciales").

Art. 156.- "Objeto. El objeto de la persona jurídica debe ser preciso y determinado."

El objeto y el fin de la persona jurídica determinan el **límite de la capacidad** de la misma, ya que en razón del principio de especialidad sólo podrá adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento del objeto y los fines de su creación (conf. art. 141). Ejemplo: una compañía de seguros no podría ejercer operaciones propias de un banco; una sociedad de socorros mutuos no podría dedicarse a operaciones de transporte, etc.

Pero tampoco se debe hacer una aplicación rígida del principio de especialidad, dado que muchas veces la persona jurídica se encuentra en la necesidad de realizar actos que son extraños a los fines de su institución. Ejemplo: una sociedad artística, tiene como fin estimular el arte entre sus asociados; sin embargo, podrá adquirir un terreno o un edificio si ellos fuesen necesarios para los fines que le son propios. Como vemos, la compraventa, si bien no es un acto que hace al fin propio de una sociedad artística, deberá ser permitida cuando ella ayude a lograr dichos fines. Desde luego, el objeto también debe ser posible y lícito.

FUNCIONAMIENTO DE LA PERSONA JURÍDICA.-

Estatuto.-

Son las reglas fundamentales que organizan y rigen la vida de la persona jurídica. El estatuto es a la persona jurídica como una Constitución es a un país. En el estatuto se establece el nombre, el domicilio y el fin u objeto de la persona jurídica; cómo se forma e invierte el patrimonio, y cuál será el destino de éste en caso de disolución.

Se establecen, además, los órganos de gobierno, de administración y de fiscalización, el modo de tomar las decisiones, la forma de votar, los derechos y obligaciones de cada miembro, los requisitos para ingresar en la entidad, etc.

Los estatutos deben ser aprobados por la Inspección General de Personas Jurídicas. Las personas jurídicas que, para actuar como tales requieren la autorización del Estado, comenzarán a existir cuando el Estado les apruebe sus estatutos y las autorice a funcionar.

La modificación del estatuto se debe hacer en la forma que establezca el mismo estatuto o la ley específica sobre esa persona jurídica (ej: SA, SRL, etc). Para los miembros, la modificación hecha es obligatoria desde que se aprobó. Para los terceros, si la modificación requiere inscripción, es oponible a partir de ésta, excepto que el tercero la conozca (conf. art. 157).

Gobierno, administración y fiscalización.-

El contenido del estatuto debe incluir normas sobre el gobierno, la administración y representación y, si la ley lo exige, sobre la fiscalización interna de la persona jurídica (conf. art. 158). Además, se fijará el modo de tomar las decisiones, la forma de votar, los derechos y obligaciones de cada miembro. Para el caso de ausencia de previsiones en el estatuto, el art. 158 fija dos normas supletorias:

a) Si todos los que deben participar del acto lo consienten, la participación en una asamblea o reunión del órgano de gobierno se puede hacer utilizando medios que les permitan a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos. El acta debe ser suscripta por el presidente y otro administrador, indicándose la modalidad adoptada, debiendo guardarse las constancias, de acuerdo al medio utilizado para comunicarse;

b) Los miembros que deban participar en una asamblea, o los integrantes del consejo, pueden autoconvocarse para deliberar, sin necesidad de citación previa. Las decisiones que se tomen son válidas, si concurren todos y el temario a tratar es aprobado por unanimidad.

Administradores de la persona jurídica.-

Los administradores de la persona jurídica deben actuar con lealtad y diligencia.

No pueden perseguir ni favorecer intereses contrarios a los de la persona jurídica. Pero si en determinada operación los tuvieran (por sí o por interpósita persona), deben hacerlo saber a los demás miembros del órgano de administración o de gobierno y abstenerse de cualquier intervención relacionada con dicha operación. Los administradores deben implementar sistemas y medios preventivos que reduzcan el riesgo de conflictos de intereses en sus relaciones con la persona jurídica (conf. art. 159).

• Responsabilidad.- Los administradores responden en forma ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica, sus miembros y terceros, por los daños causados por su culpa en el ejercicio o con ocasión de sus funciones, por acción u omisión (conf. art. 160).

• Obstáculos que impiden tomar decisiones.- Si a causa de oposiciones u omisiones sistemáticas en el desempeño de las funciones del órgano administrador (ej: el administrador omite realizar actos urgentes) la persona jurídica no puede tomar decisiones válidas, el art. 161 del nuevo Código Civil y Comercial -a fin de solucionar la situación de estancamiento- establece como se debe proceder:

- 1) El presidente, o alguno de los coadministradores, si los hay, pueden ejecutar los actos conservatorios.
- 2) Dichos actos deben ser puestos en conocimiento de la Asamblea que se convoque al efecto dentro de los diez días de comenzada su ejecución.
- 3) La Asamblea puede conferir facultades extraordinarias al presidente o a la minoría, para realizar actos urgentes o necesarios. También puede remover al administrador.

Transformación. Fusión. Escisión.-

La transformación, la fusión y la escisión, son institutos que permiten a las empresas reestructurarse, sea concentrándose o desconcentrándose.

Art. 162.- "Transformación. Fusión. Escisión. Las personas jurídicas pueden transformarse, fusionarse o escindirse en los casos previstos por este Código o por la ley especial. En todos los casos es necesaria la conformidad unánime de los miembros de la persona o personas jurídicas, excepto disposición especial o estipulación en contrario del estatuto."

• **Transformación.-** Consiste en que la sociedad cambie de tipo societario. Ej: Sociedad Colectiva que se transforma en Sociedad Anónima.

• **Fusión.-** Implica la unión de dos sociedades (que se disuelven, pero no se liquidan), que al unirse dan nacimiento a una nueva sociedad ($A+B=C$). También puede consistir en que una sociedad absorba o incorpore a otra (esta se disuelve sin liquidarse). La incorporante asume los derechos y obligaciones de la incorporada.

• **Escisión.-** De acuerdo al art. 88 de la Ley General de Sociedades, existe escisión cuando:

- a) Una sociedad, sin disolverse, destina parte de su patrimonio para fusionarse con sociedades existentes o para participar con ellas en la creación de una nueva sociedad; o
- b) Una sociedad, sin disolverse, destina parte de su patrimonio para constituir una o varias sociedades nuevas; o
- c) Una sociedad se disuelve sin liquidarse, para constituir con la totalidad de su patrimonio nuevas sociedades.

En todos los casos (transformación, fusión o escisión) es necesaria la conformidad (voto) unánime de los miembros de la persona o personas jurídicas, excepto disposición especial o estipulación en contrario del estatuto (conf. art. 162).

En los casos en que no se requiera voto unánime (por ej, si así lo establece el estatuto), los socios de la sociedad que se disuelve que han votado en contra podrán ejercer el derecho de receso (conf. art. 78, Ley General de Sociedades), el cual consiste en retirarse de la sociedad y obtener el reembolso de su parte de capital.

DISOLUCIÓN.-

Causales (conf. art. 163).-

La persona jurídica se disuelve por:

- a) Decisión de sus miembros adoptada por unanimidad o por la mayoría establecida por el estatuto o disposición especial.
- b) Cumplimiento de la condición resolutoria a la que el acto constitutivo subordinó su existencia.
- c) Consecución del objeto para el cual la persona jurídica se formó, o la imposibilidad sobreviniente de cumplirlo. Ejemplo: si la persona jurídica se creó para

cumplir un objeto o negocio determinado y éste se cumplió o es de cumplimiento imposible, la persona jurídica se disuelve.

d) Vencimiento del plazo. Si la persona jurídica tenía un plazo de duración determinado, al vencer dicho plazo se produce su disolución, salvo que los socios decidan prorrogarla o que haya reconducción (conf. arts. 165 y 167).

e) Declaración de quiebra. Vale aclarar que la disolución queda sin efecto si la quiebra concluye por avenimiento o se dispone la conversión del trámite en concurso preventivo, o si la ley especial prevé un régimen distinto.

f) Fusión y Escisión. En el caso de la fusión, se disuelven las personas jurídicas que se fusionan, o la persona o personas jurídicas cuyo patrimonio es absorbido. En el caso de la escisión, se disuelve la persona jurídica que se divide y destina todo su patrimonio.

g) Reducción a uno del número de miembros, si la ley especial exige pluralidad de ellos y ésta no es restablecida dentro de los tres meses.

h) Denegatoria o revocación firmes de la autorización estatal para funcionar, cuando ésta sea requerida. La revocación de la autorización estatal debe fundarse en la comisión de actos graves que importen la violación de la ley, el estatuto y el reglamento. La resolución es apelable, pudiendo el juez disponer la suspensión provisional de sus efectos (conf. art. 164).

i) Agotamiento de los bienes destinados a sostenerla. Ejemplo: se disuelve si la persona jurídica pierde totalmente su capital o una parte considerable del mismo que imposibilita la consecución de su objeto.

j) Cualquier otra causa prevista en el estatuto o en otras disposiciones de este Título o de ley especial.

Revocación de la autorización estatal.-

Así como el Estado da autorización estatal para funcionar a ciertas personas jurídicas (ej: una fundación), también puede (y debe) revocar esa autorización si el accionar de la persona jurídica implica la comisión de actos graves de violación a la ley, al estatuto.

Para disponer la revocación es necesario seguir un procedimiento que garantice el derecho de defensa de la persona jurídica. La resolución que dispone la revocación debe estar fundada y es apelable, pudiendo el juez disponer la suspensión provisional de sus efectos (conf. art. 164).

La revocación firme de la autorización estatal para funcionar acarrea la disolución de la persona jurídica (conf. art. 163, inc. h).

• **Reconducción.-** Ante la causal de disolución, los socios pueden decidir (mediante los votos indicados por la ley o el estatuto) reconducir la sociedad, es decir restablecer la situación de la sociedad y continuar con la actividad normal de su negocio, siempre que:

- se haga antes de que termine la liquidación; y
- la causa de disolución pueda ser removida (por ej: si la causal de disolución es el agotamiento de los bienes, puede haber reconducción si los socios acuerdan reintegrar los mismos haciendo nuevos aportes de capital).

Art. 166.- "Reconducción. La persona jurídica puede ser reconducida mientras no haya concluido su liquidación, por decisión de sus miembros adoptada por unanimidad o la mayoría requerida por la ley o el estatuto, siempre que la causa de su disolución pueda quedar removida por decisión de los miembros o en virtud de la ley."

LIQUIDACIÓN.-

Concepto.-

Producida la causal de disolución, la persona jurídica entra en la última etapa de su vida: la etapa de liquidación, durante la cual básicamente venderá su activo, pagará su pasivo y si hubiera un saldo final o remanente lo distribuirá o entregará a sus miembros o a terceros, conforme a lo que diga el estatuto o la ley.

Durante la liquidación la persona jurídica no puede realizar nuevas operaciones, debiendo limitarse a concluir las pendientes (cobro de créditos, venta de los activos y pago a los acreedores,). Paga los gastos de liquidación y de las obligaciones fiscales y luego entrega o distribuye el saldo o remanente (conf. art. 167)

La liquidación está a cargo del "liquidador", el cual generalmente es designado por los miembros de la persona jurídica. Es común que se designe como liquidador al administrador.

Responsabilidades.-

En caso de infracción a lo dispuesto, responden ilimitada y solidariamente sus administradores y aquellos miembros que, conociendo o debiendo conocer la situación y contando con el poder de decisión necesario para ponerle fin, omiten adoptar las medidas necesarias al efecto.

Art. 167.- "Liquidación y responsabilidades. Vencido el plazo de duración, resuelta la disolución u ocurrida otra causa y declarada en su caso por los miembros, la persona jurídica no puede realizar operaciones, debiendo en su liquidación concluir las pendientes. La liquidación consiste en el cumplimiento de las obligaciones pendientes con los bienes del activo del patrimonio de la persona jurídica o su producido en dinero. Previo pago de los gastos de liquidación y de las obligaciones fiscales, el remanente, si lo hay, se entrega a sus miembros o a terceros, conforme lo establece el estatuto o lo exige la ley. En caso de infracción responden ilimitada y solidariamente sus administradores y aquellos miembros que, conociendo o debiendo conocer la situación y contando con el poder de decisión necesario para ponerle fin, omiten adoptar las medidas necesarias al efecto."

ASOCIACIONES CIVILES

Regulación normativa.-

La Constitución Nacional, en el art. 14, permite "*asociarse con fines útiles*". El nuevo Código Civil y Comercial, respetando este derecho a asociarse de las personas, - se refiere a las *Asociaciones Civiles* (arts. 168 a 186) y a la *Simple Asociaciones* (arts. 187 a 192).

Las asociaciones civiles en los Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial.-

En relación a las asociaciones civiles, en los *Fundamentos* se dice: "*Si bien se han dictado normas específicas para cierto tipo de asociaciones (por ej. las mutuales con la Ley 20.321 y las cooperativas con la Ley 20.337) se hace imprescindible incluir en el Código un criterio general y básico para que los particulares puedan asociarse solidariamente y coparticipen en el cumplimiento de fines cada vez más variados. La experiencia en el país es vasta y, justamente por ello, requiere de seguridad jurídica que se desprende de la regulación.*

Las asociaciones civiles se caracterizan como personas jurídicas privadas que se constituyen con un objeto de interés y utilidad general para la comunidad, del que también participan y se benefician sus miembros. Requieren indispensablemente del aporte y sostenimiento de todos o parte de sus socios. No pueden ser la principal fuente de sus recursos la asistencia económica que reciban del Estado ni los aranceles que perciban por servicios específicos que presten a los socios, los cuales también deben ser efectivamente accesibles en igualdad de condiciones a la comunidad en general.

Su existencia comienza con el acuerdo constitutivo otorgado en la forma escrita prescripta y según sean asociaciones civiles o simples asociaciones (más flexibles, con menores controles y mayores responsabilidades para sus miembros) requieren o no autorización estatal para funcionar. Pero desde ahora, con el proyecto, tienen reconocimiento como personas jurídicas.

El punto determinante de su conformación es que no pueden perseguir fines de lucro ni distribuir bienes o dinero entre sus miembros durante su funcionamiento ni en la liquidación. Si para el cumplimiento de su objeto realizan actividades por las que obtienen algún resultado económico positivo, éste debe aplicarse a la prosecución, incremento o perfeccionamiento del desarrollo de aquel" (conf. Fundamentos del Código Civil y Comercial, Libro Primero, Título II, Capítulo 2 "Asociaciones civiles").

Objeto.-

La Asociación Civil es una persona jurídica privada creada, organizada y administrada por varias personas para lograr un objeto o fin que no sea contrario al

interés general o al bien común. Necesita autorización estatal para funcionar y no puede tener fin de lucro como fin principal.

El *bien común* o el *interés general* deben interpretarse dentro del respeto a las diversas identidades, creencias y tradiciones, sean culturales, religiosas, artísticas, literarias, sociales, políticas o étnicas que no vulneren los valores constitucionales.

Art. 168.- "Objeto. La asociación civil debe tener un objeto que no sea contrario al interés general o al bien común. El interés general se interpreta dentro del respeto a las diversas identidades, creencias y tradiciones, sean culturales, religiosas, artísticas, literarias, sociales, políticas o étnicas que no vulneren los valores constitucionales. No puede perseguir el lucro como fin principal, ni puede tener por fin el lucro para sus miembros o terceros."

Acto constitutivo.-

La Asociación Civil se crea mediante un acto constitutivo, realizado en instrumento público. Luego se solicita la autorización estatal para funcionar, y otorgada la autorización se inscribe el acto constitutivo en el registro correspondiente. Hasta la inscripción se aplican las normas de la simple asociación (conf. art. 169).

• Contenido.- El acto constitutivo debe contener (conf. art. 170):

- a) la identificación de los constituyentes;
- b) el nombre de la asociación con el aditamento "Asociación Civil" antepuesto o pospuesto;
- c) el objeto;
- d) el domicilio social;
- e) el plazo de duración o si la asociación es a perpetuidad;
- f) las causales de disolución;
- g) las contribuciones que conforman el patrimonio inicial de la asociación civil y el valor que se les asigna. Los aportes se consideran transferidos en propiedad, si no consta expresamente su aporte de uso y goce;
- h) el régimen de administración y representación;
- i) la fecha de cierre del ejercicio económico anual;
- j) en su caso, las clases o categorías de asociados, y prerrogativas y deberes de cada una (Ej: miembros activos, miembros vitalicios, miembros adherentes, etc)
- k) el régimen de ingreso, admisión, renuncia, sanciones disciplinarias, exclusión de asociados y recursos contra las decisiones;
- l) los órganos sociales de gobierno, administración y representación. Deben preverse la comisión directiva, las asambleas y el órgano de fiscalización interna, regulándose su composición, requisitos de integración, duración de sus integrantes, competencias, funciones, atribuciones y funcionamiento en cuanto a convocatoria, constitución, deliberación, decisiones y documentación;
- m) el procedimiento de liquidación;

n) el destino de los bienes después de la liquidación, pudiendo atribuirlos a una entidad de bien común, pública o privada, que no tenga fin de lucro y que esté domiciliada en la República.

Órgano de administración (conf. art. 171).-

El órgano de administración de la asociación civil es la Comisión Directiva, cuyos miembros se denominan genéricamente "directivos". Debe estar integrada por asociados, a los cuales no se les puede restringir abusivamente el derecho a integrar la comisión, pero sí es posible establecer requisitos no abusivos para ser parte de ella (ej: ser un profesional de determinada ciencia, tener una determinada antigüedad, ser alumno de la institución, etc).

La primera comisión directiva, se debe designar en el acto constitutivo; las posteriores en la Asamblea. El estatuto debe contemplar los cargos de presidente, secretario y tesorero, y establecer las funciones de cada uno. Los demás miembros de la comisión directiva tienen carácter de vocales.

Los directivos cesan en sus cargos (conf. art. 176) por: muerte, declaración de incapacidad o capacidad restringida, inhabilitación, vencimiento del lapso para el cual fueron designados, renuncia, remoción y cualquier otra causal establecida en el estatuto.

El estatuto no puede restringir la remoción ni la renuncia; la cláusula en contrario es de ningún valor.

• Renuncia de directivo.- El directivo debe comunicar su renuncia a la Comisión Directiva o a quien diga el estatuto, y se tiene por aceptada si no es expresamente rechazada dentro de los 10 días contados desde su recepción.

Pero, la renuncia de un directivo no puede afectar el funcionamiento de la Comisión Directiva ni la ejecución de actos previamente resueltos por ésta, supuestos en los cuales debe ser rechazada y el renunciante permanecer en el cargo hasta que la asamblea ordinaria se pronuncie.

Si no concurren tales circunstancias, la renuncia comunicada por escrito al presidente de la comisión directiva o a quien estatutariamente lo reemplace o a cualquiera de los directivos, se tiene por aceptada si no es expresamente rechazada dentro de los diez días contados desde su recepción.

Órgano de fiscalización (conf. art. 172).-

El órgano de fiscalización de las asociaciones civiles puede estar integrado por asociados y no asociados, ya que el art. 172 permite que lo integren personas no asociadas. El primer órgano de fiscalización se debe designar en el acto constitutivo. La fiscalización privada puede ser unipersonal (una persona: el síndico) o pluripersonal (comisión revisora de cuentas). La comisión revisora de cuentas es obligatoria en las asociaciones con más de cien asociados.

Los integrantes del órgano de fiscalización tienen incompatibilidades plasmadas en el art. 173: no pueden ser al mismo tiempo integrantes de la comisión, ni certificantes de los estados contables de la asociación. Estas incompatibilidades se extienden a los cónyuges, convivientes, parientes, aun por afinidad, en línea recta en todos los grados, y colaterales dentro del cuarto grado.

Cuando la asociación requiera para ser socio una profesión u oficio, los integrantes del órgano fiscalizador están relevados de contar con un título habilitante en la profesión u oficio de los socios. Esta normativa es coherente con la posibilidad de que el órgano de fiscalización pueda estar integrado por personas no asociadas.

Control estatal.-

Las asociaciones civiles están bajo control interno (del órgano de fiscalización), y también bajo un control externo, ya que para funcionar requieren autorización estatal y además, están sujetas a un contralor permanente de la autoridad competente, nacional o local, según corresponda (conf. art. 174).

La autorización para funcionar la otorga la *Inspección General de Justicia*. Si hay rechazo de la autorización, la decisión podrá ser impugnada (fundamentalmente si es arbitraria o contraria a derecho) ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil (conf. Ley 22.315).

Participación en los actos de gobierno.-

Todos los asociados tienen derecho a participar en los actos de gobierno, pero el estatuto puede imponer condiciones para que los asociados participen en los actos de gobierno, tales como determinada antigüedad o estar al día en el pago de cuotas sociales, etc. La cláusula que importe restricción total del ejercicio de los derechos del asociado es de ningún valor (conf. art. 175).

Responsabilidad de los directivos.-

Los administradores y representantes de la persona jurídica deben actuar con lealtad y diligencia, y no pueden perseguir intereses contrarios a los de la misma. Además, siempre deben ajustar su actuación al estatuto y a las normas que la regulan (Código Civil y Comercial y Ley General de Sociedades). De lo contrario, ellos responden en forma ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica, sus miembros y terceros, por los daños causados por su culpa en el ejercicio o con ocasión de sus funciones, sea por acción u omisión (conf. art. 160).

Son los socios (en la Asamblea) quienes deben analizar la actuación del directivo, y decidir si aprueban su gestión, si lo remueven o si ejercen acciones de responsabilidad en su contra.

• **Extinción de la responsabilidad.-** El art. 177 del nuevo Código Civil y Comercial expresa que la responsabilidad de los directivos (administradores y representantes) se extingue si, en la asamblea ordinaria, los socios resuelven:

- apobar su gestión; o
- renunciar a iniciarle acciones de responsabilidad; o
- hacer transacción.

Pero luego aclara que no se producirá la extinción en los siguientes casos:

- a) si la responsabilidad deriva de la infracción a la ley; o
- b) si en la asamblea hubo oposición expresa y fundada de asociados con derecho a voto en cantidad no menor al 10% por ciento del total. Quienes se opusieron pueden ejercer la acción social de responsabilidad prevista para las sociedades en la ley especial.

Art. 177.- "Extinción de la responsabilidad. La responsabilidad de los directivos se extingue por la aprobación de su gestión, por renuncia o transacción resueltas por la asamblea ordinaria.

No se extingue:

- a) si la responsabilidad deriva de la infracción a normas imperativas;
- b) si en la asamblea hubo oposición expresa y fundada de asociados con derecho a voto en cantidad no menor al diez por ciento del total. En este caso quienes se opusieron pueden ejercer la acción social de responsabilidad prevista para las sociedades en la ley especial."

Participación en las asambleas.-

Todos los asociados tienen derecho a participar en los actos de gobierno de la persona jurídica (conf. art. 175), pero el estatuto puede imponer condiciones para que los asociados puedan participar.

Para participar y votar en las asambleas, el requisito consiste en estar al día con el pago de las cuotas y contribuciones correspondientes al mes inmediato anterior. La falta de pago le impide participar en la asamblea, pero el art. 178 *in fine* le permite superar el obstáculo pagando lo adeudado antes del inicio de la asamblea (conf. art. 178).

Renuncia, Exclusión y Responsabilidad del asociado.-

• **Renuncia.-** El asociado tiene derecho a renunciar a tal condición, y su derecho a renunciar no puede ser limitado (se asoció libremente, se retira libremente). Sin embargo, la renuncia no evita que deba pagar lo que debe: las cuotas y contribuciones devengadas hasta la fecha de la notificación de su renuncia (conf. art. 179).

• **Exclusión.-** La asociación tiene derecho a excluir o expulsar al asociado sólo cuando la causa sea grave y esté prevista en el estatuto. Si la decisión de excluirlo fue tomada por la *Comisión Directiva*, el asociado tiene derecho a la revisión por la Asamblea (que se debe convocar en el menor plazo que indique la ley o el estatuto).

El procedimiento debe asegurar el derecho de defensa del afectado, lo cual implica básicamente que se le informe la causa de la sanción, que se le permita hacer su defensa y presentar pruebas de descargo. El incumplimiento de estos requisitos

(ej: no asegurar el derecho de defensa; no convocar la Asamblea en el menor plazo posible; o directamente no permitir la revisión por la asamblea) compromete la responsabilidad de la Comisión Directiva (conf. art. 180).

• **Responsabilidad.-** Los asociados no responden por las deudas de la asociación civil, ni en forma directa ni subsidiaria. Su responsabilidad se limita a cumplir con los aportes comprometidos, y al pago de las cuotas y contribuciones a las que estén obligados (conf. art. 181).

Intransmisibilidad.-

La calidad de asociado es intransmisible (conf. art. 182).

La fuente de esta norma es el Proyecto de 1998.

Disolución.-

De acuerdo al art. 183, las asociaciones civiles se disuelven por:

a) las mismas causas de disolución de las personas jurídicas privadas (establecidas en el art. 163). Ejemplos: decisión de sus miembros adoptada conforme al estatuto; cumplimiento de la condición resolutoria; cumplimiento o imposibilidad de cumplir el objeto de la sociedad; vencimiento del plazo; declaración de quiebra; etc.

b) cuando se reduce la cantidad de asociados a un número inferior al total de miembros (titulares y suplentes) de su comisión directiva y órgano de fiscalización. La asociación tiene un plazo de 6 meses para aumentar la cantidad de asociados y restablecer ese mínimo; de lo contrario entra en disolución.

Liquidación.-

• **Procedimiento.-** El procedimiento de liquidación se rige por las disposiciones del estatuto y se lleva a cabo bajo la vigilancia del órgano de fiscalización (conf. art. 185).

En general, todo es similar a lo que ocurre en otras personas jurídicas: producida la causal de disolución, la asociación civil entra en la etapa de liquidación, durante la cual básicamente venderá su activo y pagará su pasivo. Pero si hubiera un saldo final o remanente (acá está la diferencia con otras personas jurídicas) no se distribuye entre sus miembros, sino que se le da el destino previsto en el estatuto y, a falta de previsión, el remanente debe destinarse a otra asociación civil (domiciliada en la República) de objeto igual o similar a la liquidada.

• **Liquidador.-** El liquidador debe ser designado por la asamblea extraordinaria y de acuerdo a lo establecido en el estatuto (excepto en casos especiales en que procede la designación judicial o por la autoridad de contralor).

Puede designarse uno o más de uno (en este caso se debe establecer si actúan en forma conjunta o como órgano colegiado). La disolución y el nombramiento del liquidador deben inscribirse y publicarse (conf. art. 184).

Normas supletorias.-

A las asociaciones civiles se le aplican supletoriamente las disposiciones sobre sociedades, en lo pertinente (conf. art. 186).

SIMPLES ASOCIACIONES

Regulación normativa.-

A diferencia del Código de Vélez, en el cual sólo se las nombraba y se las consideraba sujetos de derecho, en el nuevo Código Civil y Comercial (siguiendo la idea del Proyecto de 1998) se las considera personas jurídicas privadas (conf. art. 148), con la plena capacidad que les corresponde y se las regula especialmente a través de los arts. 187 a 192.

Ley aplicable. Reenvío.-

Las simples asociaciones se rigen por lo dispuesto para las asociaciones civiles y por las disposiciones especiales del Capítulo 2 ("Asociaciones Civiles") en cuanto a las siguientes cuestiones:

- acto constitutivo;
- gobierno;
- administración;
- socios;
- órgano de fiscalización; y
- funcionamiento.

Acto constitutivo.-

La simple asociación puede ser constituida por instrumento público o por instrumento privado (con firma certificada por escribano público).

Al nombre se le debe agregar, antes o después del mismo, el aditamento "simple asociación" o "asociación simple" (conf. art. 187).

Existencia.-

La simple asociación comienza su existencia como persona jurídica a partir de la fecha del acto constitutivo (conf. art. 189).

Prescindencia de órgano de fiscalización.-

Si la simple asociación tiene menos de 20 asociados puede prescindir del órgano de fiscalización; pero subsiste la obligación de certificación de sus estados contables.

Si se prescinde del órgano de fiscalización, todo miembro, aun excluido de la gestión, tiene derecho a informarse sobre el estado de los asuntos y de consultar sus libros y registros. La cláusula en contrario se tiene por no escrita (conf. art. 190).

Insolvencia.-

El principio general es que el asociado no responde por las deudas de la persona jurídica sino hasta la concurrencia del aporte o contribuciones comprometidos y de las cuotas que deba (conf. arts. 143, 181 y 192).

El art. 191 se aparta de esta idea, y en el caso de insuficiencia de bienes (insolvencia o quiebra) se establece la responsabilidad solidaria del administrador (o de quien administró de hecho) por las obligaciones de la simple asociación que resultan de decisiones que ha suscripto (votado, firmado, aceptado) durante su administración.

Art. 191.- "Insolvencia. En caso de insuficiencia de los bienes de la asociación simple, el administrador y todo miembro que administra de hecho los asuntos de la asociación es solidariamente responsable de las obligaciones de la simple asociación que resultan de decisiones que han suscripto durante su administración.

Los bienes personales de cada una de esas personas no pueden ser afectados al pago de las deudas de la asociación, sino después de haber satisfecho a sus acreedores individuales."

El fundador o asociado que no haya intervenido en la administración de la simple asociación no está obligado por las deudas de ella, sino hasta la concurrencia de la contribución prometida o de las cuotas impagas (conf. art. 192).

FUNDACIONES**Regulación normativa.-**

El Capítulo 3 (del Libro Primero, Título II), por medio de 7 secciones, regula a las Fundaciones:

CAPÍTULO 3. FUNDACIONES	Sección 1ª. Concepto, objeto, modo de constitución y patrimonio
	Sección 2ª. Constitución y autorización
	Sección 3ª. Gobierno y administración
	Sección 4ª. Información y contralor
	Sección 5ª. Reforma del estatuto y disolución
	Sección 6ª. Fundaciones creadas por disposición testamentaria
	Sección 7ª. Autoridad de contralor

CONCEPTO, OBJETO, MODO DE CONSTITUCIÓN Y PATRIMONIO.-**Concepto.-**

Las fundaciones son personas jurídicas que se constituyen con una finalidad de bien común, sin propósito de lucro, mediante el aporte patrimonial de una o más personas (fundador/es), destinado a hacer posibles sus fines.

Para existir como tales requieren necesariamente constituirse mediante instrumento público, y solicitar y obtener autorización del Estado para funcionar.

Si el fundador es una persona humana, puede disponer su constitución por acto de última voluntad.

Características.-

Sus principales características son:

a) Es una persona jurídica privada (conf. art. 148). El Código de Vélez (luego de la reforma de la Ley 17.711) la incluyó como persona jurídica de carácter privado en el art. 33, pero no la reguló. La regulación llegó luego, con la Ley 19.836 cuyos lineamientos en general fueron seguidos por el Proyecto de 1998 y por el nuevo Código Civil y Comercial.

b) En la fundación no hay socios ni asociados. En ella sólo hay beneficiados.

c) Tiene por finalidad el bien común, sin propósito de lucro. Es decir que tiene un fin altruista, de beneficio para la comunidad, exento de intenciones lucrativas.

d) Se constituye necesariamente mediante instrumento público y necesita autorización del Estado para funcionar.

e) Cuando el fundador es una persona humana, puede disponer la constitución de una fundación por acto de última voluntad (testamento).

f) Debe tener un patrimonio inicial que posibilite razonablemente el cumplimiento de los fines propuestos estatutariamente. Este patrimonio se conforma con el aporte patrimonial donado efectivamente por el fundador (que puede ser una persona física o jurídica) y con los aportes futuros prometidos por el fundador o por terceros.

Tener este patrimonio inicial es un requisito para obtener la autorización estatal para funcionar. Sin perjuicio de ello, la autoridad de contralor puede resolver favorablemente los pedidos de autorización si (de los antecedentes de los fundadores o de los servidores de la voluntad fundacional comprometidos por la entidad a crearse, y de las características del programa a desarrollar) resulta la aptitud potencial para el cumplimiento de los objetivos previstos en los estatutos (conf. art. 194).

Constitución y autorización (arts 195 a 200).-

El acto constitutivo de la fundación debe ser otorgado por:

a) el fundador o fundadores (o por su apoderado con poder especial), si se lo hace por acto entre vivos (haciendo una donación); o

b) por la persona autorizada por el juez de la sucesión, si lo es por disposición de última voluntad (legado en un testamento).

• **Contenido del instrumento.-** El instrumento de constitución debe ser presentado ante la autoridad de contralor para su aprobación, y debe contener (conf. art. 195):

1) Los datos del fundador o fundadores:

i) cuando se trate de personas humanas, su nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y número de documento de identidad y, en su caso, el de los apoderados o autorizados;

ii) cuando se trate de personas jurídicas, la razón social o denominación y el domicilio, acreditándose la existencia de la entidad fundadora, su inscripción registral y la representación de quienes comparecen por ella. En cualquier caso, cuando se invoca mandato debe dejarse constancia del documento que lo acredita.

2) El nombre y domicilio de la fundación. Ejemplo: "Fundación Te Ayudo", sede social en calle Chile 842, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

3) La designación del objeto, que debe ser preciso y determinado. Ejemplo: recuperación y rehabilitación general de personas que padecen alguna discapacidad funcional permanente, y a tales fines desarrollar cursos, conferencias, programas de asistencia, educación, integración social y laboral, etc.

4) El patrimonio inicial, integración y recursos futuros, lo que debe ser expresado en moneda nacional. De acuerdo al art. 196, los aportes de dinero en efectivo o de títulos valores deben ser depositados (mientras se tramita la autorización) en el banco habilitado por la autoridad de contralor. De los aportes no dinerarios debe hacerse un inventario con sus respectivas valuaciones, suscripto por contador público nacional.

5) El plazo de duración. Ejemplo: generalmente se establece en 99 años.

6) La organización del consejo de administración, duración de los cargos, régimen de reuniones y procedimiento para la designación de sus miembros (se debe designar el primer consejo de administración, el cual puede estar integrado por el fundador o por terceros).

7) Las cláusulas atinentes al funcionamiento de la entidad.

8) El procedimiento y régimen para la reforma del estatuto;

9) La fecha del cierre del ejercicio anual. Ejemplo: 31 de diciembre.

10) Las cláusulas de disolución y procedimiento atinentes a la liquidación y destino de los bienes;

11) El plan trienal de acción. (Ejemplo: plan de actividades a realizar en los primeros 3 años, tales como cursos, charlas, becas, etc.). Cumplido el plazo se debe proponer un plan de acción para el próximo trienio.

Vale agregar que, en el mismo instrumento, se deben designar los integrantes del primer consejo de administración y las personas facultadas para gestionar la autorización para funcionar.

Aportes.-

El dinero en efectivo o los títulos valores que integran el patrimonio inicial deben ser depositados durante el trámite de autorización en el banco habilitado por la autoridad de contralor de la jurisdicción en que se constituye la fundación.

Los aportes no dinerarios deben constar en un inventario con sus respectivas valuaciones, suscripto por contador público nacional (conf. art. 196).

Promesas de donación.-

Las promesas de donación hechas por los fundadores son revocables o irrevocables según las circunstancias:

- Son irrevocables a partir de que la autoridad de contralor la autoriza a funcionar. Antes de esa oportunidad el fundador podrá revocarlas.

- Si el fundador fallece después de firmar el acto constitutivo, las promesas de donación no podrán ser revocadas por sus herederos, a partir de la presentación a la autoridad de contralor solicitando la autorización para funcionar como persona jurídica.

Art. 197.- "Promesas de donación. Las promesas de donación hechas por los fundadores en el acto constitutivo son irrevocables a partir de la resolución de la autoridad de contralor que autorice a la entidad para funcionar como persona jurídica. Si el fundador fallece después de firmar el acto constitutivo, las promesas de donación no podrán ser revocadas por sus herederos, a partir de la presentación a la autoridad de contralor solicitando la autorización para funcionar como persona jurídica."

Si la fundación ya tiene autorización para funcionar como persona jurídica puede demandar el cumplimiento de las promesas de donación hechas a su favor por el fundador o por terceros, no siéndoles oponible la defensa vinculada a la revocación hecha antes de la aceptación, ni la relativa al objeto de la donación (conf. art. 198).

Responsabilidad durante la etapa de gestación.-

Los fundadores y administradores de la fundación son solidariamente responsables frente a terceros por las obligaciones contraídas hasta el momento en que se obtiene la autorización para funcionar. Los bienes personales de cada uno de ellos pueden ser afectados al pago de esas deudas sólo después de haber sido satisfechos sus acreedores individuales (conf. art. 199).

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.-

Consejo de Administración.-

El Consejo de Administración se encarga del gobierno y administración de la fundación, y está integrado por un mínimo de 3 personas humanas. Tiene todas las facultades necesarias para el cumplimiento del objeto de la fundación, dentro de las condiciones que establezca el estatuto (conf. art. 201).

Al respecto, los fundadores pueden reservarse (por disposición expresa del estatuto) dos facultades:

- La facultad de ocupar cargos en el consejo de administración (ej: Presidente vitalicio de la fundación); y
- La facultad de designar los consejeros cuando se produzca el vencimiento de los plazos de designación o la vacancia de alguno de ellos.

La designación de los integrantes del consejo de administración puede además ser conferida a instituciones públicas y a entidades privadas sin fines de lucro (conf. arts. 2022 y 203).

Características del cargo de consejero.-

El cargo de *consejero* presenta las siguientes características:

- 1) El consejero puede ser permanente o temporario.
- 2) Su cargo es honorario: no pueden recibir retribuciones por el ejercicio de su cargo, pero sí se le deben reembolsar los gastos realizados para cumplir su función (conf. art. 206).
- 3) Pueden ser removidos con el voto de por lo menos las 2/3 partes de los integrantes del cuerpo. El estatuto puede prever la caducidad automática de los mandatos por ausencias injustificadas y reiteradas a las reuniones del consejo (conf. art. 209).
- 4) Sus derechos y obligaciones se rigen por: la ley y las normas reglamentarias en vigor, por los estatutos, y (subsidiariamente) por las reglas del mandato. La violación a estas normas, por parte del consejero, lo hace responsable personalmente. La acción por responsabilidad puede promoverla tanto la fundación como la autoridad de contralor, sin perjuicio de las sanciones de índole administrativa y las medidas que esta última pueda adoptar respecto de la fundación y de los integrantes del consejo (conf. art. 211).
- 5) En caso de acefalía del consejo de administración por existir cargos vacantes en el consejo, en forma tal que su funcionamiento se torne imposible y no puedan designarse nuevos miembros conforme al estatuto (o los designados rehusaran aceptar los cargos), la autoridad de contralor debe proceder a reorganizar la administración de la fundación, a designar sus nuevas autoridades, y a modificar el estatuto en las partes pertinentes (conf. art. 210).

Comité Ejecutivo.-

El *Comité Ejecutivo* es un órgano que puede o no existir, según lo que disponga el estatuto. En efecto, el estatuto puede disponer que el consejo de administración delegue facultades a un *Comité Ejecutivo* para que se ocupe diariamente de las tareas ordinarias de administración o gestión, teniendo la obligación de rendir cuentas de lo hecho al consejo de administración.

El Comité Ejecutivo puede estar integrado por miembros del consejo de administración o por terceros. De acuerdo a las tareas encomendadas, el estatuto puede prever alguna forma de retribución pecuniaria a favor de los miembros del Comité Ejecutivo (conf. art. 205).

Reuniones, convocatorias, mayorías, decisiones y actas.-

Todo lo referente a la vida de la fundación (incluso reuniones del consejo de administración o del comité ejecutivo, procedimiento de convocatoria, etc) se debe

regir por lo que diga el estatuto. No obstante, el Código establece al respecto (en el art. 207) algunas pautas supletorias:

- El quórum (cantidad de integrantes necesarios para celebrar la reunión), tanto del consejo de administración como del comité ejecutivo, debe ser el de la mitad más uno de sus integrantes.
- Las decisiones se toman por mayoría absoluta de votos de los miembros presentes, excepto que la ley o el estatuto requieran mayorías calificadas (conf. art. 207). En caso de empate, el presidente del consejo de administración o del comité ejecutivo tiene doble voto.
- Las mayorías establecidas en el artículo 207 no se requieren para la designación de nuevos integrantes del consejo de administración cuando su concurrencia se ha tomado imposible (ej: por haberse reducido el número de integrantes del consejo).
- De las reuniones y decisiones de cada órgano se deja constancia en un libro especial de actas, en el cual se hará un resumen con los detalles más relevantes de la convocatoria y de lo actuado.

Remoción del consejo de administración.-

De acuerdo al art. 209, los miembros del consejo de administración pueden ser removidos con el voto de por lo menos las 2/3 partes de los integrantes del cuerpo. El estatuto puede prever la caducidad automática de los mandatos por ausencias injustificadas y reiteradas a las reuniones del consejo.

Contrato con el fundador o sus herederos.-

Todo contrato entre la fundación y los fundadores (o sus herederos), con excepción de las donaciones que éstos hacen a aquélla, debe ser sometido a la aprobación de la autoridad de contralor, y es ineficaz de pleno derecho sin esa aprobación (conf. art. 212).

Destino de los ingresos. Deber de avisar.-

Las fundaciones deben destinar la mayor parte de sus ingresos al cumplimiento de sus fines.

Si acumulan fondos debe ser con un objeto preciso (ej: cumplir un programa futuro de mayor envergadura) que esté relacionado al objeto previsto en el estatuto.

Los miembros del consejo de administración deben avisar a la autoridad de contralor de esos planes, y presentar documentación que acredite que su realización es factible. También deben avisarle de cualquier gasto que importe una disminución apreciable del patrimonio de la fundación (conf. art. 213).

INFORMACIÓN Y CONTRALOR.-

Las fundaciones deben proporcionar a la autoridad de contralor (INPJ) de su jurisdicción toda la información que ella les requiera, sea para verificar si los planes

programados son viables, si su actividad coincide con su finalidad de bien común o si (por el contrario) se ha desvirtuado, si mantiene su patrimonio, etc.

Además, las *reparticiones oficiales* (órganos municipales, Afip, etc.) deben suministrar directamente a la autoridad de contralor la información y asesoramiento que ésta les requiera para una mejor apreciación de los programas proyectados por las fundaciones (conf. arts. 214 y 215).

REFORMA DEL ESTATUTO Y DISOLUCIÓN.-

Reforma del estatuto. Mayorías necesarias.-

Para modificar el estatuto hay que atenerse a la mayoría de votos que éste exija; pero para el caso de que éste no lo prevea, el Código establece las siguientes pautas:

a) Cualquier reforma que pretenda hacerse en el estatuto, requiere por lo menos el voto de la mayoría absoluta de los integrantes del consejo de administración.

b) En los casos específicos de: 1) modificación del objeto; 2) fusión con entidades similares; y 3) disolución de la fundación, se requiere el voto de los 2/3 de los integrantes del consejo de administración. Esto se debe a la gran trascendencia que tienen estas decisiones.

La modificación del objeto sólo es procedente cuando lo establecido por el fundador ha llegado a ser de cumplimiento imposible.

Destino de los bienes en caso de disolución.-

En caso de disolución de la fundación, el remanente de los bienes debe destinarse a una entidad de carácter público o a una persona jurídica de carácter privado, que reúna las siguientes características:

- 1) que su objeto sea de utilidad pública o de bien común;
- 2) que no tenga fin de lucro; y
- 3) que esté domiciliada en la República Argentina.

Esta disposición no se aplica a las fundaciones extranjeras.

Las decisiones que se adopten en lo relativo al traspaso del remanente de los bienes requieren la previa aprobación de la autoridad de contralor.

Revocación de las donaciones.-

En principio, el hecho de que se reforme el estatuto, o que se disuelva la fundación y se traspasen sus bienes, no habilita a los donantes (o sus herederos) a pedir la revocación de las donaciones.

La excepción es que, al hacer la donación, se haya establecido expresamente como condición resolutoria el cambio de objeto. En este caso, sí procederá la acción de revocación de la donación (conf. art. 218).

FUNDACIONES CREADAS POR DISPOSICIÓN TESTAMENTARIA.-

En los casos en que la fundación deba crearse en razón de que una persona en su testamento ha dispuesto que sus bienes sean destinados a crear una fundación, será el Ministerio Público quien se encargará (junto con los herederos y el albacea testamentario, si lo hubiera) de que la voluntad del testador se cumpla.

En estos casos, los herederos entre sí y el albacea deben ponerse de acuerdo acerca del acta constitutiva y del estatuto que habrá de regir la fundación. Si no se ponen de acuerdo, las diferencias son resueltas por el juez de la sucesión, previa vista al Ministerio Público y a la autoridad de contralor (conf. arts. 219 y 220).

AUTORIDAD DE CONTRALOR.-

Atribuciones.-

La fundación no tiene socios ni asociados (solo tiene beneficiarios que a veces incluso son indeterminados) que puedan controlar que sus fines se cumplan y no se desvirtúen, que se respete su estatuto, y que (en general) su funcionamiento sea acorde a las disposiciones legales y estatutarias.

Ante esta situación es el Estado (a través de la autoridad de contralor) quien asume esa función de control y fiscalización.

A tales efectos, y de acuerdo al art. 221, la autoridad de contralor tiene las siguientes atribuciones:

- 1) Aprobar los estatutos y su reforma.
- 2) Fiscalizar su funcionamiento y el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias que la rigen.
- 3) Fiscalizar la disolución y liquidación.

Además, por los arts. 222 y 223 también le corresponde:

a) Solicitar al juez la designación de administradores interinos de las fundaciones cuando no se llenan las vacantes de sus órganos de gobierno con perjuicio para su normal funcionamiento o cuando carecen temporariamente de tales órganos.

b) Suspender, en caso de urgencia, el cumplimiento de las deliberaciones o resoluciones contrarias a las leyes o los estatutos, y solicitar a las autoridades judiciales la nulidad de esos actos.

c) Solicitar a las autoridades la suspensión o remoción de los administradores que hubieran violado los deberes de su cargo, y la designación de administradores provisorios.

d) Convocar al consejo de administración a petición de alguno de sus miembros, o cuando se compruebe la existencia de irregularidades graves.

e) En los casos de cambio de objeto puede fijar el nuevo objeto de la fundación cuando el establecido por el fundador es de cumplimiento imposible o ha desaparecido, procurando respetar en la mayor medida posible la voluntad del fundador.

En tal caso, tiene las atribuciones necesarias para modificar los estatutos de conformidad con ese cambio.

f) Puede disponer la fusión o coordinación de actividades de dos o más fundaciones cuando haya que fijar un nuevo objeto, o cuando la multiplicidad de fundaciones de objeto análogo hacen aconsejable la medida para su mejor desenvolvimiento y sea manifiesto el mayor beneficio público.

Recursos.-

Se pueden recurrir mediante el trámite más breve (ej: trámite Sumario) que rijan en la jurisdicción que corresponda, ante el tribunal de apelación en lo civil correspondiente al domicilio de la fundación, las decisiones administrativas que:

- denieguen la autorización para la constitución de la fundación o retiren la personería jurídica acordada (en los casos de ilegitimidad y arbitrariedad); o
- denieguen la aprobación requerida por una fundación extranjera (o habiendo sido concedida, sea luego revocada).

Los órganos de la fundación pueden deducir igual recurso contra las resoluciones que dicte la autoridad de contralor en la situación prevista en el artículo 223 inciso b), o sea: cuando la resolución disponga la fusión o coordinación de dos o mas fundaciones (conf. art. 224).

PERSONAS JURÍDICAS

PERSONA JURÍDICA

Definición

• **Art. 141** — "Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación."

A diferencia de la persona humana (que "goza" de personalidad por derecho propio), en el caso de las personas jurídicas es la legislación la que "les confiere" personalidad cuando el ente es útil o necesario, pero limita esa personalidad conferida al cumplimiento del objeto y fines de su creación.

Comienzo de la existencia

La persona jurídica comienza a existir desde su constitución y en principio no necesita autorización del Estado para funcionar, excepto en los casos que la ley establezca que necesita autorización estatal, pues en este caso no puede funcionar antes de obtenerla y comienza a existir cuando el Estado le aprueba sus estatutos y las autoriza a funcionar.

Acto Constitutivo

Toda persona jurídica requiere, como primera medida, un acto constitutivo creador de la misma, el cual recibirá distinta denominación (acto conjunto, acto fundacional, contrato social, etc.) según cuál sea la persona jurídica de que se trate.

Estatuto

• En el acto constitutivo se establecerán los "estatutos" de la persona jurídica.

• El "estatuto" son las reglas fundamentales que organizan y rigen la vida de la persona jurídica.

• En él se establecen — el nombre, el domicilio y el objeto de la persona jurídica; cómo se forma e invierte el patrimonio, y cuál será su destino en caso de disolución. Se establecen los órganos de gobierno, el modo de tomar decisiones, la forma de votar, los derechos y obligaciones de cada miembro, los requisitos para ingresar en la entidad, etc. / • Los estatutos deben ser aprobados por la Inspección General de Personas Jurídicas.

Personalidad diferenciada

Art. 143 — "La persona jurídica tiene una personalidad distinta de la de sus miembros. Los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica, excepto en los supuestos que expresamente se prevén en este Título y lo que disponga la ley especial."

Inoponibilidad de la personalidad jurídica

Art. 144 — "La actuación que esté destinada a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica, constituya un recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de cualquier persona, se imputa a quienes a título de socios, asociados, miembros o contrahentes directos o indirectos, la hicieron posible quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. Lo dispuesto se aplica sin afectar los derechos de los terceros de buena fe y sin perjuicio de las responsabilidades personales de que puedan ser pasibles los participantes en los hechos por los perjuicios causados."

Clasificación

• **Personas jurídicas públicas:** son aquellas en cuya creación, existencia y funcionamiento interviene el Estado. Se rigen por el derecho público; aún cuando parte de su actividad esté bajo regulación del derecho privado.

• **Personas jurídicas privadas:** son aquellas en cuya creación, existencia y funcionamiento interviene los particulares. Se rigen por el derecho privado aun cuando requieran autorización para funcionar.

Enumeración — a) Estado nacional, Provincias, Ciudad de Buenos Aires, municipios, entidades autárquicas y demás organizaciones a las que el ordenamiento atribuya ese carácter; b) Estados extranjeros, organizaciones a las que el derecho internacional público reconozca personalidad jurídica y toda persona jurídica constituida en el extranjero cuyo carácter público resulte de su derecho aplicable; c) Iglesia Católica.

Enumeración — a) sociedades; b) asociaciones civiles; c) simples asociaciones; d) fundaciones; e) iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas; f) mutuales; g) cooperativas; h) consorcio de propiedad horizontal; i) toda otra contemplada en disposiciones del Código o en otras leyes.

PARTE GENERAL

- Participación del Estado** → El Estado puede actuar como poder público, y también en el ámbito el derecho privado. Su participación en una empresa privada no transforma a ésta en persona jurídica pública.
- Leyes aplicables** →
- Las que se constituyen en la República, se rigen por: a) las normas imperativas de la ley especial o, en su defecto, de este Código; / b) el acto constitutivo y reglamentos; / c) las normas supletorias de leyes especiales, o en su defecto, por las de este Título.
 - Las que se constituyen en el extranjero se rigen por la Ley General de Sociedades.

EFFECTOS	ATRIBUTOS
1) La persona jurídica es una persona distinta de los socios que la integran.	1) Nombre → Puede tratarse de un nombre de fantasía, o nombre de algún miembro. Se le debe agregar la forma jurídica adoptada. Se elige libremente con recaudos de: veracidad, novedad y aptitud distintiva. No puede contener términos contrarios a la ley, orden público o buenas costumbres.
2) Tiene nombre y domicilio propios.	2) Domicilio → La persona jurídica tiene su domicilio en el fijado en su estatuto o en la autorización para funcionar. El cambio de domicilio requiere modificación del estatuto.
3) Carece de capacidad de ejercicio. Su capacidad de derecho está limitada por el principio de especialidad.	3) Patrimonio → La persona jurídica debe tener un <u>patrimonio propio</u> . Es un atributo sin el cual carecería de autonomía.
4) Tiene un patrimonio propio.	4) Capacidad → Las personas jurídicas pueden adquirir derechos y contraer obligaciones. Actúan a través de representantes. Su capacidad está limitada por: objeto y fin del ente.
5) Los deudores de la persona jurídica, no son deudores de los miembros.	
6) Un miembro puede ser testigo, en un pleito de la persona jurídica.	
7) Un miembro puede celebrar contrato con la persona jurídica.	

- **Duración de la persona jurídica** → Es perpetua, salvo que la ley o estatuto dispongan lo contrario.
- **Objeto** → Es la actividad a la que la persona jurídica se va a dedicar. Debe ser indicado con claridad y exactitud, evitando indicaciones ambiguas. "Debe ser preciso y determinado." (conf. art. 156).

Estatuto → Son las reglas fundamentales que organizan y rigen la vida de la persona jurídica. En él se establecen el nombre, el domicilio y el fin u objeto de la persona jurídica; cómo se forma e invierte el patrimonio, y el destino de éste en caso de disolución. Se establecen, además, los órganos de gobierno, de administración y fiscalización, modo de tomar decisiones, forma de votar, derechos y obligaciones de cada miembro, requisitos para ingresar en la entidad, etc.

Administradores → Deben actuar con lealtad y diligencia. No pueden perseguir ni favorecer intereses contrarios a los de la persona jurídica.

- **Responsabilidad** - Responden en forma ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica, sus miembros y terceros, por los daños causados por su culpa en el ejercicio de sus funciones.

Transformación / Fusión / Escisión → Art. 162 → "Las personas jurídicas pueden transformarse, fusionarse o escindirse en los casos previstos por este Código o por la ley especial. En todos los casos es necesaria la conformidad unánime de los miembros de la persona o personas jurídicas, excepto disposición especial o estipulación en contrario del estatuto."

Disolución

- **Causales** → enumeradas en el Art. 163.
- **Reconducción** → Art. 166 → "La persona jurídica puede ser reconducida mientras no haya concluido su liquidación, por decisión de sus miembros adoptada por unanimidad o la mayoría requerida por la ley o el estatuto, siempre que la causa de su disolución pueda quedar removida por decisión de los miembros o en virtud de la ley."

Liquidación

Producida la causal de disolución, la persona jurídica entra en la etapa de liquidación. Durante la liquidación la persona jurídica no puede realizar nuevas operaciones, debiendo limitarse a concluir las pendientes.

- **Responsabilidades** → En caso de infracción a lo dispuesto, responden ilimitada y solidariamente sus administradores y los miembros que, conociendo o debiendo conocer la situación y teniendo el poder de decisión necesario para ponerle fin, omiten adoptar las medidas necesarias.

ASOCIACIONES CIVILES

La Asociación Civil es una persona jurídica privada creada, organizada y administrada por varias personas para lograr un objeto o fin que no sea contrario al interés general o al bien común. Necesita autorización estatal para funcionar y no puede tener fin de lucro como fin principal.

- **Regulación normativa** → Arts. 168 a 186 (nuevo CCCN) + Constitución Nacional (art. 14).

Acto constitutivo

La Asociación Civil se crea mediante un acto constitutivo, (hecho en instrumento público). Se solicita la autorización estatal para funcionar y, otorgada ésta, se inscribe el acto constitutivo en el registro. / • **Contenido del acto constitutivo** → Art. 170. Hasta la inscripción se aplican las normas de la simple asociación.

Órganos de Control

- **Órgano de administración** → es la Comisión Directiva. Debe estar integrada por asociados. La primera comisión directiva, se designa en el acto constitutivo.
- **Órgano de fiscalización** → puede estar integrado por asociados y no asociados. El primer órgano de fiscalización se debe designar en el acto constitutivo. La comisión revisora de cuentas es obligatoria en las asociaciones con más de cien asociados.
- **Control estatal** → para funcionar, las asociaciones civiles requieren autorización estatal, y además están sujetas a un contralor permanente de la autoridad competente. La autorización para funcionar la otorga la Inspección General de Justicia.

- **Participación** → Todos los asociados tienen derecho a participar en los actos de gobierno.

Responsabilidad de los directivos

Los directivos deben actuar con lealtad y diligencia. De lo contrario, responden en forma ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica, miembros y terceros.

Extinción de la responsabilidad

- La responsabilidad de los directivos se extingue si, en la asamblea ordinaria, los socios resuelven → apobar su gestión; o renunciar a iniciarle acciones de responsabilidad; o hacer transacción.

Asociados

- **Participación en las asambleas** → Para participar y votar en las asambleas, el requisito es estar al día con el pago de las cuotas y contribuciones.
- **Renuncia** → El asociado tiene derecho a renunciar a tal condición.
- **Exclusión** → La asociación tiene derecho a excluir o expulsar al asociado sólo cuando la causa sea grave y esté prevista en el estatuto.
- **Responsabilidad** → Los asociados no responden por las deudas de la asociación civil, ni en forma directa ni subsidiaria.
- **Intransmisibilidad** → La calidad de asociado es intransmisible.

Disolución → • **Causas (art. 183)** → a) las mismas de las personas jurídicas privadas (art. 163) / b) reducción de cantidad de asociados a un número inferior al total de miembros de su comisión directiva y órgano de fiscalización. Hay un plazo de 6 meses para restablecer ese mínimo; de lo contrario entra en disolución.

Liquidación → Se rige por las disposiciones del estatuto, bajo vigilancia del órgano de fiscalización. Todo es similar a otras personas jurídicas, pero si hubiera un remanente no se distribuye entre sus miembros, sino que se le da el destino previsto en el estatuto. A falta de previsión, el remanente se destina a otra asociación civil de objeto igual o similar. / • El liquidador debe ser designado por la asamblea extraordinaria.

- **Ley aplicable** → Lo dispuesto para las asociaciones civiles en cuanto a: acto constitutivo; gobierno; administración; socios; fiscalización; y funcionamiento.

• **Acto constitutivo** → Por instrumento público o privado (con firma certificada por escribano). Al nombre se le debe agregar "simple asociación" o "asociación simple".

• El CCCN las considera personas jurídicas privadas. Las regula en arts. 187 a 192.

SIMPLES ASOCIACIONES

- **Existencia** → Comienza en la fecha del acto constitutivo.

- **Insolvencia** → El asociado no responde por las deudas de la asociación sino hasta la concurrencia del aporte comprometido y de las cuotas que deba. En caso de insuficiencia de bienes → responsabilidad solidaria del administrador por las obligaciones que resultan de decisiones que ha suscripto.
- Puede prescindir del órgano de fiscalización si tiene menos de 20 asociados.

FUNDACIONES

Las fundaciones son personas jurídicas que se constituyen con una finalidad de bien común, sin propósito de lucro, mediante el aporte patrimonial de una o más personas, destinado a hacer posibles sus fines.

Características

a) Es una persona jurídica privada. / b) No hay socios ni asociados; sólo beneficiados. / c) Finalidad: el bien común, sin propósito de lucro. / d) Se constituye por instrumento público y necesita autorización del Estado. / e) Se puede disponer su constitución por acto de última voluntad. / f) Su patrimonio inicial debe posibilitar cumplir los fines.

Constitución

El acto constitutivo debe ser otorgado por:

- a) el fundador o fundadores; o
- b) el autorizado por el juez de la sucesión (última voluntad).
- Contenido → Art. 195 → 11 requisitos.

Aportes

- Dinero en efectivo → se deposita en el banco habilitado.
- Aportes no dinerarios → inventario y valuación.

Responsabilidad en etapa de creación

Los fundadores y administradores son solidariamente responsables frente a terceros por las obligaciones contraídas hasta obtener la autorización para funcionar.

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

Consejo de Administración

Se encarga del gobierno y administración de la fundación, y está integrado por un mínimo de 3 personas humanas. Los fundadores pueden reservarse dos facultades: • ocupar cargos en el consejo / • designar consejeros.

Consejero

- 1) Puede ser permanente o temporario.
- 2) Su cargo es honorario.
- 3) Pueden ser removidos con el voto de 2/3 partes de los integrantes del cuerpo.
- 4) Sus derechos y obligaciones se rigen por la ley, normas reglamentarias, estatutos, y reglas del mandato.
- 5) En caso de acefalía del consejo, la autoridad de contralor reorganiza la administración, designa autoridades, y modifica el estatuto.

Comité Ejecutivo

El estatuto puede disponer que el consejo de administración delegue facultades a un Comité Ejecutivo para que se ocupe diariamente de las tareas ordinarias de administración. Puede estar integrado por miembros del consejo, o terceros. Pueden recibir retribución pecuniaria.

• Reuniones, convocatorias, mayorías, decisiones y actas → se deben regir por lo que diga el estatuto. No obstante, el Código establece pautas supletorias → Art. 207.

• Remoción del consejo de administración → Los miembros del consejo de administración pueden ser removidos con el voto de por lo menos las 2/3 partes de los integrantes del cuerpo.

• Destino de los ingresos.- Las fundaciones deben destinar la mayor parte de sus ingresos al cumplimiento de sus fines.

• Información y contralor → Las fundaciones deben proporcionar a la autoridad de contralor toda la información que ella les requiera, sea para verificar si los planes programados son viables, si su actividad coincide con su finalidad de bien común o si (por el contrario) se ha desvirtuado, si mantiene su patrimonio, etc.

REFORMA DEL ESTATUTO Y DISOLUCIÓN

- La Reforma del Estatuto → requiere por lo menos el voto de la mayoría absoluta de los integrantes del consejo de administración.
- La modificación del objeto, la fusión con entidades similares y la disolución → requieren el voto de los 2/3 de los integrantes del consejo de administración.

• Si hay disolución: el remanente de los bienes debe destinarse a una entidad pública o privada de utilidad pública o bien común, sin fin de lucro y que esté domiciliada en la República.

FUNDACIONES CREADAS POR TESTAMENTO

- Si la fundación debe crearse en razón de lo dispuesto en un testamento, el Ministerio Público junto al heredero/s y el albacea se encargarán de crear la fundación.
- Si no hay acuerdo acerca del Estatuto que regirá la fundación, las diferencias las resuelve el juez de la sucesión, previa vista al Ministerio Público y a la autoridad de contralor.

AUTORIDAD DE CONTRALOR

- Atribuciones principales
 - 1) aprobar los estatutos y su reforma.
 - 2) fiscalizar su funcionamiento y el cumplimiento del Estatuto.
 - 3) fiscaliza la disolución y liquidación.

• Recursos → Se pueden recurrir mediante el trámite mas breve las decisiones administrativas que denieguen la autorización para la constitución de la fundación o retiren la personería jurídica, la resolución que disponga la fusión o coordinación de fundaciones.

CAPÍTULO XV
BIENES

Regulación normativa.-

El nuevo Código Civil y Comercial desarrolla este tema en el Libro Primero ("Parte General"), Título III, y se refiere no sólo a la especie "cosas", sino también a su género: los "bienes". Esto lo diferencia del sistema del Código de Vélez, que se refería sólo a las cosas y lo hacía en la parte de los derechos reales.

En el Capítulo 1 de este Título III dedicado a los Bienes, el nuevo Código Civil y Comercial no define a las cosas ni a los bienes, pero suministra conceptos sobre distintas categorías de ellos, regula los bienes con relación a las personas y los bienes con relación a los derechos de incidencia colectiva.

En el Capítulo 2 trata la Función de garantía del patrimonio

Por último, el Capítulo 3 es dedicado a Vivienda, cuyo régimen reemplaza al "bien de familia" regulado por la Ley 14.394 ahora derogada.

BIENES

Capítulo 1 Con relación a las personas y a los derechos de incidencia colectiva (arts. 225 a 241)	Capítulo 2 Función de garantía (arts. 242 a 243)	Capítulo 3 Vivienda (arts. 244 a 256)
Sección 1. Conceptos (arts. 225 a 234) Sección 2. Bienes c/relación a las personas (arts. 235 a 239) Sección 3. Bienes c/relación a los dchos de incidencia colectiva (arts. 240 a 241)		

CONCEPTOS.-

En esta sección se dan conceptos sobre varias categorías de cosas, frutos, productos y bienes fuera del comercio. También se eliminan algunas categorías, tal el caso de "inmuebles por accesión moral" y se hacen modificaciones a los conceptos de cosas fungibles y consumibles.

Veamos a continuación cada uno de estos conceptos.

Cosas muebles.-

Son cosas muebles las que pueden desplazarse por sí mismas o por una fuerza externa (conf. art. 227).

Las que se trasladan por sí mismas se llaman "semovientes" (ej: los animales).

Las que se trasladan por una fuerza externa, puede deberse a una fuerza externa artificial, en cuyo caso se denominan "locomóviles" (ej: auto, moto, barco, etc.); o por fuerza externa del hombre, como por ejemplo un libro, una silla, etc.

Cosas inmuebles.-

Son cosas inmuebles aquellas que se encuentran fijas en un lugar determinado y con carácter permanente (ej: una casa). Se subdividen en:

a) Inmuebles por su naturaleza (art. 225): son el suelo y las cosas incorporadas a él de una manera orgánica (ej: rocas, árboles, ríos, etc.), y las cosas que se encuentran bajo el suelo sin el hecho del hombre (ej: minas, restos fósiles, etc.).

b) Inmuebles por accesión (art. 226): son las cosas muebles que se encuentran inmovilizadas por su adhesión física al suelo, con carácter perdurable (ej: los ladrillos de una casa). En este caso, los muebles forman un todo con el inmueble y no pueden ser objeto de un derecho separado sin la voluntad del propietario.

No se consideran inmuebles por accesión las cosas afectadas a la explotación del inmueble o a la actividad del propietario (ej: las herramientas de labranza de un campo).

Cosas divisibles.-

Son cosas divisibles las que pueden ser divididas en porciones reales sin ser destruidas, cada una de las cuales forma un todo homogéneo y análogo tanto a las otras partes como a la cosa misma (art. 228).

Las cosas no pueden ser divididas si su fraccionamiento convierte en antieconómico su uso y aprovechamiento. En materia de inmuebles, la reglamentación del fraccionamiento parcelario corresponde a las autoridades locales.

De manera que, una cosa es divisible cuando puede ser dividida en porciones reales sin que por ello se destruya (ej: la tierra, cantidades de trigo, el dinero, etc). Incluso, una cosa que es divisible físicamente debe ser considerada como indivisible si la división la perjudica económicamente (ej: un rubí de grandes dimensiones es posible dividirlo, pero la división causaría disminución de su valor).

Por el contrario, son "*cosas indivisibles*" aquellas que, si son divididas, se destruyen o pierden su naturaleza (ej: un caballo, una silla, un libro, etc., pues si los dividimos físicamente se destruyen).

Cosas principales.-

Son cosas principales las que pueden existir por sí mismas (art. 229).

Son aquellas que para existir no requieren de la existencia de otra cosa; pueden existir por sí mismas, tienen una existencia propia, independiente de la existencia de cualquier otra cosa.

Cosas accesorias.-

Son cosas accesorias aquellas cuya existencia y naturaleza son determinadas por otra cosa de la cual dependen o a la cual están adheridas. Su régimen jurídico es el de la cosa principal, excepto disposición legal en contrario (art. 230).

Si las cosas muebles se adhieren entre sí para formar un todo sin que sea posible distinguir la accesoria de la principal, es principal la de mayor valor. Si son del mismo valor no hay cosa principal ni accesoria.

Las cosas accesorias no tienen existencia propia y por tanto, para existir, dependen de la existencia de otra cosa. Su régimen jurídico se basa en el principio de que "*lo accesorio sigue la suerte de lo principal*".

Ejemplos: las llaves del auto serían accesorios, en tanto que el auto sería la cosa principal; los adornos de un vestido serían accesorios de éste; etc.

Cosas consumibles.-

Son cosas consumibles aquellas cuya existencia termina con el primer uso (art. 231).

Ejemplos: el dinero, el vino, el maíz, el aceite y, en general, todas las bebidas y los alimentos, pues no pueden ser usados sin ser consumidos.

Por el contrario, son "*cosas no consumibles*" aquellas que no dejan de existir por el primer uso que de ellas se hace, aunque sean susceptibles de consumirse o deteriorarse después de algún tiempo. Ejemplos: la ropa, los muebles de una casa, los libros, etc.

Cosas fungibles.-

Son cosas fungibles aquellas en que todo individuo de la especie equivale a otro individuo de la misma especie, y pueden sustituirse por otras de la misma calidad y en igual cantidad (art. 232). Ejemplo: el dinero, el trigo, etc.

Por el contrario, son "*cosas no fungibles*" aquellas que NO pueden sustituirse las unas por las otras, porque están dotadas de características propias, que impiden que puedan ser reemplazadas por otras. Ejemplos: un cuadro famoso, un libro con anotaciones personales, etc.

Frutos y productos.-

El art. 233 establece los conceptos de "frutos" y "productos":

Frutos: son los objetos que un bien produce, de modo renovable, sin que se altere o disminuya su sustancia. Ejemplos: las cosechas, las frutas, las crías de animales.

- Frutos naturales son las producciones espontáneas de la naturaleza (ej: fruta de las plantas).

- Frutos industriales son los que se producen por la industria del hombre o la cultura de la tierra (ej: electrodomésticos).

- Frutos civiles son las rentas que la cosa produce (ej: intereses de un capital).

Las remuneraciones del trabajo se asimilan a los frutos civiles.

Productos: son los objetos no renovables que separados o sacados de la cosa alteran o disminuyen su sustancia. Ejemplo: minerales o metales sacados de una mina.

Los frutos naturales e industriales y los productos forman un todo con la cosa, si no son separados.

Bienes fuera del comercio.-

De acuerdo al art. 234, los "bienes fuera del comercio" son aquellos cuya transmisión está prohibida: a) por la ley, o b) por un acto jurídico (cuando el Código le permite esta prohibición).

- Ejemplo de transmisión prohibida por la ley: bienes del dominio público del Estado.

- Ejemplo de transmisión prohibida por actos jurídicos (cuando el Código permite tales prohibiciones): por el art. 1972, en un acto a título gratuito (por ej, donación de una propiedad) se puede disponer que lo donado no se pueda transmitir durante 6 años.

Respecto a los "bienes dentro del comercio", el Código no se refiere expresamente a ellos, quizás porque parte de la idea general de que todos los bienes están en el comercio, salvo cuando la ley o un acto jurídico prohíbe la transmisión.

BIENES CON RELACIÓN A LAS PERSONAS.-

Al tratar de los "Bienes con relación a las personas", el nuevo Código Civil y Comercial regula:

- Bienes del dominio público (art. 235)
- Bienes del dominio privado del Estado (art. 236) (nacional, provincial o municipal)
- Bienes de los particulares (art. 238)
- Aguas de los particulares (art. 239)

Bienes pertenecientes al dominio público.-

El art. 235 enumera, a través de varios incisos, los bienes pertenecientes al dominio público:

Art. 235.- "Bienes pertenecientes al dominio público. Son bienes pertenecientes al dominio público, excepto lo dispuesto por leyes especiales:

a) el mar territorial hasta la distancia que determinen los tratados internacionales y la legislación especial, sin perjuicio del poder jurisdiccional sobre la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental. Se entiende por mar territorial el agua, el lecho y el subsuelo;..."

El mar territorial (concepto que comprende el agua, el lecho y el subsuelo) es un bien perteneciente al dominio público. *¿Hasta qué distancia lo es?* Al respecto, la Ley 17.094 ("Soberanía argentina en el mar") nos da una aproximación:

- "La soberanía de la Nación Argentina se extiende al mar adyacente a su territorio hasta una distancia de doscientas millas marinas, medidas desde la línea de las más bajas mareas..." (conf. art. 1)

- "La soberanía de la Nación Argentina se extiende asimismo al lecho del mar y al subsuelo de las zonas submarinas adyacentes a su territorio hasta una profundidad de doscientos metros o más allá de este límite, hasta donde la profundidad de las aguas suprayacentes permita la explotación de los recursos naturales de dichas zonas." (conf. art. 2).

"...b) las aguas interiores, bahías, golfos, ensenadas, puertos, ancladeros y las playas marítimas; se entiende por playas marítimas la porción de tierra que las mareas bañan y desocupan durante las más altas y más bajas mareas normales, y su continuación hasta la distancia que corresponda de conformidad con la legislación especial de orden nacional o local aplicable en cada caso;

c) los ríos, estuarios, arroyos y demás aguas que corren por cauces naturales, los lagos y lagunas navegables, los glaciares y el ambiente periglacial y toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general, comprendiéndose las aguas subterráneas, sin perjuicio del ejercicio regular del derecho del propietario del fundo de extraer las aguas subterráneas en la medida de su interés y con sujeción a las disposiciones locales. Se entiende por río el agua, las playas y el lecho por donde corre, delimitado por la línea de ribera que fija el promedio de las máximas crecidas ordinarias. Por lago o laguna se entiende el agua, sus playas y su lecho, respectivamente, delimitado de la misma manera que los ríos; (límite de la ribera)..."

Es importante destacar que se mencionan "los glaciares y el ambiente periglacial" por su importancia como recurso hídrico para la población. Sobre las "aguas subterráneas" se deja a salvo el derecho del propietario del terreno a extraerlas en la medida de su interés. El río tiene su límite fijado por la línea de ribera que fija "el promedio de las máximas crecidas ordinarias".

"...d) las islas formadas o que se formen en el mar territorial, la zona económica exclusiva, la plataforma continental o en toda clase de ríos, estuarios, arroyos, o en los lagos o lagunas navegables, excepto las que pertenecen a particulares;

e) el espacio aéreo suprayacente al territorio y a las aguas jurisdiccionales de la Nación Argentina, de conformidad con los tratados internacionales y la legislación especial;

f) las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra pública construida para utilidad o comodidad común;..."

Acá se trata de bienes que no son naturales sino que fueron construidos por el Estado; pueden ser los que menciona la norma o "cualquier otra obra pública" construida para utilidad o comodidad común.

"...g) los documentos oficiales del Estado;

h) las ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos."

Vale agregar que los bienes públicos del Estado son inenajenables, inembargables e imprescriptibles. Las personas tienen su uso y goce, sujeto a las disposiciones generales y locales (conf. art. 237).

Bienes del dominio privado del Estado.-

El art. 236 enumera, a través de varios incisos, los bienes del dominio privado del Estado:

Art. 236.- "Bienes del dominio privado del Estado. Pertenecen al Estado nacional, provincial o municipal, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales:

a) los inmuebles que carecen de dueño;

b) las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas, sustancias fósiles y toda otra de interés similar, según lo normado por el Código de Minería;

- c) los lagos no navegables que carecen de dueño;
- d) las cosas muebles de dueño desconocido que no sean abandonadas, excepto los tesoros;
- e) los bienes adquiridos por el Estado nacional, provincial o municipal por cualquier título."

Sobre los bienes privados el Estado (nacional, provincial o municipal) tiene un derecho de propiedad al igual que cualquier particular, pero la enajenación de esos bienes está regulada por el derecho administrativo.

Los bienes privados del Estado, en general son prescriptibles, embargables (salvo que estén afectados a un servicio público) y enajenables (si se cumplen las exigencias de las leyes administrativas para ello).

Bienes municipales.-

Los *bienes municipales* son aquellos que el Estado (nacional o provincial) ha puesto bajo el dominio de las municipalidades (ej: plazas, calles). Las municipalidades son personas jurídicas de carácter público (art. 146) y -al igual que el Estado nacional o provincial- tienen bienes de dominio público y bienes de dominio privado.

Bienes de los particulares.-

Art. 238.- "Bienes de los particulares. Los bienes que no son del Estado nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipal, son bienes de los particulares sin distinción de las personas que tengan derecho sobre ellos, salvo aquellas establecidas por leyes especiales."

La regla general es que todos los bienes que no son del Estado (sea nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) pertenecen a los particulares. También es válida a la inversa: si un bien no pertenece a ningún particular debe considerarse del dominio privado del Estado.

Aguas de los particulares.-

La importancia fundamental del agua en diversos aspectos (para la vida, la agricultura, la ganadería, la industria, etc.) ha determinado que el Estado la regule.

En el art. 235, el Código Civil y Comercial se refiere a aguas que son del dominio público del Estado (ej: *las aguas interiores, los ríos, estuarios, arroyos y demás aguas que corren por cauces naturales, los lagos y lagunas navegables, los glaciares y el ambiente periglacial y toda otra agua que tenga o adquiriera la aptitud de satisfacer usos de interés general, incluso las aguas subterráneas*).

En el art. 239, el Código se refiere a las "*aguas que surgen en los terrenos de los particulares*". Esas aguas pertenecen al dueño del terreno, el cual puede usar libremente de ellas, siempre que no formen cauce natural. Las aguas de los particulares quedan sujetas al control y a las restricciones que en interés público establezca la autoridad de aplicación. Nadie puede usar de aguas privadas en perjuicio de terceros ni en mayor medida de su derecho.

Si constituyen cursos de agua por cauces naturales, pertenecen al dominio público, y los particulares no pueden alterar esos cursos de agua. El uso por cualquier título

de aguas públicas, u obras construidas para utilidad o comodidad común, no les hace perder el carácter de bienes públicos del Estado, inalienables e imprescriptibles. El hecho de correr los cursos de agua por los terrenos inferiores no da a los dueños de éstos derecho alguno.

BIENES CON RELACIÓN A LOS DERECHOS DE INCIDENCIA COLECTIVA.-

Límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes.-

Los derechos individuales no son absolutos y tienen limitaciones. Una de esas limitaciones es que no pueden afectar derechos de incidencia colectiva. Los derechos de incidencia colectiva (que nuestra CN -arts. 41 y 43- reconoce y protege mediante la "acción de amparo colectivo") son los que recaen sobre bienes comunes a todos los ciudadanos.

Por ello, el art. 240 del Código Civil y Comercial establece que el ejercicio de los derechos individuales sobre estos bienes (públicos o privados) que inciden en toda la sociedad, debe respetar las siguientes pautas:

- a) debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva;
- b) debe ser conforme a las normas del derecho administrativo dictadas en el interés público; y
- c) no debe afectar el medio ambiente, es decir no debe afectar al funcionamiento ni a la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales y el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial (tal el caso de la Ley 25.675 "Ley Nacional del Ambiente").

Art. 240.- "Límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes. El ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionados en las Secciones 1ª y 2ª debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. Debe conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial."

Jurisdicción.-

Sin importar en que jurisdicción (nacional o provincial) se ejerzan los derechos, siempre deben respetarse las normas de *presupuestos mínimos de protección ambiental*, entendiendo por tales a las normas que *conceden una tutela ambiental uniforme o común para el territorio nacional y tienen por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental* (conf. art. 6 de Ley 25.675).

Ejemplo: la Ley 26.815 fija Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental en materia de Incendios Forestales.

Art. 241.- "Jurisdicción. Cualquiera sea la jurisdicción en que se ejerzan los derechos, debe respetarse la normativa sobre presupuestos mínimos que resulte aplicable."

En el Anteproyecto del Código, este art. 241 establecía como un derecho fundamental el acceso al agua potable: "*Todos los habitantes tienen garantizado el*

acceso al agua potable para fines vitales". Pero el Poder Ejecutivo eliminó este texto y dejó al art. 241 refiriéndose a la jurisdicción.

No obstante esta eliminación, el derecho de acceso al agua potable se puede mantener en razón del art. 240 y la aplicación de varios tratados de derechos humanos que reconocen este derecho y que deben ser tenidos en cuenta por el juez (conf. arts. 1 a 3).

FUNCIÓN DE GARANTÍA

A través del art. 242, el nuevo Código Civil y Comercial establece la "función de garantía" de los bienes.

Art. 242.- "Garantía común. Todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de sus obligaciones y constituyen la garantía común de sus acreedores, con excepción de aquellos que este Código o leyes especiales declaren inembargables o inejecutables. Los patrimonios especiales autorizados por la ley sólo tienen por garantía los bienes que los integran."

En esta norma el nuevo Código se refiere a la función de garantía que cumple el patrimonio (constituido por todos los bienes y derechos patrimoniales de una persona) y consagra expresamente el tradicional principio de que "el patrimonio del deudor es la garantía común de los acreedores". Este principio significa que todos los bienes (presentes y futuros) del patrimonio del deudor responden por las deudas que él tenga. Si el deudor no cumple, los acreedores pueden ejecutar sus bienes (en la medida necesaria para satisfacer su crédito) y cobrarse del producido de éstos (conf. art. 743).

Bienes que constituyen la garantía.-

El art. 743 establece cuáles son los bienes que constituyen la garantía común de los acreedores.

Art. 743.- "Bienes que constituyen la garantía. Los bienes presentes y futuros del deudor constituyen la garantía común de sus acreedores. El acreedor puede exigir la venta judicial de los bienes del deudor, pero sólo en la medida necesaria para satisfacer su crédito. Todos los acreedores pueden ejecutar estos bienes en posición igualitaria, excepto que exista una causa legal de preferencia."

Limitaciones.-

Este principio de que "el patrimonio es la prenda o garantía común de los acreedores" no es absoluto, ya que tiene dos importantes limitaciones:

1) Los acreedores no son todos iguales: hay algunos de ellos que tienen derecho a ser pagados antes que otros, y otros que pueden separar bienes del deudor para cobrarse sus créditos.

Por ello, los acreedores pueden ser:

a) privilegiados: son aquellos que tienen el privilegio -dado por la ley- de ser pagados antes que otros acreedores;

b) con derecho real de garantía (prenda o hipoteca): tienen afectada una cosa (mueble o inmueble) al cobro de su crédito; se vende la cosa y cobran.

c) quirografarios (o comunes): son los que carecen de toda preferencia, y por lo tanto, cobran después de que hayan cobrado los acreedores con privilegio o con derecho real de garantía. Si el patrimonio del deudor no alcanza, ellos cobran "a prorrata" de sus créditos.

2) Hay bienes a los cuales el principio no se aplica, porque ellos no están afectados al cumplimiento de ninguna deuda, sea porque lo dispone el Código o una ley especial.

En efecto, hay bienes excluidos de la garantía común y que no pueden ser embargados ni ejecutados por los acreedores, porque se los considera indispensables para la subsistencia del deudor o de su familia y es justo que no se prive a ningún hombre de lo que necesita imperiosamente para subsistir. Los vemos a continuación.

Bienes excluidos de la garantía común.-

Quedan excluidos de la garantía común (conf. art. 744):

a) las ropas y muebles de uso indispensable del deudor, de su cónyuge o conviviente, y de sus hijos;

b) los instrumentos necesarios para el ejercicio personal de la profesión, arte u oficio del deudor;

c) los sepulcros afectados a su destino, excepto que se reclame su precio de venta, construcción o reparación;

d) los bienes afectados a cualquier religión reconocida por el Estado;

e) los derechos de usufructo, uso y habitación, así como las servidumbres prediales, que sólo pueden ejecutarse en los términos de los artículos 2144, 2157 y 2178;

f) las indemnizaciones que corresponden al deudor por daño moral y por daño material derivado de lesiones a su integridad psicofísica;

g) la indemnización por alimentos que corresponde al cónyuge, al conviviente y a los hijos con derecho alimentario, en caso de homicidio;

h) los demás bienes declarados inembargables o excluidos por otras leyes (ejemplos: las jubilaciones, las pensiones, los sueldos y los salarios, en la proporción fijada por la ley, la indemnización que se deba al trabajador sea por accidente de trabajo, por despido u otras causas). También están excluidos los inmuebles inscriptos como bien de familia, ahora regulado en el Capítulo 3 ("Vivienda": arts. 244 a 256).

Medidas cautelares.-

Antes de que el acreedor cobre pueden producirse hechos que pongan en peligro su derecho a cobrarse de los bienes del deudor, como ser: que el deudor disminuya a propósito su patrimonio; que haga desaparecer bienes; etc. Para evitar estos peligros existen las medidas cautelares, reguladas principalmente por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Las principales medidas cautelares son:

1) Embargo preventivo: medida cautelar sobre uno o varios bienes del deudor, con el objeto de inmovilizarlos y asegurar la responsabilidad del embargado.

2) Secuestro: consiste en desapoderar de un bien al deudor y entregarlo en depósito a un tercero.

3) Intervención judicial: consiste en designar a una persona para que intervenga en la vida económica de una persona física o jurídica, con el fin -por ejemplo- de: controlar la administración (fiscalizador); reemplazar al administrador (administrador judicial); informar al juzgado (veedor); incautar ingresos (recaudador); etc.

4) Inhibición general de bienes: medida cautelar que impide al deudor vender o gravar sus inmuebles o bienes registrables. Se anota en el Registro de la Propiedad correspondiente. Es muy útil cuando el embargo resulta ineficaz, por ejemplo, porque no se conocen bienes del deudor.

5) Anotación de litis: consiste en anotar en un Registro determinado que con relación a un bien existe un litigio pendiente. Esta medida no impide gravar ni vender el bien, sólo avisa que sobre el bien hay litigio, de modo que los terceros no puedan luego desconocer los derechos del vencedor del pleito.

6) Prohibición de innovar: consiste en que el juez prohíba modificar una situación de hecho o de derecho existente en determinado momento. Su fin es que esa situación se mantenga (ej: el juez ordena que el inmueble se mantenga desocupado).

7) Prohibición de contratar: consiste en prohibir contratar sobre ciertos bienes. La prohibición puede originarse en la ley, en un contrato, o en la necesidad de asegurar la ejecución o los bienes objeto de un pleito.

Patrimonios especiales.-

La parte final del art. 242 se refiere a los **patrimonios especiales** o separados y establece que los mismos sólo tienen por garantía los bienes que los integran.

Ejemplo: en el contrato de fideicomiso los bienes fideicomitidos constituyen un patrimonio separado del patrimonio del fiduciario, del fiduciante, del beneficiario y del fideicomisario.

Bienes afectados directamente a un servicio público.-

Art. 243.- "Bienes afectados directamente a un servicio público.- Si se trata de los bienes de los particulares afectados directamente a la prestación de un servicio público, el poder de agresión de los acreedores no puede perjudicar la prestación del servicio."

Los servicios públicos cumplen una función necesaria o beneficiosa para toda la comunidad, razón por la cual se debe evitar que se afecten o paralicen. El Estado puede prestar el servicio público por sí mismo o delegar la prestación del servicio a particulares. Cuando el servicio público se presta con bienes de los particulares (particulares propiamente dichos o el Estado actuando como particular) los acreedores no pueden ejercer su poder de agresión (embargo, ejecución) si ello perjudica (ej: interrumpe o paraliza) la prestación del servicio.

VIVIENDA

Regulación normativa.-

El derecho de acceso a la vivienda es un derecho humano reconocido en diversos tratados internacionales. Esto justifica que en la legislación argentina se haya protegido al inmueble destinado a vivienda familiar, estableciéndose que no podía ser embargado ni ejecutado, y que la Constitución Nacional hiciera referencia a "la protección integral de la familia y a la defensa del bien de familia" en el art. 14 bis.

La protección estaba regulada mediante el régimen del "bien de familia" de la Ley 14.394. El nuevo Código Civil y Comercial sustituye el régimen del bien de familia de la ley 14.394 por un capítulo especial dedicado a la *Vivienda* (arts. 244 a 256).

Afectación a Vivienda (conf. art. 244).-

De acuerdo al art. 244, puede afectarse a este régimen un inmueble destinado a vivienda, ya sea por su totalidad o hasta una parte de su valor. Esta protección no excluye la concedida por otras disposiciones legales

También se puede afectar un inmueble rural que no exceda de la unidad económica, de acuerdo con lo que establezcan las reglamentaciones locales (conf. art. 256)

- **Inscripción:** la afectación debe inscribirse en el Registro de la Propiedad Inmueble según las formas previstas en las reglas locales, y la prioridad temporal se rige por las normas contenidas en la ley nacional del registro inmobiliario.

- **Afectación total o parcial:** la afectación puede ser por el total o hasta una parte del valor del inmueble. En la Ley 14.394 sólo se podía afectar por el total.

- **No se puede afectar más de un inmueble:** si alguien fuese propietario único de dos o más inmuebles afectados, debe optar por la subsistencia de uno solo de ellos dentro del plazo que fije la autoridad de aplicación, bajo apercibimiento de considerarse afectado el inmueble constituido en primer término.

Legitimados.-

¿Quien puede solicitar la afectación? Según el art. 245, los legitimados para solicitar la afectación son:

- a) El titular registral, y si el inmueble está en condominio (varios titulares) deben solicitarla todos los cotitulares conjuntamente.

- b) El testador, por un acto de ultima voluntad (testamento); en este caso, el juez debe ordenar la inscripción a pedido de cualquiera de los beneficiarios, o del Ministerio Público, o de oficio si hay beneficiarios incapaces o con capacidad restringida.

La afectación también puede ser decidida por el juez, a petición de parte, en la resolución que atribuye la vivienda en el juicio (de divorcio o en el que resuelve las cuestiones sobre la conclusión de la convivencia), si hay beneficiarios incapaces o con capacidad restringida.

Beneficiarios.-

¿A quienes beneficia este régimen de "afectación a vivienda"? Son beneficiarios de la afectación (conf. art. 246):

- a) el propietario constituyente, su cónyuge, su conviviente, sus ascendientes o descendientes;
- b) en defecto de ellos, sus parientes colaterales dentro del tercer grado que convivan con el constituyente.

Acá hay una modificación importante, dado que en la Ley 14.394 se exigía la existencia de "familia" para afectar el inmueble, ya que se protegía la vivienda familiar. Ahora se permite la constitución de la afectación a favor del titular del dominio aunque no tenga familia, por un lado porque lo protegido es la "vivienda" sea familiar o no, y por otro lado porque se toma en cuenta la realidad de que hay muchas personas que viven solas.

Habitación efectiva.-

Debe existir habitación efectiva del inmueble (conf. art. 247). Es requisito que, al menos, uno de los beneficiarios habite el inmueble. Puede ser el mismo propietario constituyente, ya que el Código lo admite como beneficiario. En todos los casos, para que los efectos subsistan, basta que uno de ellos permanezca en el inmueble.

Subrogación real.-

Se admite la subrogación real (conf. art. 248). La afectación se transmite a la vivienda adquirida en sustitución de la afectada y a los importes que la sustituyen en concepto de indemnización o precio.

La subrogación real implica el cambio de una cosa por otra; en este caso es el cambio del inmueble afectado a vivienda por otro inmueble adquirido que pasa a ocupar el lugar del inmueble afectado.

Efecto principal de la afectación.-

Para determinar si la afectación es oponible a los acreedores, debemos distinguir si la deuda es anterior o posterior a la afectación:

- Si la deuda es anterior a la afectación, ésta no se puede oponer a los acreedores, y éstos (a pesar de la afectación) podrán embargar y ejecutar la vivienda.
- Si la deuda es posterior a la afectación, la vivienda afectada no puede ser ejecutada, salvo en los casos de excepción mencionados en el art. 249. Dicho artículo establece que, aún cuando la deuda sea posterior a la afectación, la vivienda podrá ser ejecutada en los siguientes casos:
 - a) si la deuda es por expensas comunes y por impuestos, tasas o contribuciones que gravan directamente al inmueble;
 - b) si la deuda tiene garantía real sobre el inmueble (hipoteca);
 - c) si la deuda tiene origen en construcciones o mejoras en el inmueble; o

- d) si la deuda es por prestaciones alimentarias a cargo del titular a favor de sus hijos menores de edad, incapaces, o con capacidad restringida.

Los acreedores sin derecho a pedir la ejecución no pueden cobrar sus créditos sobre el inmueble afectado, ni tampoco sobre la indemnización o precio que la sustituyen, aunque sea obtenido en subasta judicial, sea ésta ordenada en una ejecución individual o colectiva. Si el inmueble se subasta y queda remanente, éste se entrega al propietario del inmueble.

Frutos producidos por el inmueble.-

Los frutos que produce el inmueble afectado son embargables y ejecutables si no son indispensables para satisfacer las necesidades de los beneficiarios.

Transmisión de la vivienda afectada.-

El inmueble afectado no puede ser objeto de legados o mejoras testamentarias, salvo que favorezca a los beneficiarios de la afectación.

Para vender o gravar el inmueble, el constituyente necesita la conformidad del cónyuge o del conviviente. Si éste se opone, falta, es incapaz o tiene capacidad restringida, la transmisión o gravamen requiere autorización judicial.

Régimen de impuestos y honorarios.-

La vivienda afectada tiene un régimen especial de impuestos y de honorarios profesionales (conf. arts. 252 y 254):

- **Impuestos:** la vivienda afectada está exenta del impuesto a la transmisión gratuita por causa de muerte en todo el territorio de la República, si ella opera a favor de los beneficiarios, y no es desafectada en los cinco años posteriores a la transmisión.
- **Honorarios:** a pedido de los interesados, si en los trámites de constitución intervienen profesionales, sus honorarios no pueden exceder en conjunto el 1% de la valuación fiscal.

En el juicio sucesorio del titular de la afectación y en los concursos preventivos y quiebras, los honorarios no pueden exceder del 3% de la valuación fiscal.

Desafectación y cancelación de la inscripción.-

La desafectación es el acto por el cual se deja sin efecto la afectación del inmueble y cesan sus efectos legales. Se lleva a cabo cancelando la inscripción en el Registro.

De acuerdo al art. 255, la desafectación y cancelación de la inscripción proceden:

- a) a solicitud del constituyente; si está casado o vive en unión convivencial inscripta se requiere el asentimiento del cónyuge o del conviviente; si éste se opone, falta, es incapaz o tiene capacidad restringida, la desafectación debe ser autorizada judicialmente;
- b) a solicitud de la mayoría de los herederos, si la constitución se dispuso por testamento, excepto que medie disconformidad del cónyuge supérstite, del con-

viente inscripto, o existan beneficiarios incapaces o con capacidad restringida, caso en el cual el juez debe resolver lo que sea más conveniente para el interés de éstos;

c) a requerimiento de la mayoría de los condóminos (si se trata de un bien en condominio) computada en proporción a sus respectivas partes indivisas, con los mismos límites expresados en el caso anterior;

d) a instancia de cualquier interesado o de oficio, si no subsisten los recaudos previstos para la afectación (ejs: nadie habita el inmueble), o fallecen el constituyente y todos los beneficiarios;

e) en caso de expropiación, reivindicación o venta judicial, con los límites indicados en el art. 249.

Deberes de la autoridad de aplicación.-

La autoridad administrativa debe prestar asesoramiento y colaboración gratuitos a los interesados, a fin de concretar los trámites relacionados con la constitución, inscripción y cancelación de esta afectación (conf. art. 253).

Diferencias fundamentales entre el régimen de la Ley 14.394 y el nuevo Código Civil y Comercial.-

En los *Fundamentos del Anteproyecto*, los redactores señalan como modificaciones importantes las siguientes:

a) se autoriza la constitución del bien de familia a favor del titular del dominio sin familia, atendiendo a la situación, cada vez más frecuente, de la persona que vive sola; se permite que el bien de familia sea constituido por todos los condóminos, aunque no sean parientes ni cónyuges.

b) La afectación también puede ser decidida por el juez, a petición de parte, en la resolución que atribuye la vivienda en el juicio de divorcio o en el que resuelve las cuestiones relativas a la conclusión de la convivencia, si hay beneficiarios incapaces o con capacidad restringida.

c) Se amplía la lista de los beneficiarios al conviviente.

d) Se prevé expresamente la subrogación real, reclamada por la doctrina y recogida en diversos pronunciamientos judiciales, que permite adquirir una nueva vivienda y mantener la afectación, así como extender la protección a la indemnización que provenga del seguro o de la expropiación.

e) Se resuelven problemas discutidos en la doctrina, cuales son: la situación de la quiebra, adoptándose el criterio según el cual el activo liquidado pertenece sólo a los acreedores anteriores a la afectación, y si hay remanente se entrega al propietario; la admisión de la retroprioridad registral, en tanto se remite a las normas de la ley registral que así lo autorizan; la inoponibilidad a los créditos por expensas en la propiedad horizontal y a los créditos alimentarios, etc.

BIENES

- CONCEPTOS**
- **Cosas muebles** → Las que pueden desplazarse por sí mismas o por una fuerza externa.
 - **Cosas inmuebles** → Se encuentran fijas en un lugar determinado y con carácter permanente.
 - **Cosas divisibles** → Las que pueden ser divididas en porciones reales sin ser destruidas, cada una de las cuales forma un todo homogéneo y análogo tanto a las otras partes como a la cosa misma.
 - **Cosas indivisibles** → Aquellas que, si son divididas, se destruyen o pierden su naturaleza.
 - **Cosas principales** → Las que pueden existir por sí mismas.
 - **Cosas accesorias** → Su existencia y naturaleza son determinadas por otra cosa de la cual dependen.
 - **Cosas consumibles** → Aquellas cuya existencia termina con el primer uso.
 - **Cosas no consumibles** → Aquellas que no dejan de existir por el primer uso que de ellas se hace.
 - **Cosas fungibles** → Aquellas en que todo individuo de la especie equivale a otro individuo de la misma especie, y pueden sustituirse por otras de la misma calidad y en igual cantidad.
 - **Cosas no fungibles** → No pueden sustituirse las unas por otras, por estar dotadas de características propias.
 - **Frutos** → Objetos que un bien produce, de modo renovable, sin que se altere o disminuya su sustancia.
 - **Productos** → Objetos no renovables que separados o sacados de la cosa alteran o disminuyen su sustancia.
 - **Bienes fuera del comercio** → Aquellos cuya transmisión está prohibida: a) por ley, o b) por un acto jurídico.

BIENES CON RELACIÓN A LAS PERSONAS

Bienes pertenecientes al dominio público	Los bienes públicos del Estado son inenajenables, inembargables e imprescriptibles. Las personas tienen su uso y goce, sujeto a las disposiciones generales y locales. • Enumeración → Art. 235 (ejs: mar territorial, aguas interiores, ríos, islas, espacio aéreo, calles, plazas, caminos, puentes, obras públicas, documentos del Estado, etc).
Bienes del dominio privado del Estado	Sobre los bienes privados, el Estado tiene un derecho de propiedad al igual que cualquier particular, pero la enajenación de esos bienes está regulada por el derecho administrativo. En general son prescriptibles, embargables y enajenables. • Enumeración → Art. 236 (ejs: los inmuebles y lagos no navegables que carecen de dueño, las minas de oro, cobre, etc., los bienes adquiridos por el Estado, etc.).
Bienes municipales	Los <i>bienes municipales</i> son aquellos que el Estado ha puesto bajo el dominio de las municipalidades (ej: plazas, calles). Las municipalidades son personas jurídicas de carácter público y tienen bienes de dominio público y bienes de dominio privado.
Bienes de los particulares	La regla general es que todos los bienes que no son del Estado pertenecen a los particulares (art. 238). También es válida a la inversa: si un bien no pertenece a ningún particular debe considerarse del dominio privado del Estado.
Aguas de los particulares	Pertenecen al dueño del terreno, el cual puede usar libremente de ellas, siempre que no formen cauce natural (art. 239). Quedan sujetas al control y a las restricciones que en interés público establezca la autoridad de aplicación.

BIENES CON RELACIÓN A LOS DERECHOS DE INCIDENCIA COLECTIVA

Límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes	Los derechos individuales no son absolutos y tienen limitaciones. Una de esas limitaciones es que <u>no pueden afectar derechos de incidencia colectiva</u> (aquellos que recaen sobre bienes comunes a todos los ciudadanos). Art. 240 → El ejercicio de los derechos individuales sobre estos bienes debe: a) ser compatible con los derechos de incidencia colectiva; / b) ser conforme a las normas del derecho administrativo dictadas en el interés público; / c) no afectar el medio ambiente.
Jurisdicción	Sin importar en qué jurisdicción se ejerzan los derechos, siempre deben respetarse las normas de <i>presupuestos mínimos de protección ambiental</i> (normas que conceden una tutela ambiental uniforme o común para el territorio nacional y tienen por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental).

FUNCIÓN DE GARANTÍA DE LOS BIENES

- Art. 242 → “*Garantía común*” → Consagra expresamente el tradicional principio de que *el patrimonio del deudor es la garantía común de los acreedores*. → Este principio significa que todos los bienes (presentes y futuros) del patrimonio del deudor responden por las deudas que él tenga. Si el deudor no cumple, los acreedores pueden ejecutar sus bienes y cobrarse del producido de éstos.
- Bienes excluidos de la garantía común → Enumerados en el Art. 744 (8 incisos).
- Medidas cautelares → { Antes de que el acreedor cobre pueden producirse hechos que pongan en peligro su derecho a cobrarse de los bienes del deudor. Para evitar estos peligros existen las medidas cautelares (por ej: embargo preventivo, secuestro, intervención judicial, inhibición general de bienes, etc).
- Patrimonios especiales → Sólo tienen por garantía los bienes que los integran (art. 242).
- Bienes afectados directamente a un servicio público → { Cuando el servicio público se presta con bienes de los particulares, los acreedores no pueden ejercer su poder de agresión (embargo, ejecución) si ello perjudica (ej: interrumpe o paraliza) la prestación del servicio.

VIVIENDA

- La CN protege el derecho a la vivienda (art. 14 bis).
- La protección estaba regulada mediante el régimen del “bien de familia” de la Ley 14.394. El nuevo Código Civil y Comercial sustituye el régimen del bien de familia de la Ley 14.394 por un capítulo especial dedicado a la *Vivienda* (arts. 244 a 256).

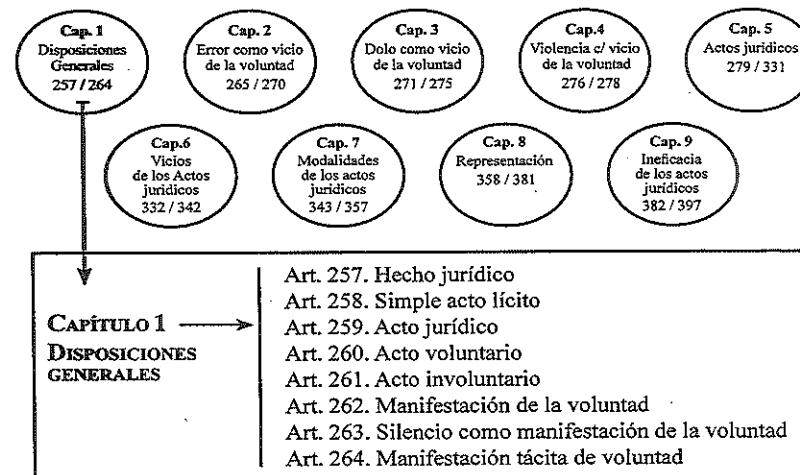
Afectación a Vivienda	Puede afectarse a este régimen un inmueble destinado a vivienda (total o parcialmente). Se inscribe en el Registro de la Propiedad Inmueble. • No se puede afectar más de un inmueble.
Legitimados	¿Quién puede solicitar la afectación? → a) El titular registral, (o todos los cotitulares conjuntamente, en su caso) / b) El testador, por un acto de última voluntad (testamento). • También, en ciertos casos, puede ser decidida por el juez, a petición de parte.
Beneficiarios	¿A quienes beneficia este régimen de “afectación a vivienda”? → a) Al propietario constituyente, su cónyuge, su conviviente, sus ascendientes o descendientes / b) En defecto de ellos, a sus parientes colaterales dentro del 3º grado que convivan con el constituyente.
Habitación efectiva	Es requisito que, al menos, uno de los beneficiarios habite el inmueble.
Subrogación real	Se admite (conf. art. 248). La afectación se transmite a la vivienda adquirida en sustitución de la afectada y a los importes que la sustituyen (por indemnización o precio).
Efecto principal de la afectación	• Si la deuda es anterior a la afectación, ésta <u>no se puede oponer a los acreedores</u> . • Si la deuda es posterior a la afectación, la vivienda afectada <u>no puede ser ejecutada</u> , salvo en los casos de excepción mencionados en el art. 249.
Frutos producidos por el inmueble	Son embargables y ejecutables si <u>no son indispensables</u> para los beneficiarios.
Transmisión de la vivienda afectada	El inmueble afectado no puede ser objeto de legados o mejoras testamentarias, salvo que favorezca a los beneficiarios de la afectación. Para vender o gravar el inmueble, el constituyente necesita la conformidad del cónyuge o del conviviente.
Impuestos y honorarios	Vivienda afectada → <u>régimen especial</u> de impuestos y honorarios (arts. 252 y 254).
Desafectación y cancelación de la inscripción	La desafectación es el acto por el cual se deja sin efecto la afectación del inmueble y cesan sus efectos legales. Se lleva a cabo cancelando la inscripción en el Registro. • Proceden: a) a solicitud del constituyente / b) a solicitud de la mayoría de los herederos / c) a requerimiento de la mayoría de los condóminos / d) a instancia de cualquier interesado o de oficio / e) en caso de expropiación, reivindicación o venta judicial.

CAPÍTULO XVI HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS

Regulación normativa.-

El Código Civil de Vélez trataba el tema de hechos y actos jurídicos en el Libro II “*De los derechos personales en las relaciones civiles*”. Como se trata de una teoría aplicable a todo el ordenamiento jurídico, acertadamente el nuevo Código Civil y Comercial lo trata en la Parte General (Libro I, Título IV “Hechos y Actos jurídicos”, arts. 257 a 397).

Libro I: Parte General, Título IV: Hechos y Actos jurídicos (Arts. 257 a 397)



“Hecho” y “Hecho jurídico”.-

• “**Hecho**”: esta expresión sirve para designar cualquier acontecimiento que ocurra en el mundo, sea producido por el hombre o no (por ej: un terremoto, una inundación, la muerte natural, etc.).

Algunos hechos no influyen para nada en el campo jurídico (ej: un estornudo, un trueno) y son simplemente “hechos”.

Otros, por el contrario, producen efectos o consecuencias jurídicas (ej: la muerte de una persona, celebrar un contrato, etc.) y se los llama “hechos jurídicos”. Estos

(los que producen efectos jurídicos) son los que importan al Derecho y a los que nos referiremos a continuación.

• Hecho jurídico (art. 257): el hecho jurídico es el acontecimiento que, conforme al ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas.

CLASIFICACIÓN DE LOS HECHOS JURÍDICOS

HECHOS NATURALES / HUMANOS.

INVOLUNTARIOS / VOLUNTARIOS. LÍCITOS / ILÍCITOS.-

1) Hechos Naturales: son aquéllos que se producen por causas extrañas al hombre. Estos hechos, ocurridos sin la intervención del hombre, pueden dar lugar a efectos jurídicos. Ejemplo: la muerte natural de una persona produce la apertura de su sucesión; un terremoto, puede destruir una casa y hacer nacer el derecho a cobrar un seguro; el nacimiento de una persona, hace surgir derechos sobre filiación, sucesión, patria potestad, etc.

2) Hechos Humanos: son aquéllos realizados por el hombre. Ejemplo: edificar, comprar, sembrar, cultivar, etc.

Los hechos humanos pueden ser voluntarios o involuntarios:

a) Involuntarios: cuando el hombre los realiza sin voluntad, es decir, sin discernimiento, sin intención o sin libertad (ej: me empujan y al caer causo daños). Los hechos involuntarios no producen, por sí, obligación alguna para su autor.

b) Voluntarios: cuando es ejecutado con discernimiento, intención y libertad que se manifiesta por un hecho exterior (conf. art. 200).

Los hechos humanos voluntarios pueden ser lícitos o ilícitos:

• Lícitos: son los hechos voluntarios no prohibidos por la ley (conf. art. 258). Respecto de esta clase de hechos, debemos diferenciar:

- Cuando el hecho voluntario lícito tiene como fin inmediato producir efectos jurídicos (o sea, la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas), se denomina "acto jurídico" (ej: contratos, testamentos, etc.).

- Cuando no tenga ese fin inmediato de producir efectos jurídicos, pero pueda producirlos se denominará "simple acto lícito".

Art. 259.- "Acto jurídico. El acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas."

Art. 258.- "Simple acto lícito. El simple acto lícito es la acción voluntaria no prohibida por la ley, de la que resulta alguna adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas."

• Ilícitos: son aquellos cuya realización, positiva o negativa, está prohibida por la ley o por disposiciones municipales o policiales, y a raíz de los cuales se produce un daño. Estos actos ilícitos se pueden producir a raíz de que su autor ha actuado con imprudencia o negligencia (culpa) o con intención de dañar (dolo).

Diferencias entre "hecho jurídico" y "acto jurídico".-

• El *hecho jurídico* produce efectos jurídicos; puede ser ejecutado por el hombre o no; si fuese ejecutado por el hombre, puede ser voluntario o no; y si fuese voluntario, puede ser lícito o ilícito.

• El *acto jurídico* es siempre un hecho humano, voluntario y lícito, y su característica principal es que tiene por fin inmediato producir efectos jurídicos; o sea, la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas (conf. art. 259). Todo "acto jurídico" queda comprendido dentro del género de "hechos jurídicos".

Diferencias entre un "acto jurídico" y un "simple acto lícito".-

Ambos son hechos jurídicos, humanos, voluntarios y lícitos; y además ambos producen efectos jurídicos. La diferencia está dada en que:

• los *actos jurídicos* (ej: comprar, donar, testar; etc.) tienen como fin inmediato producir efectos jurídicos.

• los *simples actos lícitos* (ej: sembrar, construir, etc.), si bien pueden producir efectos jurídicos, no tienen como fin inmediato producirlos.

Ejemplos: el sembrar un campo, si bien es simplemente un hecho lícito, puede dar lugar a consecuencias jurídicas, como ser: si el campo cultivado hubiese sido ajeno, se le podrá exigir a su propietario la restitución de los gastos de cultivo; levantar una pared medianera también es un hecho que (aunque el autor no haya querido) produce efectos jurídicos ya que la ley permite reclamar la mitad de lo gastado en construirla.

HECHOS JURÍDICOS

Regulación normativa

El nuevo CCCN trata el tema de hechos y actos jurídicos en la Parte General (Libro I, Título IV "Hechos y Actos jurídicos", arts. 257 a 397).

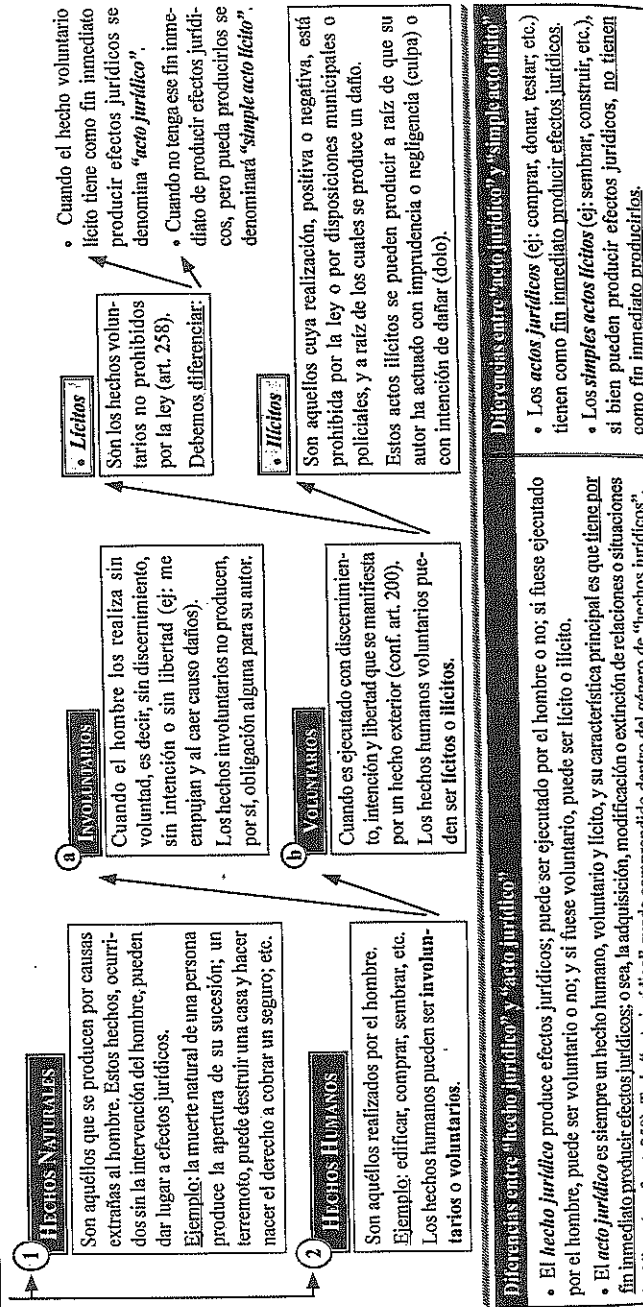
"Hecho"

Esta expresión sirve para designar cualquier acontecimiento que ocurra en el mundo, sea producido por el hombre o no. Algunos hechos no influyen en el campo jurídico y son simplemente "hechos". Otros producen consecuencias jurídicas (ej: la muerte de una persona, celebrar un contrato, etc.) y se los llama "hechos jurídicos".

• Hecho jurídico (art. 257)

El hecho jurídico es el acontecimiento que, conforme al ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas.

CLASIFICACIÓN DE LOS HECHOS JURÍDICOS



Diferencias entre "hecho jurídico" y "acto jurídico"

- El **hecho jurídico** produce efectos jurídicos; puede ser ejecutado por el hombre o no; si fuese ejecutado por el hombre, puede ser voluntario o no; y si fuese voluntario, puede ser lícito o ilícito.
- El **acto jurídico** es siempre un hecho humano, voluntario y lícito, y su característica principal es que tiene por fin inmediato producir efectos jurídicos, o sea, la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas (conf. art. 259). Todo "acto jurídico" queda comprendido dentro del género de "hechos jurídicos".

CAPÍTULO XVII TEORÍA GENERAL DE LOS ACTOS VOLUNTARIOS

Concepto.-

El art. 260 del Código Civil y Comercial nos da la definición de acto voluntario:

Art. 260.- "Acto voluntario. El acto voluntario es el ejecutado con discernimiento, intención y libertad, que se manifiesta por un hecho exterior."

Para que un acto sea considerado voluntario debe reunir condiciones internas (discernimiento, intención y libertad) y condiciones externas (forma de manifestar la voluntad).

CONDICIONES INTERNAS.-

Las condiciones internas son que el acto sea ejecutado con discernimiento, intención y libertad (conf. art. 260):

- **Discernimiento.-** Es la facultad que permite a la persona, apreciar y saber lo que está haciendo, de modo tal que le sea posible comprender el significado y alcance de sus actos. Las causas que afectan el discernimiento de una persona son: la edad y estar privado de la razón.

Art. 261.- "Acto involuntario. Es involuntario por falta de discernimiento:

- a) el acto de quien, al momento de realizarlo, está privado de la razón;
- b) el acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido diez años;
- c) el acto lícito de la persona menor de edad que no ha cumplido trece años, sin perjuicio de lo establecido en disposiciones especiales."

- **Intención.-** Consiste en el propósito de realizar el acto. Afectan la intención el error, la ignorancia y el dolo:

- a) **error:** consiste en tener una falsa noción sobre un determinado punto. La persona cree que sabe algo pero, en realidad, sabe equivocado.
- b) **ignorancia:** es la ausencia completa de conocimiento. La persona no está errada o equivocada sino que, directamente, no sabe, ignora todo lo relacionado con un determinado punto.
- c) **dolo:** existe dolo cuando una persona, por medio de cualquier astucia, artificio o maquinación, induce a otra persona a la realización o ejecución de algún acto (ej: hay dolo si yo, para poder vender mi casa, oculto al comprador que los cimientos están en mal estado, y aparte le digo que, bajo el suelo de la propiedad, hay oro).

• **Libertad.**- Consiste en la posibilidad del individuo, de decidir o elegir por sí mismo la realización de sus actos. La libertad se ve afectada por la fuerza (violencia física) y la intimidación (violencia moral).

CONDICIONES EXTERNAS.-

Para que un acto sea considerado voluntario es necesario que la voluntad sea manifestada por hechos exteriores que demuestren su existencia. Los actos pueden exteriorizarse: oralmente; por escrito; por signos inequívocos; o por la ejecución de un hecho material (conf. art. 262).

- **Oralmente:** cuando se expresa hablando.
- **Por escrito:** por ej, se expresa en un documento público o documento privado.
- **Por signos inequívocos:** por ej, decir que sí o que no con la cabeza.
- **Por la ejecución de un hecho material:** por ej, el que va a un "auto-servicio", toma las mercaderías y luego abona en la caja, está manifestando su voluntad de comprar.

Silencio como manifestación de la voluntad.-

Art. 263.- "Silencio como manifestación de la voluntad. El silencio opuesto a actos o a una interrogación no es considerado como una manifestación de voluntad conforme al acto o la interrogación, excepto en los casos en que haya un deber de expedirse que puede resultar de la ley, de la voluntad de las partes, de los usos y prácticas, o de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes."

El silencio no puede ser considerado como manifestación tácita de voluntad, salvo que se trate de alguno de los casos en que haya un deber de expedirse, el cual puede resultar:

- a) de la ley (ej: una persona es llamada por el Juez a reconocer su firma puesta en un documento privado; su silencio equivale al reconocimiento tácito de la firma);
- b) de la voluntad de las partes (ej: el marido tiene un año desde la inscripción de un nacimiento para impugnar la paternidad del hijo; si en ese lapso guardó silencio la ley presume que es hijo suyo y la acción caduca, conf. art. 259);
- c) de los usos y prácticas; o
- d) de la obligación de explicarse a raíz de que el silencio actual está relacionado con declaraciones precedentes. Ejemplo: en un caso de prestaciones periódicas, un comerciante, cada dos meses, recibe envíos de arroz a \$10 la bolsa; posteriormente, el vendedor le notifica que la bolsa subió a \$12, y que en caso de que no quieran seguir recibiendo arroz, que se lo haga saber. Si ante el envío, el comerciante lo recibe y guarda silencio, dicha actitud se interpreta como una manifestación tácita de aceptación, pues si no hubiese querido aceptar, debió hacerlo saber el vendedor.

Manifestación tácita de voluntad.-

Art. 264.- "Manifestación tácita de voluntad. La manifestación tácita de la voluntad resulta de los actos por los cuales se la puede conocer con certidumbre. Carece de eficacia cuando la ley o la convención exigen una manifestación expresa."

La manifestación de la voluntad es expresa cuando se manifiesta oralmente, o por escrito, o por otros signos inequívocos.

Por el contrario, es tácita cuando resulta de actos por los cuales se puede conocer con certidumbre la existencia de la voluntad. Ejemplo: el que sube al colectivo y sin emitir palabra paga su boleto, manifiesta su voluntad de celebrar contrato de transporte, etc.

La manifestación tácita carece de eficacia cuando la ley o la convención exigen una manifestación expresa.

VICIOS DE LA VOLUNTAD

Un acto jurídico, para ser válido, debe ser producto de la libre voluntad de las partes. Cuando está afectada la voluntad, el acto pierde eficacia y no produce los efectos que le son propios. El error, el dolo y la violencia vician la voluntad, y con más precisión a la intención.

EL ERROR COMO VICIO DE LA VOLUNTAD

Concepto.-

El error consiste en que la persona cree que sabe algo, pero en realidad sabe equivocada; o sea que: el error consiste en tener falsas nociones sobre un punto determinado.

El error de hecho causa la nulidad (si es esencial y reconocible por el destinatario).

Diferencia con la "ignorancia".-

Conceptualmente, el error se puede diferenciar de la ignorancia.

En la ignorancia, la persona no está equivocada ni errada, sino que, directamente no sabe, ignora todo lo relacionado con un determinado punto, es decir, sufre una ausencia completa de conocimiento.

A pesar de estas diferencias conceptuales, jurídicamente error e ignorancia son equivalentes.

Clases de Error.-

El error puede ser de derecho o de hecho:

1) **Error de Derecho.**- Es el que recae sobre la legislación aplicable al acto que se realiza. El error de derecho no sirve como excusa y en ningún caso impedirá los efectos legales de los actos lícitos, ni excusará la responsabilidad por los actos ilícitos (conf. art. 8).

Ejemplo: acepto una herencia sin beneficio de inventario, y luego pretendo rechazarla, alegando que no sabía que el heredero también debía pagar las deudas del causante; o secuestro a una persona, y luego pretendo excusarme diciendo que ignoraba que era delito.

Este principio de que *“el error de derecho no excusa”*, se fundamenta en que las leyes son obligatorias y se presumen conocidas por todos (lo cual no admite prueba en contrario). Si alguien actúa ignorándolas o errando con respecto a ellas, es responsable de sus hechos y no puede excusarse basándose en el error de derecho.

Este principio brinda seguridad jurídica, pues en caso contrario cualquier persona podría violar la ley, y luego evitar su responsabilidad civil o penal, con solo alegar que cometió el hecho porque ignoraba que la ley le asignaba determinados efectos, o lo reprimía.

2) Error de Hecho.- Es el que recae sobre circunstancias de hecho del acto, como ser: sobre la persona de la otra parte del acto, sobre la naturaleza del acto, sobre un objeto, etc.

Art. 265.- “Error de hecho. El error de hecho esencial vicia la voluntad y causa la nulidad del acto. Si el acto es bilateral o unilateral recepticio, el error debe, además, ser reconocible por el destinatario para causar la nulidad.”

El error de hecho causa la nulidad del acto si es esencial, y además si es reconocible por el destinatario (cuando el acto es bilateral o unilateral recepticio).

El error de hecho puede ser: *accidental o esencial*.

a) Error accidental: recae sobre elementos o cualidades accidentales, secundarios, que carecen de importancia, y que las partes no han tenido en mira al realizar el acto. No causa la nulidad del acto.

Ejemplos de error accidental:

- compro un caballo pensando que tiene gran resistencia, y resulta que su resistencia es mínima; errores sobre el valor de la cosa: compro una cosa como barata, cuando en verdad es cara; errores sobre la persona, cuando su identidad o cualidades carecen de importancia: contrato un obrero especializado en albañilería, creyendo que es Juan Pérez, pero luego resulta ser Juan García, de la misma profesión y especialización.
- los errores materiales o de cálculo en el documento, fácilmente rectificables (ej: si se venden 3 autos, cada uno de ellos en \$ 3.000, y se pone como total, \$ 9.500 en vez de \$ 9.000).

b) Error esencial: según el art. 267, el error de hecho es esencial cuando recae sobre:

- la naturaleza del acto;
- un bien o un hecho diverso o de distinta especie que el que se pretendió designar, o una calidad, extensión o suma diversa a la querida;

- la cualidad sustancial del bien que haya sido determinante de la voluntad jurídica según la apreciación común o las circunstancias del caso;
- los motivos personales relevantes que hayan sido incorporados expresa o tácitamente;
- la persona con la cual se celebró o a la cual se refiere el acto si ella fue determinante para su celebración.

Síntesis y ejemplos.-

Son esenciales los errores:

- sobre la naturaleza del acto. Ej: un amigo me da plata en préstamo y yo creo que se trata de una donación.
- sobre el objeto del acto (sobre un bien o un hecho diferente al que se pretendió designar, o una calidad, extensión o suma diversa a la querida). Ej: Juan me ofrece en locación su casa de Mendoza, y yo acepto creyendo que alquilo su casa de Bs. As.
- sobre la cualidad principal o sustancial de la cosa, y que se ha tenido en mira. Ej: me venden porcelana nacional, y yo creo que es de la mejor porcelana china; me venden una copia y yo creo comprar un cuadro de Picasso.
- sobre la causa (motivos) principal del acto (sobre los motivos personales relevantes que hayan sido incorporados al acto). Ej: si alquilo un negocio para poner un bar, y el dueño cree que es para poner una farmacia.
- sobre la persona (con la cual se celebra o a la cual se refiere el acto). Ej: si contrato con un músico desconocido y creo estar contratando a Serrat; creo hacer un préstamo a mi primo Luis y se lo hago a su vecino Pedro.

Para que el error de lugar a la nulidad, debe ser esencial y además, debe ser reconocible por el destinatario. Al respecto, el art. 266 establece que: *“El error es reconocible cuando el destinatario de la declaración lo pudo conocer según la naturaleza del acto, las circunstancias de persona, tiempo y lugar.”*

Este requisito reemplaza al requisito del Código de Vélez, respecto de que el error fuera “excusable”.

Error de cálculo.-

Art. 268.- “Error de cálculo. El error de cálculo no da lugar a la nulidad del acto, sino solamente a su rectificación, excepto que sea determinante del consentimiento.”

No es un error esencial, sino accidental y fácilmente rectificable (ej: si se venden 3 autos, cada uno de ellos en \$ 3.000, y se pone como total, \$ 9.500 en vez de \$ 9.000).

Subsistencia del acto.-

Art. 269.- “Subsistencia del acto. La parte que incurre en error no puede solicitar la nulidad del acto, si la otra ofrece ejecutarlo con las modalidades y el contenido que aquélla entendió celebrar.”

Es una solución justa, porque si la contraparte ofrece celebrar el acto tal cual la otra entendió celebrarlo (en los ejemplos anteriores, llevarle a Serrat o darle en locación la casa de Bs. As.), no hay motivos para mantener la nulidad.

Error en la declaración y en la transmisión.-

Art. 270.- "Error en la declaración. Las disposiciones de los artículos de este Capítulo son aplicables al error en la declaración de voluntad y en su transmisión."

Son casos que entre la voluntad y la declaración externa de la misma hay discordancias, sea por apresuramiento, distracción o mala interpretación, etc. Se suele dar el ejemplo clásico de quien, al entrar a un salón de remate, levanta la mano saludando a un amigo y el rematador entiende que hizo una oferta.

EL DOLO COMO VICIO DE LA VOLUNTAD

Concepto.-

"Dolo", genéricamente, es toda aserción (afirmación) de lo que es falso o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplea con ese fin.

La conducta dolosa puede llevarse a cabo por acción u omisión.

Acción dolosa y Omisión dolosa.-

- La acción dolosa puede consistir en maquinaciones, artificios, astucias, trampas, mentiras, ocultaciones, etc.; pero en forma genérica, siempre hay "engaño".
- La omisión dolosa (causa los mismos efectos que la acción dolosa) consiste en obrar con reticencia u ocultación acerca del engaño, es decir callando la verdad u ocultándola, dejando con toda malicia que la otra parte siga engañada acerca de elementos esenciales del acto.

Art. 271.- "Acción y omisión dolosa. Acción dolosa es toda aserción de lo falso o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee para la celebración del acto. La omisión dolosa causa los mismos efectos que la acción dolosa, cuando el acto no se habría realizado sin la reticencia u ocultación."

Especies de dolo.-

El dolo puede ser esencial o incidental.

1) **Dolo esencial:** es el que induce y determina que la víctima realice el acto. Este tipo de dolo hace invalido el acto; de manera que la víctima podrá demandar la nulidad del acto y la indemnización por daños y perjuicios. Los requisitos del dolo esencial están enumerados en el art. 272.

2) **Dolo incidental:** a diferencia del anterior, éste no ha sido causa determinante para la realización del acto. El dolo incidental no permite a la víctima demandar la nulidad del acto, pero le permite reclamar la indemnización por daños y perjuicios (conf. art. 273).

Requisitos del dolo para invalidar el acto.-

Los requisitos del dolo para invalidar el acto surgen del art. 272:

1) Debe ser GRAVE. Reúne este carácter cuando las trampas, astucias, etc, empleadas, sean de tal magnitud que hubiesen podido engañar a cualquier persona normal, sagaz y prudente.

2) Ser CAUSA DETERMINANTE DE LA ACCION. El dolo es causa determinante cuando, de no mediar el engaño, el acto no se hubiese realizado. Es el que se denomina "dolo esencial".

3) Debe haber ocasionado un DAÑO IMPORTANTE. El daño debe ser más o menos grande; si fuera de poca magnitud, o simplemente no hubiera daño, NO habrá nulidad del acto.

4) NO debe haber DOLO RECÍPROCO. Si hubiera dolo de ambas partes, la ley no protege a ninguna de las dos, y por tanto no se hará lugar a la nulidad.

Efectos del dolo esencial.-

El dolo (si reúne los requisitos del art. 272) produce dos consecuencias:

- 1) Causa la nulidad del acto.
- 2) Da derecho a reclamar la indemnización por daños y perjuicios.

Efectos del dolo incidental.-

En este caso, el dolo no afecta la validez del acto y la víctima no podrá pedir la nulidad del mismo, pero podrá reclamar la reparación de los daños y perjuicios sufridos por el dolo (art. 275).

Efectos del dolo recíproco.-

Si ambas partes actuaron dolosamente (ej: Juan y Luis permutan una vaca por un caballo. Juan omite dolosamente decir que la vaca tenía peste, y Luis, que el caballo era ciego) la ley no ampara a ninguno de los dos, y ninguno podrá demandar la nulidad de la permuta.

Dolo de un tercero.-

El dolo puede provenir de la parte o de un tercero.

• El dolo esencial, provenga de la parte del acto o provenga de un tercero, da lugar a la nulidad del acto, y la víctima podrá pedir la reparación de los daños y perjuicios (conf. art. 275).

Si la otra parte y el tercero fueron cómplices, ellos serán responsables solidariamente de la indemnización por daños y perjuicios (conf. art. 275).

• Si el dolo sólo fuese incidental, la solución será la misma; sólo que no se podrá demandar la nulidad del acto.

Prueba del dolo.-

La regla es que quien invoca un hecho, debe probarlo; y como el dolo no se presume, quien quiera anular un acto por haber sufrido dolo, deberá probar que hubo dolo y también que el mismo reúne los requisitos del art. 272 (que es grave, determinante, que causa daño importante y que no es recíproco).

En cuanto a la forma de la prueba, como se trata de un hecho, se admite todo tipo de pruebas, incluso las de testigos y presunciones.

LA VIOLENCIA COMO VICIO DE LA VOLUNTAD**Conceptos.-**

La violencia física (fuerza) o la violencia moral ("amenazas o intimidación") implican coerción sobre una persona para obligarla a ejecutar un acto que no quería realizar. Va de suyo entonces que la violencia puede presentarse bajo dos aspectos distintos:

- la violencia física (denominada "fuerza"); y
- la violencia moral (denominada "amenazas o intimidación").

Art. 276.- "Fuerza e intimidación. La fuerza irresistible y las amenazas que generan el temor de sufrir un mal grave e inminente que no se puedan contrarrestar o evitar en la persona o bienes de la parte o de un tercero, causan la nulidad del acto. La relevancia de las amenazas debe ser juzgada teniendo en cuenta la situación del amenazado y las demás circunstancias del caso."

La víctima puede ser obligada a realizar el acto que no quiere realizar, mediante golpes, malos tratos, privación de la libertad, etc. (violencia física o fuerza), o mediante amenazas e intimidaciones (violencia moral).

El autor de la fuerza irresistible y de las amenazas puede ser una de las partes del acto o un tercero (conf. art. 277).

El uso de la fuerza o las amenazas con determinadas características causa la nulidad del acto.

Requisitos para que el uso de fuerza invalide el acto.-

Debe tratarse de una *fuerza física irresistible* (conf. art. 276), es decir, una fuerza de tal gravedad, de tal magnitud, que la persona que la sufre no haya podido impedirla o resistirla.

Si la fuerza fue irresistible o no, lo determinará el juez, tomando en cuenta las condiciones físicas y espirituales de la víctima.

Requisitos para que el uso de intimidación invalide el acto.-

El art. 276 dice que: las amenazas deben generar el temor de sufrir *un mal grave e inminente que no se puedan contrarrestar o evitar*, en la persona o los bienes

de la parte (ej: libertad, honra, bienes, etc.) o de un tercero (ej: de su cónyuge, descendientes o ascendientes, etc.).

Por lo tanto, para que la intimidación vicie la voluntad, el mal amenazado debe ser inminente y grave:

- Inminente: significa que el mal debe ser próximo, inmediato, que no de tiempo a la víctima a poder reclamar la protección de las autoridades.

- Grave: significa que el mal debe ser susceptible de causar daños de magnitud.

Si el mal no es inminente y grave no se hace lugar a la nulidad.

El mal amenazado puede recaer sobre la persona de la víctima o de sus familiares (ej: amenaza de muerte, de secuestro, etc.), sobre la honra (ej: amenaza de revelar secretos familiares), sobre los bienes (ej: amenaza de incendiarle la casa, el auto, etc.).

En el Código de Vélez también se requería que la amenaza fuera *injusta*, es decir, que se amenazara "sin tener derecho a hacerlo". Hay amenaza injusta si digo: véndame su casa o mato ya mismo a sus hijos. Hay amenaza justa si un abogado amenaza a la parte contraria con el embargo si no paga sus deudas. En los casos de amenazas justas no había vicio de la voluntad. También se requería que hubiera "*temor fundado*", o sea, que el temor de la víctima de sufrir el mal amenazado, debía tener fundamento, ser real, y no imaginario o aparente.

Estos requerimientos no existen en el nuevo Código Civil y Comercial, pero el art. 276 in fine sí establece que "*...La relevancia de las amenazas debe ser juzgada teniendo en cuenta la situación del amenazado y las demás circunstancias del caso*".

Efectos de la violencia.-

La víctima podrá:

- 1) Demandar la nulidad del acto; y
- 2) Reclamar los daños y perjuicios al autor de la violencia.

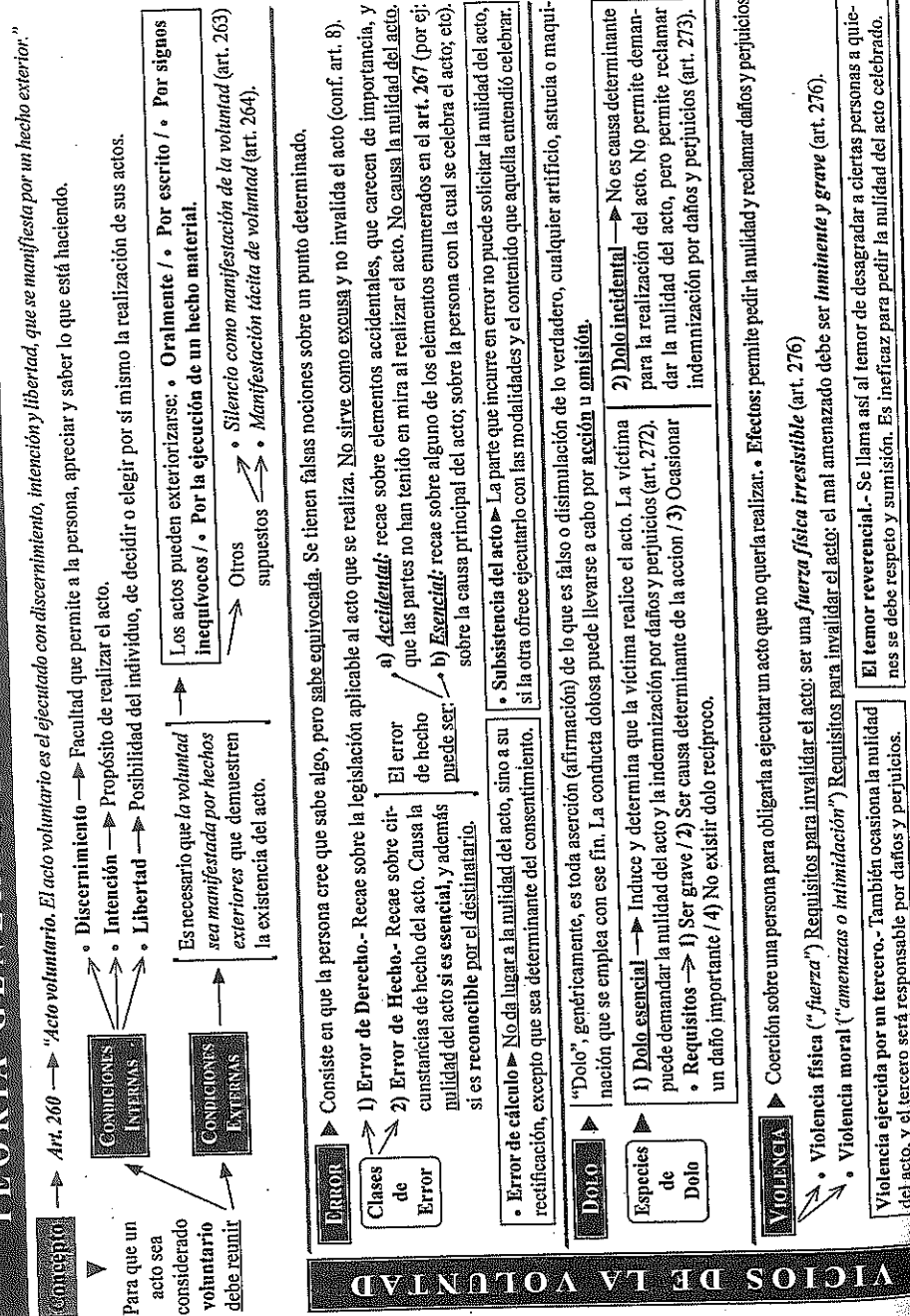
Violencia ejercida por un tercero.-

Si el que ejerce la violencia (sea fuerza o intimidación) fuese un tercero, también habrá nulidad del acto, y el tercero será responsable por daños y perjuicios. Si el tercero y la otra parte fuesen cómplices, ambos serán responsables solidariamente por la indemnización (conf. art. 278).

El temor reverencial.-

Se llama así al temor de desagradar a ciertas personas a quienes se debe respeto y sumisión (ej: el obrero con relación al dueño de una empresa). Este tipo de temor es ineficaz para pedir la nulidad del acto celebrado.

TEORÍA GENERAL DE LOS ACTOS VOLUNTARIOS

CAPÍTULO XVIII
ACTO JURÍDICO

Concepto.-

El concepto de "acto jurídico" lo encontramos en el art. 259 del nuevo Código Civil y Comercial:

Art. 259.- "Acto jurídico. El acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas."

La característica principal del acto jurídico es que tiene como **fin inmediato** la **producción de efectos jurídicos** (sea la adquisición, la modificación o la extinción de relaciones o situaciones jurídicas). Ejemplos: un contrato, un testamento, etc.

Cuando el acto voluntario lícito no tenga ese fin inmediato de producir efectos jurídicos, **pero los produzca** se denominará "**simple acto lícito**" (conf. art. 258). Ejemplos: sembrar o alambrar un campo, produce efectos jurídicos (son actos posesorios sobre el terreno) aunque su autor no haya tenido la intención de producirlos.

ELEMENTOS ESENCIALES

Los "**elementos esenciales**" son aquellos elementos indispensables para que el acto jurídico exista:

- A) Los **sujetos** del acto;
- B) El **objeto** del acto;
- C) La **causa** del acto (en doctrina, hubo profundas divergencias con respecto a considerarla o no como elemento esencial de los actos jurídicos).
- D) La **forma** del acto;

A) SUJETOS

Los **sujetos** son las personas "otorgantes" del acto, o sea, aquellas de las cuales emana el acto. El sujeto debe ser capaz de ejercicio y además debe tener capacidad específica para realizar ese acto (capacidad de derecho).

Ejemplo: para una compraventa, se requiere que la persona sea mayor de edad, y además, que la ley, por motivo especial, no le haya prohibido celebrar esa compraventa.

B) OBJETO

El **objeto** es el hecho o el bien (cosa material o inmaterial) sobre la cual recae el acto jurídico.

En el Código de Vélez el objeto del acto jurídico se regulaba en el art. 953, estableciéndose qué hechos o cosas no podían ser objeto del acto jurídico.

Dado que el nuevo Código Civil no introduce grandes modificaciones al respecto y que art. 953 del viejo Código es fuente del art. 279 del nuevo Código, transcribimos el art. 953 del Código de Vélez y luego art. 279 del Nuevo Código.

Art. 953 (Código Civil de Vélez Sarsfield).- "El objeto de los actos jurídicos deben ser cosas que estén en el comercio, o que por un motivo especial no se hubiese prohibido que sean objeto de algún acto jurídico, o hechos que no sean imposibles, ilícitos, contrarios a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes, o que se opongan a la libertad de las acciones o de la conciencia, o que perjudiquen los derechos de un tercero. Los actos jurídicos que no sean conformes a esta disposición, son nulos como si no tuviesen objeto".

Art. 279 (nuevo Código Civil y Comercial).- "Objeto. El objeto del acto jurídico no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley, contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público o lesivo de los derechos ajenos o de la dignidad humana. Tampoco puede ser un bien que por un motivo especial se haya prohibido que lo sea."

Análisis del art. 279.-

La primera parte del art. 279 (del nuevo Código Civil y Comercial) enumera los requisitos que debe reunir aquel hecho que sea objeto del acto jurídico.

Al respecto establece que el hecho no debe ser:

a) **Imposible.** La imposibilidad puede ser material o jurídica. (Ejemplo de hecho imposible materialmente: pintar un cuadro con el corazón; tocar el cielo con las manos. Ejemplo de hecho imposible jurídicamente: prender un inmueble.).

b) **Prohibido por la ley.** Ejemplo: constituir una sociedad para ejercer el contrabando.

c) **Contrario a la moral, a las buenas costumbres o al orden público.** (Ejemplo: sería el caso de ofrecer dinero a una persona para que golpee a los padres).

El concepto de lo que es moral o son buenas costumbres puede variar en el tiempo, por tanto corresponde interpretarlo como la "*moral media*" de la sociedad en un momento determinado. Cuando se habla de orden público se hace referencia a normas o principios indispensables para mantener el orden jurídico-social y que hacen al interés o bienestar general, tal el caso de la protección integral de las mujeres, el régimen de familia, de la patria potestad, etc.

d) **Lesivo de los derechos ajenos.** Ejemplo: actos fraudulentos que perjudiquen a terceros, tal el caso de vender todos los bienes en fraude de los acreedores.

e) **Lesivo de la dignidad humana.** Ejemplo: acto que obliga a una persona a someterse a prácticas vergonzosas lesivas de su dignidad humana; acto que obliga a alguien a profesar o no determinada religión.

La segunda parte del art. 279 establece las características que debe reunir aquel bien (cosa material o imaterial) que sea objeto del acto jurídico.

Al respecto dispone que no debe ser un bien que por un motivo especial se haya prohibido que sea objeto de un acto jurídico. Ejemplo: un mueble no puede ser objeto de hipoteca; un inmueble no puede ser objeto de prenda.

El nuevo Código Civil y Comercial no lo dice expresamente, pero la sanción por falta de requisitos debe acarrear la nulidad.

Objeto de los contratos.-

Cabe tener en cuenta que el tema del objeto no solo es tratado acá (arts. 279 y 280) sino que vuelve a ser tratado en "*objeto de los contratos*" (arts. 1003 a 1011), siendo evidente que por un lado hay superposiciones y por otro más requisitos para el objeto. Así, el art. 1003 establece que el objeto de los contratos debe ser lícito, posible, determinado o determinable, susceptible de valoración económica y corresponder a un interés de las partes aunque éste no sea patrimonial.

El objeto es "*determinado*" cuando al celebrar el acto se conoce con exactitud cual es el objeto. El objeto es "*determinable*" cuando se puede determinar al momento de cumplir.

El art. 1004, en general, reitera los requisitos del art. 279; pero además admite que el cuerpo humano o las piezas separadas de él (órganos, células, lípidos, etc.), puedan ser objeto de los contratos si hay un fin afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social (conf. arts. 17 y 56).

Convalidación.-

Art. 280.- "Convalidación. El acto jurídico sujeto a plazo o condición suspensiva es válido, aunque el objeto haya sido inicialmente imposible, si deviene posible antes del vencimiento del plazo o del cumplimiento de la condición."

El plazo y la condición son modalidades de los actos jurídicos que postergan su eficacia y efectos hasta que venza el plazo o se cumpla la condición.

Si un acto sujeto a plazo o condición suspensiva tiene un objeto imposible no es válido (art. 279), pero será válido si el objeto que inicialmente era imposible se vuelve posible antes de vencer el plazo o de cumplirse la condición.

C) CAUSA

El art. 281 nos da el concepto de *causa* de los actos jurídicos.

Art. 281.- "Causa. La causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad."

También integran la causa los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa, o tácitamente si son esenciales para ambas partes."

La palabra "*causa*", puede entenderse bajo dos acepciones diferentes:

a) **Causa-fuente:** es el origen o fuente del acto.

b) **Causa-fin:** es el propósito o finalidad perseguida por las partes al llevar a cabo el acto.

Vélez Sarsfield legisla sobre la causa al tratar las obligaciones (arts. 499 a 501), pero no quedó claro a qué causa se refería y tampoco si la causa final era o no un elemento de los actos jurídicos.

El "problema" de la causa.-

Lo que se denominó "el problema de la causa" giró alrededor de la "causa-fin", dando lugar a profundos debates doctrinarios respecto a si ella era o no un elemento esencial de los actos jurídicos:

- Los que niegan que la causa final sea un elemento de los actos jurídicos, consideran que ella se confunde con el objeto del acto o con el consentimiento. Para este sector los elementos del acto jurídico son sólo: sujeto, objeto y forma.
- Los que aceptan que la causa-fin es un elemento de los actos jurídicos, distinguen fundamentalmente el "objeto" de la "causa" (objeto: materia sobre la cual versa el acto o sea, los hechos o cosas; causa: finalidad tenida en mira por las partes al ejecutar el acto). El objeto responde a ¿qué se debe?, en tanto que la causa fin responde a: ¿por qué debo?. También distinguen entre:

"Causa fin inmediata".- Es la finalidad abstracta que han tendido las partes al contratar y que en los contratos iguales es siempre la misma. Ej: en las compraventas, para el vendedor es recibir el precio y para el comprador es recibir la cosa en propiedad. Esta causa fin inmediata es la que interesa al derecho y es elemento del acto jurídico.

La acepta el art. 281 al decir: "*La causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad...*".

"Causa fin mediata".- Denominada también "*motivos*", son las razones particulares que ha tenido cada parte para obligarse. Ej.: en una compraventa, el motivo o fin mediato del vendedor puede ser *el destino* que dará al dinero que reciba, como ser: viajar por el mundo, comprar una estancia, hacerse una cirugía, etc.

Los motivos dependen de cada persona, pueden variar y como están ocultos en el fuero interno de cada contratante son irrelevantes para el Derecho. La validez del acto no se afecta por el hecho de que una de las partes no haya logrado su motivo interno o fin mediato, salvo que lo haya exteriorizado y pactado en el acto celebrado.

También la acepta el art. 281 al establecer: "...*También integran la causa los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa, o tácitamente si son esenciales para ambas partes*".

Presunción de causa.-

Art. 282.- "*Presunción de causa. Aunque la causa no esté expresada en el acto se presume que existe mientras no se pruebe lo contrario. El acto es válido aunque la causa expresada sea falsa si se funda en otra causa verdadera.*"

La norma establece una presunción legal fundada en la idea de que nadie se obliga sin tener una causa. Sin embargo, la ley admite la prueba en contrario. Se trata entonces de una presunción "iuris tantum".

- "**Falsa causa**".- Acá se prevé una simulación. Si en un acto se expresa falsamente una causa pero en realidad hay oculta otra causa, el acto será válido en razón de la existencia de esa causa oculta. Ejemplo: se manifiesta recibir un dinero en razón de una venta, pero en realidad se trata de una donación.

La causa en el acto abstracto.-

Art. 283.- "*Acto abstracto. La inexistencia, falsedad o ilicitud de la causa no son discutibles en el acto abstracto mientras no se haya cumplido, excepto que la ley lo autorice.*"

- **Actos abstractos**: son actos jurídicos totalmente desvinculados de la "causa" que les dio origen (Ej.: los títulos de crédito, como ser la letra de cambio, el pagaré, el cheque, etc.). En estos títulos, en principio la causa carece de relevancia y el deudor no puede discutir la causa alegando la inexistencia, falsedad o ilicitud de la misma, debe limitarse a cumplir. Luego de cumplir podrá, en un juicio posterior, probar la inexistencia, falsedad o ilicitud de la causa.

Veamos un ejemplo: Ud. realiza una compra de mercaderías y documenta el pago mediante un pagaré. Como el pagaré es un título "abstracto", Ud. no puede negarse a pagarlo al tercero poseedor de buena fe que se lo presente, alegando que en realidad no hubo compraventa (causa) porque el vendedor no le entregó las mercaderías. O sea, el pagaré es válido y debe pagarse, independientemente de la causa que le dio origen. Luego, en un juicio ordinario posterior, Ud. podrá reclamar el reintegro de lo pagado fundado en la falta de causa.

D) FORMA Y PRUEBA

Concepto de "forma".-

Para la realización del acto jurídico, se requiere no sólo la voluntad interna del sujeto de realizar el acto, sino también que dicha voluntad se manifieste exteriormente de alguna forma.

La forma es la manera o medio por el cual el sujeto manifiesta exteriormente su voluntad. Es un elemento esencial del acto jurídico, pues todo acto exige alguna forma que lo de a conocer. La forma sería como un molde que contiene la voluntad del sujeto. Ihering decía: "*la forma es a un acto jurídico, como el cuño es a una moneda*".

La "forma" en el Código de Vélez.-

En el Código de Vélez, los actos jurídicos podían ser:

- **No formales**: cuando la ley no les imponía ninguna formalidad especial y dejaba la forma librada a la elección de las partes (art. 974).

• **Formales:** cuando la ley exigía determinadas formalidades para su realización (ej: por escritura pública). Los actos formales se subclasificaban en:

- 1) **Solemnes:** cuando la ley exigía formalidades determinadas como requisito de validez (*ad solemnitatem*), pues si el acto carecía de la forma exigida era nulo. (Ej.: la donación de un inmueble debía ser hechas por escritura pública, bajo pena de nulidad);
- 2) **No solemnes:** es estos casos, la ley también exigía determinadas formalidades, pero no como requisito de validez, sino como requisito "ad probationem" o sea, al solo efecto de la prueba. Si se omitía la formalidad exigida, el acto igual era válido, pero su existencia deberá ser probada por otros medios de prueba.

La "forma" en el nuevo Código Civil y Comercial.-

En los Fundamentos del Anteproyecto se dice: "En cuanto a la forma impuesta, se clasifican las formas distinguiendo entre formas absolutas, las relativas y formalidades para la prueba, en lugar de la clásica bipartición entre formas ad solemnitatem y ad probationem, que resultaba insuficiente, sobre todo a la vista de diversos negocios con forma exigida legalmente cuya no observancia no hace a la validez sino sólo a la producción de sus efectos propios".

Por su parte, el nuevo Código establece (al igual que el Código de Vélez) la libertad de formas en el art. 284:

Art. 284.- "Libertad de formas. Si la ley no designa una forma determinada para la exteriorización de la voluntad, las partes pueden utilizar la que estimen conveniente. Las partes pueden convenir una forma más exigente que la impuesta por la ley."

Las partes pueden utilizar la forma que quieran (verbalmente, por escrito sea instrumento privado o público) salvo que la ley designe una forma determinada.

Aún en el supuesto que la ley exija una forma determinada, la norma permite que las partes puedan convenir una forma más exigente que la impuesta por la ley. O sea, se permite que las partes elijan una forma con mas recaudos que la indicada en la ley.

Ejemplo: conf. art. 1188, la locación debe hacerse por escrito y las partes pueden convenir hacer el contrato mediante escritura pública.

Forma impuesta.-

El art. 285 contempla aquel caso en el cual se omite cumplir con una forma exigida o impuesta por la ley.

Art. 285.- "Forma impuesta. El acto que no se otorga en la forma exigida por la ley no queda concluido como tal mientras no se haya otorgado el instrumento previsto, pero vale como acto en el que las partes se han obligado a cumplir con la expresada formalidad, excepto que ella se exija bajo sanción de nulidad."

Si se omite la forma exigida por la ley ¿que consecuencias hay?. Debemos diferenciar:

• Si la ley exige la forma bajo sanción de nulidad, el acto no será válido y carecerá de efectos si no se lleva a cabo en la forma exigida.

Son los llamados "**Actos formales Absolutos**".

Ejemplo: las donaciones de inmuebles, muebles registrables o de prestaciones periódicas o vitalicias, deben hacerse en escritura pública, bajo pena de nulidad (conf. art. 1552).

• Si la forma no esta exigida bajo sanción de nulidad, el acto no queda concluido hasta que se cumpla con la forma exigida, pero vale como acto en el que las partes se han obligado a cumplir con la formalidad exigida.

Son los llamados "**Actos formales Relativos**".

Ejemplo: la compra de un inmueble debe hacerse por escritura pública (conf. art. 1017); si se hace por instrumento privado, la compra no queda concluida como tal (como venta con la consiguiente transmisión del dominio) hasta que se cumpla la forma exigida (la escritura pública), pero vale como acto en el que las partes se han obligado a cumplir con la formalidad exigida (ej: vale como obligación de escriturar).

Expresión escrita.-

La forma escrita o "**expresión escrita**" (como la llama el nuevo Código) es la que se utiliza en la mayoría de los casos, y si bien tradicionalmente se hace constar sobre un papel, el Código Civil y Comercial, admitiendo las nuevas tecnologías (en especial los medios electrónicos) establece que "puede hacerse constar en cualquier soporte..." (papel, plástico, un cd, un video, etc.), "...siempre que su contenido sea representado con texto inteligible..." (es decir, que se entienda), "...aunque su lectura exija medios técnicos".

Art. 286.- "Expresión escrita. La expresión escrita puede tener lugar por instrumentos públicos, o por instrumentos particulares firmados o no firmados, excepto en los casos en que determinada instrumentación sea impuesta."

Puede hacerse constar en cualquier soporte, siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos."

La forma escrita comprende: 1) los instrumentos públicos; 2) los instrumentos particulares firmados (instrumentos privados); 3) los instrumentos particulares no firmados.

1) **Instrumentos públicos:** son los instrumentos otorgados con las formalidades que la ley establece en presencia de un oficial público a quien la ley confiere facultades para autorizarlos. Están enumerados en el art. 289. La característica fundamental de los instrumentos públicos es que ellos se celebran "en presencia de un oficial público". La intervención del oficial público otorga al acto seriedad y seguridad pública, y da fe acerca del contenido del instrumento.

2) **Instrumentos particulares firmados (instrumentos privados):** son aquellos que las partes otorgan sin que medie intervención de ningún oficial público. En estos instrumentos el requisito fundamental es la firma de las partes.

3) **Instrumentos particulares no firmados:** esta categoría comprende todo escrito no firmado, entre otros, los impresos, los registros visuales o auditivos de cosas o hechos y, cualquiera que sea el medio empleado, los registros de la palabra y de información.

Estas dos últimas clases de instrumentos se encuentran reguladas en el art. 287:

Art. 287.- "Instrumentos privados y particulares no firmados. Los instrumentos particulares pueden estar firmados o no. Si lo están, se llaman instrumentos privados. Si no lo están, se los denomina instrumentos particulares no firmados; esta categoría comprende todo escrito no firmado, entre otros, los impresos, los registros visuales o auditivos de cosas o hechos y, cualquiera que sea el medio empleado, los registros de la palabra y de información."

Firma.-

La firma de las partes es una condición esencial del documento. La firma consiste en el nombre del firmante escrito de una manera particular o en un signo (ej, iniciales, símbolos o garabatos) que la persona usa habitualmente para demostrar su voluntad o conformidad con el contenido del documento. La firma puesta en un instrumento privado prueba que es de la autoría de esa persona. Generalmente se coloca al final del documento de modo tal que no queden espacios para agregar frases y dar lugar a un fraude.

Art. 288.- "Firma. La firma prueba la autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde. Debe consistir en el nombre del firmante o en un signo. En los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital, que asegure indubitadamente la autoría e integridad del instrumento."

¿La impresión dactilar puede reemplazar a la firma y darle validez al acto? Puede suceder que una persona (debido a que no sabe o no puede firmar) estampe su impresión dactilar en el documento. Al respecto las opiniones son contradictorias.

- Para algunos, si la parte no sabe o no puede firmar, la impresión dactilar puede reemplazar a la firma.

- Otros sostienen que el documento con impresión dactilar sólo sirve como un principio de prueba por escrito. Esta es la solución adoptada en el art. 314.

Firma a ruego.-

Hay **firma a ruego** (o documento firmado a ruego) cuando una de las partes pide, "ruega" a otra persona, que firme el documento por él, sea porque él no sabe, o porque no puede físicamente hacerlo.

Si bien la firma a ruego es válida en un instrumento público (porque en él interviene el oficial público que garantiza el acto), en un instrumento privado es discutible su validez.

- Para algunos es válida, pues hay una autorización o mandato verbal de quien no sabe o no puede firmar a otra persona para que lo haga por él.

- Para otros, el documento privado firmado a ruego sólo sirve como principio de prueba por escrito.

Instrumentos generados por medios electrónicos.- En los instrumentos generados por medios electrónicos, la firma digital equivale a la firma manuscrita, ya que así lo establece el art. 288: "...En los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital, que asegure indubitadamente la autoría e integridad del instrumento."

Firma digital.-

Sobre "**Firma Digital**" rige la **Ley 25.506** que regula el empleo de la firma electrónica y de la firma digital y su eficacia jurídica en las condiciones que establece la misma ley (conf. art. 1).

¿**Que es la Firma Digital?** Se entiende por firma digital al resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control.

- **Verificación.-** La firma digital debe ser susceptible de verificación por terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permita:

- a) identificar al firmante, y

- b) detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma.

Los procedimientos de firma y verificación a ser utilizados para tales fines serán los determinados por la Autoridad de Aplicación en consonancia con estándares tecnológicos internacionales vigentes (art. 2).

¿**Qué garantiza?** Permite garantizar la identidad del autor del documento, la inalterabilidad del documento firmado digitalmente, y la certeza de la fecha y hora en que ha sido firmado. (conf. arts. 7, 8 y 10).

¿**Cómo funciona?** Desde el punto de vista práctico, quien va a usar un documento digital firmado con firma digital, previamente debe generar dos claves:

- una **privada** (que el autor debe mantener siempre en secreto), y

- otra **pública** (que puede ser conocida por todos).

Estas claves se generan juntas porque están relacionadas de tal forma que todo lo que sea encriptado por una de ellas sólo podrá ser descryptado por la otra.

Sobre el documento y la clave privada se aplica un programa de encriptación y mediante complejas operaciones matemáticas se genera una huella o firma digital que el firmante enviará junto con el documento al destinatario.

El destinatario, mediante la clave pública del firmante, verifica la identidad del autor del documento, y que el mismo no tuvo alteraciones.

Es importante destacar que todas las firmas digitales que una persona genere son distintas de un documento a otro.

¿**"Firma Digital" y "Firma Electrónica" son lo mismo?** No, la firma digital está prevista en el art. 2 de la Ley 25.506, en tanto que la firma electrónica está

prevista en el art. 5 de la misma ley. La firma digital (conf. al art. 2) debe cumplir los requisitos legales determinados por la Autoridad de Aplicación. Si faltan esos requisitos tendríamos una "firma electrónica".

Pero, la diferencia fundamental entre ambas está en el valor probatorio atribuido a cada una de ellas:

- Si un documento lleva "firma digital", y ella fue verificada, se presume "*iuris tantum*" (salvo prueba en contrario) que proviene del firmante y que el documento no ha sido alterado.

- Por el contrario, si el documento lleva "firma electrónica", se invierte la carga probatoria. O sea que, en caso de ser desconocida la firma, corresponde a quien invoca su autenticidad acreditar su validez.

Actos excluidos del régimen de documentos digitales.- La ley 25.506, en su art. 4, indica cuáles son los actos que quedan excluidos del régimen de los documentos digitales. Ellos son: a) las disposiciones por causa de muerte; b) los actos jurídicos del derecho de familia; c) los actos personalísimos en general; d) los actos que deban ser instrumentados bajo exigencias o formalidades incompatibles con la utilización de la firma digital, ya sea como consecuencia de disposiciones legales o acuerdo de partes.

INSTRUMENTO PÚBLICO

Concepto.-

Instrumento público es el instrumento otorgado con las formalidades que la ley establece en presencia de un oficial público, a quien la ley confiere facultades para autorizarlo.

La característica fundamental de los instrumentos públicos es que ellos se celebran "*en presencia de un oficial público*". La intervención del oficial público otorga al acto seriedad y seguridad pública y da fe acerca del contenido del instrumento.

Requisitos de validez del instrumento público.-

Los requisitos del instrumento público se encuentran detallados en el art. 290.

Art. 290.- "Requisitos del instrumento público. Son requisitos de validez del instrumento público:

- a) la actuación del oficial público en los límites de sus atribuciones y de su competencia territorial, excepto que el lugar sea generalmente tenido como comprendido en ella;
- b) las firmas del oficial público, de las partes, y en su caso, de sus representantes; si alguno de ellos no firma por sí mismo o a ruego, el instrumento carece de validez para todos."

Por lo tanto, los requisitos de validez del instrumento público son:

1) **Actuación del oficial público.**- Que se celebre ante oficial público. Este requisito es fundamental pues en todos los casos que enumera el art. 289 interviene el oficial o funcionario público.

2) **Que el oficial público tenga atribuciones.**- Esto implica que esté facultado para otorgar instrumentos públicos, que haya sido puesto en posesión del cargo, que esté en funciones y que sea competente en razón de la materia (ej, un secretario de juzgado puede hacer un acta judicial, pero no podría otorgar una donación) y del territorio (ej, si se lo autorizó para otorgar instrumentos públicos sólo en la Capital Federal, no podrá hacerlo en otro lugar).

Carece de valor el instrumento otorgado por un oficial público que no está en funciones; pero por excepción son válidos los actos otorgados por él antes de la notificación de la suspensión o cesación de sus funciones (conf. art. 292).

3) **Desinterés del oficial público (o sus familiares) en el acto.**- Es de ningún valor el instrumento autorizado por un funcionario público en asunto en que él, su cónyuge, su conviviente, o un pariente suyo dentro del cuarto grado o segundo de afinidad, sean personalmente interesados (conf. art. 291).

4) **Las firmas de los intervinientes.**- Hay dos requisitos que, por lo general, se exigen en todo instrumento público: la firma de los intervinientes y la concurrencia de testigos.

El instrumento público debe estar firmado por todos los intervinientes en el instrumento público. Si alguno no lo firmare el acto sería de ningún valor para todos los que lo hubiesen firmado. Si alguno de los interesados no supiese o no pudiese firmar, se dejará constancia de ello en el instrumento, y se recurrirá a la "firma a ruego", es decir, se le pedirá a otra persona que firme en nombre de él (conf. art. 290 inc. b).

- Concurrencia de testigos: la mayoría de los instrumentos públicos, deben ser otorgados con la concurrencia de testigos. Los testigos pueden ser: instrumentales (su presencia sirve para dar más garantías de veracidad al acto), de conocimiento (su presencia es al solo efecto de justificar la identidad de las partes del acto), honorarios (generalmente son denominados así, los testigos del matrimonio).

Testigos inhábiles: son lo que no pueden ser testigos en un instrumento público. Están enumerados en el art. 295:

- a) las personas incapaces de ejercicio y aquellas a quienes una sentencia les impide ser testigo en instrumentos públicos;
- b) los que no saben firmar;
- c) los dependientes del oficial público;
- d) el cónyuge, el conviviente y los parientes del oficial público, dentro del cuarto grado y segundo de afinidad; El error común sobre la idoneidad de los testigos salva la eficacia de los instrumentos en que han intervenido.

5) **Que no tenga defectos de forma.**- Carece de validez el instrumento público que tenga enmiendas, agregados, borraduras, entrelíneas y alteraciones en partes esenciales, si no están salvadas antes de las firmas requeridas.

El instrumento que no tenga la forma debida vale como instrumento privado si está firmado por las partes.

Enumeración legal.-

Los instrumentos públicos se encuentran enumerados en el art. 289.

Art. 289.- "Enunciación. Son instrumentos públicos:

- a) las escrituras públicas y sus copias o testimonios;*
- b) los instrumentos que extienden los escribanos o los funcionarios públicos con los requisitos que establecen las leyes;*
- c) los títulos emitidos por el Estado nacional, provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a las leyes que autorizan su emisión."*

a) **Las escrituras públicas y sus copias o testimonios:** dentro del género de instrumentos públicos, la especie más importante es la escritura pública, y es tal, la que hace el escribano en su protocolo. Las copias o testimonios de esas escrituras también son instrumentos públicos y hacen plena fe. Copia y testimonio son sinónimos y consisten en reproducciones de la escritura.

b) **Los instrumentos que extienden los escribanos o los funcionarios públicos con los requisitos que establecen las leyes:** este inciso ya no se refiere a las escrituras públicas, sino a "cualquier otro instrumento" hecho por esos funcionarios.

Ejemplos: inventarios realizados por los escribanos públicos o por los jueces de paz; actas o partidas de nacimiento, defunción o matrimonios; actas del oficial de justicia; los cónsules argentinos y los ministros diplomáticos en el extranjero, etc.

c) **Los títulos emitidos por el Estado nacional, provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a las leyes que autorizan su emisión.**

Ejemplos: las letras aceptadas por el gobierno, los billetes o cualquier título de crédito emitido por el Tesoro público; bonos o títulos de empréstitos emitidos por el Estado; también se consideran instrumentos públicos las cédulas de identidad, las actas policiales, los certificados de transferencia de automotores, etc.

Eficacia probatoria.-

El art. 296 se refiere a la eficacia probatoria de los instrumentos públicos.

Art. 296.- "Eficacia probatoria. El instrumento público hace plena fe:

- a) en cuanto a que se ha realizado el acto, la fecha, el lugar y los hechos que el oficial público enuncia como cumplidos por él o ante él hasta que sea declarado falso en juicio civil o criminal;*
- b) en cuanto al contenido de las declaraciones sobre convenciones, disposiciones, pagos, reconocimientos y enunciaciones de hechos directamente relacionados con el objeto principal del acto instrumentado, hasta que se produzca prueba en contrario."*

Al respecto, hay que distinguir:

a) **Hechos cumplidos por el oficial público o que han pasado en su presencia.-** Sobre estos hechos el instrumento público hace plena fe hasta que sea argüido de falso (conf. art. 296 inc. a).

¿Por qué hace plena fe? Porque esos hechos han sido realizados por el oficial público o han ocurrido ante él, y ello da garantías de veracidad. Si alguien quiere impugnarlos como falsos, no podrá hacerlo con una simple prueba, sino que deberá

recurrir a un procedimiento especial: la "querrela de falsedad", mediante acción civil o mediante acción criminal.

Ejemplos de estos hechos: ejecución del acto, fecha y lugar de celebración, presencia o identidad de las partes, autenticidad de firmas, realidad de las entregas de cosas o de dinero, etc.

b) **Hechos declarados por las partes (o cláusulas dispositivas del instrumento).**- Estos hechos hacen plena fe, pero la misma puede ser destruida simplemente mediante prueba en contrario (conf. art. 296 inc. b), no requiriéndose la querrela de falsedad. ¿Por qué? Porque no son hechos que ha realizado o presenciado el oficial público, sino hechos que las partes le dicen -al oficial público- haber realizado (ej: que celebran una compraventa; o que una de las partes, con anterioridad, entregó una suma de dinero a la otra, etc.) y que el oficial público se limita a exponerlos en el instrumento público, pero sin garantizar su veracidad.

La fuerza probatoria de los instrumentos públicos puede hacerse valer contra las partes, los sucesores de éstas, y también contra terceros.

Impugnación del contenido del instrumento público.-

Tanto los instrumentos privados como los instrumentos públicos, sirven de medio de prueba, pero hay diferencias con respecto a la fuerza probatoria de cada uno.

• Tratándose de un instrumento privado, la autenticidad del documento debe ser probada (prueba que, generalmente, se lleva a cabo mediante el reconocimiento de la firma de las partes).

• Tratándose de un instrumento público, éste prueba su autenticidad por sí mismo ("per se"), ya que la ley presume que tanto el documento como su contenido son auténticos, en virtud de las garantías que lo rodean: lo otorga un oficial público, el cual agrega su firma y sello en el documento. En base a estas garantías, la ley considera que el instrumento público "hace plena fe hasta que sea argüido de falso". En otras palabras: se presume que tanto el instrumento público en sí mismo, como su contenido, son auténticos; y que si alguien quiere demostrar lo contrario -impugnarlo-, deberá probar lo que pretende, por medio de la querrela de falsedad (caso del inc. a) o mediante prueba en contrario (caso del inc. b).

El nuevo Código Civil y Comercial nada dice sobre las simples enunciaciones hechas accidentalmente por las partes y que no son directamente relativas al acto, pero la doctrina considera que sólo valen como un principio de prueba por escrito.

• Incolabilidad formal.- La plena fe y la seguridad que ofrece el instrumento público sería desvirtuada si los testigos o el oficial público que lo otorgó pudieran contradecir, variar o alterar su contenido. Por ello, la norma no admite que lo hagan, salvo que alegaran que testificaron u otorgaron el acto con su voluntad viciada por dolo o violencia.

Art. 297.- "Incolabilidad formal. Los testigos de un instrumento público y el oficial público que lo autorizó no pueden contradecir, variar ni alterar su contenido, si no alegan que testificaron u otorgaron el acto siendo víctimas de dolo o violencia."

• **Contradocumento.** - "El contradocumento es una declaración de voluntad formulada por escrito por las partes de carácter generalmente secreto y destinada a probar que el acto ha sido simulado" (conf. Borda). Prueba que el acto contenido en el instrumento público es simulado y que hay oculto otro acto que es el realmente querido por las partes. El contradocumento es válido entre las partes, pero no se puede oponer a terceros de buena fe.

Art. 298.- "Contradocumento. El contradocumento particular que altera lo expresado en un instrumento público puede invocarse por las partes, pero es inoponible respecto a terceros interesados de buena fe."

ESCRITURA PÚBLICA

Definición.-

La escritura pública es el instrumento matriz extendido en el protocolo de un escribano público o de otro funcionario autorizado para ejercer las mismas funciones, que contienen uno o más actos jurídicos. La copia o testimonio de las escrituras públicas que expiden los escribanos es instrumento público y hace plena fe como la escritura matriz. Si hay alguna variación entre ésta y la copia o testimonio, se debe estar al contenido de la escritura matriz (conf. art. 299).

Otros conceptos.-

• **Escritura matriz:** son las escrituras originales que el escribano extiende en el protocolo.

• **Copias:** son reproducciones de la escritura matriz; se llama primera copia a la que se entrega a las partes y segunda copia a la que se extiende posteriormente (ej: si la parte perdió la primera copia).

• **Protocolo:** tradicionalmente era un "libro de registro" en el cual el escribano extendía las escrituras matrices. Estaba numerado, rubricado o sellado y las escrituras se incorporaban por orden cronológico. Actualmente, el protocolo consiste en "folios habilitados" (hojas de papel numeradas y selladas que expiden los colegios de escribanos) para el uso de cada registro notarial; la numeración es correlativa en cada año calendario.

Por ello, el nuevo Código Civil y Comercial no habla de "libro", sino que directamente dice que el protocolo "*se forma con los folios habilitados para el uso de cada registro notarial, numerados correlativamente en cada año calendario, y con los documentos que se incorporan por exigencia legal o a requerimiento de las partes del acto*". Todo lo relativo a los folios y al protocolo debe ser reglamentado por las leyes locales (conf. art. 300).

• **Protocolización:** consiste en la incorporación de un instrumento al protocolo del escribano. Puede ser de un instrumento público o privado, pero generalmente se trata de estos últimos. La protocolización convierte al instrumento privado en un instrumento público. La protocolización del instrumento privado debe ser ordenada por el juez.

Requisitos de las escrituras públicas y deberes del notario.-

En los arts. 301 a 308 quedan incorporados al Código Civil y Comercial diversos requisitos de las escrituras públicas, y deberes que debe observar el notario. Así:

1) El escribano debe recibir por sí mismo las declaraciones de los comparecientes, sean las partes, sus representantes, testigos, cónyuges u otros intervinientes (conf. art. 301).

2) El escribano debe calificar los presupuestos y elementos del acto, y configurarlo técnicamente (conf. art. 301). Aparte de la función de dar fe al acto que se realiza, el notario debe brindar asesoramiento a los otorgantes acerca de la naturaleza y trascendencia del acto que llevan a cabo.

3) Las escrituras públicas deben extenderse en un único acto (mismo día, misma hora). Pueden ser manuscritas o mecanografiadas, pudiendo utilizarse mecanismos electrónicos de procesamiento de textos. En los casos de pluralidad de otorgantes en los que no haya entrega de dinero, valores o cosas en presencia del notario, los interesados pueden suscribir la escritura en distintas horas del mismo día de su otorgamiento. Este procedimiento puede utilizarse siempre que no se modifique el texto (conf. art. 301).

4) La escritura pública debe hacerse en idioma nacional. Si alguno de los otorgantes declara ignorarlo, la escritura debe redactarse conforme a una minuta firmada, que debe ser expresada en idioma nacional por traductor público, y si no lo hay, por intérprete que el escribano acepte. Ambos instrumentos deben quedar agregados al protocolo. Los otorgantes pueden requerir al notario la protocolización de un instrumento original en idioma extranjero, siempre que conste de traducción efectuada por traductor público, o intérprete que aquél acepte. En tal caso, con el testimonio de la escritura, el escribano debe entregar copia certificada de ese instrumento en el idioma en que está redactado.

Los otorgantes pueden requerir al notario la protocolización de un instrumento original en idioma extranjero, siempre que conste de traducción efectuada por traductor público, o intérprete que aquél acepte. En tal caso, con el testimonio de la escritura, el escribano debe entregar copia certificada de ese instrumento en el idioma en que está redactado (conf. art. 302).

5) En las escrituras públicas no se deben dejar espacios en blanco, ni utilizar abreviaturas, o iniciales, excepto que estas dos últimas consten en los documentos que se transcriben, se trate de constancias de otros documentos agregados o sean signos o abreviaturas científicas o socialmente admitidas con sentido unívoco. Pueden usarse números, excepto para las cantidades que se entregan en presencia del escribano y otras cantidades o datos que corresponden a elementos esenciales del acto jurídico (conf. art. 303).

6) Si hay un otorgante del acto con discapacidad auditiva, deben intervenir dos testigos, que puedan dar cuenta del conocimiento y comprensión del acto por la persona otorgante. Si es alfabeta (sabe leer y escribir), además, la escritura debe

hacerse de conformidad a una minuta firmada por ella y el escribano debe dar fe de ese hecho. La minuta debe quedar protocolizada (conf. art. 304).

7) La escritura debe contener (conf. art. 305):

- lugar y fecha de su otorgamiento; y si alguno lo requiere o el escribano lo considera conveniente, la hora en que se firma el instrumento;
- los datos de los otorgantes (nombres, apellidos, documento de identidad, domicilio real y especial si lo hubiera, fecha de nacimiento y estado de familia de los otorgantes); si se trata de personas casadas, se debe consignar también si lo son en primeras o posteriores nupcias y el nombre del cónyuge, si resulta relevante en atención a la naturaleza del acto; si se trata de una persona jurídica, se debe dejar constancia de su denominación completa, domicilio social y datos de inscripción de su constitución si corresponde;
- la naturaleza del acto y la individualización de los bienes que constituyen su objeto (ej: compraventa de inmueble sito en calle Chile 880, unidad 32, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires);
- la constancia instrumental de la lectura que el escribano debe hacer en el acto del otorgamiento de la escritura (el notario no sólo debe leer la escritura a los otorgantes sino que, además, debe dejar constancia de haberlo hecho);
- las enmiendas, testados, borraduras, entrelíneas, u otras modificaciones efectuadas al instrumento en partes esenciales, que deben ser realizadas de puño y letra del escribano y antes de la firma;
- la firma de los otorgantes, del escribano y de los testigos si los hubiera; si alguno de los otorgantes no sabe o no puede firmar, debe hacerlo en su nombre otra persona; debe hacerse constar la manifestación sobre la causa del impedimento y la impresión digital del otorgante.

8) Los comparecientes deben justificar su identidad por cualquiera de los siguientes medios:

- a) por exhibición que se haga al escribano de documento idóneo (ej: DNI); en este caso, se debe individualizar el documento y agregar al protocolo reproducción certificada de sus partes pertinentes (ej: fotocopia del documento); o
- b) por afirmación del conocimiento por parte del escribano (conf. art. 306).

9) Si el otorgante es un representante, el escribano debe exigirle la presentación del documento original que lo acredite (ej: el poder), el que ha de quedar agregado al protocolo, excepto que se trate de poderes para más de un asunto o de otros documentos habilitantes que hagan necesaria la devolución, supuesto en el cual se debe agregar copia certificada por el escribano. En caso de que los documentos habilitantes ya estén protocolizados en el registro del escribano interviniente, basta con que se mencione esta circunstancia, indicando folio y año (conf. art. 307).

10) El escribano debe dar copia o testimonio de la escritura a las partes. Ese instrumento puede ser obtenido por cualquier medio de reproducción que asegure su permanencia indeleble, conforme a las reglamentaciones locales. Si alguna de las partes solicita nueva copia, el escribano debe entregarla, excepto que la escritura

contenga la constancia de alguna obligación pendiente de dar o de hacer, a cargo de otra de las partes. En este caso, se debe requerir la acreditación en instrumento público de la extinción de la obligación, la conformidad del acreedor o la autorización judicial, que debe tramitar con citación de las partes del acto jurídico (conf. art. 308).

Nulidad de la escritura.-

Son nulas las escrituras que no tengan la designación del tiempo y lugar en que sean hechas, el nombre de los otorgantes, la firma del escribano y de las partes, la firma a ruego de ellas cuando no saben o no pueden escribir y la firma de los dos testigos del acto cuando su presencia sea requerida.

La inobservancia de las otras formalidades no anula las escrituras, pero los escribanos o funcionarios públicos pueden ser sancionados (conf. art. 309).

Actas Notariales.-

Las actas son documentos notariales que tienen por objeto la comprobación de hechos. Las actas están sujetas a los requisitos de las escrituras públicas, con las siguientes modificaciones (conf. art. 311):

- a) se debe hacer constar el requerimiento que motiva la intervención del notario y, en su caso, la manifestación del requirente respecto al interés propio o de terceros con que actúa;
- b) no es necesaria la acreditación de personería ni la del interés de terceros que alega el requirente;
- c) no es necesario que el notario conozca o identifique a las personas con quienes trata a los efectos de realizar las notificaciones, requerimientos y otras diligencias;
- d) las personas requeridas o notificadas, en la medida en que el objeto de la comprobación así lo permita, deben ser previamente informadas del carácter en que interviene el notario y, en su caso, del derecho a no responder o de contestar; en este último supuesto se deben hacer constar en el documento las manifestaciones que se hagan;
- e) el notario puede practicar las diligencias sin la concurrencia del requirente cuando por su objeto no sea necesario;
- f) no requieren unidad de acto ni de redacción; pueden extenderse simultáneamente o con posterioridad a los hechos que se narran, pero en el mismo día, y pueden separarse en dos o más partes o diligencias, siguiendo el orden cronológico;
- g) pueden autorizarse aun cuando alguno de los interesados rehúse firmar, de lo cual debe dejarse constancia.

INSTRUMENTOS PRIVADOS Y PARTICULARES

Concepto.-

Los instrumentos privados son aquellos instrumentos particulares que las partes otorgan sin que medie la intervención del oficial público.

En estos instrumentos el requisito fundamental es la firma de las partes, porque ella prueba la autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde.

Firma.-

La firma consiste en el nombre del firmante escrito de una manera particular, y si se trata de un instrumento electrónico la firma digital equivale a la firma manuscrita de la persona.

Art. 313.- "Firma de los instrumentos privados. Si alguno de los firmantes de un instrumento privado no sabe o no puede firmar, puede dejarse constancia de la impresión digital o mediante la presencia de dos testigos que deben suscribir también el instrumento."

Si la persona no sabe o no puede firmar, el Código da como solución:

- a) que dicha persona estampe su impresión digital; o
- b) que se pongan dos testigos que suscriban el documento dejando constancia de la situación.

En rigor de verdad, la impresión digital no es igual a la firma, porque si bien la impresión digital sirve para identificar a la persona, no sirve para demostrar que ella conoce el contenido del documento, pues un analfabeto mal puede dar conformidad acerca de lo que dice el documento, si él no se puede enterar porque no sabe leer ni escribir. También facilitaría fraudes, pues sería posible estampar la impresión dactilar de un fallecido en un documento. Lo lógico sería admitir la validez de la impresión dactilar en aquellos casos en que la parte no puede firmar por un impedimento físico, como ser, la fractura de su mano. Además, del art. 314 surge que el documento firmado y el que tiene impresión digital tienen distinto valor probatorio.

Reconocimiento de la firma.-

A diferencia del instrumento público que prueba su autenticidad por sí mismo (ya que la ley presume que tanto el documento como su contenido son auténticos, en virtud de las garantías que lo rodean), tratándose de un documento privado la autenticidad del documento debe ser probada, prueba que generalmente se lleva a cabo mediante el reconocimiento de firma de la parte a quien se atribuye.

Art. 314.- "Reconocimiento de la firma. Todo aquel contra quien se presente un instrumento cuya firma se le atribuye debe manifestar si ésta le pertenece. Los herederos pueden limitarse a manifestar que ignoran si la firma es o no de su causante. La autenticidad de la firma puede probarse por cualquier medio."

El reconocimiento de la firma importa el reconocimiento del cuerpo del instrumento privado.

El instrumento privado reconocido, o declarado auténtico por sentencia, o cuya firma está certificada por escribano, no puede ser impugnado por quienes lo hayan reconocido, excepto por vicios en el acto del reconocimiento. La prueba resultante es indivisible. El documento signado con la impresión digital vale como principio de prueba por escrito y puede ser impugnado en su contenido."

El Código establece que la persona contra quien se presente un instrumento cuya firma se le atribuye tiene la obligación de manifestar si la firma le pertenece o no. Si no lo hace, su silencio se interpreta como un reconocimiento (vale aclarar que en el caso de los herederos, éstos no son los firmantes y por lo tanto no tienen esta obligación y pueden limitarse a manifestar que "ignorán" si la firma es o no de su causante).

El reconocimiento de la firma importa el reconocimiento del cuerpo del instrumento privado (es decir, queda demostrada la autenticidad del documento en sí, y también la autenticidad o veracidad de su contenido).

Si la persona a la cual se atribuye el documento niega la firma será necesario proceder a probar la autenticidad de la firma o comprobación del documento, lo cual -dice el nuevo Código- se puede lograr por cualquier medio (como ser: testigos, informes, presunciones, etc.) aunque el medio más eficaz es el "cotejo", realizado por peritos calígrafos.

El "cotejo" consiste en comparar la letra o firma del documento cuya autenticidad se niega, con la letra o firma de un documento indubitado, es decir, de un documento que no ofrezca dudas de su autenticidad (ej: firma puesta en una escritura pública, firma registrada en un banco, firma en el Registro Civil, etc.). El cotejo es realizado por peritos calígrafos.

Si no hubiese documentos indubitados, la persona a la cual se atribuye la letra y firma, deberá formar un cuerpo de escritura (el perito dicta y el imputado escribe). Cabe destacar que, en la actualidad, los peritos cuentan con técnicas muy adelantadas para saber si la letra o firma pertenece o no a determinada persona, tal el caso del procedimiento escopométrico (que consiste en fotografiar la firma y aumentarla varias veces) o de la prueba de luz rasante (se pasa una luz por el documento y ella hace resaltar la presión ejercida por la persona al firmar o escribir); etc. Valorando el dictamen pericial caligráfico el juez podrá dictar sentencia declarando auténtico o no al documento.

El instrumento privado reconocido por el firmante, o declarado auténtico por sentencia, o cuya firma está certificada por escribano, no puede ser impugnado por quienes lo hayan reconocido, excepto por vicios en el acto del reconocimiento. La prueba resultante es indivisible.

El documento signado con la impresión digital vale como principio de prueba por escrito y puede ser impugnado en su contenido.

Documento firmado en blanco.-

Por lo general, se redacta el contenido de un documento y luego las partes lo firman; pero puede suceder que una de las partes, en confianza, firme el documento en blanco para que la otra luego lo llene de acuerdo a lo que han convenido. Se considera que hay un mandato del firmante a la otra parte para que lo llene.

¿Cuál es el régimen de estos documentos firmados en blanco? ¿Son válidos? Estos documentos firmados en blanco, tras ser llenados por la otra parte, son válidos si la

parte que los firmó en blanco reconoce su firma y está de acuerdo con el contenido dado al documento.

Por el contrario, el firmante en blanco puede oponerse al contenido del documento en los siguientes casos:

a) Si considera que se ha abusado de su firma en blanco. En este caso deberá probar que lo que dice el documento no responde a sus instrucciones, es decir, no es lo que él ha tenido intención de hacer o contratar. Esta prueba no puede hacerse por testigos si no existe principio de prueba por escrito pero sí se podrán utilizar otros medios (presunciones, otros documentos, etc.). Si se declara la nulidad del contenido, ella tendrá efectos entre las partes, pero no podrá afectar a terceros de buena fe que hubiesen contratado con quien llenó el documento (conf. art. 315).

b) Si el documento fue sustraído a la persona a la cual se le dio y lo guardaba, y hubiese sido llenado por un tercero. En este caso se deberá probar la sustracción y el abuso de firma en blanco, circunstancias que pueden probarse por cualquier medio de prueba. Probados estos extremos, el contenido del instrumento no puede oponerse al firmante, salvo que sean terceros de buena fe que hayan adquirido derechos a título oneroso en base al instrumento (conf. art. 315).

Art. 315.- "Documento firmado en blanco. El firmante de un documento en blanco puede impugnar su contenido mediante la prueba de que no responde a sus instrucciones, pero no puede valerse para ello de testigos si no existe principio de prueba por escrito. El desconocimiento del firmante no debe afectar a terceros de buena fe. Cuando el documento firmado en blanco es sustraído contra la voluntad de la persona que lo guarda, esas circunstancias pueden probarse por cualquier medio. En tal caso, el contenido del instrumento no puede oponerse al firmante excepto por los terceros que acrediten su buena fe si han adquirido derechos a título oneroso en base al instrumento."

Fecha cierta.-

La fecha cierta es aquella fecha que se pueda considerar verídica, auténtica, porque ella da certeza de que el instrumento privado ya estaba firmado al momento de su producción, o que no pudo ser firmado después de su acaecimiento (conf. Rivera).

Por lo tanto, la fecha cierta está determinada por un hecho que produce la certeza de que el documento ya estaba firmado o no pudo ser firmado después. Ejemplo: un documento tendría como fecha cierta, el día en que el firmante hubiese sido amputado de ambas manos o la fecha de su fallecimiento, etc.

¿Por qué se exige? Para evitar que las partes de común acuerdo simulen actos poniendo fechas falsas (anteriores o posteriores a la fecha real del acto) para perjudicar a terceros. Es una forma de proteger a terceros.

¿El documento privado sin fecha cierta es válido? Si, es válido, pero frente a terceros no tendrá valor probatorio (para ellos sólo lo tiene desde su fecha cierta).

¿Cómo se adquiere la fecha cierta? Veamos cómo se adquiría con el régimen del Código de Vélez, y cómo se adquiere en el nuevo Código Civil y Comercial:

- En el Código de Vélez, el art. 1035 enumeraba 4 modos en que un documento privado podía adquirir fecha cierta: 1) La de su exhibición en juicio o en cualquier repartición pública...si allí quedase archivado; 2) La de su reconocimiento ante un escribano y dos testigos que lo firmaren; 3) La de su transcripción en cualquier registro público; 4) La del fallecimiento de quien lo firmó como parte o como testigo, o de quien lo escribió de su puño y letra. La enumeración no era taxativa, pues podía haber otros casos que hicieran imposible la firma posterior del documento (Ej: fecha de la amputación de ambas manos del firmante).

- El nuevo Código Civil y Comercial no enumera hechos que produzcan fecha cierta y permite probar por cualquier medio ese hecho que da certeza de que el documento no pudo ser firmado después, pero dada la importancia de esta prueba la norma establece que el juez debe apreciarla rigurosamente (conf. art. 317).

Art. 317.- "Fecha cierta. La eficacia probatoria de los instrumentos privados reconocidos se extiende a los terceros desde su fecha cierta. Adquieren fecha cierta el día en que acontece un hecho del que resulta como consecuencia ineludible que el documento ya estaba firmado o no pudo ser firmado después.

La prueba puede producirse por cualquier medio, y debe ser apreciada rigurosamente por el juez."

Correspondencia.-

La correspondencia (término que incluye a las cartas misivas) son comunicaciones escritas que una persona dirige a otra, manifestándole sus pensamientos sobre alguna cosa, en donde frecuentemente el remitente expresa su opinión, su voluntad o intención sobre algo, comenta que se debe algo, etc.

El nuevo Código Civil y Comercial hace referencia a la correspondencia en general, cualquiera sea el medio empleado para crearla o transmitirla, por lo cual deben considerarse incluidas en la norma las cartas familiares o comerciales, los telegramas, cartas documentos, tarjetas postales, etc.

- La correspondencia como medio de prueba.- La correspondencia plantea el problema de determinar si puede ser presentada como medio de prueba. Acá hay que tener presente que la correspondencia luego de recibida pertenece al destinatario y, además, que quien la presente como prueba debe haberla obtenido por medios lícitos y no por medios fraudulentos, porque sino estaríamos ante un delito.

Retomando el tema de su admisibilidad como prueba, hay que distinguir si la correspondencia es o no confidencial:

a) Si no es confidencial, el destinatario puede presentarla como prueba.

b) Si es confidencial: el destinatario necesita el consentimiento del remitente.

Los terceros, para valerse de ellas como prueba, necesitan el consentimiento del destinatario, y si se trata de correspondencia confidencial, el consentimiento de ambos (conf. art. 318).

Art. 318.- "Correspondencia. La correspondencia, cualquiera sea el medio empleado para crearla o transmitirla, puede presentarse como prueba por el destinatario, pero

la que es confidencial no puede ser utilizada sin consentimiento del remitente. Los terceros no pueden valerse de la correspondencia sin asentimiento del destinatario, y del remitente si es confidencial."

Valor probatorio de los instrumentos particulares.-

El art. 319 del nuevo Código Civil y Comercial se refiere a los instrumentos particulares no firmados (ej: una carta misiva no firmada, un ticket de compra, un boleto, una factura, un remito, comunicación por medio electrónica sin firma digital, etc).

El valor probatorio de estos documentos debe ser apreciado por el juez ponderando, entre otras pautas, la congruencia (relación lógica y coherente) entre lo sucedido y narrado, la precisión y claridad técnica del texto, los usos y prácticas del tráfico, las relaciones precedentes y la confiabilidad de los soportes utilizados y de los procedimientos técnicos que se apliquen (conf. art. 319).

Art. 319.- "Valor probatorio. El valor probatorio de los instrumentos particulares debe ser apreciado por el juez ponderando, entre otras pautas, la congruencia entre lo sucedido y narrado, la precisión y claridad técnica del texto, los usos y prácticas del tráfico, las relaciones precedentes y la confiabilidad de los soportes utilizados y de los procedimientos técnicos que se apliquen."

Requisito del "doble ejemplar".-

El requisito del doble ejemplar, exigido en el Código Civil de Vélez, se ha eliminado en el nuevo Código Civil y Comercial. Consistía en que, en los actos con intereses opuestos (ej: una parte vende y la otra compra), se debían hacer tantos ejemplares como partes había. Sólo se exigía en las convenciones bilaterales perfectas (las que tienen obligaciones recíprocas para ambas partes) pero no en las bilaterales imperfectas (ej: depósito) ni en las unilaterales (ej: donación).

Su importancia consistía en que permitía a ambas partes probar el acto. La falta de doble ejemplar se sancionaba con la nulidad.

CONTABILIDAD Y ESTADOS CONTABLES

Regulación normativa.-

La Sección 7ª del nuevo Código Civil y Comercial (arts. 320 a 331) está dedicada a la contabilidad y estados contables. La Comisión Redactora del nuevo Código tomó como base el Proyecto de 1998 y otros anteriores, pero consideró adecuado optimizar y actualizar el tema.

Los contenidos básicos son los siguientes:

1) Se extiende la obligación del llevado de contabilidad a todas las personas, sean humanas o jurídicas, que desarrollen una actividad económica o sean titulares de empresas.

Se exceptúa de tal obligación a las personas físicas a las que el llevado de libros pudiera resultar gravoso, tales como agricultores y profesionales no organizados en

forma de empresa. Asimismo, se faculta a las jurisdicciones locales a exceptuar también a aquellas actividades cuyo volumen de giro no justifiquen el llevado de libros.

Se introduce, en favor de todas las personas, la posibilidad de llevar contabilidad legal en forma voluntaria (si así lo deciden) en un pie de igualdad respecto de los sujetos obligados.

2) En cuanto al llevado de la contabilidad, se hace hincapié en la verosimilitud de las registrações, las que deben reflejar los hechos, instrumentos y documentos que les dan origen, sobre bases y criterios uniformes (a fin de evitar distorsiones originadas en las variaciones de los mismos) y con carácter eminentemente inclusivo de todos los actos que pudieran tener efecto sobre el patrimonio del obligado y el resultado de sus operaciones.

3) Se imponen como libros obligatorios mínimos el "Diario", a fin de la anotación de las operaciones en orden cronológico, y el de "Inventarios y Balances", para la anotación en forma detallada de los activos, pasivos y patrimonio neto, al comienzo de las actividades y al cierre de cada ejercicio, así como para la transcripción de los estados contables anuales. Se agrega, también con carácter de obligatorio, todo otro libro o registro que resulte necesario en función de la dimensión y características de la actividad del obligado o los que en forma especial impongan el Código u otras leyes.

4) Se prevé la posibilidad, previa autorización, del llevado de libros, registros y del archivo de la documentación de respaldo por medios alternativos hoy existentes (electrónicos, magnéticos, ópticos, etcétera) u otros que puedan crearse en el futuro. Se exceptúa de tal posibilidad al libro de "Inventarios y Balances", donde deben quedar registradas las características de los medios alternativos solicitados, así como las autorizaciones que se confieran, debiendo los referidos medios garantizar la inalterabilidad, inviolabilidad, verosimilitud y completitud de los registros.

5) Se ha dejado a cargo de los Registros Públicos de cada jurisdicción el otorgamiento de autorizaciones para su llevado por medios alternativos.

6) En cuanto a la forma del llevado de los libros, se mantienen las normas de seguridad que hacen a la fe de sus registros.

Se imponen en forma expresa para los libros y registros, el idioma y la moneda nacional, lo que excluye otras lenguas o unidades de medida técnicas o foráneas.

7) Se fija expresamente el lugar en que han de permanecer los libros y registros contables, lo que aventará controversias al respecto.

A la vez, ese mismo lugar se constituye en aquél en que se deben llevar a cabo (en su caso) las diligencias probatorias sobre los libros y registros del obligado.

8) Se dispone que los registros han de permitir determinar al cierre de cada ejercicio la determinación del patrimonio, de su evolución y de sus resultados, estableciéndose el contenido mínimo de los estados contables anuales.

9) En cuanto a la conservación de los libros y registros se establece el plazo de diez años, el que se computará: desde el último asiento en el caso de los libros;

desde la última anotación efectuada en el caso de los demás registros y desde la fecha de su emisión, en el caso de los instrumentos o documentos respaldatorios.

10) Se establecen reglas concretas acerca de la eficacia probatoria de la contabilidad, incluyéndose todas las posibilidades, tanto entre obligados a llevar contabilidad y quienes decidan hacerlo en forma voluntaria, como entre éstos y los no obligados.

11) Se sostiene el criterio general de confidencialidad, prohibiéndose las pesquisas genéricas a fin de determinar si las personas llevan o no contabilidad legal.

En resguardo de la confidencialidad, se limita el examen probatorio a las cuestiones estrictamente en debate, sin perjuicio del examen genérico del sistema contable a fin de establecer si éste es llevado de acuerdo a las prescripciones legales.

Concepto de "contabilidad".-

La contabilidad es una técnica para dejar registradas las actividades económicas o financieras de una persona. Permite saber los ingresos, los gastos y sus repercusiones (ganancias o pérdidas) sobre el patrimonio, lo cual se manifiesta en los estados contables o financieros que resumen la situación económica. Permite obtener información de gran utilidad para la toma de decisiones.

Obligados a llevar contabilidad.-

De acuerdo al art. 320 (primera parte), están obligadas a llevar contabilidad las siguientes personas:

1) Las personas jurídicas privadas. Por ej: sociedades; asociaciones civiles; simples asociaciones; fundaciones; iglesias; mutuales; cooperativas; consorcios de propiedad horizontal; etc.

2) Las personas humanas, cuando realizan una actividad económica organizada o son titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios.

Cualquier persona, aunque no esté obligada, puede llevar contabilidad si solicita su inscripción y la habilitación de sus registros o la rubricación de los libros.

Art. 320 (primera parte).- "Obligados. Excepciones. Están obligadas a llevar contabilidad todas las personas jurídicas privadas y quienes realizan una actividad económica organizada o son titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios.

Cualquier otra persona puede llevar contabilidad si solicita su inscripción y la habilitación de sus registros o la rubricación de los libros, como se establece en esta misma Sección..."

Eximidos de llevar contabilidad.-

De acuerdo al art. 320 (segunda parte), no están obligadas a llevar contabilidad las siguientes personas:

1) Las personas humanas que desarrollan profesiones liberales (ej: abogados, escribanos, médicos, etc.), o actividades agropecuarias (ej: ganadería, apicultura, etc) o conexas a ellas, siempre que no estén organizadas en forma de empresa o sociedad.

Se consideran "conexas" las actividades dirigidas a la transformación o a la enajenación de productos agropecuarios cuando están comprendidas en el ejercicio normal de tales actividades (ej: elaboración de miel, de productos lácteos, de encurtidos, etc).

2) También pueden ser eximidas de llevar contabilidad las personas que realicen actividades de escaso volumen (ej: un pequeño comercio, un kiosco). En este caso la eximición de llevar contabilidad debe ser pedida y resuelta en cada jurisdicción local.

Art. 320 (segunda parte).- "Obligados. Excepciones. ... Sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales, quedan excluidas de las obligaciones previstas en esta Sección las personas humanas que desarrollan profesiones liberales o actividades agropecuarias y conexas no ejecutadas u organizadas en forma de empresa. Se consideran conexas las actividades dirigidas a la transformación o a la enajenación de productos agropecuarios cuando están comprendidas en el ejercicio normal de tales actividades. También pueden ser eximidas de llevar contabilidad las actividades que, por el volumen de su giro, resulta inconveniente sujetar a tales deberes según determine cada jurisdicción local."

Modo de llevar la contabilidad.-

La contabilidad debe ser llevada sobre una base uniforme, es decir en base a principios contables que se mantengan de un período contable a otro. Es fundamental que de la contabilidad surja un cuadro verídico de la situación patrimonial de la persona: las actividades y actos que deben registrarse, de modo que se puedan individualizar las operaciones y las correspondientes cuentas acreedoras y deudoras.

La contabilidad debe complementarse con la documentación respectiva que respalde los asientos contables. Todo debe archivar en forma metódica y que permita su localización y consulta.

Cabe destacar que actualmente existe software que facilita la tarea de llevar la contabilidad, permitiendo obtener todo tipo de informes a partir de los datos ingresados.

Art. 321.- "Modo de llevar la contabilidad. La contabilidad debe ser llevada sobre una base uniforme de la que resulte un cuadro verídico de las actividades y de los actos que deben registrarse, de modo que se permita la individualización de las operaciones y las correspondientes cuentas acreedoras y deudoras.

Los asientos deben respaldarse con la documentación respectiva, todo lo cual debe archivar en forma metódica y que permita su localización y consulta."

Registros indispensables.-

El art. 322 se refiere a los registros y libros considerados indispensables para llevar la contabilidad:

Art. 322.- "Registros indispensables. Son registros indispensables, los siguientes:

a) diario;

b) *inventario y balances*;

c) *aquellos que corresponden a una adecuada integración de un sistema de contabilidad y que exige la importancia y la naturaleza de las actividades a desarrollar*;

d) *los que en forma especial impone este Código u otras leyes.*"

• **Diario.**- En este libro se deben registrar todas las operaciones relativas a la actividad de la persona y que influyen en su patrimonio. Cada asiento debe dejar en claro quien es el acreedor y quien el deudor en cada operación.

Se puede hacer día por día o en registros resumidos que cubran periodos no superiores a un mes. Estos resúmenes deben surgir de anotaciones detalladas practicadas en subdiarios. El *Libro de Caja* (entrada y salida de dinero) es un libro auxiliar que integra el libro *Diario* y debe cumplir, al igual que otros diarios auxiliares, con las formalidades establecidas para el mismo (legalizado y foliado).

• **Inventario y balances.**- Se trata de un solo libro que contiene el inventario donde se detalla el dinero, bienes, derechos, etc., que conforman el capital de la persona o empresa al comenzar su actividad. También en este libro se asienta el estado contable (Balance) que registra todo el activo y pasivo de la persona al cierre de cada ejercicio, y que toda persona que lleva contabilidad obligada o voluntaria debe realizar (conf. art. 326)

• **Libros exigidos por la importancia y la naturaleza de las actividades a desarrollar y libros que en forma especial impone este Código u otras leyes.**- Ejemplos: si se trata de una sociedad, deberá llevar un *Libro de Actas de Asambleas* y otro de *Actas de Directorio*, etc. La Ley de Contrato de Trabajo (art. 52) exige llevar un *Libro de Registro de Empleados*; las leyes impositivas exigen el *Libro de IVA Compras e IVA Ventas*, etc.

• **Libros auxiliares.**- Son aquellos libros complementarios de los libros *Diario* y de *Inventario y Balances*, y que son necesarios para llevar una contabilidad adecuada (ej: libro de Caja, libro de Bancos, libro de Vencimientos, etc).

Formalidades de los libros.-

El interesado en llevar su contabilidad debe llevar sus libros debidamente encuadernados y foliados (numeración impresa) al Registro Público correspondiente (en Capital Federal es la *Inspección General de Justicia*) para que se los rubriquen o individualicen.

La individualización consiste en una nota que se coloca en el primer folio (hoja del libro), indicando: número del ejemplar, nombre de su titular, número de folios que contiene, destino del libro, fecha, y firma de la persona a cargo del Registro.

El que quiera llevar la contabilidad de otra forma (ej: mediante software de contabilidad) debe pedir la correspondiente autorización al Registro (conf. art. 329).

El Registro debe llevar una *nómina alfabética*, de consulta pública, de las personas que solicitan rubricación de libros o autorización para llevar los registros contables de otra forma, de la que surgen los libros que les fueron rubricados y, en su caso, de las autorizaciones que se les confieren (conf. art. 323).

Las operaciones asentadas deben hacerse en orden cronológico y actualizado (sin demoras en hacer el asiento), sin alteración alguna que no haya sido debidamente salvada. Debe utilizarse el idioma y la moneda nacional (español y peso). Los libros deben permanecer en el domicilio de su titular (conf. art. 325).

Prohibiciones.-

De acuerdo al art. 324, en los libros se prohíbe:

a) alterar el orden en que los asientos deben ser hechos;

b) dejar blancos que puedan utilizarse para intercalaciones o adiciones entre los asientos;

c) interlinear, raspar, enmendar o tachar (las equivocaciones y omisiones deben salvarse mediante un nuevo asiento, hecho en la fecha en que se advierta la omisión o el error);

d) mutilar parte alguna del libro, arrancar hojas o alterar la encuadernación o foliatura;

e) cualquier otra circunstancia que afecte la inalterabilidad de las registraciones.

Conservación de libros y registros.-

Los libros y el resto de la documentación contable deben conservarse por 10 años, salvo que leyes especiales fijen un plazo más largo (conf. art. 328).

• Para los libros el plazo de 10 años se cuenta desde el último asiento.

• Para los demás registros, desde la fecha de la última anotación practicada sobre los mismos.

• Para los instrumentos respaldatorios (ej: facturas) desde la fecha del instrumento.

Los herederos deben conservar los libros del causante y, en su caso, exhibirlos en la forma prevista en el artículo 331, hasta que se cumpla el plazo de 10 años.

Actos sujetos a autorización.-

El nuevo Código Civil y Comercial (art. 329), permite:

a) Reemplazar los libros contables (salvo el de *Inventario y Balances*) por otros medios, como ser: por el uso de ordenadores u otros medios mecánicos, magnéticos o electrónicos que permitan la individualización de las operaciones y de las correspondientes cuentas deudoras y acreedoras y su posterior verificación.

b) Conservar la documentación en microfilm, discos ópticos u otros medios aptos para ese fin.

Pero, para hacerlo, previamente debe pedir autorización al Registro Público indicando una adecuada descripción del sistema, con dictamen técnico de Contador Público e indicación de los antecedentes de su utilización. Una vez aprobado, el pedido de autorización y la respectiva resolución del organismo de contralor, deben transcribirse en el libro de *Inventarios y Balances*.

La autorización sólo se debe otorgar si los medios alternativos son equivalentes, en cuanto a inviolabilidad, verosimilitud y completitud, a los sistemas cuyo reemplazo se solicita.

Art. 329.- "Actos sujetos a autorización. El titular puede, previa autorización del Registro Público de su domicilio:

a) sustituir uno o más libros, excepto el de Inventarios y Balances, o alguna de sus formalidades, por la utilización de ordenadores u otros medios mecánicos, magnéticos o electrónicos que permitan la individualización de las operaciones y de las correspondientes cuentas deudoras y acreedoras y su posterior verificación;

b) conservar la documentación en microfilm, discos ópticos u otros medios aptos para ese fin.

La petición que se formule al Registro Público debe contener una adecuada descripción del sistema, con dictamen técnico de Contador Público e indicación de los antecedentes de su utilización. Una vez aprobado, el pedido de autorización y la respectiva resolución del organismo de contralor, deben transcribirse en el libro de Inventarios y Balances.

La autorización sólo se debe otorgar si los medios alternativos son equivalentes, en cuanto a inviolabilidad, verosimilitud y completitud, a los sistemas cuyo reemplazo se solicita."

Eficacia probatoria de la contabilidad.-

Del art. 330 surge que:

1) La contabilidad llevada en la forma legal debe ser admitida en juicio, como medio de prueba.

2) Es prueba contra quien la lleva, aunque no estuviera en forma legal, sin admitírsele prueba en contrario. El adversario debe aceptarla en su totalidad, no pudiendo aceptar sólo los asientos que le son favorables y desechando los que no lo son.

3) Es prueba a favor de quien la lleva cuando el adversario no lleva contabilidad o llevándola no tiene registros contrarios incorporados en una contabilidad regular. En estos casos, el juez puede pedir otra prueba supletoria.

4) Si ambas partes llevan su contabilidad en forma legal y la prueba es contradictoria, el juez debe rechazar este medio de prueba y valerse de las demás pruebas que se presentaron.

5) Si se trata de litigio contra quien no está obligado a llevar contabilidad, ni la lleva voluntariamente, la contabilidad sólo sirve como principio de prueba.

6) La prueba que resulta de la contabilidad es indivisible, se acepta o rechaza en su totalidad.

Pesquisas, investigaciones y exhibición de libros.-

Ninguna autoridad, bajo ningún pretexto, puede hacer investigaciones de oficio acerca de si las personas llevan o no registros arreglados a derecho, salvo los casos previstos en leyes especiales (conf. art. 331).

La prueba sobre la contabilidad (libros y registros) debe realizarse en el domicilio del titular, aun cuando esté fuera de la competencia territorial del juez que la ordena.

La exhibición general de registros o libros contables sólo puede decretarse a instancia de parte en los siguientes casos:

- en los juicios de sucesión,
- en todo tipo de comunión de bienes,
- en contrato asociativo o sociedad,
- en administración por cuenta ajena,
- en caso de liquidación,
- en concurso o quiebra.

Fuera de estos casos, únicamente puede requerirse la exhibición de registros o libros en cuanto tenga relación con la cuestión controvertida de que se trata, así como para establecer si el sistema contable del obligado cumple con las formas y condiciones establecidas en los artículos 323, 324 y 325.

CLASIFICACIÓN DE LOS ACTOS JURÍDICOS

Los actos jurídicos se clasifican en:

- 1) unilaterales y bilaterales;
- 2) entre vivos y de última voluntad;
- 3) positivos y negativos;
- 4) extrapatrimoniales y patrimoniales;
- 5) onerosos y gratuitos;
- 6) de disposición y de administración;
- 7) formales y no formales;
- 8) principales y accesorios;
- 9) actos puros y simples y actos modales.

1) **Unilaterales:** cuando basta para formarlos la voluntad de una sola persona (ej: el testamento, la renuncia de un derecho, etc.);

Bilaterales: cuando requieren el consentimiento unánime de dos o más personas (ej: compraventa, locación, etc.).

2) **Entre vivos:** son aquéllos cuya eficacia no depende del fallecimiento de los otorgantes (ej: los contratos). Producen efectos desde el día en que se celebran.

De última voluntad: son los que tienen eficacia después del fallecimiento de la persona de la cual emanan (ej: testamento). Producen sus efectos después de la muerte del otorgante.

3) **Positivos:** son aquellos en los cuales, para crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar derechos, es necesaria la realización de un acto (ej: pagar una suma de dinero, firmar un contrato, etc.).

Negativos: cuando para que los efectos se produzcan es necesario una omisión (ej: el cumplimiento de una obligación de no hacer, ya que para cumplir es necesario omitir la realización de algún hecho).

4) **Extrapatrimoniales:** los que no tienen contenido económico (ejs: en general, los actos relacionados al derecho de familia, como contraer matrimonio, divorciarse, ejercer la responsabilidad parental, adoptar, reconocer hijos, etc.).

Patrimoniales: los que tienen contenido económico (ejs: comprar, vender, alquilar, donar, etc.), y se subclasifican en: onerosos y gratuitos; de disposición y de administración.

5) **Onerosos:** cuando ambas partes se benefician, pues hay prestaciones recíprocas (ejs: compraventa, permuta, locación, etc.).

Gratuitos: sólo una de las partes se beneficia, pues la otra debe una prestación sin recibir nada a cambio (ejs: la donación, el legado, el comodato, etc.).

6) **De disposición:** son los que modifican sustancialmente el patrimonio, pues implican salida de bienes del mismo (ejs: venta, donación, etc.).

De administración: los que tienden a la explotación de los bienes del patrimonio, pero conservando la integridad del mismo (ejs: la locación o arrendamiento).

7) **Formales:** cuando la ley les exige una determinada forma como requisito de validez del acto (solemnes) o como requisito ad probationem (no solemnes).

No formales: cuando la ley no les impone ninguna formalidad y deja la forma librada a la elección de las partes.

8) **Principales:** son aquéllos que tienen existencia y validez propia, sin depender para ello de otros actos (ejs: contratos de locación, de compraventa, etc.).

Accesorios: son aquellos cuya existencia y validez dependen de la existencia y validez de otros actos, a los cuales acompañan (ejs: pacto comisorio, pacto de reventa y de retroventa, hipoteca, prenda, etc.).

9) **Actos puros y simples:** cuando la ejecución del acto no está sujeta a ninguna modalidad.

Actos modales: cuando la ejecución del acto está sujeta a alguna modalidad, como ser, la condición, el plazo o el cargo.

ACTO JURÍDICO

"El acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas." (conf. art. 259).

ELEMENTOS ESENCIALES: ▶ A) Sujetos del acto; B) Objeto del acto; D) Causa del acto D) Forma del acto;

A) SUJETOS ▶ Son las personas "otorgantes" del acto, o sea, aquellas de las cuales emana el acto. Deben ser capaces de ejercicio y además tener capacidad específica para realizar ese acto (capacidad de derecho).

B) OBJETO ▶ Es el hecho o el bien sobre el cual recae el acto jurídico.

- Si es un hecho, no debe ser → a) Imposible / b) Prohibido por la ley / c) Contrario a la moral, a las buenas costumbres o al orden público / d) Lesivo de los derechos ajenos / e) Lesivo de la dignidad humana.
- Si es un bien, no debe ser un bien que por un motivo especial se haya prohibido que sea objeto de un acto jurídico.

Objeto de los contratos → Debe ser lícito, posible, determinado o determinable, susceptible de valoración económica y corresponder a un interés de las partes. / Es "determinado" cuando al celebrar el acto se conoce con exactitud cual es el objeto. Es "determinable" cuando se puede determinar al momento de cumplir.

C) CAUSA ▶ Es el propósito o finalidad perseguida por las partes al llevar a cabo el acto (causa-fin).

• "Causa fin inmediata" → Es la finalidad abstracta que han tendido las partes al contratar y que en los contratos iguales es siempre la misma. La acepta el art. 281 al decir: "La causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad..."

• "Causa fin mediata" → Denominada también "motivos", son las razones particulares que ha tenido cada parte para obligarse. Integran la causa si han sido exteriorizados e incorporados al acto en forma expresa o tácita. También la acepta el art. 281 al establecer: "...También integran la causa los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa, o tácitamente si son esenciales para ambas partes".

Presunción de causa / Falsa causa ▶ Aunque la causa no esté expresada en el acto se presume que existe mientras no se pruebe lo contrario. El acto es válido aunque la causa expresada sea falsa si se funda en otra causa verdadera.

La causa en el acto abstracto ▶ La inexistencia, falsedad o ilicitud de la causa no son discutibles en el acto abstracto mientras no se haya cumplido, excepto que la ley lo autorice (art. 283).

En los títulos abstractos (ej: letra de cambio, pagaré, cheque) en principio la causa carece de relevancia y el deudor no puede discutir la causa alegando la inexistencia, falsedad o ilicitud de la misma, debe limitarse a cumplir. Luego de cumplir podrá en un juicio posterior probar la inexistencia, falsedad o ilicitud de la causa.

D) FORMA ▶ La forma es la manera o medio por el cual el sujeto manifiesta exteriormente su voluntad.

Libertad de formas ▶ Las partes pueden utilizar la forma que quieran (verbal, por escrito sea instrumento privado o público) salvo que la ley designe una forma determinada. Aún cuando la ley exija una forma determinada, las partes pueden convenir una forma más exigente que la impuesta por la ley (conf. art. 284).

Forma impuesta ▶ Si se omite la forma exigida por la ley, debemos diferenciar:

- Si la ley exige la forma bajo sanción de nulidad, el acto no será válido y carecerá de efectos ("Actos formales Absolutos").
- Si la forma no está exigida bajo sanción de nulidad, el acto no queda concluido hasta que se cumpla con la forma exigida, pero vale como acto en el que las partes se han obligado a cumplir con la formalidad exigida ("Actos formales Relativos").

Expresión escrita ▶ 1) **Instrumentos públicos:** son los otorgados con las formalidades que la ley establece en presencia de un oficial público. Están enumerados en el art. 289.

2) **Instrumentos particulares firmados (instrumentos privados):** son aquellos que las partes otorgan sin intervención de oficial público. Requisito fundamental: la firma de las partes.

3) **Instrumentos particulares no firmados:** es todo escrito no firmado, entre otros, los impresos, registros visuales o auditivos de cosas o hechos y los registros de la palabra y de información.

Firma

La firma de las partes es una condición esencial del documento. Consiste en el **nombre del firmante** escrito de una manera particular o en un **signo** (ej, iniciales, símbolos o garabatos) que la persona usa habitualmente para demostrar su voluntad o conformidad con el contenido del documento.

- La firma puesta en un instrumento privado prueba que es de la autoría de esa persona

Firma a ruego

Una de las partes pide, "ruega" a otra persona, que firme el documento por él, sea porque él no sabe, o porque no puede físicamente hacerlo.

Si bien la firma a ruego es válida en un instrumento público (interviene el oficial público), en un instrumento privado es discutible su validez.

Firma digital

Es el resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control.

¿"Firma Digital" y "Firma Electrónica" son lo mismo? No. La **diferencia fundamental** entre ambas está en el valor probatorio atribuido a cada una de ellas.

INSTRUMENTO PÚBLICO

Instrumento público es el instrumento otorgado con las formalidades que la ley establece en presencia de un oficial público (característica fundamental), a quien la ley confiere facultades para autorizarlo.

Requisitos de validez

1) Actuación del oficial público / 2) Que el oficial público tenga atribuciones / 3) Desinterés del oficial público en el acto / 4) Firmas de los intervinientes / 5) Que no tenga defectos de forma.

Enumeración legal

Art. 289

- a) Las escrituras públicas y sus copias o testimonios
- b) Los instrumentos que extienden los escribanos o los funcionarios públicos con los requisitos que establecen las leyes
- c) Los títulos emitidos por el Estado nacional, provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a las leyes que autorizan su emisión

Eficacia probatoria

Hay que distinguir:

- a) **Hechos cumplidos por el oficial público o que han pasado en su presencia.** Sobre estos hechos el instrumento público **hace plena fe** hasta que sea argüido de falso (conf. art. 296 inc. a).
- b) **Hechos declarados por las partes (o cláusulas dispositivas del instrumento).** Estos hechos hacen plena fe, pero la misma puede ser destruida simplemente mediante prueba en contrario (conf. art. 296 inc. b), no requiriéndose la querrela de falsedad.

La fuerza probatoria de los instrumentos públicos puede hacerse valer contra las partes, los sucesores de éstas, y también contra terceros.

Impugnación del contenido

Tanto los instrumentos privados como los instrumentos públicos, sirven de medio de prueba, pero hay **diferencias** con respecto a la fuerza probatoria de cada uno.

• Tratándose de un **instrumento privado**, la autenticidad del documento debe ser probada (prueba que, generalmente, se lleva a cabo mediante el reconocimiento de la firma de las partes).

• Tratándose de un **instrumento público**, éste prueba su autenticidad por sí mismo ("per se"). La ley presume que tanto el documento como su contenido son auténticos, ya que lo otorga un oficial público, agregando su firma y sello en el documento.

• **Incoluntad formal** → La plena fe y la seguridad que ofrece el instrumento público sería desvirtuada si los testigos o el oficial público que lo otorgó pudieran contradecir, variar o alterar su contenido. Por ello, la norma no admite que lo hagan, salvo que alegaran que testificaron u otorgaron el acto con su voluntad viciada por dolo o violencia.

• **Contradocumento** → "El contradocumento es una declaración de voluntad formulada por escrito por las partes de carácter generalmente secreto y destinada a probar que el acto ha sido simulado" (conf. Borda). Prueba que el acto contenido en el instrumento público es simulado y que hay oculto otro acto que es el realmente querido por las partes. El contradocumento es válido entre las partes, pero no se puede oponer a terceros de buena fe.

— ESCRITURA PÚBLICA —

La escritura pública es el instrumento matriz extendido en el protocolo de un escribano público o de otro funcionario autorizado para ejercer las mismas funciones, que contienen uno o más actos jurídicos. La copia o testimonio de las escrituras públicas que expiden los escribanos es instrumento público y hace plena fe como la escritura matriz. Si hay alguna variación entre ésta y la copia o testimonio, se debe estar al contenido de la escritura matriz (conf. art. 299).

- **Escritura matriz** → son las escrituras originales que el escribano extiende en el protocolo.
- **Copias** → son reproducciones de la escritura matriz.
- **Protocolo** → son "folios habilitados" (hojas de papel numeradas y selladas que expiden los colegios de escribanos) para el uso de cada registro notarial; la numeración es correlativa en cada año calendario.
- **Protocolización** → consiste en la incorporación de un instrumento al protocolo del escribano.

Requisitos de las escrituras públicas y deberes del notario → Arts. 301 a 308 (10 requisitos).

Nulidad de la escritura

Cuando no tengan la designación del tiempo y lugar en que sean hechas, el nombre de los otorgantes, la firma del escribano y de las partes, la firma a ruego de ellas cuando no saben o no pueden escribir y la firma de los dos testigos del acto cuando su presencia sea requerida.

ACTAS NOTARIALES

Las **actas** son documentos notariales que tienen por objeto la comprobación de hechos. Las actas están sujetas a los **requisitos de las escrituras públicas**, con algunas **modificaciones** → Art. 311.

INSTRUMENTOS PRIVADOS Y PARTICULARES

Instrumentos privados son aquellos instrumentos particulares que las partes otorgan sin que medie la intervención del oficial público. En estos instrumentos el **requisito fundamental** es la firma de las partes, porque ella prueba la autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde.

Firma

La firma consiste en el **nombre del firmante** escrito de una manera particular, y si se trata de un instrumento electrónico la firma digital equivale a la firma manuscrita de la persona.

Si la persona no sabe o no puede firmar, la solución es:

- a) que estampe su **impresión digital**; o
- b) que se pongan **2 testigos** que suscriban el documento.

Reconocimiento de la firma

Tratándose de un **documento privado**, su **autenticidad** debe ser probada → generalmente mediante el **reconocimiento de firma** de la parte a quien se atribuye → Ésta tiene la obligación de **manifestar si la firma le pertenece o no**.

- Si no lo hace, su silencio se interpreta como un reconocimiento.
- Si niega la firma, se deberá probar la autenticidad de la firma o comprobación del documento, "**por cualquier medio**". El medio más eficaz es el "**cotejo**".
- **Cotejo** → consiste en **comparar** la letra o firma del documento cuya autenticidad se niega, con la letra o firma de un documento indubitado (que no ofrezca dudas de su autenticidad). El cotejo es realizado por peritos calígrafos.

El instrumento privado **reconocido por el firmante, o declarado auténtico por sentencia, o cuya firma está certificada por escribano, no puede ser impugnado por quienes lo hayan reconocido.**

Documento firmado en blanco

Estos documentos, tras ser llenados por la otra parte, son válidos si la parte que los firmó en blanco **reconoce su firma y está de acuerdo** con el contenido dado al documento.

El firmante en blanco puede oponerse al contenido del documento en los siguientes casos:

- a) Si considera que se ha **abusado** de su firma en blanco.
- b) Si el documento fue **sustraído** a la persona a la cual se le dió, y hubiese sido llenado por un tercero.

Fecha cierta

Es aquella fecha que se pueda considerar verídica, auténtica, porque ella da certeza de que el instrumento privado ya estaba firmado al momento de su producción, o que no pudo ser firmado después de su acaecimiento (conf. Rivera).

¿Por qué se exige? Para evitar que las partes simulen actos poniendo fechas falsas para perjudicar a terceros.

¿El documento privado sin fecha cierta es válido? Si, pero frente a terceros no tendrá valor probatorio.

¿Cómo se adquiere la fecha cierta? Se permite probar por cualquier medio ese hecho que da certeza de que el documento no pudo ser firmado después.

Requisito del "doble ejemplar" → Se ha eliminado en el nuevo Código.

CONTABILIDAD Y ESTADOS CONTABLES

Regulación normativa: → Sección 7ª del nuevo Código (arts. 320 a 331). → **Contenidos básicos** → 11.

Concepto. La contabilidad es una técnica para dejar registradas las actividades económicas o financieras de una persona. Permite saber los ingresos, los gastos y sus repercusiones (ganancias o pérdidas) sobre el patrimonio, lo cual se manifiesta en los *estados contables* o *financieros* que resumen la situación económica. Permite obtener información de gran utilidad para la toma de decisiones.

Obligados a llevar contabilidad

- 1) Las personas jurídicas privada.
- 2) Las personas humanas, si realizan una actividad económica organizada o son titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios.

Eximidos de llevar contabilidad

- 1) Las personas humanas que desarrollan profesiones liberales o actividades agropecuarias o conexas a ellas, siempre que no estén organizadas en forma de empresa o sociedad.
- 2) Pueden ser eximidas las personas que realicen actividades de escaso volumen.

Modo de llevar la contabilidad

La contabilidad debe llevarse sobre una base uniforme (principios contables que se mantengan de un período contable a otro). De ella debe surgir un cuadro verídico de la situación patrimonial de la persona. Se complementa con la documentación respectiva que respalde los asientos contables.

- Registros indispensables**
- **Diario.** En este libro se deben registrar todas las operaciones relativas a la actividad de la persona y que influyen en su patrimonio.
 - **Inventario y balances.** Es un solo libro que contiene el inventario donde se detalla el dinero, bienes, derechos, etc., que conforman el capital de la persona o empresa al comenzar su actividad.
 - **Libros exigidos por la importancia y la naturaleza de las actividades a desarrollar y libros que en forma especial impone el Código u otras leyes.**
 - **Libros auxiliares.** Son aquellos libros complementarios de los libros *Diario* y de *Inventario y Balances* (ej: libro de Caja, libro de Bancos, libro de Vencimientos, etc).

Formalidades

- El interesado en llevar su contabilidad debe llevar sus libros debidamente encuadernados y foliados al Registro Público correspondiente para que se los rubriquen o individualicen.
- Las operaciones asentadas deben hacerse en orden cronológico y actualizado, sin alteración alguna que no haya sido salvada. Debe utilizarse el idioma y la moneda nacional. Los libros deben permanecer en el domicilio de su titular.

Prohibiciones

- a) alterar el orden en que los asientos deben ser hechos;
- b) dejar blancos que puedan utilizarse para intercalaciones o adiciones entre los asientos;
- c) interlinear, raspar, enmendar o tachar;
- d) mutilar parte alguna del libro, arrancar hojas o alterar la encuadernación o foliatura;
- e) cualquier otra circunstancia que afecte la inalterabilidad de las registraciones.

Conf.
Art. 324

Conservación

- Los libros y el resto de la documentación contable deben conservarse por 10 años, salvo que leyes especiales fijen un plazo más largo (conf. art. 328).

Actos sujetos a autorización

- El nuevo Código permite:
 - a) Reemplazar los libros contables (salvo el de *Inventario y Balances*) por otros medios.
 - b) Conservar la documentación en microfilm, discos ópticos u otros medios aptos para ese fin.
- Pero previamente se debe pedir autorización al Registro Público.

CLASIFICACIÓN DE LOS ACTOS JURÍDICOS

1) unilaterales / bilaterales	4) extrapatrimoniales / patrimoniales	7) formales / no formales
2) entre vivos / de última voluntad	5) onerosos / gratuitos	8) principales / accesorios
3) positivos / negativos	6) de disposición / de administración	9) actos puros y simples / modales

CAPÍTULO XIX VICIOS DE LOS ACTOS JURÍDICOS

LESIÓN (o "Explotación").-

Concepto.-

La lesión consiste en que una de las partes, explotando la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la otra, obtuviera, por medio de ello, una ventaja patrimonial desproporcionada y sin justificación.

Esta causa de nulidad fue introducida por la Ley 17.711, en el art. 954 del Código Civil de Vélez.

El nuevo Código Civil y Comercial trata a la *lesión* (art. 332) como un vicio de los actos jurídicos que afecta la buena fe. En general se mantiene el texto del art. 954 del Código de Vélez.

Art. 332.- "Lesión. Puede demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes explotando la necesidad, debilidad síquica o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación.

Se presume, excepto prueba en contrario, que existe tal explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones.

Los cálculos deben hacerse según valores al tiempo del acto y la desproporción debe subsistir en el momento de la demanda.

El afectado tiene opción para demandar la nulidad o un reajuste equitativo del convenio, pero la primera de estas acciones se debe transformar en acción de reajuste si éste es ofrecido por el demandado al contestar la demanda.

Sólo el lesionado o sus herederos pueden ejercer la acción."

Requisitos fundamentales.-

Los requisitos fundamentales para que exista "lesión" son dos:

a) **La desproporción** (elemento objetivo): debe existir una ventaja patrimonial desproporcionada, en provecho de una de las partes.

Se presume, excepto prueba en contrario, que existe tal explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones.

Los cálculos deben hacerse según valores al tiempo del acto y la desproporción debe subsistir en el momento de la demanda.

b) **La explotación** (elemento subjetivo): debe existir un estado de necesidad, debilidad síquica o inexperiencia de la parte que sufre el perjuicio. Quien alegue haber sido víctima del vicio de lesión, deberá probar que obró en tal estado, y que la otra

parte aprovechó en favor propio, esa necesidad, debilidad síquica o inexperiencia. Sin embargo, dicha prueba no se requiere cuando la desproporción fuese notable.

Efectos del vicio.-

Los efectos que produce la existencia del vicio de lesión, están establecidos en el último párrafo del art. 332, y son los siguientes, a opción del demandante:

- 1) nulidad del acto viciado;
- 2) reajuste equitativo.

Si se pidió la nulidad, la contraparte puede evitarla ofreciendo un reajuste al contestar la demanda, en cuyo caso la acción pasa a ser de reajuste. Sólo el lesionado o sus herederos pueden ejercer la acción.

SIMULACIÓN

Concepto.-

La simulación es un vicio exclusivo de los actos jurídicos, y su característica es la de viciar la buena fe de terceros. En términos generales, "simular" es ocultar la verdad. La definición de "simulación" la encontramos en el art. 333 del nuevo Código Civil y Comercial:

Art. 333.- "Caracterización. La simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, o fechas que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas, que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o transmiten."

Ejemplo de simulación: el Sr. "A" simula vender su casa al Sr. "B", pero en realidad no la vende, sino que la está donando. En este caso, se simuló una venta para ocultar una donación. Otro caso: Luis tiene muchos acreedores, y para que éstos no le ejecuten los bienes, simula que los vende a Juan.

Supuestos de simulación.-

El Código nos da una definición general, de carácter descriptivo, acerca de la simulación, en el art. 333. Este artículo establece que habrá "simulación" en los siguientes supuestos:

- 1) *cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro* (ej: se encubre una donación, simulando que es una venta); o
- 2) *cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras* (ej: cláusulas en las cuales el precio por el cual se transmite la cosa, es inferior o superior al verdadero precio de venta); o
- 3) *cuando el acto contiene fechas que no son verdaderas* (ej: si al acto se le pone una fecha anterior o posterior a la verdadera fecha de la celebración); o

4) *cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas, que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o transmiten* (ej: quiero donar mis bienes a Luis, pero como no quiero que nadie se entere, simulo donarlos a Aníbal, quien por un contradocumento, se obliga a transmitirlos a Luis).

Clases de simulación.-

La simulación puede ser *absoluta* o *relativa*; y desde otro punto de vista, *lícita* o *ilícita*.

- **Absoluta:** cuando se celebra un acto que nada tiene de real (ej: tengo muchos acreedores y simulo vender mi casa a un amigo para que no la ejecuten).
- **Relativa:** cuando se emplea para dar a un acto jurídico una apariencia que oculta su verdadero carácter (ej: quiero donar mi estancia a una amiga, pero para evitar una revocación, simulo vendérsela).
- **Lícita:** cuando la simulación no es reprobada por la ley, a nadie perjudica ni tiene un fin ilícito.
- **Ilícita:** cuando la simulación perjudica a terceros o tiene un fin ilícito (es decir, cuando se hace para violar las leyes). Provoca la nulidad del acto ostensible. Si el acto simulado encubre otro real, éste es plenamente eficaz si concurren los requisitos propios de su categoría y no es ilícito ni perjudica a un tercero (conf. art. 334)

ACCIÓN DE SIMULACIÓN.-

Concepto.-

Cuando hay un acto jurídico simulado, la ley concede la "acción de simulación" a efectos de lograr que judicialmente se declare que el acto no existió (*simulación absoluta*) o que sólo existió un acto oculto (*simulación relativa*).

La acción de simulación se concede a las partes del acto simulado, y a los terceros interesados en el acto, como los acreedores de cualquier clase, herederos, legatarios, etc. Los terceros afectados por el acto simulado pueden demandar su nulidad y pueden acreditar la simulación por cualquier medio de prueba.

El "contradocumento".-

La simulación alegada por las partes debe probarse mediante el respectivo contradocumento.

El *contradocumento* es una declaración de voluntad formulada por escrito por las partes de carácter generalmente secreto y destinada a probar que el acto ha sido simulado (conf. Borda). Prueba que el acto contenido en el instrumento público es simulado y que hay oculto otro acto que es el realmente querido por las partes. El contradocumento es válido entre las partes, pero no se puede oponer a terceros de buena fe.

Puede prescindirse del contradocumento, cuando la parte justifica las razones por las cuales no existe o no puede ser presentado y median circunstancias que hacen inequívoca la simulación.

Ejercicio de la acción.-

Debemos diferenciar si la acción de simulación es ejercida por alguna de las partes, o por terceros:

a) Ejercida por las partes:

- Cuando la simulación es lícita, cualquiera de las partes puede ejercer la acción de simulación contra la otra.
- Cuando la simulación es ilícita, en principio no pueden ejercer acción el uno contra el otro sobre la simulación. Excepción: podrán ejercerla cuando no puedan obtener beneficio alguno de las resultas del ejercicio de la acción.

El efecto de la acción es que el juez declarará la anulación del acto simulado.

b) Ejercida por terceros:

La acción de simulación también pueden ejercerla aquéllos que no sean parte en el acto simulado; o sea, los acreedores o cualquier tercero interesado, con tal que hayan sufrido perjuicios a raíz del acto (art. 336).

- Los terceros podrán ejercer la acción, sólo en el caso de que el acto simulado les perjudique; en otras palabras: sólo cuando la simulación sea ilícita.
- Por el contrario, tratándose de una simulación lícita, los terceros no podrán intentar la acción, dado que la simulación lícita no perjudica a terceros, y que en nuestro ordenamiento jurídico rige el principio de que *"a falta de interés o perjuicio, no hay acción"*.

Efectos frente a terceros. Indemnización.-

El art. 337 del nuevo Código Civil y Comercial se refiere a los efectos de la simulación frente a terceros, y contempla diversos casos.

Art. 337.- "Efectos frente a terceros. Deber de indemnizar. La simulación no puede oponerse a los acreedores del adquirente simulado que de buena fe hayan ejecutado los bienes comprendidos en el acto.

La acción del acreedor contra el subadquirente de los derechos obtenidos por el acto impugnado sólo procede si adquirió por título gratuito, o si es cómplice en la simulación. El subadquirente de mala fe y quien contrató de mala fe con el deudor responden solidariamente por los daños causados al acreedor que ejerció la acción, si los derechos se transmitieron a un adquirente de buena fe y a título oneroso, o de otro modo se perdieron para el acreedor. El que contrató de buena fe y a título gratuito con el deudor, responde en la medida de su enriquecimiento."

- En el primer caso, los acreedores del adquirente simulado han ejecutado el bien objeto de la simulación. A ellos, si son de buena fe, no se les puede oponer la simulación.

• En el segundo caso, el adquirente simulado ha transmitido el bien objeto de la simulación a otra persona (subadquirente). Al subadquirente, si es de buena fe y a título oneroso, no se le puede oponer la simulación (es decir que los acreedores no pueden accionar contra él). Pero sí se le puede oponer, y se podrá accionar contra él, si adquirió a título gratuito o es cómplice en la simulación.

• **Indemnización.-** Además, el subadquirente de mala fe y quien contrató de mala fe con el deudor responden solidariamente por los daños causados al acreedor que ejerció la acción, si los bienes o derechos transmitidos por alguna razón no se pueden recuperar.

Pero el que contrató de buena fe y a título gratuito con el deudor, sólo responde en la medida de su enriquecimiento.

FRAUDE

Concepto.-

La denominación *"Fraude"* es comprensiva del *"fraude a la ley"* que el nuevo Código Civil y Comercial contempla en el art. 12, y del *"fraude a los acreedores"* que, como un vicio de los actos jurídicos, el Código regula a través de los arts. 338 a 342 y que trataremos ahora.

Hay *fraude a los acreedores* cuando un deudor enajena o grava sus bienes, con el propósito de sustraerlos de su patrimonio, provocando o agravando su insolvencia, y evitando así el pago a sus acreedores, o cuando omite ejercer derechos que podrían haber mejorado su patrimonio o evitado que este empeorara.

Ejemplo: "A" tiene muchos acreedores, y éstos, para cobrar, van a rematarle su casa; entonces "A", en fraude a sus acreedores, vende la casa para que éstos no puedan cobrar.

ACCIÓN DE INOPONIBILIDAD.-

Concepto.-

En el Código de Vélez, la solución contra el fraude era la acción revocatoria prevista en el art. 961 (también llamada "acción de fraude" o "acción pauliana"), para hacer revocar (anular) los actos fraudulentos de deudor.

El nuevo Código Civil y Comercial, en general, sigue los lineamientos del Código anterior, pero le cambia la denominación, llamándola *"acción de inoponibilidad"*, porque en rigor de verdad la acción del acreedor no causa la nulidad del acto impugnado (el cual es válido y real) sino que lo hace inoponible a los acreedores.

Legitimación.-

¿Quien puede promover la acción? Todo acreedor puede promover la acción de inoponibilidad (conf. art. 338).

En el Código de Vélez se concedía solo a los "acreedores quirografarios" y no se hacía mención de los acreedores hipotecarios y privilegiados, debido a que éstos estaban protegidos por el derecho real de hipoteca o por el privilegio.

Con el nuevo Código Civil y Comercial, quedan legitimados todos los acreedores, incluso los hipotecarios y privilegiados, porque éstos también pueden llegar a sufrir perjuicios a raíz del acto fraudulento.

Art. 338.- "Declaración de inoponibilidad. Todo acreedor puede solicitar la declaración de inoponibilidad de los actos celebrados por su deudor en fraude de sus derechos, y de las renunciaciones al ejercicio de derechos o facultades con los que hubiese podido mejorar o evitado empeorar su estado de fortuna."

Requisitos de procedencia.-

De acuerdo al art. 339, son requisitos de procedencia de la acción de declaración de inoponibilidad los siguientes:

1) *Que el crédito sea de causa anterior al acto impugnado*, excepto que el deudor haya actuado con el propósito de defraudar a futuros acreedores.

El crédito por el cual se intenta la acción debe ser de fecha anterior al acto impugnado, porque si fuese posterior a la enajenación no le estaría causando perjuicio, salvo que el deudor dolosamente haya realizado los actos fraudulentos anticipadamente con el propósito de defraudar a futuros acreedores.

2) *Que el acto haya causado o agravado la insolvencia del deudor.*

Por insolvencia debe entenderse desequilibrio patrimonial, o sea, falta de bienes para cubrir las deudas existentes.

3) *Que quien contrató con el deudor a título oneroso haya conocido o debido conocer que el acto provocaba o agravaba la insolvencia.*

Se requiere la complicidad, dolosa o culposa, del que contrató a título oneroso, (ej: una compra) con el deudor.

Efectos frente a terceros. Indemnización.-

El art. 340 del nuevo Código Civil y Comercial se refiere a los efectos del fraude frente a terceros, y contempla diversos casos (similares a los del art. 337 referido a la simulación).

Art. 340.- "Efectos frente a terceros. Deber de indemnizar. El fraude no puede oponerse a los acreedores del adquirente que de buena fe hayan ejecutado los bienes comprendidos en el acto."

La acción del acreedor contra el subadquirente de los derechos obtenidos por el acto impugnado sólo procede si adquirió por título gratuito, o si es cómplice en el fraude; la complicidad se presume si, al momento de contratar, conocía el estado de insolvencia. El subadquirente de mala fe y quien contrató de mala fe con el deudor responden solidariamente por los daños causados al acreedor que ejerció la acción, si los derechos se transmitieron a un adquirente de buena fe y a título oneroso, o de otro modo se perdieron

para el acreedor. El que contrató de buena fe y a título gratuito con el deudor, responde en la medida de su enriquecimiento."

- En el primer caso, los acreedores del adquirente han ejecutado el bien objeto del fraude. A ellos, si son de buena fe, no se les puede oponer el fraude.

- En el segundo caso, el adquirente ha transmitido el bien objeto del fraude a otra persona (subadquirente). Al subadquirente, si es de buena fe y a título oneroso, no se le puede oponer el fraude (es decir que los acreedores no pueden accionar contra él). Pero sí se le puede oponer, y se podrá accionar contra él, si adquirió a título gratuito o es cómplice en el fraude. La complicidad del subadquirente se presume si, al momento de contratar (para adquirir el bien objeto del fraude), conocía la insolvencia del deudor.

- **Indemnización.-** Además, el subadquirente de mala fe y quien contrató de mala fe con el deudor responden solidariamente por los daños causados al acreedor que ejerció la acción, si los bienes o derechos transmitidos por alguna razón no se pueden recuperar.

Pero el que contrató de buena fe y a título gratuito con el deudor, sólo responde en la medida de su enriquecimiento.

Extinción de la acción.-

De acuerdo al art. 341, la acción de los acreedores cesa si el adquirente de los bienes transmitidos por el deudor los desinteresa (es decir si el adquirente paga el crédito) o da garantía suficiente al acreedor que promovió la acción.

Extensión de la inoponibilidad.-

La declaración de inoponibilidad sólo beneficia a los acreedores que la pidieron y hasta el importe de sus respectivos créditos (conf. art. 342).

VICIOS DE LOS ACTOS JURÍDICOS

LESIÓN

Consiste en que una de las partes, explotando la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la otra, obtuviera, por medio de ello, una ventaja patrimonial desproporcionada y sin justificación.

Requisitos fundamentales

- La **desproporción** (elemento objetivo): debe existir una ventaja patrimonial desproporcionada, en provecho de una de las partes.
- La **explotación** (elemento subjetivo): debe existir un estado de necesidad, debilidad síquica o inexperiencia de la parte que sufre el perjuicio.

Efectos del vicio

Están establecidos en el último párrafo del art. 332, y son los siguientes, a opción del demandante: 1) nulidad del acto viciado; 2) reajuste equitativo.

SIMULACIÓN

La simulación es un vicio exclusivo de los actos jurídicos, y su característica es la de viciar la buena fe de terceros. "Simular" es ocultar la verdad. / • Definición → Art. 333.

Supuestos

- cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro.
- cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras.
- cuando el acto contiene fechas que no son verdaderas.
- cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas, que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o transmiten.

Clases

- **Absoluta** → Cuando se celebra un acto que nada tiene de real.
- **Relativa** → Cuando se emplea para dar a un acto jurídico una apariencia que oculta su verdadero carácter.
- **Lícita** → Cuando no es reprobada por la ley, a nadie perjudica ni tiene un fin ilícito.
- **Ilícita** → Cuando perjudica a terceros o tiene un fin ilícito.

Acción de Simulación

La ley concede esta acción a efectos de lograr que judicialmente se declare que el acto no existió (*simulación absoluta*) o que sólo existió un acto oculto (*simulación relativa*).

- **Contradocumento** → La simulación alegada por las partes debe probarse con el respectivo contradocumento.
- **Ejercicio de la acción**
 - Ejercida por las partes** → • Simulación lícita, cualquiera de las partes puede ejercer la acción contra la otra. / • Simulación ilícita, en principio no pueden ejercer la acción el uno contra el otro.
 - Ejercida por terceros (acreedores o cualquier tercero interesado)**: sólo podrán ejercer la acción cuando el acto simulado los perjudique (simulación ilícita).
- **Efectos frente a terceros. Indemnización** → Art. 337.

FRAUDE

Hay **fraude a los acreedores** cuando un deudor enajena o grava sus bienes, con el propósito de sustraerlos de su patrimonio, provocando o agravando su insolvencia, y evitando así el pago a sus acreedores, o cuando omite ejercer derechos que podrían haber mejorado su patrimonio o evitado que este empeorara.

Acción de Inoponibilidad

→ **Legitimación** → ¿Quién puede promover la acción? Todo acreedor, incluso los hipotecarios y privilegiados.

Requisitos de procedencia

- Que el crédito sea de causa anterior al acto impugnado, excepto que el deudor haya actuado con el propósito de defraudar a futuros acreedores.
- Que el acto haya causado o agravado la insolvencia del deudor.
- Que quien contrató con el deudor a título oneroso haya conocido o debido conocer que el acto provocaba o agravaba la insolvencia.

- **Efectos frente a terceros. Indemnización** → Art. 340.
- **Extinción de la acción** → La acción cesa si el adquirente de los bienes transmitidos por el deudor los desinteresa (es decir si el adquirente paga el crédito) o da garantía suficiente al acreedor que promovió la acción.
- **Extensión de la inoponibilidad** → La declaración de inoponibilidad sólo beneficia a los acreedores que la pidieron y hasta el importe de sus respectivos créditos (conf. art. 342).

CAPÍTULO XX MODALIDADES DE LOS ACTOS JURÍDICOS

Concepto.-

Las **modalidades** son cláusulas accesorias que acompañan al acto jurídico y que alteran o modifican sus efectos. Los tipos de modalidades reguladas son: la condición, el plazo y el cargo.

• El Código Civil de Vélez las trataba en la parte de las Obligaciones en general. La doctrina criticaba esta ubicación porque las modalidades no se aplican sólo a las obligaciones sino a los actos jurídicos que crean esas obligaciones.

• El nuevo Código Civil y Comercial, aceptando esas críticas, ubica a las modalidades correctamente en el Título IV dedicado a "*Hechos y Actos Jurídicos*".

CONDICIÓN

Concepto.-

Se denomina condición a la cláusula de los actos jurídicos por la cual las partes subordinan su plena eficacia o resolución a un hecho futuro e incierto (conf. art. 343).

Se subordina la plena eficacia o resolución del acto jurídico a la producción de un hecho futuro e incierto. El hecho es **futuro** en el tiempo, e **incierto** en el sentido de que puede o no suceder.

Ejemplo: te donaré mi auto cuando te recibas de abogado.

Art. 343.- "Alcance y especies. Se denomina condición a la cláusula de los actos jurídicos por la cual las partes subordinan su plena eficacia o resolución a un hecho futuro e incierto.

Las disposiciones de este capítulo son aplicables, en cuanto fueran compatibles, a la cláusula por la cual las partes sujetan la adquisición o extinción de un derecho a hechos presentes o pasados ignorados."

Especies de condición.-

En el Código de Vélez lo que quedaba subordinado a la condición era la *adquisición o pérdida de un derecho*.

En el nuevo Código Civil y Comercial lo que queda subordinado a la condición es la **eficacia plena** o la **resolución del acto jurídico**. De manera que, por efecto de la condición, celebrado un acto jurídico sus efectos comenzarán a producirse si ocurre el hecho futuro e incierto; o a la inversa sus efectos se extinguirán si ocurre el hecho futuro e incierto. Esto nos permite distinguir entre:

a) **Condición suspensiva:** cuando la plena eficacia de un acto jurídico depende de que la condición se produzca (ej: te regalaré mi auto cuanto te recibas de abogado). La adquisición del derecho está en suspenso.

b) **Condición resolutoria:** cuando la resolución del acto jurídico depende de que la condición se produzca (ej: te doy mi auto, pero me lo devuelves si la nafta baja un 50%). El acto jurídico es válido y produce efectos, pero deja de producirlos si se da el hecho condicional.

En la condición suspensiva los efectos se producen a partir de que la condición se cumple. En la condición resolutoria los efectos se producen desde el comienzo del acto, pero cesan al cumplirse la condición.

Debe tenerse presente la distinción entre la "**condición**" (cláusula que implica una modalidad del acto jurídico) del "**hecho condicional**" que es el acontecimiento (ej: recibirse de abogado) del cual depende que el acto produzca sus efectos o deje de producirlos.

El "hecho condicional" debe ser futuro e incierto y además no estar comprendido en el art. 344 que se refiere a condiciones prohibidas.

Condiciones prohibidas.-

Las "condiciones prohibidas" causan la nulidad del acto jurídico.

Art. 344.- "Condiciones prohibidas. Es nulo el acto sujeto a un hecho imposible, contrario a la moral y a las buenas costumbres, prohibido por el ordenamiento jurídico o que depende exclusivamente de la voluntad del obligado.

La condición de no hacer una cosa imposible no perjudica la validez de la obligación, si ella fuera pactada bajo modalidad suspensiva.

Se tienen por no escritas las condiciones que afecten de modo grave las libertades de la persona, como la de elegir domicilio o religión, o decidir sobre su estado civil."

Si bien el título del artículo es "condiciones prohibidas", en realidad se refiere a aquellas condiciones que, de ser impuestas al acto jurídico, lo toman nulo. Por lo tanto, el acto será nulo cuando esté sujeto a alguno de los siguientes "hechos condicionales":

1) **Hecho imposible.-** La imposibilidad puede ser física (ej: tocar el cielo con las manos) o jurídica (ej: venta de una cosa fuera del comercio).

La condición de no hacer una cosa imposible no perjudica la validez del acto, si ella fuera pactada bajo modalidad suspensiva (ej: te daré mi auto si no tocas el cielo con las manos).

2) **Hecho contrario a la moral y a las buenas costumbres** (ej: que concurra desnudo al cine).

3) **Hecho prohibido por el ordenamiento jurídico** (ej: te daré 1000 pesos si cometes delitos).

4) **Hecho que dependa exclusivamente de la voluntad del obligado** (ej: te daré mi auto si quiero).

5) **Hecho que afecte de modo grave las libertades de la persona** (ej: que cambie de religión, que nunca se case, etc.).

Condición impropia o suposición.-

Art. 343 (segundo párrafo).- Alcance y especies. "...Las disposiciones de este capítulo son aplicables, en cuanto fueran compatibles, a la cláusula por la cual las partes sujetan la adquisición o extinción de un derecho a hechos presentes o pasados ignorados."

El segundo párrafo del art. 343 introduce una especie distinta de **condición**, ya que, en este caso, el hecho condicional si bien es incierto no es futuro, pues las partes sujetan la adquisición o extinción de un derecho a un **hecho presente o pasado ignorado**, o sea, a un hecho que está ocurriendo o que ya ocurrió.

Ejemplo: compro un auto y subordino la adquisición al hecho de que la numeración de motor y chasis sea la original.

Inejecución de la condición.-

La parte que dolosamente impidió que la condición se cumpla, no puede alegar que la condición no se cumplió. Se sanciona la mala fe de quien impidió que se cumpliera y se debe tener por cumplida la condición.

Art. 345.- "Inejecución de la condición. El incumplimiento de la condición no puede ser invocado por la parte que, de mala fe, impide su realización."

Efecto.-

Art. 346.- "Efecto. La condición no opera retroactivamente, excepto pacto en contrario."

Se cambió el criterio seguido en el Código Civil de Vélez (art. 553), que era el de la retroactividad.

En el nuevo Código Civil y Comercial (art. 346) se establece que la condición **no opera retroactivamente**, salvo que las partes pacten lo contrario. Es decir que en principio la condición no tiene efecto retroactivo, pero las partes pueden pactar que sí lo tenga (conf. arts. 346 y 348).

Si se hubiese pactado el efecto retroactivo de la condición (suspensiva), el cumplimiento de ésta obliga a la entrega recíproca de lo que a las partes les habría correspondido al tiempo de la celebración del acto. No obstante, subsisten los actos de administración, y los frutos quedan a favor de la parte que los ha percibido (conf. art. 348).

Condición pendiente.-

Estando pendiente la condición (es decir, mientras ésta no se haya cumplido), el criterio es permitir a las partes tomar medidas de conservación de sus derechos (conf. art. 347).

• Si está pendiente la **condición suspensiva**, el titular del derecho puede adoptar medidas de conservación que protejan sus derechos.

• Si está pendiente la *condición resolutoria*, el titular del derecho puede ejercerlo, pero la otra parte puede solicitar, también, medidas conservatorias.

• En todo supuesto, mientras la condición no se haya cumplido, la parte que constituyó o transmitió un derecho debe comportarse de acuerdo con la buena fe, de modo de no perjudicar a la contraparte (conf. art. 347).

Cumplimiento de la condición suspensiva o resolutoria.-

De acuerdo al art. 348, el cumplimiento de la condición obliga a las partes a entregarse o restituirse, recíprocamente, las prestaciones convenidas, aplicándose los efectos correspondientes a la naturaleza del acto concertado, a sus fines y objeto.

Si las partes hubieran pactado el efecto retroactivo de la condición (conf. art. 346), el cumplimiento de ésta obliga a la entrega recíproca de lo que a las partes habría correspondido al tiempo de la celebración del acto. Sin embargo, subsisten los actos de administración, y los frutos quedan a favor de la parte que los ha percibido.

No cumplimiento de la condición suspensiva.-

Si el acto celebrado bajo condición suspensiva se hubiese ejecutado antes del cumplimiento de la condición, y ésta no se cumple, debe restituirse el objeto con sus accesorios, pero no los frutos percibidos (conf. art. 349).

PLAZO

Concepto.-

El *plazo* es la cláusula por la cual se subordina la exigibilidad o la extinción de un acto a la producción de un *hecho futuro y cierto*.

Ejemplos: pagaré \$ 1.000 dentro de 90 días; pagaré \$ 1.000 el 5 de julio; pagaré \$ 1.000 a la muerte de Pedro.

En la práctica, se habla de "*plazo*" para referirse al período que se debe esperar para que nazca o se extinga el derecho (ej: 10 días, un mes, etc.); y de "*término*" para referirse al momento en que finaliza el plazo (ej: el 5 de julio).

Diferencia con la condición.-

¿Qué diferencia fundamentalmente al plazo de la condición? En la condición el hecho es incierto, puede o no suceder. En el plazo, el hecho es cierto en el sentido de que ocurrirá necesaria o fatalmente.

Ejemplo: no hay dudas de que el 5 de julio llegará, o de que la muerte de Pedro se producirá.

Clases de plazo.-

El plazo puede clasificarse en:

1) *Suspensivo* (plazo inicial): posterga hasta su vencimiento la exigibilidad de un derecho (ej: te cobraré \$ 1000 el 5 de julio); o

Resolutorio (plazo final): a su vencimiento se extingue el derecho (ej: te cobraré \$ 100 diarios hasta el 5 de julio).

2) *Cierto*: se sabe cuando vencerá (ej: 5 de julio); o

Incierto: se sabe que ocurrirá, pero no se sabe exactamente cuando (ej: cuando muera Pedro).

3) *Esencial*: cuando el tiempo en que debe ser cumplida la obligación fue determinante para que se contrajera la misma; o

Accidental: cuando no ha sido determinante para que se contrajera la obligación.

4) *Expreso*: está expresamente convenido en la obligación; o

Tácito: no está expresamente convenido, pero resulta de la naturaleza y circunstancias de la obligación.

5) *Legal*: lo fija la ley; o

Judicial: lo fija el juez; o

Convencional: lo fijan las partes.

Beneficiario del plazo.-

¿A quién favorece el plazo? La respuesta la da el art. 351:

Art. 351.- "*Beneficiario del plazo. El plazo se presume establecido en beneficio del obligado a cumplir o a restituir a su vencimiento, a no ser que, por la naturaleza del acto, o por otras circunstancias, resulte que ha sido previsto a favor del acreedor o de ambas partes.*"

A diferencia del Código Civil de Vélez, en el cual el plazo se presumía a favor de a ambas partes (art. 570), en el nuevo Código Civil y Comercial el plazo se presume a favor del deudor, salvo que por alguna circunstancia (ej: por la naturaleza del acto o porque lo acordaron las partes, etc) resulte que ha sido previsto a favor del acreedor o de ambas partes.

Estando el plazo a favor del deudor, éste podrá pagar antes del vencimiento del plazo y el acreedor no podrá negarse a aceptarlo. Asimismo, el acreedor no podrá exigir el pago antes del vencimiento.

Pero acá hay que tener presente que, de acuerdo al art. 352, "el obligado que cumple o restituye antes del plazo no puede repetir lo pagado" (*pago anticipado*).

Efectos.-

¿Desde cuándo produce efectos? La regla general, en el plazo, es que sus efectos se producen a partir de su vencimiento ("*ex nunc*"). Pero, por excepción, no es necesario esperar al cumplimiento del plazo para cobrar al deudor en los casos de caducidad del plazo.

Caducidad del plazo.-

El art. 353 enumera (no taxativamente) casos en que el plazo caduca y el acreedor puede exigir lo que se le debe aunque dicho plazo no haya transcurrido. Tales casos son:

a) *Si el deudor es declarado en quiebra.* Se trata de la declaración de judicial de quiebra y no de un simple estado de insolvencia ni de la apertura de su concurso.

La norma aclara que la apertura del concurso del obligado al pago no hace caducar el plazo, pero el acreedor tiene derecho a verificar su crédito, y a todas las consecuencias previstas en la legislación concursal.

b) *Si el deudor disminuye por acto propio las seguridades otorgadas al acreedor para el cumplimiento de la obligación.* Ej: vendió la cosa dada en prenda y no la sustituyó por otra.

c) *Si no ha constituido las garantías prometidas.* Ej: no presentó fiador, no contrató un seguro, etc.

d) *Otros supuestos relevantes.* Queda comprendida cualquier otra causa que perjudique los derechos del acreedor y que sea lo suficientemente importante para hacer caducar el plazo. La cuestión debe ser resuelta judicialmente.

Art. 353.- "Caducidad del plazo. El obligado a cumplir no puede invocar la pendency del plazo si se ha declarado su quiebra, si disminuye por acto propio las seguridades otorgadas al acreedor para el cumplimiento de la obligación, o si no ha constituido las garantías prometidas, entre otros supuestos relevantes.

La apertura del concurso del obligado al pago no hace caducar el plazo, sin perjuicio del derecho del acreedor a verificar su crédito, y a todas las consecuencias previstas en la legislación concursal."

Cómputo del plazo.-

¿Cómo se computa el plazo? Conforme al art. 6 del nuevo Código Civil y Comercial.

Remitimos al Capítulo III de esta obra, en el punto *"Modo de contar los intervalos del derecho"*.

CARGO**Concepto.-**

El *cargo* (también denominado "carga" o "modo") es una obligación accesoria y de carácter excepcional que se impone al adquirente de un derecho.

Ejemplos: Vendo un caballo de raza, y le impongo al comprador el cargo de que me lo preste una vez por mes. Dejo toda mi fortuna a alguien, pero le impongo el cargo de construir una capilla con mi nombre. En un legado se impone al legatario el cargo de alimentar a los parientes del testador, etc.

Art. 354.- "Cargo. Especies. Presunción. El cargo es una obligación accesoria impuesta al adquirente de un derecho. No impide los efectos del acto, excepto que su cumplimiento se haya previsto como condición suspensiva, ni los resuelve, excepto que su cumplimiento se haya previsto como condición resolutoria. En caso de duda, se entiende que tal condición no existe."

Caracteres.-

1) *Es una obligación accesoria.* Como es una obligación, puede exigirse su cumplimiento coercitivamente; y por ser accesoria, su existencia y validez depende del acto al que accede; la nulidad de éste acarrea la nulidad del cargo.

2) *Es una obligación excepcional,* ya que es extraña a la naturaleza del acto por el cual se adquiere el derecho.

3) *Se impone al adquirente de un derecho* (ej: al comprador, al donatario, al legatario, etc.). Tiende a limitar el derecho adquirido.

4) *Debe ser lícito y posible.*

Incumplimiento del cargo.-

¿Qué sucede si el cargo no se cumple? Se puede exigir compulsivamente su cumplimiento. Es importante destacar que el incumplimiento del cargo no impide la adquisición del derecho, ni produce la pérdida del mismo, salvo que el cargo se hubiere impuesto como condición suspensiva o resolutoria.

Especies.-

El cargo puede ser *simple* o *condicional*.

a) El *cargo simple*, si no se cumple, no produce la pérdida del derecho, y el que lo impuso sólo puede exigir su cumplimiento judicialmente.

b) El *cargo condicional*, se comporta como una condición resolutoria o suspensiva y tiene sus efectos:

- si fue impuesto como condición suspensiva: el derecho recién se adquiere después de haberse cumplido el cargo (conf. art. 558);
- si fue impuesto como condición resolutoria: la falta de cumplimiento del cargo producirá la pérdida del derecho adquirido.

En caso de duda acerca de si el cargo fue o no impuesto como condición se juzgará que no importan una condición (art. 354 *"in fine"*).

Cargo prohibido.-

La estipulación como cargo en los actos jurídicos de hechos que no pueden serlo como condición, se tiene por no escrita, pero no provoca la nulidad del acto (conf. art. 357).

Si en un acto jurídico una cláusula estipula, como cargo, un hecho que no puede ser puesto como condición (ej: un hecho imposible, contrario a la moral y a las buenas costumbres, prohibido por el ordenamiento jurídico o que afecte de modo grave las libertades de la persona), dicha cláusula se tiene por no escrita, pero no provoca la nulidad del acto.

Se trata de una innovación del nuevo Código Civil y Comercial, ya que en el Código Civil de Vélez, si el cargo consistía en un hecho imposible, ilícito o inmoral, la consecuencia era la nulidad del acto.

Tiempo de cumplimiento.-

El art. 355 trata sobre el plazo para cumplir el cargo, y su prescripción.

Art. 355.- "Tiempo de cumplimiento. Prescripción. Al plazo de ejecución del cargo se aplica lo dispuesto en los artículos 350 y concordantes.

Desde que se encuentra expedita, la acción por cumplimiento prescribe según lo establecido en el artículo 2559."

El cargo puede estar sometido a un plazo para cumplirlo, en cuyo caso corresponde aplicar las normas sobre plazo de los arts. 350 y concordantes. En consecuencia:

- Si hay un plazo determinado para cumplir el cargo, el mismo debe cumplirse en el lapso acordado por las partes.
- Si el plazo es indeterminado, el cargo debe cumplirse en el tiempo que fije el juez, a solicitud de cualquiera de las partes, mediante el procedimiento más breve que prevea la ley local.

La acción por cumplimiento del cargo comienza a prescribir desde que se encuentra expedita. De conformidad al art. 2559, debemos tener en cuenta que:

- el plazo de prescripción para deducir la acción para la fijación judicial del plazo se computa desde la celebración del acto; y
- si prescribe esta acción, también prescribe la de cumplimiento.

Transmisibilidad de derechos adquiridos con cargo.-

El derecho adquirido con un cargo es transmisible por actos entre vivos o por causa de muerte, pero junto con el derecho se traspaşa la obligación de cumplir el cargo, y los adquirentes del derecho estarán obligados a cumplir el cargo.

• Excepción a lo anterior:

La excepción a lo anterior está dada por los cargos inherentes a la persona y que sólo puede ser ejecutados por quien se obligó inicialmente a cumplirlo.

Ejemplo: doné una Ferrari a un famoso pintor con el cargo de que realice un óleo de mi esposa e hija.

Si el cumplimiento del cargo es inherente a la persona y ésta muere sin cumplirlo, la adquisición del derecho principal queda sin efecto, volviendo los bienes al titular originario o a sus herederos.

De acuerdo al art. 356 in fine, "...La reversión no afecta a los terceros sino en cuanto pudiese afectarlos la condición resolutoria."

Es decir que:

- El principio general es que la reversión (retorno de los bienes) no puede afectar los derechos de terceros.
- La reversión sólo puede afectar a terceros si el cargo se hubiera impuesto bajo condición resolutoria.

MODALIDADES DE LOS ACTOS JURÍDICOS

Las modalidades son cláusulas accesorias que acompañan al acto jurídico y que alteran o modifican sus efectos. Los tipos de modalidades reguladas son → • **Condición** / • **Plazo** / • **Cargo**.

CONDICIÓN

Se denomina **condición** a la cláusula de los actos jurídicos por la cual las partes subordinan su plena eficacia o resolución a un hecho futuro e incierto (conf. art. 343).

Especies

- a) **Condición suspensiva**: la plena eficacia del acto jurídico depende de que la condición se produzca. Los efectos se producen a partir de que la condición se cumple.
- b) **Condición resolutoria**: la resolución del acto jurídico depende de que la condición se produzca. Los efectos se producen desde el comienzo del acto, pero cesan al cumplirse la condición.

Condiciones prohibidas

- El acto será nulo cuando esté sujeto a alguno de los siguientes "hechos condicionales":
- 1) Hecho imposible.
 - 2) Hecho contrario a la moral y a las buenas costumbres.
 - 3) Hecho prohibido por el ordenamiento jurídico.
 - 4) Hecho que dependa exclusivamente de la voluntad del obligado.
 - 5) Hecho que afecte de modo grave las libertades de la persona.

Condición impropia o suposición

- El hecho condicional si bien es incierto no es futuro, pues las partes sujetan la adquisición o extinción de un derecho a un hecho presente o pasado ignorado, o sea, a un hecho que está ocurriendo o que ya ocurrió (conf. art. 343, 2º párr.).

Inejecución de la condición

- La parte que dolosamente impidió que la condición se cumpla, no puede alegar que la condición no se cumplió. Se sanciona la mala fe, y se debe tener por cumplida la condición.

Efecto

- La condición no opera retroactivamente, salvo que las partes pacten lo contrario. Es decir que en principio la condición no tiene efecto retroactivo, pero las partes pueden pactar que sí lo tenga.

Condición pendiente

- Estando pendiente la condición (es decir, mientras ésta no se haya cumplido), el criterio es permitir a las partes tomar medidas de conservación de sus derechos → Art. 347.

Cumplimiento de la condición

- El cumplimiento de la **condición** obliga a las partes a entregarse o restituirse, recíprocamente, las prestaciones convenidas.
- Si las partes hubieran pactado el efecto retroactivo de la condición, el cumplimiento de ésta obliga a la entrega recíproca de lo que les habría correspondido al tiempo de la celebración del acto. Subsisten los actos de administración, y los frutos quedan a favor de la parte que los ha percibido.

No cumplimiento de la condición suspensiva

- Si el acto celebrado bajo condición suspensiva se hubiese ejecutado antes del cumplimiento de la condición, y ésta no se cumple, debe restituirse el objeto con sus accesorios, pero no los frutos percibidos (conf. art. 349).

PLAZO

El **plazo** es la cláusula por la cual se subordina la exigibilidad o la extinción de un acto a la producción de un hecho futuro y cierto.

Diferencia con la condición

- En la condición el hecho es incierto, puede o no suceder.
- En el plazo, el hecho es cierto en el sentido de que ocurrirá necesaria o fatalmente.

Clases

- 1) **Suspensiva**: posterga hasta su vencimiento la exigibilidad de un derecho. / **Resolutoria**: a su vencimiento se extingue el derecho.
- 2) **Cierto**: se sabe cuando vencerá. / **Incierto**: se sabe que ocurrirá, pero no se sabe cuando.
- 3) **Esencial**: el tiempo en que debe ser cumplida la obligación fue determinante para que se contrajera la misma. / **Accidental**: cuando no ha sido determinante para que se contrajera la obligación.
- 4) **Expreso**: está expresamente convenido en la obligación. / **Tácito**: no está expresamente convenido, pero resulta de la naturaleza y circunstancias de la obligación.
- 5) **Legal**: lo fija la ley. / **Judicial**: lo fija el juez. / **Convencional**: lo fijan las partes.

Beneficiario del plazo

- El plazo se presume a favor del deudor, salvo que por alguna circunstancia resulte que ha sido previsto a favor del acreedor o de ambas partes.
- El deudor podrá pagar antes del vencimiento del plazo y el acreedor no podrá negarse a aceptarlo. Asimismo, el acreedor no podrá exigir el pago antes del vencimiento.

Efectos

- La regla general, en el plazo, es que sus efectos se producen a partir de su vencimiento ("ex nunc").

Caducidad del plazo

- El art. 353 enuncia casos en que el plazo caduca y el acreedor puede exigir lo debido aunque dicho plazo no haya transcurrido. Tales casos son:
- a) Si el deudor es declarado en quiebra.
 - b) Si el deudor disminuye por acto propio las seguridades otorgadas al acreedor para el cumplimiento de la obligación.
 - c) Si no ha constituido las garantías prometidas.
 - d) Otros supuestos relevantes.

Cómputo del plazo

- Conforme al art. 6 del nuevo Código Civil y Comercial. (Ver Capítulo III).

CARGO

El **cargo** (también denominado "carga" o "modo") es una obligación accesorias y de carácter excepcional que se impone al adquirente de un derecho.

Caracteres

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1) Es una obligación accesorias. | 3) Se impone al adquirente de un derecho. |
| 2) Es una obligación excepcional. | 4) Debe ser lícito y posible. |

Incumplimiento del cargo

- ¿Qué sucede si el cargo no se cumple? Se puede exigir compulsivamente su cumplimiento. El incumplimiento no impide la adquisición del derecho, ni produce la pérdida del mismo, salvo que el cargo se hubiere impuesto como condición suspensiva o resolutoria.

Especies

- a) **Cargo simple**, si no se cumple, no produce la pérdida del derecho, y el que lo impuso sólo puede exigir su cumplimiento judicialmente.
- b) **Cargo condicional**, se comporta como una condición resolutoria o suspensiva y tiene sus efectos:
- si fue impuesto como **condición suspensiva**: el derecho recién se adquiere después de haberse cumplido el cargo.
 - si fue impuesto como **condición resolutoria**: la falta de cumplimiento del cargo produce la pérdida del derecho adquirido.

Cargo prohibido

- La estipulación como cargo en los actos jurídicos de hechos que no pueden serlo como condición, se tiene por no escrita, pero no provoca la nulidad del acto (conf. art. 357).
- Si en un acto jurídico una cláusula estipula, como cargo, un hecho que no puede ser puesto como condición, dicha cláusula se tiene por no escrita, pero no provoca la nulidad del acto.

Tiempo de cumplimiento

- El cargo puede estar sometido a un **plazo** para cumplirlo. (se aplican los arts. 350 y concordantes)
- Si hay un **plazo determinado** para cumplir el cargo, el mismo debe cumplirse en el lapso acordado por las partes.
 - Si el **plazo es indeterminado**, el cargo debe cumplirse en el tiempo que fije el juez, a solicitud de cualquiera de las partes, mediante el procedimiento más breve que prevea la ley local.

La acción por cumplimiento del cargo comienza a prescribir desde que se encuentra expedita.

- Art. 2559
- el plazo de prescripción para deducir la **acción para la fijación judicial del plazo** se computa desde la celebración del acto; y
 - si prescribe esta acción, también prescribe la de cumplimiento.

Transmisibilidad de derechos adquiridos con cargo

- El derecho adquirido con un cargo es transmisible por actos entre vivos o por causa de muerte, pero junto con el derecho se traspa la obligación de cumplir el cargo, y los adquirentes del derecho estarán obligados a cumplir el cargo.

Excepción

La excepción a lo anterior está dada por los **cargos inherentes a la persona** y que sólo puede ser ejecutados por quien se obligó inicialmente a cumplirlo. Si la persona muere sin cumplirlo, la adquisición del derecho principal queda sin efecto, volviendo los bienes al titular originario o a sus herederos.

CAPÍTULO XXI REPRESENTACIÓN

Concepto.-

La representación es la institución por la cual una persona debidamente autorizada (el representante), celebra actos jurídicos entre vivos por orden y cuenta de otra persona (el representado) sobre la cual recaen los efectos del acto.

Quedan excluidos de la representación los actos la ley exige que sean otorgados por el titular del derecho (ej: derechos personalísimos).

En la representación es fundamental tener presente que el acto que se lleva a cabo no es del representante, sino de la persona por quien él actúa, y que por tanto, éste obra sólo en concepto de tal y sin que (en principio) quiera quedar vinculado y responder de ese acto.

A veces se recurre a la representación por razones de necesidad, tal el caso de dar protección a las personas incapaces o relativamente capaces que al no poder actuar por si mismos deben valerse necesariamente de un representante (ej: tutor, curador, padres) para hacer valer sus derechos.

Otras veces la razón es la utilidad ya que una persona (valiéndose de representantes) puede celebrar varios actos jurídicos al mismo tiempo y en lugares muy distantes.

También puede deberse a la comodidad del representado, tal el caso de tener un representante judicial que le evite tener que concurrir a las audiencias o firmar los escritos del litigio.

Art. 358.- "Principio. Fuentes. Los actos jurídicos entre vivos pueden ser celebrados por medio de representante, excepto en los casos en que la ley exige que sean otorgados por el titular del derecho. La representación es voluntaria cuando resulta de un acto jurídico, es legal cuando resulta de una regla de derecho, y es orgánica cuando resulta del estatuto de una persona jurídica.

En las relaciones de familia la representación se rige, en subsidio, por las disposiciones de este Capítulo."

Clases de representación.-

Según su fuente la representación puede ser *voluntaria, legal, u orgánica*:

a) **Voluntaria:** esta clase de representación tiene su origen en un acto voluntario del representado, el cual da poder al representante para que obre por orden y cuenta suya. De este modo, los actos celebrados por el representante en nombre del representado producen efecto directamente para el representado.

b) **Legal:** esta clase de representación está impuesta por la ley. Es el caso de la representación del tutor (para los relativamente incapaces), del curador (para los declarados incapaces) y de los padres (para los hijos menores de edad).

c) **Orgánica:** son los casos de representación de una persona jurídica. Ejemplo: en una Sociedad Anónima, el representante de la misma es el Presidente del Directorio; en una SRL el representante es el Gerente (conf. Ley de General de Sociedades).

En las relaciones de familia, la representación se rige, en subsidio, por las disposiciones de este Capítulo (*Capítulo 8 "Representación", arts. 358 a 381*). Al respecto, vale agregar que en algunos casos de familia el representante necesita *facultades expresas*. Ejemplo: para petitionar el divorcio o la nulidad de matrimonio; reconocer hijos; aceptar herencias; realizar donaciones; etc. (conf. art. 375).

Efectos.-

Los actos celebrados por el representante en nombre del representado y en los límites de las facultades conferidas por la ley o por el acto de apoderamiento, producen efecto directamente para el representado (conf. art. 359).

Extensión.-

La representación alcanza a los actos objeto del apoderamiento, a las facultades otorgadas por la ley y también a los actos necesarios para su ejecución (conf. art. 360).

Limitaciones.-

De acuerdo al art. 361, la existencia de supuestos no autorizados y las limitaciones o la extinción del poder son oponibles a terceros, siempre que:

- éstos las conocieran; o
- pudieran haberlas conocido actuando con la debida diligencia.

En resumen:

- Los actos celebrados por el representante en nombre del representado producen efecto directamente para el representado, siempre que dichos actos estén dentro de lo autorizado (por la ley o por el acto de apoderamiento).
- La representación se extiende a aquellos actos que es necesario realizar para poder ejecutar los actos facultados por la ley o por el acto de apoderamiento.
- Si el representante realiza actos fuera de los límites de las facultades conferidas por la ley o por el acto de apoderamiento, no hay representación válida.
- Pero, si los terceros "conocían" o "podían conocer" (actuando con la debida diligencia) que se trataba de actos no autorizados o de que el poder estaba vencido, dichas circunstancias se pueden oponer a terceros.

REPRESENTACIÓN VOLUNTARIA

Concepto.-

Como ya dijimos antes, la representación voluntaria es aquella que tiene su origen en un acto voluntario del representado, el cual (sea por razones de comodidad o de utilidad) da poder al representante para que obre por orden y cuenta suya. De este modo, los actos que celebre el representante en nombre del representado producen efecto directamente para el representado, sea en su patrimonio o en sus derechos.

Caracteres.-

De acuerdo al art. 362, la representación voluntaria presenta las siguientes características:

- 1) La representación voluntaria sólo puede comprender los actos que el representado puede otorgar por sí mismo, de modo tal que lo que él no podría realizar (ej: porque se lo prohíbe la ley) tampoco puede darle poder al representante para que lo haga.
- 2) El poder tiene como destinatarios a los terceros, porque el contenido del poder permite a los terceros saber qué actos está facultado a realizar el representante. Por ello, los límites de la representación, su extinción, y las instrucciones que el representado dio a su representante, son oponibles a terceros si éstos "*han tomado conocimiento*" (ej: vieron el poder) o "*debieron conocer obrando con cuidado y previsión*" (ej: pidiendo copia certificada del poder) que se trataba de actos no autorizados o de que el poder estaba vencido.

Art. 362.- "Caracteres. La representación voluntaria comprende sólo los actos que el representado puede otorgar por sí mismo. Los límites de la representación, su extinción, y las instrucciones que el representado dio a su representante, son oponibles a terceros si éstos han tomado conocimiento de tales circunstancias, o debieron conocerlas obrando con cuidado y previsión."

Forma.-

La forma en que deba realizarse el poder estará sujeta a la forma del acto que el representante debe realizar. Así, si debe celebrar un contrato que debe otorgarse por escritura pública (conf. art. 1017), el poder también debe ser extendido en escritura pública. Ejemplo: compraventa de un inmueble.

Art. 363.- "Forma. El apoderamiento debe ser otorgado en la forma prescripta para el acto que el representante debe realizar."

Representación en juicio.-

Cuando alguien quiere que otra persona lo represente en sede judicial, generalmente le da un poder, hecho por un escribano, que puede ser *general* (es amplio y sirve para todo los juicios) o *especial* (sirve para un juicio en particular).

Al respecto, el Código Procesal Civil y Comercial establece que:

- La persona que se presente en juicio por un derecho que no sea propio, deberá acompañar con su primer escrito los documentos que acrediten el carácter que inviste (conf. art. 46, CPCCN).

- Los procuradores o apoderados acreditarán su personería con la pertinente escritura de poder, o con una copia de éste, si fuese un poder para realizar varios actos (conf. art. 47, CPCCN).

• **Gestor procesal:** en casos de urgencia en la realización de actos procesales, el Código Procesal (art. 48) admite la intervención de quien no tenga representación suficiente (gestor procesal), pero con la condición de que dentro de los 40 días hábiles presente la documentación que acredite la representación o acompañe un escrito de la parte ratificando todo lo actuado. De lo contrario se considerará nula su actuación y deberá satisfacer las costas y los daños y perjuicios que produzca.

En su presentación, el gestor debe indicar: a) la parte en cuyo beneficio pretende actuar; b) las razones que justifiquen la seriedad del pedido.

Esta facultad acordada por el art. 48 del CPCCN sólo podrá ejercerse una vez en el curso del proceso.

Capacidad.-

El art. 364 se refiere a la capacidad que deben tener el representado y el representante al momento de otorgar el poder.

Art. 364.- "Capacidad. En la representación voluntaria el representado debe tener capacidad para otorgar el acto al momento del apoderamiento; para el representante es suficiente el discernimiento."

• El representado debe gozar de capacidad para otorgar el acto al momento de otorgar el poder.

• Para el representante no se requiere esa capacidad, ya que la ley sólo exige que tenga discernimiento (que sepa lo que está haciendo, que le sea posible comprender el significado y alcance de sus actos). Esto se debe a que los efectos del acto que celebre no recaerán sobre él sino sobre el representado, de modo que el acto celebrado no lo perjudica.

Ejemplo: ¿podría ser representante un incapaz? Sí, porque hay incapaces que tienen discernimiento; ¿podría ser representante una persona menor de 13 años? No, porque no tiene discernimiento (conf. art. 261, inc. c).

Vicios.-

Si el representante realiza el acto con su voluntad viciada, es decir con alguna causa que afecta su discernimiento, su intención o su libertad (ej: sufrió error, dolo o violencia) el acto que celebró es nulo.

Pero, en el caso de que el representante hubiera actuado conforme a facultades o instrucciones previas del representado, es nulo sólo si estuvo viciada la voluntad del representado.

Por último, el Código Civil y Comercial establece que el representado de mala fe no puede aprovecharse de la ignorancia o la buena fe del representante.

Art. 365.- "Vicios. El acto otorgado por el representante es nulo si su voluntad está viciada. Pero si se ha otorgado en ejercicio de facultades previamente determinadas por el representado es nulo sólo si estuvo viciada la voluntad de éste.

El representado de mala fe no puede aprovecharse de la ignorancia o la buena fe del representante."

Actuación en ejercicio del poder.-

El poder otorgado, marca los límites de lo que puede hacer el representante en nombre del representado. Actuando dentro de esos límites sus actos obligan sólo al representado, y el representante no queda obligado con los terceros, salvo que él haya garantizado de algún modo el negocio.

Dado que el representante puede celebrar un acto en nombre de su representado, pero que también puede celebrarlo en nombre propio, el art. 366 establece que la voluntad de obrar en nombre de otro debe aparecer claramente, de lo contrario se entiende que ha procedido en nombre propio.

Ejemplo: AA es Presidente de una Sociedad y como tal es su representante; va a una agencia de autos y deja señal por un vehículo. Si la voluntad de comprar el auto para la sociedad no aparece claramente expresada, se entiende que AA adquirió el auto en nombre propio.

Representación aparente.-

Cuando el representado, con su conducta, haga creer a un tercero que está negociando con un representante suyo, y tal representación no exista expresamente, el art. 367 establece (en protección a los terceros) que debe entenderse que se ha otorgado tácitamente poder suficiente.

Además, la norma contempla 3 casos en los que (aunque no exista representación expresa) se presume que hay representación. Por lo tanto, se presume que:

- a) quien de manera notoria tiene la administración de un establecimiento abierto al público es apoderado para todos los actos propios de la gestión ordinaria de éste;
- b) los dependientes que se desempeñan en el establecimiento están facultados para todos los actos que ordinariamente corresponden a las funciones que realizan;
- c) los dependientes encargados de entregar mercaderías fuera del establecimiento están facultados a percibir su precio otorgando el pertinente recibo.

Acto consigo mismo.-

El art. 368 contempla 2 casos de "acto consigo mismo", prohibiéndolos:

Art. 368.- "Acto consigo mismo. Nadie puede, en representación de otro, efectuar consigo mismo un acto jurídico, sea por cuenta propia o de un tercero, sin la autorización del representado. Tampoco puede el representante, sin la conformidad del representado,

aplicar fondos o rentas obtenidos en ejercicio de la representación a sus propios negocios, o a los ajenos confiados a su gestión."

Por lo tanto:

a) Se prohíbe la situación en la cual **la misma persona** interviene en el acto, por un lado, como representante de alguien, y por el otro actuando por cuenta propia (ej: Juan extendió un poder a Luis para vender su casa y Luis es el comprador); o el caso de que actúe con doble representación (ej: en una compraventa es representante del vendedor y también del comprador). La prohibición responde a razones morales, ya que, ante un conflicto de intereses, el representante seguramente defenderá mas sus intereses que los de su representado. No obstante, el defecto de representación queda salvado si hay autorización previa del representado o su ratificación posterior.

b) La norma también prohíbe (salvo que haya conformidad del representado) que el representante aplique fondos o rentas obtenidos en ejercicio de la representación a sus propios negocios, o a negocios que sean ajenos a los confiados a su gestión.

Ratificación.-

La ratificación es la declaración de voluntad del representado aceptando, aprobando o autorizando lo hecho por el representante que actuó con vicios de representación.

La ratificación suple el defecto de representación. Luego de la ratificación, la actuación se da por autorizada, y entre las partes tiene efecto retroactivo al día del acto, pero es inoponible a terceros que hayan adquirido derechos con anterioridad (conf. art. 369).

• **Tiempo y forma para hacerla:** la ratificación puede hacerse en cualquier tiempo, pero los interesados pueden requerirle al representado que se expida dentro del plazo de 15 días (o de los 3 meses si la ratificación depende de la autoridad administrativa o judicial). El silencio del representado se debe interpretar como negativa a ratificar. El tercero que no haya requerido la ratificación puede revocar su consentimiento sin esperar el vencimiento de estos términos (conf. art. 370).

• **Manifestación de la ratificación:** para hacer la ratificación hay libertad de forma, y puede ser *expresa* o *tácita* (conf. art. 371).

a) **Expresa:** cuando haya una manifestación clara del representado respecto a que aprueba lo hecho.

b) **Tácita:** cuando de cualquier acto o comportamiento concluyente del representado surja que necesariamente importe una aprobación de lo que haya hecho el que invoca la representación (ej: recibió mercadería).

Obligaciones y deberes del representante.-

El representante tiene las siguientes obligaciones y deberes (conf. art. 372):

1) de fidelidad, lealtad y reserva;

2) de realización de la gestión encomendada, que exige la legalidad de su prestación, el cumplimiento de las instrucciones del representado, y el desarrollo de una conducta según los usos y prácticas del tráfico;

3) de comunicación, que incluye los de información y de consulta;

4) de conservación y de custodia;

5) de prohibición, como regla, de adquirir por compraventa (o actos jurídicos análogos) los bienes de su representado;

6) de restitución de documentos y demás bienes que le correspondan al representado al concluirse la gestión.

A su vez, los terceros pueden exigir al representante que suscriba y les entregue copia firmada por él del instrumento del que resulta su representación, o sea, del poder (conf. art. 374).

Obligaciones y deberes del representado.-

El representado tiene las siguientes obligaciones y deberes (conf. art. 373):

a) de prestar los medios necesarios para el cumplimiento de la gestión;

b) de retribuir la gestión, si corresponde;

c) de dejar indemne al representante.

Poder conferido en términos generales y facultades expresas (conf. art. 375).-

En el Código Civil de Vélez se trataba lo referente a los *poderes generales y especiales* en el contrato de mandato a través de los arts. 1879 a 1888, y de ellos surgía que el poder general se refería a todos los negocios del mandante pero sólo facultaba para realizar actos de administración; en cambio, el poder especial era para ciertos actos en particular que estaban indicados en el art. 1881.

El nuevo Código Civil y Comercial se refiere a los poderes en el art. 375 y comienza fijando una regla básica: "las facultades contenidas en el poder son de interpretación restrictiva".

Luego establece que el *poder conferido en términos generales* (poder general) sólo incluye los actos propios de administración ordinaria y los necesarios para su ejecución.

Y para la realización de determinados actos exige (a fin de rodearlos de más seguridad) que el representante tenga facultades expresas (poder especial). Los actos que requieren facultades expresas son:

a) peticionar el divorcio, la nulidad de matrimonio, la modificación, disolución o liquidación del régimen patrimonial del matrimonio;

b) otorgar el asentimiento conyugal si el acto lo requiere, caso en el que deben identificarse los bienes a que se refiere;

c) reconocer hijos, caso en el que debe individualizarse a la persona que se reconoce;

d) aceptar herencias;

e) constituir, modificar, transferir o extinguir derechos reales sobre inmuebles u otros bienes registrables;

f) crear obligaciones por una declaración unilateral de voluntad;

g) reconocer o novar obligaciones anteriores al otorgamiento del poder;

h) hacer pagos que no sean los ordinarios de la administración;

i) renunciar, transar, someter a juicio arbitral derechos u obligaciones, sin perjuicio de las reglas aplicables en materia de concursos y quiebras;

j) formar uniones transitorias de empresas, agrupamientos de colaboración empresarial, sociedades, asociaciones, o fundaciones;

k) dar o tomar en locación inmuebles por más de tres años, o cobrar alquileres anticipados por más de un año;

l) realizar donaciones, u otras liberalidades, excepto pequeñas gratificaciones habituales;

m) dar fianzas, comprometer servicios personales, recibir cosas en depósito si no se trata del necesario, y dar o tomar dinero en préstamo, excepto cuando estos actos correspondan al objeto para el que se otorgó un poder en términos generales.

La doctrina entiende que esta enumeración no es de carácter taxativo.

Responsabilidad por inexistencia o exceso en la representación.-

Aquél que actúe como representante de otro sin serlo, o excediendo las facultades otorgadas por el representado, es responsable del daño que sufra la otra parte por haber confiado (sin culpa suya) en la validez del acto.

En cambio, si hace saber al tercero la falta o deficiencia de su poder, estará exento de dicha responsabilidad (conf. art. 376).

Sustitución.-

El representante puede sustituir el poder en otro. Esto significa que puede hacerse sustituir por otra persona en el cumplimiento de su representación, salvo que el representado le haya prohibido la sustitución.

El representante responde por lo que haga el sustituto sólo si el lo designó e incurrió en culpa al elegirlo (ej: eligió a alguien que notoriamente no era idóneo).

Si quien designó al sustituto fue el representado, el representante no tendrá ninguna responsabilidad (conf. art. 377).

Pluralidad de representantes.-

Si el representado encarga la gestión a varios representantes, y no aclaró nada acerca de si deben actuar de forma separada o conjuntamente, todos o algunos

de ellos, *se presume que facultó a actuar indistintamente a cualquiera de ellos* (conf. art. 378).

Apoderamiento plural.-

El "*apoderamiento plural*" es el caso en que varios representados otorguen poder a un representante para un negocio de interés común. En este supuesto, cada representado puede revocar el poder sin dependencia de los otros (conf. art. 379).

Extinción.-

De acuerdo al art. 380, el poder se extingue por las siguientes causas:

a) por el cumplimiento del o de los actos encomendados en el apoderamiento;

b) por la muerte del representante o del representado; sin embargo subsiste en caso de muerte del representado siempre que haya sido conferido para actos especialmente determinados y en razón de un interés legítimo que puede ser solamente del representante, de un tercero o común a representante y representado, o a representante y un tercero, o a representado y tercero;

c) por la revocación efectuada por el representado; sin embargo, un poder puede ser conferido de modo irrevocable, siempre que lo sea para actos especialmente determinados, limitado por un plazo cierto, y en razón de un interés legítimo que puede ser solamente del representante, o de un tercero, o común a representante y representado, o a representante y un tercero, o a representado y tercero; se extingue llegado el transcurso del plazo fijado y puede revocarse si media justa causa;

d) por la renuncia del representante, pero éste debe continuar en funciones hasta que notifique aquélla al representado, quien puede actuar por sí o reemplazarlo, excepto que acredite un impedimento que configure justa causa;

e) por la declaración de muerte presunta del representante o del representado;

f) por la declaración de ausencia del representante;

g) por la quiebra del representante o representado;

h) por la pérdida de la capacidad exigida en el representante o en el representado.

Poder irrevocable.-

Del art. 380 inc. c), surge que el poder puede ser irrevocable si reúne los siguientes requisitos:

- ser otorgado para actos especialmente determinados,
- ser limitado por un plazo cierto, y
- ser otorgado en razón de un interés legítimo (que puede ser solamente del representante, o de un tercero, o común a representante y representado, o a representante y un tercero, o a representado y tercero).

El *poder irrevocable* se extingue llegado el transcurso del plazo fijado, y puede revocarse si media justa causa.

Oponibilidad a terceros.-

Ya habíamos dicho que los destinatarios del poder son los terceros, para que ellos estén informados sobre cuáles son las facultades del representante. En consecuencia, todo acto que altere el poder (como ser modificaciones, la renuncia y la revocación del poder) debe ser puesto *en conocimiento de los terceros* por *medios idóneos*.

En su defecto, no son oponibles a los terceros, a menos que se pruebe éstos conocían las modificaciones o la revocación en el momento de celebrar el acto jurídico.

Las demás causas de extinción del poder (ej: muerte del representado) no son oponibles a los terceros que las hayan ignorado sin su culpa (conf. art. 381).

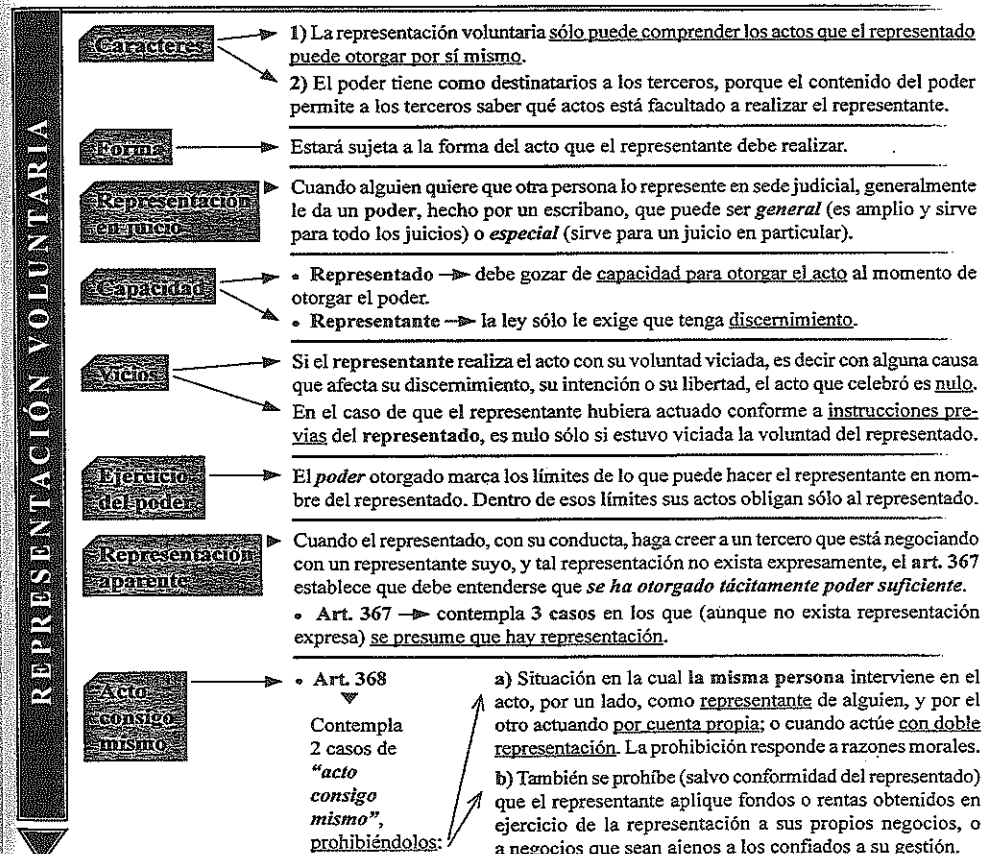
Art. 381.- "Oponibilidad a terceros. Las modificaciones, la renuncia y la revocación de los poderes deben ser puestas en conocimiento de los terceros por medios idóneos. En su defecto, no son oponibles a los terceros, a menos que se pruebe que éstos conocían las modificaciones o la revocación en el momento de celebrar el acto jurídico. Las demás causas de extinción del poder no son oponibles a los terceros que las hayan ignorado sin su culpa."

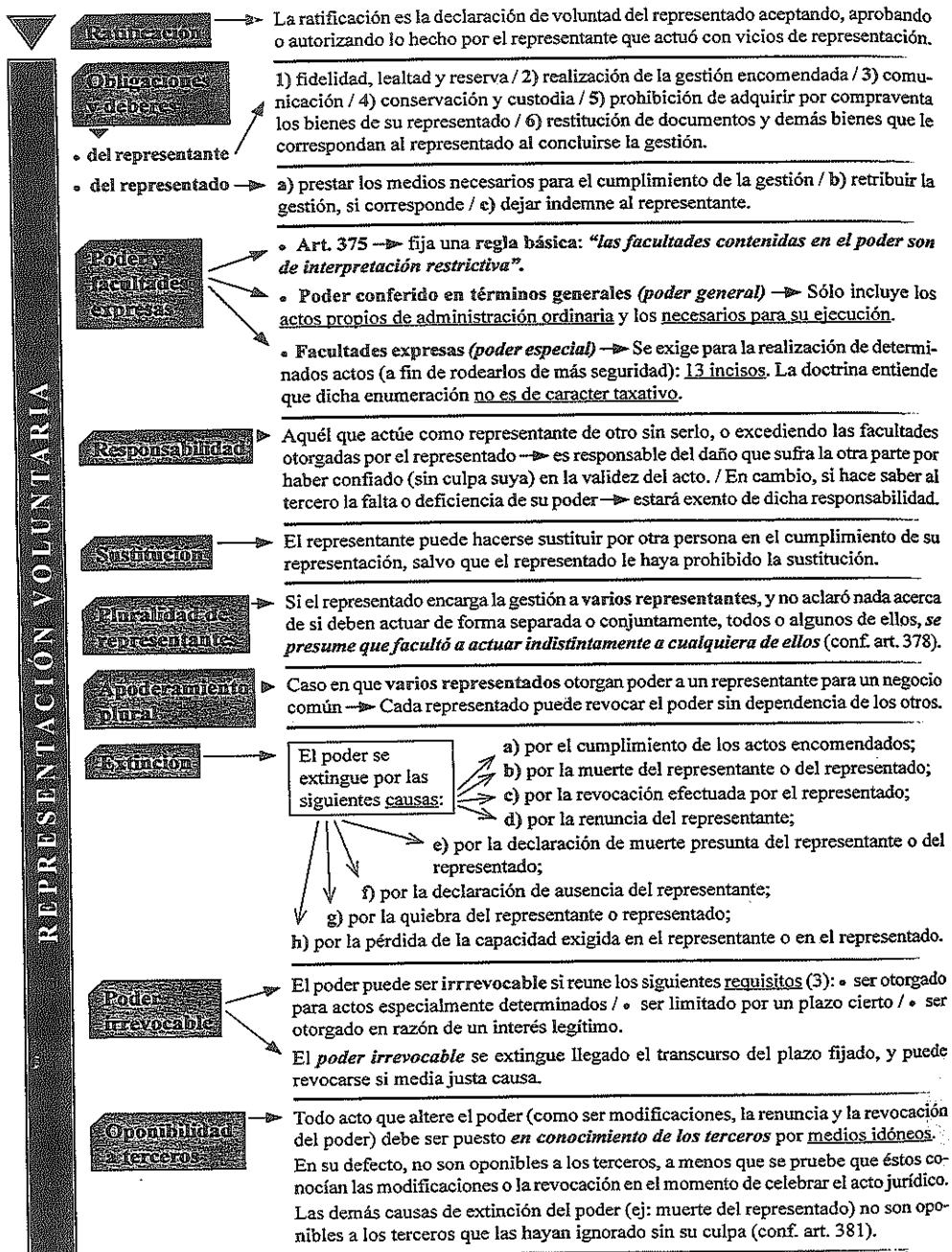
REPRESENTACIÓN

CONCEPTO
La representación es la institución por la cual una persona debidamente autorizada (el representante), celebra actos jurídicos entre vivos por orden y cuenta de otra persona (el representado) sobre la cual recaen los efectos del acto. Quedan excluidos de la representación los actos que la ley exige que sean otorgados por el titular del derecho.

CLASE
a) **Voluntaria**: tiene su origen en un acto voluntario del representado, el cual da poder al representante para que obre por orden y cuenta suya.
b) **Legal**: está impuesta por la ley. Es el caso de la representación del tutor, del curador, y de los padres (para los hijos menores de edad).
c) **Orgánica**: son los casos de representación de una persona jurídica.

Efectos (art. 359)	Extensión (art. 360)	Limitaciones (art. 361)
Los actos celebrados por el representante en nombre del representado y en los límites de las facultades conferidas, producen efecto directamente para el representado.	La representación alcanza a los actos objeto del apoderamiento, a las facultades otorgadas por la ley y también a los actos necesarios para su ejecución.	La existencia de supuestos no autorizados y las limitaciones o la extinción del poder son oponibles a terceros, siempre que: • éstos las conocieran; o • pudieran haberlas conocido actuando con la debida diligencia.





CAPÍTULO XXII

INEFICACIA DE LOS ACTOS JURÍDICOS

INTRODUCCIÓN

En este tema hay importantes modificaciones, ya que el Código Civil de Vélez regulaba sólo las *nulidades* de los actos jurídicos, en tanto que ahora, en el nuevo Código Civil y Comercial, las nulidades se regulan dentro del moderno concepto de la *Ineficacia Jurídica*, el cual comprende dos especies:

- la nulidad, y
- la inoponibilidad.

De modo que, la ineficacia es el género y la nulidad y la inoponibilidad sus dos especies.

Art. 382.- "Categorías de ineficacia. Los actos jurídicos pueden ser ineficaces en razón de su nulidad o de su inoponibilidad respecto de determinadas personas."

Eficacia e Ineficacia.-

• La *eficacia* del acto jurídico es la aptitud del mismo para producir sus efectos normales, es decir para producir aquellos efectos o fines que las partes pretendían lograr al realizarlo.

Ejemplo: en una compraventa una de las partes quería obtener el dominio y la otra un precio en dinero.

• La *ineficacia* del acto tiene lugar cuando el acto no produce (total o parcialmente) los efectos que le son propios. Esto, a veces se debe a defectos en su estructura, tal el caso de un acto jurídico con fallas en sus elementos esenciales (ej: acto con objeto inmoral o lesivo de la dignidad humana; o con vicios de la voluntad, como ser el error, el dolo o la violencia, etc). En estos supuestos de ineficacia por defecto en la estructura del acto la consecuencia es la *nulidad*.

Otras veces la ineficacia se debe a causas sobrevinientes externas al acto, tal el caso de que se produzca revocación, rescisión o resolución del acto jurídico.

NULIDAD

Concepto.-

La nulidad es la sanción legal que priva a un acto jurídico de los efectos que le son propios o normales, a raíz de una causa (defecto o vicio) existente al momento de su creación, que tiene efectos retroactivos y erga omnes (frente a todos, sean partes o terceros).

Caracteres esenciales.-

Los caracteres esenciales de la nulidad son:

1) *Es una sanción legal*: es un castigo que la ley impone a quien ha transgredido un deber legal. Algunos autores consideran que no se trata técnicamente de una "sanción" o castigo, sino simplemente de una "falta de eficacia del acto" por omisión de algún requisito.

2) *Priva al acto jurídico de sus efectos propios o normales*: significa que no le permite producir las consecuencias jurídicas que las partes querían lograr.

3) *Se produce a raíz de una causa (vicio o defecto) existente en el acto al momento de su celebración*: esto se suele denominar "causa originaria" de la nulidad.

4) *Tiene efecto retroactivo*: lo actuado vuelve para atrás hasta el momento de celebrarse el acto, las cosas deben volver al mismo estado en que se hallaban antes de ejecutarse el acto.

5) *Tiene efecto erga omnes*: se puede oponer frente a todos, sean partes o terceros.

Articulación: vía de acción o de excepción.-

Se mantiene el criterio del Código Civil de Vélez, por el cual (en base al art. 1058 bis) era posible invocar la nulidad del acto por vía de acción o de excepción.

El nuevo Código Civil y Comercial trata esta cuestión en el art. 383.

Art. 383.- "Articulación. La nulidad puede argüirse por vía de acción u oponerse como excepción. En todos los casos debe sustanciarse."

Al respecto, conviene distinguir entre acto ya ejecutado y acto que aun no fue ejecutado:

a) Si el acto ya fue ejecutado, la parte que (fundándose en la nulidad) quiera dejarlo sin efecto, deberá impugnarlo mediante la *acción de nulidad* expuesta en la demanda.

Declarada la nulidad, las cosas deben volver al mismo estado en que se hallaban antes de ejecutarse el acto. Las partes deben restituirse lo que han percibido en razón del acto inválido (conf. art. 390). Ejemplo: si uno dio dinero y otro un auto, uno devolverá el dinero y el otro el auto.

b) Si el acto aún no ha sido ejecutado, no se podrá exigir su cumplimiento; y si se lo hiciese, la parte demandada puede negarse a cumplirlo al contestar la demanda oponiendo, por *vía de excepción* (es decir, como defensa), la nulidad del acto.

Ejemplo: "X.X." se obligó a entregar un auto pero el acto está viciado de nulidad. Si a "X.X.", se le exige la entrega del auto, él puede negarse a cumplir, oponiendo como excepción la nulidad del acto.

• Sustanciación.- Sea por vía de acción o de excepción, la nulidad debe sustanciarse, es decir, tramitarse, observándose los pasos procesales correspondientes para que la nulidad sea declarada.

Refiriéndose a la sustanciación de la excepción de nulidad, en los *Fundamentos del Anteproyecto* se dice que: "...por tratarse de una defensa de fondo sólo será invocable al contestar la demanda y no se resolverá como de previo y especial pronunciamiento sino en la sentencia, que resolverá el planteo luego de producida la prueba ofrecida".

La conversión del acto.-

La *conversión del acto* es un instituto por el cual un acto viciado de nulidad (porque no reúne los requisitos esenciales, o porque no cumple el fin perseguido por las partes) se transforma en otro válido, siempre que este último satisfaga los requisitos esenciales requeridos por el ordenamiento jurídico.

Se encuentra prevista en el art. 384 del nuevo Código.

Art. 384.- "Conversión. El acto nulo puede convertirse en otro diferente válido cuyos requisitos esenciales satisfaga, si el fin práctico perseguido por las partes permite suponer que ellas lo habrían querido si hubiesen previsto la nulidad."

Ejemplo: una venta de inmueble que no se hizo por escritura pública se convierte en una obligación de hacer la escritura.

Este instituto introducido expresamente por el nuevo Código Civil y Comercial es de gran utilidad práctica porque permite a las partes lograr el fin que perseguían con el acto nulo.

• Requisitos para la conversión.- Se precisan 2 requisitos:

1) Requisito Objetivo: que los elementos esenciales del acto nulo (si bien son insuficientes para darle validez a él) sean suficientes para darle validez al nuevo acto.

2) Requisito Subjetivo: que pueda suponerse que las partes habrían llevado adelante el acto convertido de haber previsto la nulidad del acto.

Acto indirecto.-

El nuevo Código Civil y Comercial regula el *acto indirecto* en el art. 385.

Art. 385.- "Acto indirecto. Un acto jurídico celebrado para obtener un resultado que es propio de los efectos de otro acto, es válido si no se otorga para eludir una prohibición de la ley o para perjudicar a un tercero."

Se admite el *acto indirecto*, que consiste en que las partes recurran a un acto jurídico determinado a efectos de alcanzar una finalidad práctica distinta de aquella que es típica del acto realizado. Se recurre a realizar un acto jurídico, a fin de alcanzar un resultado propio de otro acto.

¿Es válida esta conducta? Sí, siempre que no se lleve a cabo para:

- eludir una prohibición de la ley; o
- perjudicar a un tercero.

En estos supuestos habría fraude a la ley (conf. art. 12), y el acto y sus efectos deberían someterse a la norma imperativa que se trató de eludir.

Ejemplos de acto indirecto:

Caso del fideicomiso: supongamos que Ud. quiere dejar sus bienes a un sobrino pero teme que los administre mal, los malvenda o despilfarre el dinero. La solución es celebrar un fideicomiso por el cual usted transmite sus bienes a una persona de su entera confianza para que los administre correctamente por 15 años y que (con las utilidades) costee los gastos de alimentación y estudios de su sobrino; al vencer el plazo los bienes se le entregarán a su sobrino.

• **Diferencia entre acto indirecto y simulación.** - El acto indirecto se diferencia de la simulación, ya que en ésta la finalidad de las partes es darle valor a un acto que nada tiene de real o la de encubrir otro que se mantiene oculto; en tanto que en el acto indirecto es un acto real pero sus efectos son empleados con una finalidad diversa a la del negocio utilizado.

Categorías de nulidades.

• El Código Civil de Vélez distinguía entre *nulidad manifiesta* o *nulidad no manifiesta*, según que el vicio de la nulidad fuese manifiesto o patente en el acto (ej: acto de un menor) o por el contrario no fuese manifiesto en el acto y para verificarlo el juez tuviese que hacer una investigación (ej: existencia de dolo).

Además, distinguía entre *actos nulos* y *acto anulables*, a los cuales enumeraba pero no definía, entendiendo la doctrina que dicha clasificación coincidía con la de la nulidad manifiesta o no manifiesta.

• El nuevo Código Civil y Comercial abandona la distinción entre *nulidad manifiesta* y *nulidad no manifiesta*, y también la de *actos nulos* y *acto anulables*, por considerar que han perdido utilidad práctica.

Pero mantiene las distinciones entre:

- a) *nulidad absoluta* y *nulidad relativa* (arts. 386 a 388); y
- b) *nulidad total* y *nulidad parcial* (art. 389).

A) NULIDAD ABSOLUTA Y NULIDAD RELATIVA.**Distinción.**

Esta distinción se encuentra regulada en el art. 386 del nuevo Código.

• Son de *nulidad absoluta* los actos que contravienen el orden público, la moral o las buenas costumbres. La nulidad absoluta se impone a un acto para proteger el interés público, el interés de la sociedad.

• Son de *nulidad relativa* los actos a los cuales la ley impone esta sanción sólo en protección del interés de ciertas personas. La nulidad relativa protege el interés privado, es decir, el interés de una de las partes.

Ejemplos: si un acto tiene un objeto o una causa ilícita, es de nulidad absoluta, porque la nulidad se impone para proteger el interés público; si un incapaz de

ejercicio celebra un acto jurídico, la nulidad es relativa, porque ella está impuesta para proteger el interés privado del menor.

Consecuencias de la nulidad absoluta.

Sus consecuencias son (conf. art. 387):

- 1) Si la nulidad absoluta está manifiesta en el acto, puede ser declarada de oficio.
- 2) Puede alegarla el Ministerio Público y cualquier interesado (excepto la parte que invoque la propia torpeza para lograr un provecho).
- 3) Los actos con nulidad absoluta no pueden ser confirmados.
- 4) La acción por nulidad absoluta es imprescriptible.

Ejemplos de actos con nulidad absoluta: cuando el acto tiene un objeto prohibido o una causa ilícita; cuando no se respeta la forma exigida por la ley; cuando se realiza sin la autorización judicial que exige la ley; cuando el acto está contenido en un instrumento que es nulo (nulidad refleja); etc.

Consecuencias de la nulidad relativa.

Sus consecuencias son (conf. art. 388):

- 1) No puede ser declarada de oficio por el juez.
- 2) Puede ser pedida por "*las personas en cuyo beneficio se establece*" (ej: un incapaz de ejercicio por medio de su representante). Excepcionalmente puede invocarla la otra parte, si es de buena fe y ha experimentado un perjuicio importante. (En principio no podría pedirla el Ministerio Público, salvo que lo haga en representación de un incapaz cuando los representantes del mismo, por negligencia, no lo hagan).
- 3) La nulidad relativa se puede confirmar.
- 4) La acción por nulidad relativa es prescriptible (los plazos de prescripción varían según las causas, pero por lo general son de dos años).

Ejemplos de actos con nulidad relativa: actos con vicios de error, dolo, fuerza o intimidación, lesión; acto de un incapaz de ejercicio; etc.

B) NULIDAD TOTAL Y NULIDAD PARCIAL.**Distinción.**

Esta distinción se encuentra regulada en el art. 389 del nuevo Código.

Art. 389.- "Principio. Integración. Nulidad total es la que se extiende a todo el acto. Nulidad parcial es la que afecta a una o varias de sus disposiciones.

La nulidad de una disposición no afecta a las otras disposiciones válidas, si son separables. Si no son separables porque el acto no puede subsistir sin cumplir su finalidad, se declara la nulidad total.

En la nulidad parcial, en caso de ser necesario, el juez debe integrar el acto de acuerdo a su naturaleza y los intereses que razonablemente puedan considerarse perseguidos por las partes."

• La nulidad es total (completa) cuando se extiende a todo el acto. Es decir que afecta la totalidad del contenido del acto, de manera tal que todo el acto es inválido.

• La nulidad es parcial cuando afecta a una o varias de sus disposiciones. Es decir que sólo afecta una o algunas de las partes del acto, quedando válido el resto (ej: es nula una cláusula del testamento, pero el resto es válido).

Para que proceda la nulidad parcial, las disposiciones del acto deben ser separables, de manera que la nulidad de una de las disposiciones del acto, no afecte a las otras disposiciones válidas.

Si las disposiciones del acto no son separables (debido a que la separación de la disposición nula llevaría a que el acto no cumpla su finalidad), se declara la nulidad total (ej: nulidad de todo el testamento).

Integración.-

El juez, en caso de ser necesario, debe integrar el acto de acuerdo a su naturaleza y los intereses que razonablemente puedan considerarse perseguidos por las partes. Se trata de un deber que se le impone al juez en los casos de nulidad parcial: cuando sea necesario deberá integrar el acto (es decir, completar aquellos vacíos que resulten de la exclusión de la "parte" o "disposición" del acto declarada nula), a fin de salvar la subsistencia del acto.

EFFECTOS DE LA NULIDAD.-

Los efectos de la nulidad se encuentran regulados en los arts. 390 a 392 del nuevo Código Civil y Comercial. Los vemos a continuación.

Restitución con efecto retroactivo.-

La declaración judicial de nulidad del acto (se trate de nulidad absoluta o relativa) vuelve las cosas hacia atrás, al mismo estado en que se hallaban antes de ejecutarse el acto.

Las partes deben restituirse mutuamente lo que han percibido en razón del acto inválido (conf. art. 390). Ejemplo: si uno dio dinero y otro un auto, uno devolverá el dinero y el otro el auto.

Art. 390.- "Restitución. La nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo estado en que se hallaban antes del acto declarado nulo y obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han recibido. Estas restituciones se rigen por las disposiciones relativas a la buena o mala fe según sea el caso, de acuerdo a lo dispuesto en las normas del Capítulo 3 del Título II del Libro Cuarto."

Consecuencias y reparaciones.-

El acto jurídico nulo, aunque no produzca los efectos de los actos válidos, puede dar lugar a las consecuencias de los hechos en general, y a las reparaciones que correspondan (conf. art. 391).

Por lo tanto, por más que sea declarado nulo, el acto jurídico subsiste como hecho, con sus respectivas consecuencias. Entre dichas consecuencias, puede estar el pedido de reparación de quien se haya visto perjudicado con el acto declarado nulo; o la indemnización sustitutiva de restitución, cuando la restitución a la que se refiere el art. 390 ya no fuera posible (por ej, en caso de que la cosa a restituir ya se hubiera consumido).

Art. 391.- "Hechos simples. Los actos jurídicos nulos, aunque no produzcan los efectos de los actos válidos, dan lugar en su caso a las consecuencias de los hechos en general y a las reparaciones que correspondan."

En los Fundamentos del Anteproyecto se explica que el acto declarado nulo es susceptible de ser subsumido en otro supuesto jurídico (constituyendo un hecho jurídico *strictu sensu*, un simple acto lícito, un acto ilícito o aún otro acto jurídico si se presenta un fenómeno de conversión), que dé lugar en su caso a las consecuencias de los hechos en general y a las reparaciones (indemnización de los daños y perjuicios) que correspondan.

Ejemplo: un acto jurídico con vicio de error esencial, si bien no vale como acto jurídico, es un hecho que hace surgir la obligación de reparar los daños y perjuicios ocasionados por el mismo.

Efecto entre las partes.-

• Si el acto aún no ha sido ejecutado, no se podrá exigir su cumplimiento; y si alguien lo hiciese, la parte demandada puede negarse a cumplir oponiendo como excepción (es decir, como defensa) la nulidad del acto.

• Si el acto ya fue ejecutado, las cosas deben volver al mismo estado en que se hallaban antes de ejecutarse el acto. Las partes deben restituirse lo que han percibido en razón del acto inválido (conf. art. 390).

Estas restituciones se rigen por las disposiciones relativas a la buena o mala fe según sea el caso, de acuerdo a lo dispuesto en las normas del Capítulo 3 del Título II del Libro Cuarto (*Efectos de las relaciones de poder, arts. 1932 a 1940*).

Efectos para terceros adquirentes de cosas registrables.-

El art. 392 se refiere a la situación de aquel tercero que adquiere una cosa registrable, transmitida a él por quien la adquirió en virtud de un acto nulo. Al respecto establece que:

a) Todos los derechos reales o personales sobre una cosa registrable (mueble o inmueble) transmitidos a terceros por los otorgantes del acto anulado, quedan sin ningún valor y pueden ser reclamados directamente a su poseedor actual (es decir al tercero adquirente), salvo que el tercero adquirente sea de buena fe y a título oneroso.

b) Sin embargo, los terceros subadquirentes no pueden ampararse en su buena fe y título oneroso si el acto se ha realizado sin intervención del titular del derecho.

En síntesis, el principio es que el tercero subadquirente debe devolver lo que ha recibido, pero si es de buena fe y a título oneroso, no restituye siempre y cuando en el acto de transmisión haya intervenido el verdadero titular del derecho. De lo contrario (es decir, si en el acto de transmisión no participó el verdadero titular del derecho), no puede ampararse en la buena fe y debe restituir.

CONFIRMACIÓN DE LOS ACTOS JURÍDICOS.-

Concepto.-

Según el art. 393, hay confirmación cuando la parte que puede articular la nulidad relativa, manifiesta expresa o tácitamente su voluntad de tener al acto por válido, después de haber desaparecido la causa de nulidad. El acto de confirmación no requiere la conformidad de la otra parte.

La confirmación es la manifestación de voluntad (expresa o tácita), efectuada por aquel en favor de quien se declaró la nulidad, de tener por válido el acto afectado de nulidad relativa, luego de que desaparezcan las causas que lo invalidaron.

Desde el punto de vista práctico consiste en sanear el acto jurídico inválido, en hacer desaparecer las causas que lo invalidaron, dándolo por válido.

Actos confirmables.-

Los únicos actos que pueden confirmarse son los de nulidad relativa (conf. art. 393). Los actos de nulidad absoluta no son confirmables.

- La nulidad relativa está impuesta para proteger el interés privado, el interés de la persona que sufre el vicio (ej: del que sufra el dolo, del incapaz de hecho, etc.), por tanto es aceptable que la persona a favor de la cual se estableció la nulidad pueda renunciar a ella y confirmar el acto viciado.

- La nulidad absoluta, en cambio, está impuesta en defensa y protección del interés público, por eso es que no se permite que el acto afectado con nulidad absoluta pueda ser confirmable.

Condiciones.-

Para que la confirmación sea válida se deben dar 3 condiciones:

- a) Que sea solicitada (en forma expresa o tácita) por aquel en favor de quien se estableció la nulidad. Es decir, por el titular de la acción de nulidad.
- b) Que haya desaparecido la causa de invalidez.
- c) Que en el acto de confirmación, no concorra ninguna causal de nulidad.

Ejemplo: si un menor celebró un acto, sólo podrá confirmarlo cuando deje de ser menor. Además, se requiere que al confirmar no exista ningún otro vicio; así, habría nuevo vicio, si mediante violencia se lo obligara a confirmar el acto.

Formas.-

La confirmación puede ser expresa o tácita (conf. art. 394).

1) Expresa: la confirmación es expresa cuando la voluntad de confirmar el acto se manifiesta por escrito. El instrumento de confirmación debe tener la misma forma exigida para el acto que se sana (ej: instrumento público) y debe contener:

- a) la mención precisa de la causa la nulidad (ej: aclarar que cuando celebró el acto era menor);
- b) la mención de la desaparición de la causa de nulidad.
- c) la manifestación de la voluntad de confirmar el acto.

2) Tácita: la confirmación es tácita cuando resulta del cumplimiento total o parcial del acto nulo realizado con conocimiento de la causa de nulidad, o de otro acto del que se deriva la voluntad inequívoca de sanear el vicio del acto.

Ejemplo: cuando tenía 17 años contraí una deuda por \$ 10.000, y por ser menor no la pagué. Al cumplir 18 y llegar a la mayoría de edad, me presento ante el acreedor y pago mi deuda.

Prueba.-

La prueba de la confirmación del acto incumbe a la parte que la invoca, debiendo demostrar ésta que existió confirmación y que reunió todos los requisitos necesarios para ser válida.

Efectos de la confirmación.-

La confirmación sana el acto, hace desaparecer el vicio con efecto retroactivo al día de la celebración del acto (si se trata de actos entre vivos) o al día del fallecimiento del causante (si se trata de actos de última voluntad).

Sin embargo, este efecto retroactivo no puede perjudicar los derechos de terceros de buena fe (conf. art. 395).

Ejemplo: siendo menor de edad, vendo una casa a "X", y al llegar a la mayoría de edad, vendo esa misma casa a "L", y posteriormente confirmo la venta hecha a "X". La confirmación a favor de "X" no puede afectar los derechos de "L" sobre la casa.

INOPONIBILIDAD

Concepto.-

Ya hemos dicho que la ineficacia del acto jurídico tiene dos especies, una es la nulidad, la otra es la inoponibilidad.

La inoponibilidad es una especie de ineficacia que priva a un acto jurídico (válido entre las partes) de producir sus efectos frente a determinados terceros protegidos

por la ley, los cuales pueden actuar como si ese acto no existiera, y en consecuencia alegar la inoponibilidad por vía de acción o de excepción.

Los casos de inoponibilidad deben estar expresamente establecidos por la ley.

Efectos del acto inoponible frente a terceros.-

Nótese que el acto inoponible es perfectamente válido entre las partes, y que el tercero protegido no pretende que deje de serlo, sino simplemente que los efectos no puedan hacerse valer frente a él.

Art. 396.- "Efectos del acto inoponible frente a terceros. El acto inoponible no tiene efectos con respecto a terceros, excepto en los casos previstos por la ley."

La inoponibilidad se funda en proteger a los terceros ajenos al acto, pero no a cualquier tercero, sino a los terceros indicados en la ley (ej: según el caso, acreedor, tercero interesado, tercero de buena fe y a título oneroso)

Ejemplos: si falta la fecha cierta en un instrumento privado (art. 317: el instrumento no será oponible a terceros); acto fraudulento (art. 342: es inoponible al acreedor que triunfó en la acción de oponibilidad); contradocumento particular que altera lo expresado en un instrumento público (art. 298: vale entre las partes pero es inoponible a terceros interesados de buena fe); modificaciones al poder no notificadas por medio idóneo (art. 381); falta de publicidad suficiente -inscripción en el Registro- en la adquisición o transmisión de derechos reales (art. 1893); etc.

Oportunidad para invocar la inoponibilidad.-

La inoponibilidad puede hacerse valer en cualquier momento, sin perjuicio del derecho de la otra parte a oponer la prescripción o la caducidad (conf. art. 397).

La norma es clara respecto a que el tercero protegido puede hacer valer la inoponibilidad en cualquier momento, agreguemos que puede alegarla por *vía de acción* (ej: en caso de fraude a los acreedores, arts. 338 a 342) o por *vía de excepción* (ej: si alguien quiere hacer valer contra el tercero una hipoteca que no fue registrada, art. 1893).

La contraparte puede oponer la *prescripción de la acción de oponibilidad* (de 2 años conf. arts. 2562 y 2563) y la *caducidad del derecho*.

Diferencias entre Nulidad e Inoponibilidad.-

- La *nulidad* ataca la *validez* del acto mismo y lo priva de eficacia *erga omnes*, es decir, tanto respecto de las partes como de terceros.
- La *inoponibilidad* no ataca la validez del acto, sólo lo priva de efectos frente a determinados terceros.

Las *nulidades absolutas y relativas* son una sanción de orden público y no puede renunciarse anticipadamente. La inoponibilidad puede renunciarse, ya que es una sanción de orden privado establecida a favor de los terceros.

INEFICACIA DE LOS ACTOS JURÍDICOS

Ineficacia Jurídica

comprende dos especies

- a) la nulidad, y
- b) la inoponibilidad

La ineficacia es el género. → La nulidad y la inoponibilidad sus dos especies (conf. art. 382).

- La *eficacia* del acto jurídico es la aptitud del mismo para producir sus efectos normales.
- La *ineficacia* tiene lugar cuando el acto no produce (total o parcialmente) los efectos que le son propios.

NULIDAD

Concepto

La nulidad es la sanción legal que priva a un acto jurídico de los efectos que le son propios o normales, a raíz de una causa (defecto o vicio) existente al momento de su creación, que tiene efectos retroactivos y erga omnes (frente a todos, sean partes o terceros).

Caracteres esenciales

- 1) Es una sanción legal.
- 2) Priva al acto jurídico de sus efectos propios o normales.
- 3) Se produce a raíz de una causa (vicio o defecto) existente en el acto al momento de su celebración.
- 4) Tiene efecto retroactivo.
- 5) Tiene efecto erga omnes.

Articulación

- a) Si el acto ya fue ejecutado, la parte que (fundándose en la nulidad) quiera dejarlo sin efecto, deberá impugnarlo mediante la *acción de nulidad* expuesta en la demanda (*vía de acción*). Declarada la nulidad, las cosas deben volver al mismo estado en que se hallaban antes de ejecutarse el acto.
- b) Si el acto aún no ha sido ejecutado, no se podrá exigir su cumplimiento; y si se lo hiciese, la parte demandada puede negarse a cumplirlo al contestar la demanda oponiendo, por *vía de excepción* (es decir, como defensa), la nulidad del acto.

Conversión

La *conversión del acto* es un instituto por el cual un acto viciado de nulidad se transforma en otro válido, siempre que este último satisfaga los requisitos esenciales requeridos por el ordenamiento jurídico.

Requisitos

- 1) *Requisito Objetivo:* que los elementos esenciales del acto nulo sean suficientes para darle validez al nuevo acto.
- 2) *Requisito Subjetivo:* que pueda suponerse que las partes habrían llevado adelante el acto convertido de haber previsto la nulidad del acto.

Acto indirecto

Consiste en que las partes recurran a un acto jurídico determinado a efectos de alcanzar una *finalidad práctica distinta* de aquella que es típica del acto realizado.

¿Es válida esta conducta?

- a) eludir una prohibición de la ley; o
- b) perjudicar a un tercero.

Categoría de nulidades

- En el nuevo Código se mantienen las distinciones entre:
 - a) *nulidad absoluta y nulidad relativa* (arts. 386 a 388); y
 - b) *nulidad total y nulidad parcial* (art. 389).

NULIDAD ABSOLUTA Y NULIDAD RELATIVA

Distinción

→ Esta distinción se encuentra regulada en el art. 386 del nuevo Código.

Nulidad Absoluta

- Son de *nulidad absoluta* los actos que contravienen el orden público, la moral o las buenas costumbres. La nulidad absoluta se impone a un acto para proteger el *interés público*, el interés de la sociedad.

Nulidad Relativa

- Son de *nulidad relativa* los actos a los cuales la ley impone esta sanción sólo en protección del interés de ciertas personas. La nulidad relativa protege el *interés privado*, es decir, el interés de una de las partes.

• Consecuencias de la nulidad absoluta

- 1) Si está manifiesta, puede ser declarada de oficio.
- 2) Puede alegarla el Ministerio Público y cualquier interesado.
- 3) Los actos con nulidad absoluta no pueden ser confirmados.
- 4) La acción por nulidad absoluta es imprescriptible.

• Consecuencias de la nulidad relativa

- 1) No puede ser declarada de oficio por el juez.
- 2) Puede ser pedida por *"las personas en cuyo beneficio se establece"*.
- 3) La nulidad relativa se puede confirmar.
- 4) La acción por nulidad relativa es prescriptible (por lo general prescribe a los dos años).

5 NULIDAD TOTAL Y NULIDAD PARCIAL

Distinción: → Esta distinción se encuentra regulada en el art. 389 del nuevo Código.

Nulidad Total	Nulidad Parcial
La nulidad es <i>total</i> (completa) cuando se extiende a todo el acto. Es decir que afecta la totalidad del contenido del acto, de manera tal que todo el acto es inválido.	La nulidad es <i>parcial</i> cuando afecta a una o varias de sus disposiciones. Es decir que sólo afecta una o algunas de las partes del acto, quedando válido el resto.
Para que proceda la nulidad <u>parcial</u> , las disposiciones del acto deben ser <u>separables</u> . Si las disposiciones del acto <u>no son separables</u> , se declara la nulidad <u>total</u> .	

EFECTOS DE LA NULIDAD

Restitución con efecto retroactivo	La declaración judicial de nulidad del acto <u>vuelve las cosas hacia atrás</u> , al mismo estado en que se hallaban antes de ejecutarse el acto
Consecuencias y reparaciones	El acto jurídico nulo, aunque no produzca los efectos de los actos válidos, puede dar lugar a las consecuencias de los hechos en general, y a las reparaciones que correspondan. Por lo tanto, por más que sea declarado nulo, el acto jurídico subsiste como <i>hecho</i> , con sus respectivas consecuencias.
Efecto entre las partes	- Si el acto <u>aún no ha sido ejecutado</u> → no se podrá exigir su cumplimiento; y si alguien lo hiciese, la parte demandada <u>puede negarse a cumplir</u> oponiendo como excepción (es decir, como defensa) la nulidad del acto. - Si el acto <u>ya fue ejecutado</u> → las cosas <u>deben volver al mismo estado en que se hallaban</u> antes de ejecutarse el acto.
Efectos para terceros adquirentes de cosas registrables	El tercero subadquirente debe devolver lo que ha recibido. Pero si es de <i>buena fe y a título oneroso</i> , <u>no restituye</u> (siempre y cuando en el acto de transmisión haya intervenido el verdadero titular del derecho; de lo contrario no puede ampararse en la buena fe y debe restituir).

CONFIRMACIÓN DE LOS ACTOS

Concepto	Hay <u>confirmación</u> cuando la parte que puede articular la nulidad relativa, manifiesta expresa o tácitamente su voluntad de tener al acto por válido, después de haber desaparecido la causa de nulidad.
Actos confirmables	Los de nulidad relativa. Los actos de nulidad absoluta no son confirmables.
Condiciones	a) Que la confirmación sea solicitada por el titular de la acción de nulidad. b) Que haya desaparecido la causa de invalidez. c) Que en el acto de confirmación, no concorra ninguna causal de nulidad.
Formas	1) Expresa / 2) Tácita.
Prueba	La prueba de la confirmación del acto incumbe a la parte que la invoca.
Efectos	Sanea el acto, hace desaparecer el vicio con efecto retroactivo.

INOPONIBILIDAD

Concepto

La **inoponibilidad** es una especie de ineficacia que priva a un acto jurídico (válido entre las partes) de producir sus efectos frente a determinados terceros protegidos por la ley, los cuales pueden actuar como si ese acto no existiera, y en consecuencia alegar la inoponibilidad por vía de acción o de excepción. Los casos de inoponibilidad deben estar expresamente establecidos por la ley.

Efectos del acto inoponible frente a terceros

- El acto inoponible es perfectamente válido entre las partes → El tercero protegido no pretende que deje de serlo, sino simplemente que los efectos no puedan hacerse valer frente a él.
- Art. 396 → "El acto inoponible no tiene efectos con respecto a terceros, excepto en los casos previstos por la ley."

La inoponibilidad se funda en proteger a los terceros ajenos al acto, pero no a cualquier tercero, sino a los terceros indicados en la ley (ej: según el caso, acreedor, tercero interesado, tercero de buena fe y a título oneroso).

Oportunidad para invocar la inoponibilidad

- La inoponibilidad puede hacerse valer en cualquier momento, sin perjuicio del derecho de la otra parte a oponer la prescripción o la caducidad (conf. art. 397).
- El tercero protegido puede hacer valer la inoponibilidad por vía de acción o por vía de excepción.
- La contraparte puede oponer la prescripción de la acción de inoponibilidad (de 2 años conf. arts. 2562 y 2563) y la caducidad del derecho.

DIFERENCIAS ENTRE NULIDAD E INOPONIBILIDAD

Nulidad	Inoponibilidad
Ataca la <u>validez</u> del acto mismo y lo priva de eficacia <i>erga omnes</i> , es decir, tanto respecto de las partes como de terceros.	No ataca la validez del acto, sólo lo priva de efectos frente a <u>determinados terceros</u> .
Las <u>nulidades absolutas y relativas</u> son una sanción de orden público y no pueden renunciarse anticipadamente.	La inoponibilidad <u>puede renunciarse</u>, ya que es una sanción de orden privado establecida a favor de los terceros.

CAPÍTULO XXIII TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS

TRANSMISIÓN.-

Concepto.-

Hay *transmisión* de un derecho cuando una persona sucede a otra en la titularidad del mismo.

Clasificación.-

Según su origen, su extensión o su causa, la transmisión puede ser:

1) Según su origen:

- *legal* (ej: sucesión hereditaria); o
- *voluntaria* (ej: cesión de créditos).

2) Según su extensión:

- *a título universal* (se transmite todo el patrimonio. Ej: sucesor universal); o
- *a título particular* (se transmite sólo una parte del patrimonio).

3) Según su causa:

- *por acto entre vivos* (ej: compraventa, permuta, donación, cesión, etc.); o
- *mortis causa* (tiene como causa el fallecimiento del titular del derecho; puede ser: universal, tal el heredero, o singular, tal el legatario).

Sucesores.-

Se le llama *sucesor* al que recibe los derechos de otro.

- **Sucesor universal** es el que recibe todo (ej: el heredero) o una parte indivisa del patrimonio de otro (ej: el legatario de una parte alícuota).
- **Sucesor singular** es el que recibe un derecho en particular (Ej: comprador, donatario, cesionario, legatario, etc).

Transmisibilidad.-

El principio general es que *todos los derechos son transmisibles*.

Esto significa que cualquier derecho (aún cuando sea eventual, aleatorio, condicional, a plazo, con cargo, litigioso, etc.) puede ser transmitido a otra persona.

• **Excepciones.-** El principio general tiene excepciones o limitaciones, que impiden que el derecho se transmita. Según el art. 398, la limitación puede surgir de:

- 1) *Una estipulación válida de las partes* (ej: alquilo un local y se conviene que no puedo transferir mis derechos a otro).

2) *Una prohibición de la ley* (alimentos futuros, beneficios previsionales, derecho de uso y habitación).

3) *Una transgresión a la buena fe, a la moral o a las buenas costumbres* (derechos inherentes a la personalidad: vida, honor, etc; derechos de familia).

Art. 398.- "Transmisibilidad. Todos los derechos son transmisibles excepto estipulación válida de las partes o que ello resulte de una prohibición legal o que importe transgresión a la buena fe, a la moral o a las buenas costumbres."

Legitimación. Regla general "nemo plus iuris".-

Art. 399.- "Regla general. Nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso que el que tiene, sin perjuicio de las excepciones legalmente dispuestas."

Ejemplo: el que tiene un dominio revocable sobre un inmueble, no puede transmitir un dominio irrevocable sobre el mismo.

En este artículo se consagra la regla general de que *nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso que el que tiene*. Esta regla, denominada "*nemo plus iuris*", es proveniente del Derecho Romano. Fue receptada en el Código Civil de Vélez (art. 3270), y en el Proyecto de 1998 (art. 399), el cual sirvió como fuente del nuevo Código Civil y Comercial.

• Así, el *Código Civil de Vélez* establecía en el art. 3270: "*Nadie puede transmitir a otro sobre un objeto, un derecho mejor o más extenso que el que gozaba; y recíprocamente, nadie puede adquirir sobre un objeto un derecho mejor y más extenso que el que tenía aquel de quien lo adquiere.*". Y el art. 3271 establecía una excepción: "*La disposición del artículo anterior no se aplica al poseedor de cosas muebles*".

• A su vez, el *Proyecto de 1988* establecía el principio "*nemo plus iuris*" en su art. 399 diciendo: "*Principio. Nadie puede transmitir a otro sobre un objeto, un derecho mejor o más extenso que el que gozaba*"; y el art. 400 fijaba excepciones: "*La regla del artículo precedente no se aplica al poseedor de cosa mueble no registrable...ni al tercero poseedor de buena fe que ha adquirido un título valor conforme con la ley de circulación*".

Excepciones.- Sin dudas el "*nemo plus iuris*" es un principio indiscutible, ya que nadie puede dar más de lo que tiene ni recibir derechos mejores que los que tenía quien se los transmitió.

Pero se debe tener en cuenta que está limitado a los inmuebles (porque tratándose de cosa mueble no registrable, la posesión de buena fe y a título oneroso permite adquirir la propiedad de la misma, si la cosa no es hurtada ni perdida, conf. art. 1895), y que tiene numerosas excepciones que admiten la apariencia de titularidad y tienden a proteger a los adquirentes de buena fe y a título oneroso. Así lo prevé el art. 399 cuando expresa: "... *sin perjuicio de las excepciones legalmente dispuestas.*"

Ejemplos:

- el heredero aparente (el que tomó posesión de los bienes a pesar de que podían existir otros herederos) debe restituir lo recibido si luego aparecen otros herederos con mejor derecho. Sin embargo, el art. 2315 dice que los actos de disposición a título oneroso que haga el heredero son válidos si el tercero adquirente es de buena fe (por ignorar que existen otros herederos con igual o mejor derecho que el heredero aparente);

- El fraude no puede oponerse a los acreedores del adquirente que, de buena fe, hayan ejecutado los bienes comprendidos en el acto (conf. art. 340).

- La simulación no puede oponerse a los acreedores del adquirente simulado que, de buena fe, hayan ejecutado los bienes comprendidos en el acto (conf. art. 337).

- Si alguien adquirió un derecho por un acto que es nulo y luego se lo transmite a un tercero, este tercero en principio (por aplicación de la regla del *nemo plus iuris* (nadie puede transmitir un derecho mejor o más extenso que el que tiene-) debe restituir, salvo que este tercero haya adquirido de buena fe y a título oneroso, en cuyo caso no está obligado a restituir (conf. art. 392).

TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS

Hay *transmisión* de un derecho cuando una persona sucede a otra en la titularidad del mismo.

- Clasificación**
- 1) Según su origen:
 - *legal* (ej: sucesión hereditaria); o
 - *voluntaria* (ej: cesión de créditos).
 - 2) Según su extensión:
 - *a título universal* (se transmite todo el patrimonio. Ej: sucesor universal); o
 - *a título particular* (se transmite sólo una parte del patrimonio).
 - 3) Según su causa:
 - *por acto entre vivos* (ej: compraventa, permuta, donación, cesión, etc.); o
 - *mortis causa* (tiene como causa el fallecimiento del titular del derecho; puede ser: universal, tal el heredero, o singular, tal el legatario).

Sucesores → Se le llama *sucesor* al que recibe los derechos de otro.

- | | |
|--------------------------|--|
| Sucesor universal | → Es el que recibe todo, o una parte indivisa, del patrimonio de otro. |
| Sucesor singular | → Es el que recibe un derecho en particular. |

Transmisibilidad

- | | | |
|--|---|---|
| Principio general
El <u>principio general</u> es que <i>todos los derechos son transmisibles</i> . Esto significa que cualquier derecho (aún cuando sea eventual, aleatorio, condicional, a plazo, con cargo, litigioso, etc.) puede ser transmitido a otra persona. | ➔ | Excepciones
El principio general tiene excepciones o limitaciones, que impiden que el derecho se transmita.
La limitación puede surgir de: <ul style="list-style-type: none"> 1) <i>Una estipulación válida de las partes.</i> 2) <i>Una prohibición de la ley.</i> 3) <i>Una transgresión a la buena fe, a la moral o a las buenas costumbres.</i> |
|--|---|---|

Legitimación

- | | |
|--|---|
| Regla general "nemo plus iuris" | → Art. 399 → En este artículo se consagra la regla general de que <i>nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso que el que tiene</i> . Esta regla, se denomina " <i>nemo plus iuris</i> ".
Ejemplo: el que tiene un dominio revocable sobre un inmueble, no puede transmitir un dominio irrevocable sobre el mismo. |
| Excepciones | → La regla general " <i>nemo plus iuris</i> " está <u>limitada</u> a los inmuebles (porque tratándose de cosa mueble no registrable, la posesión de buena fe y a título oneroso permite adquirir la propiedad de la misma, si la cosa no es hurtada ni perdida, conf. art. 1895), y tiene numerosas excepciones que admiten la apariencia de titularidad y tienden a proteger a los adquirentes de buena fe y a título oneroso.
➤ Así lo prevé el art. 399 cuando expresa: "... <i>sin perjuicio de las excepciones legalmente dispuestas.</i> " |

TEST DE AUTOEVALUACIÓN

TEST de AUTOEVALUACIÓN

NOTA- Todas las preguntas aquí formuladas encuentran respuesta en el texto de esta guía

INTRODUCCIÓN. ANTECEDENTES DEL CÓDIGO CIVIL DE VÉLEZ SARSFIELD Y DEL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL

- 1) ¿Cuáles fueron las fuentes del Código Civil de Vélez?
- 2) Enumere los proyectos de reforma del Código Civil de Vélez.
- 3) Comente brevemente cuáles fueron los pasos y procedimiento para llegar a la promulgación del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.
- 4) Enumere y explique los “aspectos valorativos” del nuevo Código Civil y Comercial.
- 5) ¿Cuáles son los aspectos generales del nuevo Código Civil y Comercial?
- 6) ¿En qué consiste la Ley 26.994? ¿Qué normativa aprueba y qué normativa deroga?
- 7) Explique brevemente cómo es el método o estructura interna del nuevo Código Civil y Comercial.

CAPÍTULO I. TÍTULO PRELIMINAR. DERECHO. FUENTES.

- 1) ¿En qué consiste el “Título Preliminar” del nuevo Código Civil y Comercial? ¿Cuál es su contenido?
- 2) Defina la expresión “Derecho”. ¿Desde qué puntos de vista se puede emplear dicha expresión?
- 3) Explique los conceptos de “Derecho Natural” y “Derecho Positivo”. ¿Cuál prevalece cuando no coinciden?
- 4) ¿Cuáles son las ramas del Derecho Positivo?
- 5) ¿En qué consiste el “Digesto Jurídico Argentino”?
- 6) ¿Cuál es el contenido actual del Derecho Civil?
- 7) ¿Qué son las “fuentes del derecho”? ¿Cómo se las clasifica?
- 8) ¿Cuáles son las “fuentes” en el nuevo Código Civil y Comercial?
- 9) ¿Qué es la “costumbre”? ¿Cuáles son sus elementos?
- 10) Explique brevemente cuál es el valor que tiene la costumbre, tanto en el sistema de “derecho escrito” como en el sistema del “common law”.

- 11) ¿Cuáles son los distintos tipos de costumbre? ¿Cuáles de ellos son aceptados por el nuevo Código Civil y Comercial?

CAPÍTULO II. INTERPRETACIÓN DE LA LEY

- 1) ¿Qué significa "interpretar" la ley?
- 2) ¿Qué especies de interpretación conoce? Explíquelas brevemente.
- 3) Explique resumidamente cuáles son los métodos y las escuelas de la "interpretación".
- 4) ¿Qué es la "teoría de la hermenéutica"?
- 5) Comente brevemente los conceptos de los siguientes elementos interpretativos: gramatical, histórico, lógico, sistemático, y teleológico.
- 6) ¿Qué cuestiones se deben tener en cuenta para interpretar la ley, según el nuevo Código Civil y Comercial? Explique cada una de ellas.
- 7) ¿En qué consiste el "deber de resolver"?

CAPÍTULO III. LA LEY

- 1) ¿Qué es la "ley"? ¿Cuáles son sus dos acepciones? Enumere sus caracteres.
- 2) ¿Cómo pueden clasificarse las leyes en sentido amplio?
- 3) Explique y desarrolle cuáles son los pasos básicos en el proceso de formación de las leyes.
- 4) ¿Cuáles son los sistemas que determinan los efectos de la ley con relación al territorio? ¿Cuál de ellos adopta nuestro Código Civil y Comercial?
- 5) ¿Desde cuándo es obligatoria una ley? ¿Hasta cuándo es obligatoria?
- 6) ¿En qué consiste el "principio de inexcusabilidad"?
- 7) ¿A qué se le llama "efecto inmediato" de las leyes?
- 8) ¿Qué significa que las leyes son "irretroactivas"? ¿Cuáles son los requisitos para que una ley pueda ser retroactiva?
- 9) ¿Cuál es la excepción al "efecto inmediato", que surge del art. 7 del nuevo Código Civil y Comercial?
- 10) Explique brevemente cómo es el modo de contar los intervalos del derecho.

CAPÍTULO IV. EJERCICIO DE LOS DERECHOS

- 1) ¿En qué consiste el "principio de buena fe"?
- 2) ¿Qué es la "Teoría del abuso del Derecho"? ¿Qué modificación introdujo la Ley 17.711 respecto de esta teoría?

- 3) ¿Cuál es la posición del nuevo Código respecto del abuso del derecho? ¿Qué casos de abuso contempla?
- 4) ¿A qué se hace referencia cuando se habla de "leyes de orden público"?
- 5) ¿En qué consiste el "fraude a la ley"?
- 6) ¿Es posible la renuncia general de las leyes?
- 7) ¿A qué se le llama "derechos de incidencia colectiva"? ¿Son reconocidos por el nuevo Código Civil y Comercial?

CAPÍTULO V. DERECHOS Y BIENES

- 1) ¿Cuál es la concepción de "bienes" en el Código de Vélez? ¿Y en el nuevo Código Civil y Comercial?
- 2) ¿Cuál es la definición de "cosas" en el nuevo Código?
- 3) ¿Cuál es la postura del Código Civil y Comercial acerca de los "derechos sobre el cuerpo humano"?
- 4) ¿Qué establece el nuevo Código en relación a los derechos de las comunidades indígenas? ¿Qué dispone el art. 9 de la Ley 26.994 al respecto?

CAPÍTULO VI. PERSONA HUMANA

- 1) ¿Qué establece el nuevo Código respecto del comienzo de la existencia de la persona humana?
- 2) ¿Qué es la "concepción"? ¿Qué nuevas técnicas de concepción son aceptadas y utilizadas habitualmente en el mundo?
- 3) ¿Qué es la "Reproducción Médicamente Asistida"? ¿Cuál es la ley que garantiza la posibilidad de acceder a ella?
- 4) Explique los siguientes conceptos: "período de embarazo", "concepción", y "época de la concepción".
- 5) ¿Cuál es la importancia de determinar la "época de la concepción"? ¿Qué presunción establece el art. 2° del nuevo Código al respecto? ¿admite prueba en contrario?
- 6) ¿En qué consiste el "nacimiento"? Si el niño no nace con vida, ¿se considera que la persona existió o no?
- 7) En caso de que exista duda en relación a si el niño nació con o sin vida, ¿qué se presume?, ¿qué tipo de presunción es?
- 8) ¿Qué tipo de fraudes pueden producirse en relación al embarazo?
- 9) ¿A qué se le llama "viabilidad"? ¿Exigida por el nuevo Código?
- 10) ¿A qué se le llama tradicionalmente "atributos de la persona"? Enumérelas. ¿Cuáles son sus caracteres?

CAPÍTULO VII. CAPACIDAD

- 1) ¿Qué es la capacidad? ¿Qué tipos de capacidad conoce?
- 2) ¿En qué consiste la incapacidad de derecho? ¿Por qué se dice que es "excepcional"?
- 3) ¿En qué consiste la incapacidad de ejercicio? ¿Cuáles son las personas incapaces de ejercicio enumeradas en el nuevo Código?
- 4) ¿Quién representa a las personas por nacer en el ejercicio de sus derechos?
- 5) ¿A quiénes se les llama "menor de edad" y "adolescente" en el nuevo Código?
- 6) ¿Qué factor toma en cuenta el nuevo Código, respecto de los menores, para que éstos adquieran la capacidad de ejercicio? ¿Cómo puede diferenciarse a los menores en torno a ello?
- 7) ¿Qué establece el nuevo Código respecto de la decisión del adolescente en los tratamientos médicos a los que deba someterse?
- 8) ¿Qué establece el nuevo Código respecto de los "pequeños contratos" celebrados por los menores? ¿Y qué establece respecto de los menores de edad con título profesional habilitante?
- 9) ¿Cuándo se es mayor de edad? ¿Qué efectos produce? ¿Es necesaria alguna formalidad?
- 10) ¿Qué es la emancipación? Explique en qué consiste la "emancipación por matrimonio".
- 11) ¿Cuáles son los actos prohibidos al emancipado? ¿Y los actos sujetos a autorización judicial?
- 12) ¿Qué establece el nuevo Código en torno a los "progenitores adolescentes"?
- 13) ¿Cuáles son las emancipaciones que dejaron de tener vigencia?
- 14) ¿Qué reglas generales establece el nuevo Código, en su art. 31, respecto a las limitaciones en la capacidad de ejercicio de una persona?
- 15) ¿A qué personas se les llama "persona con capacidad restringida"? ¿Cuáles son los actos que se le restringe realizar por sí mismo?
- 16) ¿Cuáles son los requisitos para que a una persona se la declare "persona con incapacidad"?
- 17) ¿Quiénes pueden solicitar la declaración de incapacidad o capacidad restringida?
- 18) Explique brevemente cómo es el proceso de declaración de incapacidad o capacidad restringida. ¿Cuáles son las cuestiones sobre las que debe pronunciarse la sentencia? ¿Qué alcance tiene la sentencia?
- 19) ¿En qué consiste la "internación de la persona"? ¿Cuáles son las "reglas mínimas" que deben cumplirse en la internación sin consentimiento?

- 20) ¿Qué soluciones establece el nuevo Código respecto de los actos celebrados por la persona declarada incapaz o con capacidad restringida?
- 21) ¿Cómo es el procedimiento para que el juez haga cesar la incapacidad o las restricciones a la capacidad de la persona?
- 22) ¿Quiénes son, en el nuevo Código, los "inhabilitados"?
- 23) ¿A quién se le llama "pródigo"? ¿Cuál es la finalidad de su inhabilitación? ¿Cuáles son los requisitos para que proceda su inhabilitación?
- 24) ¿Cuáles son los efectos de la inhabilitación del pródigo? ¿Cómo se produce el cese de su inhabilitación?

CAPÍTULO VIII. LOS DERECHOS SUBJETIVOS. DERECHOS Y ACTOS PERSONALÍSIMOS

- 1) ¿Qué se entiende por "derechos subjetivos"? ¿Cuáles son las teorías acerca de su naturaleza jurídica?
- 2) ¿Cómo se clasifican los derechos subjetivos?
- 3) ¿Qué son los "derechos personalísimos"? ¿Cómo los regula el nuevo Código Civil y Comercial?
- 4) ¿Qué establece el art. 51 respecto de la "inviolabilidad de la persona humana"?
- 5) ¿Qué requisito se exige para captar o reproducir la imagen o voz de una persona? ¿Por cuánto tiempo se extiende la protección post mortem del derecho a la imagen y a la voz?
- 6) Explique qué es el "derecho a la intimidad" y cómo lo protegen la Constitución Nacional y el nuevo Código Civil y Comercial.
- 7) ¿Cómo protege nuestro Código Civil y Comercial el "derecho a la vida"? ¿Qué es la "eutanasia"? ¿Está permitida en Argentina?
- 8) ¿Cuáles son las normas del nuevo Código Civil y Comercial que protegen el derecho a la integridad física?
- 9) ¿En qué consiste el derecho a la "identidad"? ¿Qué es la identidad de género? ¿Qué ley la protege en nuestro país? Explique brevemente qué derechos ampara.
- 10) ¿Cuáles son los derechos personalísimos protegidos por el Pacto de San José de Costa Rica?
- 11) ¿Cuál es la naturaleza jurídica de los derechos personalísimos? ¿Cuáles son sus caracteres?

CAPÍTULO IX. EL NOMBRE

- 1) ¿Cuál es el concepto de "nombre"? ¿Cuáles son sus elementos? ¿Y sus caracteres?
- 2) Realice un breve repaso de la evolución histórica del nombre.

- 3) ¿Cómo se adquiere el nombre? ¿Quién elige el prenombre? ¿Qué prohibiciones establece el nuevo Código Civil y Comercial con respecto al nombre?
- 4) ¿Cómo puede adquirirse el apellido?
- 5) Enumere y explique los casos de adquisición originaria del apellido.
- 6) Enumere y explique los casos de adquisición derivada del apellido.
- 7) ¿Qué requisitos se necesitan para que una persona pueda cambiar su nombre o apellido? ¿Cuáles son los "justos motivos" a los que hace referencia el art. 69? ¿Cómo es el proceso para el cambio de nombre o apellido?
- 8) ¿Qué acciones prevé el nuevo Código para la protección jurídica del nombre?
- 9) ¿Qué se entiende por "sobrenombre"? ¿Cuál es su importancia?
- 10) ¿A qué se le llama "seudónimo"? ¿Cuál es su importancia?

CAPÍTULO X. DOMICILIO

- 1) Brinde un concepto de "domicilio". ¿Qué importancia práctica tiene? ¿Cuáles son sus caracteres? Enumere las especies y clases de domicilio establecidas en el nuevo Código Civil y Comercial.
- 2) ¿Qué es el "domicilio real"?
- 3) ¿Cuáles son los requisitos y características del domicilio real? Explique brevemente cómo se constituye, cómo se conserva, cómo se cambia y cómo se extingue el domicilio real.
- 4) ¿Qué es el "domicilio legal"? ¿Cuáles son sus características?
- 5) Enumere y explique los casos de "domicilio legal" establecidos en el art. 74.
- 6) ¿Qué es el "domicilio especial"?
- 7) Explique brevemente los conceptos de: domicilio contractual, domicilio procesal, y domicilio conyugal.

CAPÍTULO XI. AUSENCIA SIMPLE Y AUSENCIA CON PRESUNCIÓN DE FALLECIMIENTO

- 1) ¿En qué caso procede la declaración de "ausencia simple"? ¿Qué implica esta declaración?
- 2) ¿Cuáles son los requisitos para la declaración de ausencia simple? ¿Quiénes están legitimados para solicitarla?
- 3) ¿Quién es el juez competente para la declaración de ausencia simple? Explique brevemente el procedimiento para dicha declaración. ¿En qué casos concluye la curatela?
- 4) ¿En qué consiste la "ausencia con presunción de fallecimiento"? Enumere y explique brevemente los distintos casos que conozca.

- 5) ¿Cómo se computan los términos en la "ausencia con presunción de fallecimiento"? ¿Quiénes están legitimados para solicitarla?
- 6) Explique resumidamente el procedimiento para la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento.
- 7) ¿Cómo se establece el día presuntivo de fallecimiento?
- 8) ¿Qué efectos produce la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento?
- 9) ¿En qué consiste la "prenotación"? ¿Cómo concluye?

CAPÍTULO XII. FIN DE LA EXISTENCIA DE LA PERSONA HUMANA

- 1) ¿Cuál es el hecho que determina el fin de la existencia de la persona humana? ¿Qué establecen el art. 94 y la Ley 24.193 en cuanto a la comprobación de este hecho?
- 2) ¿En qué consiste la "conmoriencia"? ¿Qué establece, por el contrario, la "teoría de los premorientes"?
- 3) ¿Qué son las "partidas del Registro Civil"? ¿Cuál es su carácter? ¿Qué eficacia probatoria tienen?
- 4) ¿Cuáles son los requisitos de las partidas? ¿En qué casos son nulas? ¿En qué casos procede la rectificación de las partidas?
- 5) ¿Cómo se prueban el nacimiento o muerte ocurridos en un país extranjero?
- 6) ¿Cómo se prueban el nacimiento o muerte en caso de falta de registro o nulidad del asiento?

CAPÍTULO XIII. REPRESENTACIÓN Y ASISTENCIA. TUTELA Y CURATELA.

- 1) ¿Qué finalidad tienen la representación y la asistencia por apoyos? ¿Cuál es la diferencia entre ellos?
- 2) ¿Quiénes son las personas que, según el art. 24 del nuevo Código, no pueden ejercer por sí mismos sus derechos? ¿Quiénes son los representantes de esas personas? ¿Cuáles son las características de la representación de incapaces?
- 3) ¿En qué consiste el "sistema de apoyos"? ¿Qué actuación desempeña el Ministerio Público?
- 4) Brinde una definición de "tutela". ¿Cuáles son sus características?
- 5) ¿En qué consiste la "tutela dada por los padres"?
- 6) ¿En qué consiste la "tutela dativa"? ¿Cuáles son las personas a las que no se puede nombrar como tutor en esta clase de tutela?
- 7) ¿En qué consiste la "tutela especial"? ¿En qué casos procede?
- 8) ¿Cuáles son las personas que no pueden ser tutores según el art. 110?

- 9) ¿Quiénes son los obligados a denunciar la situación de vulnerabilidad de un menor que carece de un adulto que lo proteja? ¿Cuáles son las consecuencias si el obligado omite hacer la denuncia?
- 10) ¿Qué se entiende por “discernimiento de la tutela”? ¿Cuál es el juez competente? ¿Existe intervención del menor?
- 11) ¿Qué es la “rendición de cuentas” del tutor? ¿En qué momentos debe hacerla?
- 12) ¿Cuáles son los actos que el tutor puede hacer “libremente”? ¿Cuáles son los actos que requieren autorización judicial? ¿Qué actos tiene prohibido realizar?
- 13) Enumere las causas de terminación de la tutela, y las causas de remoción del tutor. ¿Quiénes pueden pedir la remoción?
- 14) ¿En qué consiste la “curatela”? ¿En qué se diferencia de la tutela?
- 15) ¿Cuál es la función principal del curador?
- 16) ¿Quiénes pueden ser curadores?
- 17) Cuando una persona con hijos menores tiene designado un curador, ¿quién es el tutor de sus hijos?
- 18) ¿Cuáles son las causas de terminación de la curatela?

CAPÍTULO XIV. PERSONAS JURÍDICAS

- 1) ¿Cómo define el nuevo Código Civil y Comercial a las “personas jurídicas”? ¿En qué momento comienza su existencia?
- 2) ¿Qué se entiende por “estatuto”?
- 3) ¿A qué se refiere el Código cuando habla de “personalidad diferenciada” entre la persona jurídica y los miembros que la componen?
- 4) ¿En qué casos es inoponible la “personalidad jurídica”? ¿Qué consecuencias produce la inoponibilidad?
- 5) ¿Cómo se clasifica a las personas jurídicas?
- 6) Enumere a las personas jurídicas públicas. ¿Qué ley se les aplica?
- 7) Enumere a las personas jurídicas privadas. ¿Qué ley se les aplica?
- 8) ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de reconocerle personalidad jurídica a un ente? Enumere y explique brevemente los atributos de las personas jurídicas.
- 9) ¿Cuál es la duración de una persona jurídica?
- 10) ¿En qué consiste el objeto de la persona jurídica? ¿Qué límite determina?
- 11) ¿Cómo se aprueba el estatuto? ¿Y cómo se modifica?
- 12) ¿Qué debe establecer el estatuto en cuanto al gobierno, administración y fiscalización de la persona jurídica? ¿Qué sucede en caso de ausencia de previsiones al respecto?

- 13) ¿Qué pautas y reglas establece el nuevo Código en cuanto a los administradores de la persona jurídica?
- 14) ¿En qué consisten la transformación, la fusión, y la escisión? ¿Qué cantidad de votos se necesita para llevarlas a cabo?
- 15) Enumere y explique brevemente las causales de disolución de la persona jurídica.
- 16) ¿En qué casos y a través de qué tipo de procedimiento se puede revocar la autorización estatal de una persona jurídica para funcionar? ¿En qué consiste la “reconducción”?
- 17) ¿En qué consiste la liquidación de la persona jurídica? ¿Qué tipo de responsabilidades prevé el nuevo Código en la etapa de liquidación?
- 18) ¿Qué característica debe tener el objeto de las asociaciones civiles?
- 19) ¿Cómo se crea una asociación civil? ¿Cuál es el contenido que debe tener el acto constitutivo?
- 20) ¿Cuál es el órgano de administración de la asociación civil? ¿En qué momento se designa?
- 21) ¿Bajo qué tipo de controles se encuentran las asociaciones civiles?
- 22) Explique brevemente el régimen de responsabilidad de los directivos de una asociación civil.
- 23) ¿Cuál es el requisito para que el asociado pueda participar en las asambleas de la asociación civil?
- 24) ¿En qué casos la simple asociación puede prescindir del órgano de fiscalización? ¿Cuál es el régimen de responsabilidad del asociado en la simple asociación?
- 25) ¿Qué se entiende por “fundación”? ¿Cuáles son sus principales características?
- 26) ¿Por quién debe ser otorgado el acto constitutivo de la fundación? ¿Qué información debe contener el instrumento?
- 27) ¿Cómo está integrado el órgano de gobierno y administración de la fundación? ¿Qué características presenta el cargo de consejero?
- 28) ¿Qué destino tienen los bienes de la fundación en caso de disolución?
- 29) ¿Qué atribuciones tiene la autoridad de contralor respecto de las fundaciones?

CAPÍTULO XV. BIENES

- 1) Defina cosas muebles y cosas inmuebles. ¿Cómo se subdividen estas últimas?
- 2) ¿Cuáles son las cosas divisibles? ¿Y las cosas principales?
- 3) ¿A qué se le llama “cosas fungibles”?
- 4) ¿Qué son los “frutos”? ¿Y los “productos”?

- 5) Mencione, al menos, 5 bienes pertenecientes al dominio público.
- 6) Mencione, al menos, 3 bienes de dominio privado del Estado.
- 7) ¿Cuáles son los límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes, establecidos en el art. 240?
- 8) ¿En qué consiste la “función de garantía” de los bienes? ¿Cuáles son los bienes que constituyen esa garantía? ¿Cuáles son las limitaciones a este principio?
- 9) ¿Cuáles son los bienes excluidos de la garantía común?
- 10) ¿Qué inmuebles pueden afectarse al régimen de vivienda? ¿Quién puede solicitar la afectación? ¿A quiénes beneficia este régimen?
- 11) ¿Cuál es el efecto principal de la afectación de un inmueble al régimen de vivienda? ¿En qué casos procede la desafectación del inmueble?

CAPÍTULO XVI. HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS

- 1) ¿A qué se le llama “hecho”? ¿Y “hecho jurídico”?
- 2) ¿Cómo se clasifican los hechos jurídicos?
- 3) ¿Cuáles son las diferencias entre “hecho jurídico” y “acto jurídico”?
- 4) ¿Cuáles son las diferencias entre un “acto jurídico” y un “simple acto lícito”?

CAPÍTULO XVII. TEORÍA GENERAL DE LOS ACTOS VOLUNTARIOS

- 1) ¿Cuál es la definición de acto voluntario?
- 2) Enumere y explique brevemente cuáles son las condiciones internas del acto voluntario.
- 3) ¿Cuáles son las condiciones externas del acto voluntario?
- 4) ¿En qué consiste el “error”? ¿En qué se diferencia de la “ignorancia”?
- 5) ¿Qué clases de error conoce? Explíquelas brevemente.
- 6) ¿En qué consiste el “dolo”? Comente resumidamente los conceptos de “acción dolosa” y “omisión dolosa”.
- 7) ¿Qué especies de dolo conoce? ¿Cuáles son los requisitos que debe reunir para invalidar el acto?
- 8) Comente brevemente los efectos de: el dolo esencial, el dolo incidental, el dolo recíproco, y el dolo de un tercero.
- 9) ¿En qué consiste la “violencia”? ¿Bajo qué aspectos se presenta?
- 10) ¿Cuáles son los requisitos para que el uso de la fuerza invalide el acto?
- 11) ¿Cuáles son los requisitos para que el uso de la intimidación invalide el acto?

CAPÍTULO XVIII. ACTO JURÍDICO

- 1) ¿Cuál es el concepto de “acto jurídico”? Enumere sus elementos esenciales.
- 2) ¿Cuáles son los requisitos que debe reunir el hecho que sea objeto del acto? ¿Qué características debe reunir el bien que sea objeto del acto?
- 3) ¿Qué se entiende por “causa” del acto jurídico? ¿Cuáles son sus acepciones?
- 4) ¿Qué se entiende por “forma” del acto jurídico? ¿Qué establece al respecto, en su art. 284, el nuevo Código Civil y Comercial?
- 5) ¿Cuál es la consecuencia si se omite cumplir con una “forma impuesta” por la ley?
- 6) ¿En qué consiste la “expresión escrita”? ¿Qué instrumentos comprende la “forma escrita”?
- 7) ¿Qué se entiende por “firma”? Defina “firma a ruego” y “firma digital”.
- 8) ¿Cuál es el concepto de “instrumento público”? Enumere y explique sus requisitos de validez.
- 9) ¿Cuál es la eficacia probatoria de los instrumentos públicos? ¿Cómo se los impugna?
- 10) ¿Qué es una “escritura pública”? Enumere y explique brevemente los requisitos de las escrituras públicas y los deberes del notario, establecidos en los arts. 301 a 308 del nuevo Código Civil y Comercial.
- 11) ¿Qué son las “actas notariales”?
- 12) ¿Qué se entiende por “instrumentos privados”? ¿En qué consiste el “reconocimiento de firma”?
- 13) ¿Son válidos los documentos firmados en blanco? ¿El firmante puede oponerse al contenido del documento?
- 14) ¿En qué consiste la “fecha cierta”? ¿Para qué se exige? ¿Cómo se adquiere?
- 15) ¿Cuáles son los “contenidos básicos” del nuevo Código Civil y Comercial con respecto a la contabilidad y estados contables?
- 16) ¿Qué se entiende por “contabilidad”? ¿Quiénes están obligados a llevarla? ¿Quiénes están eximidos de llevarla?
- 17) ¿Cuáles son los registros y libros indispensables para llevar la contabilidad?
- 18) ¿Por cuánto tiempo deben conservarse los libros y el resto de la documentación contable? ¿Cuál es la eficacia probatoria de la contabilidad?
- 19) ¿Cómo se clasifican los actos jurídicos?

CAPÍTULO XIX. VICIOS DE LOS ACTOS JURÍDICOS

- 1) ¿En qué consiste la "lesión"? ¿Cuáles son sus requisitos fundamentales?
- 2) ¿Qué efectos produce la lesión?
- 3) ¿Qué se entiende por "simulación"? ¿Cuáles son los supuestos en los que existe simulación? ¿Qué clases de simulación conoce?
- 4) ¿Qué finalidad tiene la "acción de simulación"? ¿Qué es y para qué sirve el "contradocumento"?
- 5) Explique brevemente en qué casos pueden ejercer la acción de simulación las partes, y en qué casos pueden ejercerla los terceros.
- 6) ¿Qué efectos produce la simulación frente a terceros?
- 7) ¿Qué se entiende por "fraude"?
- 8) ¿En qué consiste la "acción de inoponibilidad"? ¿Quién puede promover la acción?
- 9) ¿Cuáles son los requisitos de procedencia de la acción de inoponibilidad?
- 10) ¿Qué efectos produce el fraude frente a terceros?

CAPÍTULO XX. MODALIDADES DE LOS ACTOS JURÍDICOS

- 1) ¿Qué son las "modalidades" de los actos jurídicos? ¿Cuáles conoce?
- 2) ¿Qué se entiende por "condición"? ¿Qué especies de condición existen?
- 3) ¿Cuáles son las "condiciones prohibidas" que prevé el Código Civil y Comercial? ¿Qué efecto ocasionan?
- 4) ¿La condición tiene efecto retroactivo? ¿Qué efectos acarrea el cumplimiento de la condición?
- 5) ¿A qué se le llama "plazo"? ¿En qué se diferencia de la condición?
- 6) ¿Qué clases de plazo conoce? ¿A quién favorece el plazo?
- 7) ¿Desde cuándo produce efectos el plazo? ¿En qué casos caduca? ¿Cómo se computa el plazo?
- 8) ¿Qué se entiende por "cargo"? ¿Cuáles son sus caracteres? ¿Qué sucede si el cargo no se cumple?
- 9) ¿Qué especies de cargo conoce? ¿Qué sucede cuando se estipula un cargo prohibido?
- 10) ¿Qué sucede cuando se transmite un derecho adquirido con cargo?

CAPÍTULO XXI. REPRESENTACIÓN

- 1) ¿En qué consiste la "representación"? ¿Qué clases de representación conoce?
- 2) Comente brevemente los efectos, la extensión y las limitaciones de la representación.

- 3) ¿Qué se entiende por "representación voluntaria"? ¿Cuáles son sus caracteres?
- 4) ¿Qué tipo de capacidad deben tener el representado y el representante al momento de otorgar el poder? ¿Qué sucede en caso de que el representante realice el acto con su voluntad viciada?
- 5) ¿Cuáles son los dos casos de "acto consigo mismo" que prohíbe el Código?
- 6) Enumere las obligaciones y deberes del representante, y del representado.
- 7) ¿Cuáles son los actos que requieren "poder conferido en términos generales", y cuáles los que requieren "facultades expresas"?
- 8) ¿Cuáles son las causas de extinción del poder? ¿En qué casos el poder es irrevocable?

CAPÍTULO XXII. INEFICACIA DE LOS ACTOS JURÍDICOS

- 1) ¿En qué consiste la "nulidad" de un acto jurídico? ¿Cuáles son sus caracteres? ¿De qué formas se la puede articular?
- 2) ¿Qué se entiende por "conversión del acto"? ¿Qué requisitos se precisan?
- 3) ¿En qué consiste el "acto indirecto"? ¿Es válido?
- 4) Explique brevemente la distinción entre "nulidad absoluta" y "nulidad relativa". ¿Cuáles son las consecuencias de una y otra?
- 5) Explique brevemente la distinción entre "nulidad total" y "nulidad parcial".
- 6) ¿Qué efectos produce la nulidad? Comente resumidamente el efecto que ocasiona entre las partes, y los efectos para terceros adquirentes de cosas registrables.
- 7) ¿A qué se le llama "confirmación" de los actos jurídicos? ¿Cuáles son los actos confirmables?
- 8) Comente brevemente cuáles son las condiciones para que la confirmación sea válida, las formas en que puede ser manifestada, y los efectos de la confirmación.
- 9) ¿En qué consiste la "inoponibilidad"? ¿Cuáles son los efectos del acto inoponible frente a terceros? ¿En qué oportunidad se puede invocar la inoponibilidad?
- 10) ¿Cuáles son las diferencias entre "nulidad" e "inoponibilidad"?

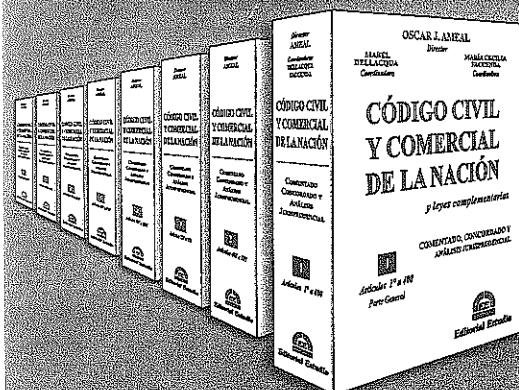
CAPÍTULO XXIII. TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS

- 1) ¿A qué se le llama "transmisión" de un derecho? ¿Qué clases de transmisión existen?
- 2) ¿Qué es un "sucesor universal"? ¿Y un "sucesor singular"?
- 3) ¿Cuáles son las excepciones al principio general de que "todos los derechos son transmisibles"?
- 4) ¿En qué consiste la regla general "nemo plus iuris"? ¿Tiene excepciones?



Editorial Estudio

NOVEDAD



CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN

y leyes complementarias

COMENTADO, CONCORDADO Y ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL

8 tomos

Director de la obra:

Oscar J. AMEAL

Tomo 1: Parte General

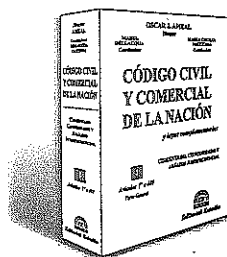
-arts. 1 a 400-

Derecho - Ley - Ejercicio de los Derechos - Derechos y Bienes - Persona Humana - Tutela y Curatela - Persona Jurídica - Bienes - Vivienda - Hechos y Actos Jurídicos - Transmisión de los Derechos.

Precio Promocional

Coordinadores de Tomo:

Mabel DELLACQUA
María Cecilia FACCENDA



Tomo 1: Parte General (Arts. 1 a 400) - **Coordinadoras:** Mabel Dellacqua y María Cecilia Faccenda.

Tomo 2: Familia (Arts. 401 a 723) - **Directores de tomo:** Lidia B. Hernández y Luis A. Ugarte.

Tomo 3: Obligaciones (Arts. 724 a 956) - **Coordinadores:** María Fabiana Compiani y Javier Santamaría.

Tomo 4: Contratos (Arts. 957 a 1186) - **Coordinadores:** Roberto Grané y María Natalia Garozzo.

Tomo 5: Contratos (Arts. 1187 a 1707) - **Coordinadores:** Roberto Grané y María Natalia Garozzo.

Tomo 6: Responsabilidad - Titulos (Arts. 1708 a 1881) - **Coordinadoras:** Carolina Martínez Garbino y Marialma Berrino.

Tomo 7: Reales (Arts. 1882 a 2276) - **Director de tomo:** Carlos M. Clerc - **Coordinador:** Julio Ramos Vardé.

Tomo 8: Sucesiones - Internacional Privado (Arts. 2277 a 2671) - **Directores de tomo:** Lidia B. Hernández y Luis A. Ugarte.



Editorial Estudio S. A.

(011) 4862-2014 / 4865-0537

www.editorialestudio.com.ar

ventas@editorialestudio.com.ar



facebook.com/editorialestudio



linkedin.com/company/editorial-estudio



twitter.com/EditEstudio



Editorial Estudio

Esta edición se terminó de imprimir en Enero de 2016,
en Altuna Impresores SRL, Doblas 1968, Buenos Aires, Argentina.

MANUALES

- Contratos (de próxima aparición)
Ameal, Oscar J.
- Reales (de próxima aparición)
Causse, Federico J. - Pettis, Christian R.
- Familia (de próxima aparición)
- Sociedades (de próxima aparición)
Vítolo, Daniel R.
- Sociedades (de próxima aparición)
Llorente, Sara P.

MODELOS DE ESCRITOS

- Guía de Modelos de Demandas Civiles
Otero, Mariano C.
- Guía de Modelos de Escritos y Documentos Civil y Comercial (de próxima aparición)
Bernasconi, Ana M.
- Guía de Modelos de Escritos y Documentos Derecho Laboral (de próxima aparición)

OTRAS OBRAS

- Manual de Práctica Forense (7 ed)
Grisolia, Julio A.
Bernasconi, Ana M.
- Temas Estructurales del Derecho Internacional Privado
Soto, Alfredo M.
- La nueva minería sustentable
Krom, Beatriz S.
- Curso de Derecho Tributario (de próxima aparición)
Naveira de Casanova, Gustavo J.

CÓDIGOS

- CIVIL Y COMERCIAL
Edición Bolsillo
(incluye lineamientos que explican las nuevas normas del derecho civil y comercial)
- CIVIL Y COMERCIAL
Edición Texto. Rústica y Encuadernada
(incluye lineamientos que explican las nuevas normas del derecho civil y comercial)
- PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL
Edición Bolsillo
(incluye diccionario jurídico/modelos de escritos/formularios/jurisprudencia)
- PEVAL, PROCESAL PENAL Y CONSTITUCIÓN NACIONAL
Edición Bolsillo
(incluye diccionario jurídico/modelos de escritos/jurisprudencia/tratados con jerarquía constitucional)
- CONSTITUCIÓN NACIONAL
Edición Bolsillo
(incluye tratados internacionales con jerarquía constitucional)